

DIGESTO

ACTO JURÍDICO

MANUAL DE ESTUDIO · NIVEL EXAMEN DE GRADO

Elaborado por **Laura Schultz Solano**

Texto refundido a partir de los apuntes de Cristián Boetsch Gillet, jurisprudencia seleccionada y comparaciones doctrinales · Borrador completo, pendiente de revisión

Índice

I. Teoría general del acto jurídico

1. Introducción
2. La teoría del acto jurídico en el Código Civil chileno
3. Los hechos jurídicos. Concepto y clasificación
4. Concepto de acto jurídico
5. El principio de la autonomía de la voluntad
 - 5.1. Conceptos generales
 - 5.2. Consecuencias de la autonomía de la voluntad
 - 5.3. Limitaciones a la autonomía de la voluntad
6. Estructura y elementos constitutivos del acto jurídico
 - 6.1. Elementos o cosas esenciales
 - 6.2. Elementos o cosas de la naturaleza
 - 6.3. Elementos o cosas accidentales
7. Requisitos o condiciones de los actos jurídicos
 - 7.1. Doctrina que afirma la distinción entre requisitos de existencia y de validez de los actos jurídicos
 - 7.2. Doctrina que afirma que el Código únicamente se refiere a requisitos de eficacia de los actos jurídicos
8. Clasificaciones de los actos jurídicos
 - 8.1. Actos unilaterales, bilaterales y plurilaterales
 - 8.2. Actos patrimoniales y actos de familia
 - 8.3. Actos patrimoniales a título gratuito y a título oneroso
 - 8.4. Actos de administración y actos de disposición
 - 8.5. Actos entre vivos y actos por causa de muerte
 - 8.6. Actos solemnes y actos no solemnes
 - 8.7. Actos consensuales y actos reales
 - 8.8. Actos puros y simples y actos sujetos a modalidades
 - 8.9. Actos causales y actos abstractos
 - 8.10. Actos principales y actos accesorios
 - 8.11. Actos constitutivos, declarativos y traslaticios
 - 8.12. Actos de ejecución instantánea, de ejecución diferida y de tracto sucesivo
 - 8.13. Actos típicos o nominados y actos atípicos o innominados

II. Requisitos de los actos jurídicos

A. La voluntad

1. Conceptos generales
2. Requisitos de la voluntad
 - 2.1. Seriedad de la voluntad
 - 2.2. Manifestación de la voluntad
3. La voluntad en las diversas clases de actos jurídicos
 - 3.1. La voluntad en los actos jurídicos unilaterales
 - 3.2. La voluntad en los actos jurídicos bilaterales: el consentimiento
 - 3.3. Casos especiales de formación del consentimiento
4. Vicios de la voluntad
5. El error
 - 5.1. Concepto
 - 5.2. Error de derecho y error de hecho
 - 5.3. Diversas clases de error de hecho y sus efectos
 - 5.4. El error en los actos bilaterales
 - 5.5. El error en los actos unilaterales
 - 5.6. Error común
6. El dolo
 - 6.1. Concepto
 - 6.2. Clases de dolo
 - 6.3. Cuándo el dolo vicia el consentimiento
 - 6.4. Prueba del dolo
 - 6.5. Condonación o renuncia del dolo
 - 6.6. Sanción del dolo
 - 6.7. Acción de dolo
7. La fuerza
 - 7.1. Concepto
 - 7.2. Clases
 - 7.3. Cuándo la fuerza vicia el consentimiento
 - 7.4. Indiferencia de la persona que ejerce la fuerza
 - 7.5. Prueba de la fuerza
 - 7.6. Efectos de la fuerza
 - 7.7. Prescripción de la acción de nulidad

7.8. Temor reverencial

8. Lesión y simulación: remisión

B. La capacidad

1. Concepto
2. Clases de capacidad
 - 2.1. Capacidad de goce
 - 2.2. Capacidad de ejercicio
3. Las incapacidades de ejercicio
 - 3.1. Incapacidad absoluta
 - 3.2. Incapacidad relativa
 - 3.3. Incapacidades particulares o especiales

C. El objeto

1. Concepto
2. Requisitos que debe reunir el objeto que recae sobre una cosa
 - 2.1. Cosa real
 - 2.2. Cosa comerciable
 - 2.3. Cosa determinada
3. Requisitos del objeto que recae sobre un hecho
 - 3.1. Hecho determinado
 - 3.2. Hecho físicamente posible
 - 3.3. Hecho moralmente posible
4. El objeto ilícito
 - 4.1. Actos que contravienen el derecho público chileno
 - 4.2. Pactos sobre sucesiones futuras
 - 4.3. Enajenación de las cosas enumeradas en el art. 1464
 - 4.4. Condonación del dolo futuro
 - 4.5. Deudas contraídas en juego de azar
 - 4.6. Venta de libros prohibidos, objetos inmorales e impresos abusivos de la libertad de prensa
 - 4.7. Actos prohibidos por la ley

D. La causa

1. Generalidades
2. Evolución histórica de la noción de causa
3. Doctrinas elaboradas en relación con la causa

- 3.1. Doctrina tradicional o clásica
 - 3.2. Doctrina italiana
 - 3.3. Doctrina del móvil o motivo determinante
 - 3.4. Doctrina anticausalista
 - 4. La teoría de la causa en el Código Civil chileno
 - 4.1. ¿Qué es lo que debe tener causa: el acto o la obligación?
 - 4.2. ¿Criterio objetivo o subjetivo?
 - 4.3. Doctrina dual de la causa
 - 4.4. Doctrina unitaria de la causa
 - 5. Causa real
 - 6. Licitud de la causa
 - 7. Actos causales y actos abstractos
 - 7.1. Conceptos
 - 7.2. La relación fundamental y subyacente del acto abstracto
 - 7.3. Razón de ser de los actos abstractos
 - 7.4. Solo la ley puede establecer actos abstractos
 - 7.5. Actos abstractos en la legislación chilena
 - 8. Relación de la causa con el error y con la fuerza o el dolo
 - E. Las formalidades
 - 1. Concepto
 - 2. Clases de formalidades
 - 2.1. Las solemnidades (formalidades propiamente tales)
 - 2.2. Formalidades habilitantes
 - 2.3. Las formalidades de prueba
 - 2.4. Las medidas de publicidad
- III. Los efectos de los actos jurídicos**
- 1. Generalidades
 - 2. Personas respecto de las cuales se producen los efectos de los actos jurídicos
 - 2.1. Concepto de parte
 - 2.2. Concepto de tercero
 - 3. El efecto relativo de los actos jurídicos y sus excepciones
 - 3.1. Generalidades
 - 3.2. Excepciones al efecto relativo de los contratos
 - 3.3. El efecto absoluto, indirecto o erga omnes

IV. Ineficacia de los actos jurídicos

A. La inexistencia jurídica

1. Conceptos generales
2. Origen de la teoría de la inexistencia jurídica
3. Diferencias entre la inexistencia y la nulidad
4. ¿Distingue el Código Civil chileno la inexistencia y la nulidad absoluta?
 - 4.1. Doctrina que afirma que sí distingue
 - 4.2. Doctrina que niega la distinción
 - 4.3. Análisis desde la historia fidedigna del establecimiento del Código
 - 4.4. Jurisprudencia sobre la materia

B. Nulidad

B.1 Aspectos generales

1. Reglas del Código Civil sobre la nulidad
2. Concepto general de nulidad
3. Especies de nulidad: absoluta y relativa
4. Terminología
5. Especie de nulidad que constituye la regla general
6. Diferencias entre la nulidad absoluta y la relativa
7. Principios aplicables a ambas clases de nulidad
8. Nulidad total y nulidad parcial del acto jurídico
9. Nulidad consecucional y nulidad refleja

B.2 La nulidad absoluta

1. Concepto
2. Causales
3. Fundamento y caracteres de la nulidad absoluta
4. Declaración de nulidad absoluta
5. La nulidad absoluta no puede sanearse por la ratificación de las partes
6. Saneamiento de la nulidad absoluta por el transcurso del tiempo
7. La nulidad absoluta no se produce de pleno derecho

B.3 La nulidad relativa

1. Definición y fundamento
2. Causales
3. Características
4. Personas legitimadas para alegar la nulidad relativa
 - 4.1. Regla general

4.2. Situación excepcional del incapaz que no podría demandar la rescisión

5. La nulidad relativa puede sanearse por el transcurso del tiempo

6. La nulidad relativa puede sanearse por la ratificación o confirmación de las partes

6.1. Concepto

6.2. Clases

6.3. Características de la ratificación

6.4. Requisitos de la ratificación

B.4 Los efectos de la nulidad

1. Conceptos generales

2. Efectos de la nulidad respecto de las partes

3. Efectos de la nulidad respecto de terceros

4. Acciones a que da origen la nulidad

5. La conversión

C. La lesión

1. Concepto doctrinal

2. La lesión en el Código Civil chileno: ¿constituye un vicio del consentimiento?

3. Casos de lesión regulados en el Código Civil chileno

4. Sanción de la lesión

D. La simulación

1. Concepto

2. La simulación en el ordenamiento jurídico chileno

3. Simulación lícita

4. La simulación ilícita

4.1. Requisitos

4.2. Clases de simulación: absoluta y relativa

4.3. Sanción civil a la simulación ilícita

4.4. Consideraciones probatorias

E. La inoponibilidad

1. Concepto

2. Inoponibilidades de un derecho nacido de un acto jurídico válido

2.1. Inoponibilidades de forma

2.2. Inoponibilidades de fondo

3. Inoponibilidades de un derecho nacido de la nulidad o resolución de un acto jurídico

4. Maneras de hacer valer la inoponibilidad

5. Diferencias entre la nulidad y la inoponibilidad

F. El fraude a la ley

1. Concepto
2. El fraude a la ley en el ordenamiento jurídico nacional
3. Requisitos para que un obrar sea en fraude a la ley
4. Fraude a la ley y figuras afines
 - 4.1. Fraude a la ley y simulación
 - 4.2. Fraude a la ley y abuso del derecho (en su variante de abuso de formas jurídicas)

5. Sanción al fraude a la ley

G. Otras causales de ineficacia

1. La suspensión
2. La resolución
3. La resciliación
4. La revocación
5. El desistimiento unilateral
6. La caducidad
7. La terminación
8. La renuncia
9. La muerte

V. La representación

1. Concepto
2. Utilidad y ámbito de aplicación de la representación
3. Poder de representación
 - 3.1. Conceptos generales
 - 3.2. Clases de representación
 - 3.3. Mandato y representación voluntaria
4. Naturaleza jurídica de la representación
 - 4.1. Teoría de la ficción
 - 4.2. Teoría del nuntius o mensajero
 - 4.3. Teoría de la cooperación de voluntades
 - 4.4. Teoría de la representación modalidad del acto jurídico
5. Influencia de las circunstancias personales del representante o del representado
 - 5.1. En relación a la capacidad
 - 5.2. En relación con las formalidades habilitantes

- 5.3. En relación con los vicios del consentimiento
- 5.4. En relación a la buena o mala fe
- 5.5. En relación al principio *nemo auditur propriam turpitudinem allegans*
- 6. Requisitos necesarios para que exista representación y produzca plenamente sus efectos
 - 6.1. Declaración de voluntad del representante
 - 6.2. Existencia al contratar de la *contemplatio domini*
 - 6.3. Existencia de poder, y obrar dentro de sus límites
- 7. Efectos de la representación
- 8. Sanción de los actos ejecutados sin poder o con extralimitación
- 9. La ratificación
- 10. Otras hipótesis en que los efectos de los actos jurídicos alcanzan a los terceros
 - 10.1. Estipulación para otro
 - 10.2. Promesa de hecho ajeno

VI. Modalidades de los actos jurídicos

- A. La condición
 - 1. Concepto
 - 2. Clasificaciones
 - 2.1. Positivas y negativas
 - 2.2. Posibles e imposibles
 - 2.3. Suspensiva y resolutoria
 - 2.4. Potestativa, casual o mixta
 - 3. Estados en que pueden hallarse las condiciones
 - 3.1. Efectos de la condición suspensiva
 - 3.2. Efectos de la condición resolutoria
- B. El plazo
 - 1. Concepto
 - 2. Semejanzas y diferencias del plazo y la condición
 - 3. Clasificaciones
 - 3.1. Plazo expreso y tácito
 - 3.2. Plazo determinado e indeterminado
 - 3.3. Plazo convencional, legal y judicial
 - 3.4. Plazo suspensivo y extintivo
 - 4. Efectos del plazo
 - 4.1. Efectos del plazo suspensivo

4.2. Efectos del plazo extintivo

C. El modo

1. Concepto
2. Efectos del modo
3. Cumplimiento del modo

I. TEORÍA GENERAL DEL ACTO JURÍDICO

1. INTRODUCCIÓN

¿Qué tienen en común un testamento y una compraventa? A primera vista, nada: uno reparte un patrimonio para después de la muerte, la otra intercambia bienes entre vivos. Pero mirados con más cuidado aparecen dos coincidencias que no son triviales. La primera es que ambos nacen de una voluntad dirigida a un fin concreto: el testador quiere repartir sus bienes de cierta manera, comprador y vendedor quieren intercambiar cosa por precio. La segunda es que ambos producen efectos jurídicos, porque crean, modifican o extinguen una relación de derecho.

Como observa el profesor **VIAL**, encontrar ese denominador común entre instituciones tan distintas del derecho privado no es tarea fácil: a simple vista, sus diferencias pesan más que cualquier semejanza. Decir que ambas "surgen de la voluntad del hombre" es cierto, pero demasiado amplio para sostener por sí solo una teoría jurídica.

El aporte de la doctrina fue, justamente, partir de esas dos coincidencias para construir una categoría común, el *acto jurídico*, y con ella las reglas que valen para cualquiera de sus especies, sea un testamento, una compraventa o un contrato de arriendo. A esa construcción se le llama **Teoría General del Acto Jurídico**, y su fundamento último es el principio de la autonomía de la voluntad: la facultad de las personas para, mediante su propia voluntad, crear, modificar o extinguir derechos.

2. LA TEORÍA DEL ACTO JURÍDICO EN EL CÓDIGO CIVIL CHILENO

La mayoría de los códigos civiles contemporáneos, siguiendo en esto al Derecho Romano, no regulan una teoría general de los actos jurídicos: prefieren tratar cada institución por separado (el contrato, el testamento, el matrimonio) sin un capítulo común que las agrupe. Entre las pocas excepciones que sí construyen esa teoría de forma sistemática están los códigos de Argentina, Alemania, Brasil, Portugal y Perú (este último desde 1984), además del Derecho Canónico.

El Código Civil chileno pertenece al primer grupo: no tiene un título ni un capítulo dedicado a la teoría general del acto jurídico. Lo que existe es una construcción doctrinal, inspirada en la doctrina francesa e italiana, apoyada en dos conjuntos de normas del Código de **BELLO**: el título *De los actos y declaraciones de voluntad* (**arts. 1445 a 1469**) y el dedicado a la nulidad y rescisión de los actos y contratos (**arts. 1681 a 1697**).

Doctrina y jurisprudencia coinciden en que esas normas rigen a todo acto jurídico, salvo que su propio texto o la naturaleza de las cosas las limite a las convenciones o los contratos.

3. LOS HECHOS JURÍDICOS. CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN

Todo lo que ocurre en el mundo, sea por obra de la naturaleza o del ser humano, es un **hecho**. Cuando ese hecho tiene consecuencias para el derecho, se llama **hecho jurídico**; cuando no las tiene, es un simple hecho material, irrelevante para el derecho. Los hechos jurídicos pueden ser *naturales*, si los produce la naturaleza, o *humanos*, si los produce una persona.

EJEMPLO

Hechos jurídicos de la naturaleza: una semana movida en el huerto de don Pato

Don Pato tiene un huerto de paltos en Quillota, a orillas del estero. En una sola semana de temporal le pasa de todo, y nada de eso lo decidió él: (i) el estero cambia de curso, y la parte de su antiguo cauce que queda en seco para siempre pasa a ser de los dueños de los predios vecinos, don Pato incluido (**art. 654**); (ii) nace su nieta Amanda, y con eso empieza su existencia legal (**art. 74**); (iii) muere su compadre Ruperto, y sus herederos pasan a ocupar su lugar en todos sus bienes, derechos y obligaciones transmisibles (**art. 951**); (iv) los paltos siguen dando paltas, que son de don Pato por ser el dueño de los árboles (**art. 646**); y (v) el barro corta el camino y el camión no alcanza a entregar en la Vega las paltas comprometidas para el viernes: si el atraso se debe solo al temporal, que se califica de caso fortuito, y don Pato no estaba ya en mora, no responde por él (**arts. 45 y 1547**).

Los **hechos jurídicos humanos**, a su vez, son los que resultan de una conducta del hombre, generalmente voluntaria, a la que el ordenamiento atribuye consecuencias jurídicas. Se dividen en *lícitos*, que el ordenamiento admite y protege, e *ilícitos*, que prohíbe o que lesionan injustamente el interés de otro (los delitos y cuasidelitos pertenecen a esta categoría). El acto jurídico, en definitiva, no es más que un hecho jurídico humano y lícito.

NO CONFUNDIR**Negocio jurídico vs. acto jurídico**

Parte de la doctrina comparada, sobre todo la alemana y la italiana, separa, dentro de los hechos jurídicos humanos lícitos, el **negocio jurídico** del **acto jurídico** en sentido estricto. En el negocio jurídico los efectos que se producen son exactamente los que quiso su autor: la voluntad los persigue de forma directa e inmediata, como en cualquier compraventa. En el acto jurídico, en cambio, los efectos no siempre van de la mano de lo querido, y a veces son del todo ajenos a la voluntad de quien actuó: si el Nacho levanta un quincho convencido de que el sitio es suyo, y resulta que es del vecino, construir fue un acto voluntario. Pero lo que la ley hace con ese quincho, darle al vecino que no sabía nada la opción de quedarse con él pagando las indemnizaciones que correspondan o de obligar al Nacho a pagarle el terreno (**art. 669**), no es algo que el Nacho haya buscado. Esta distinción no existe en Chile: aquí acto jurídico y negocio jurídico se usan, sin mayor rigor, como sinónimos.

4. CONCEPTO DE ACTO JURÍDICO

Existen varias definiciones de acto jurídico, y todas apuntan a lo mismo con distintas palabras. Una definición clásica lo describe como una declaración de voluntad, o un conjunto de ellas, dirigida a producir determinados efectos jurídicos que el derecho objetivo reconoce y garantiza: esos efectos pueden ser la creación, modificación o extinción de una relación jurídica, pero también la confirmación de una relación preexistente que era dudosa o incierta. Otra la describe, de forma más amplia, como la manifestación de voluntad, unilateral o bilateral, ejecutada conforme a la ley y destinada a producir un efecto jurídico: adquirir, conservar, modificar, transmitir, transferir o extinguir un derecho.

Para **VIAL**, el acto jurídico es "la manifestación de voluntad hecha con el propósito de crear, modificar o extinguir derechos, y que produce los efectos queridos por su autor o las partes porque el derecho sanciona dicha manifestación de voluntad".

De esta última definición conviene extraer tres elementos, porque reaparecerán a lo largo de todo este apunte.

a) El acto jurídico es, antes que nada, una manifestación de voluntad.

No basta con querer algo internamente: la sola voluntad psicológica, mientras permanece oculta, no produce ningún efecto para el derecho. Es necesario que se exteriorice, sea mediante una declaración expresa o mediante un comportamiento que permita conocerla. Y a la inversa: tampoco produce efectos una manifestación que no responda a una intención real y seria, aunque tenga toda la apariencia de serlo.

b) Esa manifestación debe perseguir un propósito específico y determinado.

Aquí la doctrina se divide. Para la posición tradicional, ese propósito tiene que ser jurídico: quien actúa busca, precisamente, producir un efecto de derecho. Para la doctrina más moderna, en cambio, lo que se persigue es un resultado práctico o económico, y el efecto jurídico es solo la forma en que el derecho traduce ese resultado. **VIAL** concilia ambas posturas, entendiendo que describen lo mismo desde ángulos distintos: una mira el propósito desde el derecho, la otra desde quien actúa. Para **ROUBIER**, en cambio, no hay término medio posible: lo que distingue al contrato del delito es, justamente, que en el acto jurídico la voluntad privada persigue de forma consciente las consecuencias jurídicas que espera obtener, y sin ese mínimo de conciencia jurídica no hay acto jurídico, sino otra cosa.

EJEMPLO

La Coni y el Kevin persiguen el mismo fin práctico, pero solo ella celebra un acto jurídico

La Coni y el Kevin quieren exactamente lo mismo: andar en la misma bicicleta eléctrica. La Coni la compra en una tienda de Providencia; el Kevin se la lleva sin permiso del estacionamiento del metro. En el fin práctico, como advierte **STOLFI**, coinciden por completo. La diferencia aparece en el paso siguiente: a la Coni el ordenamiento le reconoce y protege ese resultado, porque coincide con el efecto que la compraventa está destinada a producir. Al Kevin, en cambio, el derecho no solo le niega esa protección, sino que le atribuye una consecuencia bien distinta de la que buscaba: la obligación de indemnizar el daño causado. De ahí la distinción entre efecto práctico (lo que los dos querían) y efecto jurídico (lo que el ordenamiento efectivamente reconoce): solo la compraventa es, en este sentido, un acto jurídico.

c) Por último, esos efectos se producen porque el derecho sanciona la manifestación de voluntad, no por la sola fuerza de esta.

Dicho de otro modo, los efectos de un acto jurídico tienen dos causas que operan en planos distintos: de forma inmediata, la voluntad de quien actúa; de forma mediata, la ley, que reconoce a los particulares el poder jurídico de crear relaciones de derecho. Sin ese respaldo legal, la sola voluntad no bastaría para producir ningún efecto.

5. EL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD

5.1. Conceptos generales

Detrás de la Teoría General del Acto Jurídico hay dos ideas que la sostienen: libertad y voluntad. Toda persona es libre de vincularse jurídicamente con otra o de no hacerlo, y si decide vincularse, lo hace porque así lo quiere. De la unión de esas dos ideas, propia del pensamiento jurídico y filo-

sófico del siglo XVIII, nace el **principio de la autonomía de la voluntad**, piedra angular del derecho civil desde el Código francés y de todos los códigos, como el chileno, que lo tomaron como modelo. Estos códigos organizan el derecho privado en torno a la libertad de los particulares, y ponen al acto jurídico en el centro de ese sistema, como la forma típica en que la voluntad crea, modifica o extingue relaciones personales o patrimoniales.

En el Código chileno este principio aparece reconocido en distintas normas, la más importante de las cuales consagra la libertad de contratar, dándole al contrato una fuerza obligatoria equivalente a la de la ley (**art. 1545**), aunque siempre condicionada al respeto de las leyes, las buenas costumbres y el orden público (**arts. 1445, 1461 y 1467**). La doctrina contemporánea prefiere hablar de *autonomía privada*: la facultad que la ley reconoce a cada particular para regular sus propios intereses según su criterio, asumiendo las consecuencias de sus decisiones, buenas o malas.

5.2. Consecuencias de la autonomía de la voluntad

De este principio se desprenden varias consecuencias prácticas:

(i) Nadie está obligado a obligarse.

Cualquier persona decide, libremente, si contrae una obligación o no, y el Código lo refleja en expresiones como *acepta* (**art. 1386**) o *concurso real de voluntades de dos o más personas* (**art. 1437**).

(ii) Cualquiera puede renunciar a lo suyo.

Un derecho establecido en beneficio propio puede renunciarse libremente, mientras esa renuncia mire solo al interés individual del renunciante y la ley no la prohíba (**art. 12**).

(iii) Las partes deciden el contenido de lo que celebran.

Mientras respeten la ley, el orden público y las buenas costumbres, pueden pactar las cláusulas que estimen convenientes, que pasan entonces a ser tan obligatorias entre ellas como la propia ley (**art. 1545**).

(iv) También deciden la forma.

Pueden optar por lo escrito, lo oral o cualquier otro modo de manifestarse, salvo que la ley exija una forma específica. Y cuando la exige, normalmente es para proteger a las partes de decisiones apresuradas o para resguardar a terceros, no porque el formalismo sea un valor en sí mismo: algo que el derecho moderno exige, de hecho, cada vez menos.

(v) La intención real prima sobre lo declarado.

Como el acto y su contenido son obra de la voluntad, interpretarlo correctamente exige buscar la intención real de quienes lo celebraron, por sobre lo que hayan declarado literalmente.

5.3. Limitaciones a la autonomía de la voluntad

Esa libertad, sin embargo, no es absoluta. Tiene, al menos, cinco límites:

(i) Solo se puede disponer de lo propio.

Disponer de un bien ajeno no perjudica a su verdadero dueño: el acto simplemente le es inoponible (así, por ejemplo, la compraventa de cosa ajena, **art. 1815**).

(ii) Querer un efecto no basta para obtenerlo.

El acto solo produce los efectos buscados si cumple los requisitos que la ley exige para su valor jurídico.

(iii) Hay materias donde no se puede inventar.

En algunas, como el derecho de familia, las partes no pueden crear figuras propias: deben ajustarse al tipo exacto que la ley diseñó.

(iv) El orden público.

Aunque el legislador lo menciona con frecuencia (por ejemplo, **art. 1461**), no lo define. La jurisprudencia lo ha descrito, alternativamente, como *la organización considerada como necesaria para el buen funcionamiento general de la sociedad*, o como *el conjunto de disposiciones establecidas por el legislador para resguardar los intereses superiores de la colectividad y de la moral social*.

(v) Las buenas costumbres.

Tan sin definición legal como el orden público, funcionan como una variante suya: la doctrina las describe como los principios moralmente predominantes en una época determinada, que incluyen, pero no se agotan en, la moral sexual.

6. ESTRUCTURA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ACTO JURÍDICO

El acto jurídico tiene una estructura interna que la doctrina divide, tradicionalmente, en tres capas: los elementos esenciales, los de la naturaleza y los accidentales.

6.1. Elementos o cosas esenciales

Los elementos esenciales son, a la vez, necesarios y suficientes: necesarios, porque sin ellos el acto pierde su eficacia (para algunos, incluso su existencia); suficientes, porque su sola presencia basta para que el acto produzca efecto. El propio Código los define así: son aquellos sin los cuales el acto no produce efecto alguno, o degenera en un acto distinto (**art. 1444**).

Dentro de estos elementos hay dos categorías. Los **generales o comunes** son los que no pueden faltar en ningún acto jurídico, sea cual sea su tipo: la doctrina identifica tres, la **voluntad**, el **objeto** y la **causa**, aunque el **art. 1445** (que enumera los requisitos para obligarse) no los distingue expresamente de los demás. Los otros cuatro requisitos que menciona esa norma (la capacidad, la voluntad libre de vicios, el objeto lícito y la causa lícita) no son esenciales en este sentido: su ausencia no impide que el acto produzca efectos, solo lo deja expuesto a que se declare su nulidad. Los elementos esenciales **especiales o específicos**, en cambio, son propios de cada acto en particular: sin ellos, el acto puede seguir existiendo, pero como uno distinto del que las partes quisieron celebrar.

EJEMPLO

Un elemento esencial específico que falta hace degenerar el acto

La Vale le pasa su PlayStation al Mati y él, a cambio, le da su bicicleta. Aunque lo llamen "venta", no hay compraventa, porque el precio no se paga en dinero (**art. 1793**): hay permuta (**art. 1897**). Y si el tío Hernán le presta su carpa al sobrino para ir a Pucón, pero le cobra 10 lucas por el fin de semana, ya no hay comodato, que es esencialmente gratuito (**art. 2174**), sino arrendamiento (**art. 1915**).

6.2. Elementos o cosas de la naturaleza

Los elementos de la naturaleza no requieren de una cláusula especial para formar parte del acto: la ley los incorpora automáticamente cuando las partes guardan silencio, y solo hace falta la voluntad de estas para modificarlos o excluirllos (**art. 1444**). Más que elementos, en rigor son efectos que la ley sobreentiende. En la compraventa, por ejemplo, el vendedor queda obligado a sanear la evicción y los vicios redhibitorios aunque nada se diga al respecto; como no es un elemento esencial, las partes sí pueden eliminar esa obligación si lo pactan.

6.3. Elementos o cosas accidentales

Los elementos accidentales, por el contrario, ni la ley los sobreentiende ni son necesarios para que el acto produzca efectos: solo existen si las partes los agregan mediante una cláusula expresa. Pueden afectar la existencia misma del acto (por ejemplo, si las partes acuerdan que una compraventa de un mueble no se perfeccione hasta que se otorgue escritura pública, **art. 1802**) o, más comúnmente, su eficacia, a través de una condición, un plazo o un modo.

De los tres, solo los elementos esenciales son verdaderos requisitos constitutivos del acto. Los naturales no forman parte de su estructura, sino de sus efectos; y los accidentales, simplemente, no son necesarios en absoluto.

7. REQUISITOS O CONDICIONES DE LOS ACTOS JURÍDICOS

¿Qué necesita un acto jurídico para nacer y para valer? La doctrina lleva discutiendo esta pregunta desde hace mucho tiempo, y no es una discusión meramente teórica: la respuesta cambia la sanción que corresponde cuando algo falta. Una parte distingue entre requisitos de existencia y requisitos de validez: sin los primeros, el acto ni siquiera nace, es inexistente; sin los segundos, nace, pero viciado, es nulo. Otra parte rechaza esa distinción, porque entiende que el Código solo habla de requisitos de eficacia, de modo que cualquier ausencia, sea cual sea, siempre termina en nulidad.

7.1. Doctrina que afirma la distinción entre requisitos de existencia y de validez de los actos jurídicos

Quienes sostienen esta distinción explican que un acto necesita, primero, nacer sano (requisitos de existencia) y, después, mantenerse sano para producir sus efectos de forma estable (requisitos de validez).

Los **requisitos de existencia** son los que el acto necesita para nacer a la vida del derecho: sin ellos, simplemente no hay acto, y por eso no produce ningún efecto. Son cuatro: la voluntad, el objeto, la causa y, para algunos, las solemnidades que la ley exige para la existencia de ciertos actos (aunque otros prefieren entender que, en esos casos, la solemnidad no es un requisito aparte, sino la única forma en que la voluntad puede manifestarse).

Los **requisitos de validez**, en cambio, son los que el acto necesita para mantenerse sano, aunque su falta no impida que nazca: el acto nace, pero enfermo, expuesto a morir si alguien pide su invalidación. Son la voluntad libre de vicios, el objeto lícito, la causa lícita, la capacidad y, cuando corresponda, las solemnidades exigidas para la validez. La diferencia práctica es clara: faltando un requisito de existencia, el acto simplemente no vive; faltando uno de validez, vive, pero corre el riesgo de morir.

7.2. Doctrina que afirma que el Código únicamente se refiere a requisitos de eficacia de los actos jurídicos

Para quienes rechazan esta distinción, el argumento central es que el Código nunca habla de "existencia". El **art. 1444** dice que, si falta un elemento esencial, el acto *no produce efecto alguno* o *degenera en otro contrato diferente*: eso describe ineficacia, no inexistencia. Y el **art. 1445**, que enumera los requisitos para que una persona *se obligue* por un acto, tampoco distingue entre existencia y validez: solo habla de lo que se necesita para que el acto sea eficaz.

Bajo esta lectura, todos los requisitos (voluntad sin vicios, objeto y causa lícitos, las solemnidades que correspondan y la capacidad) son, por igual, condiciones de eficacia, y su ausencia siempre termina en nulidad, absoluta o relativa según el caso, nunca en inexistencia.

Esta es una pregunta clásica de cédula, y conviene tener clara la respuesta: no se contesta con un sí o un no, sino exponiendo las dos tesis anteriores. Siguiendo la doctrina que distingue existencia y validez, todo depende de cuál requisito falte: sin voluntad, objeto, causa o las solemnidades de existencia, el acto es **inexistente** (jurídicamente, la nada misma); si falta uno de validez (voluntad libre de vicios, objeto o causa lícitos, capacidad), el acto nace, pero viciado de **nulidad**. Siguiendo la doctrina que solo reconoce requisitos de eficacia, la respuesta es más simple: como el Código nunca habla de existencia, cualquier requisito que falte se sanciona siempre con nulidad, absoluta o relativa según el caso.

8. CLASIFICACIONES DE LOS ACTOS JURÍDICOS

Los actos jurídicos admiten muchas clasificaciones, según el criterio que se use para agruparlos. Estas son las más relevantes.

8.1. Actos unilaterales, bilaterales y plurilaterales

Esta clasificación mira cuántas *partes*, no cuántas personas, necesitan manifestar su voluntad para que el acto se forme. Una parte puede estar compuesta por una sola persona o por varias: lo que importa es que compartan un mismo centro de interés, como reconoce el **art. 1438** al hablar de las partes del contrato.

EJEMPLO

Centro de intereses, no número de personas

Las cuatro hermanas Fuentealba heredaron la casa de veraneo de la Nona en El Quisco y se la venden al tío Checho, que lleva años pidiéndosela. Firman cinco personas, pero hay solo dos partes: las cuatro hermanas, que comparten un mismo centro de interés (vender), y el tío Checho (comprar). El acto es bilateral, no plurilateral: cada parte puede ser una o muchas personas (**art. 1438**).

(i) Acto jurídico unilateral

Se forma con la voluntad de una sola parte, llamada su *autor*: el testamento, la oferta, la aceptación, la renuncia de un derecho, la revocación de un poder, la ratificación de un acto nulo. Puede ser *simple*, si proviene de una sola persona (el testamento), o *complejo*, si varias personas manifiestan juntas una misma voluntad (los tres primos Soto, que firman juntos una sola oferta para vender el furgón escolar que compraron a medias). Y puede ser *no recepticio*, si produce sus efectos sin necesidad de llegar a conocimiento de nadie más, o *recepticio*, si, como explica **ALESSANDRI**, su eficacia depende de que se comunique a un destinatario determinado.

Esta distinción importa por su consecuencia práctica: todo acto unilateral recepticio (por ejemplo, ejercer una opción *put*) deja de poder modificarse tan pronto el destinatario toma conocimiento de él, es decir, se vuelve irrevocable desde ese momento. Antes de que eso ocurra, en cambio, quien emitió la declaración todavía puede arrepentirse y revocarla.

Que el heredero deba, después, aceptar la herencia no le quita al testamento su carácter unilateral: basta la sola voluntad del testador para que nazca; lo que hace el heredero es una condición para que ese acto, ya nacido, despliegue todos sus efectos.

(ii) Acto jurídico bilateral

Necesita la voluntad de dos partes para nacer a la vida jurídica: los contratos, la tradición, el pago, el matrimonio. Todo acto bilateral es, para la doctrina nacional, una *convención*; si además está dirigido a crear obligaciones, se llama específicamente *contrato*. De ahí que todo contrato sea una convención, pero no toda convención sea un contrato: cuando una convención modifica o extingue una obligación ya existente, en vez de crear una nueva, sigue siendo convención, pero deja de ser contrato. La compraventa crea obligaciones (dar la cosa, pagar el precio), así que es un contrato; la tradición de esa cosa y el pago del precio, en cambio, solo extinguen esas obligaciones, así que son convenciones, pero no contratos. El propio Código confunde ambos términos (**arts. 1437 y 1438**), algo que la doctrina considera un descuido.

NO CONFUNDIR

Unilateral/bilateral del acto vs. unilateral/bilateral del contrato

Que un contrato sea unilateral o bilateral (**art. 1439**) es una distinción distinta, aunque suene parecida. La de este punto mira cuántas partes se necesitan para que el acto exista. La del **art. 1439** mira, en cambio, cuántas partes de un contrato ya bilateral quedan obligadas: si solo una (unilateral) o ambas recíprocamente (bilateral). Número de partes versus número de obligados.

(iii) Acto jurídico plurilateral

Requiere la voluntad de más de dos partes. La novación por cambio de acreedor es un buen ejemplo: hacen falta la voluntad del deudor, la del tercero que acepta la nueva obligación y la del acreedor original, que consiente en liberar al deudor (**art. 1631 N° 2**).

8.2. Actos patrimoniales y actos de familia

Según qué tipo de interés regulan, los actos jurídicos pueden ser de **familia** o **patrimoniales**. Los de familia regulan el estado de las personas dentro del núcleo familiar, y en ellos la voluntad de los particulares tiene un rol acotado: solo decide si el acto se celebra, mientras la ley fija directamente

sus efectos, como ocurre en el matrimonio. Los patrimoniales, en cambio, crean, modifican o extinguen relaciones que sí pueden valorarse en dinero, como la compraventa.

8.3. Actos patrimoniales a título gratuito y a título oneroso

Según qué beneficio reciben las partes, los actos pueden ser **onerosos** o **gratuitos**. En el acto oneroso, ambas partes reciben una ventaja a cambio de la que dan: si esa ventaja se mira como equivalente a lo entregado, el acto es *conmutativo* (la compraventa, el arrendamiento); si el equivalente depende de un hecho incierto, es *aleatorio* (la renta vitalicia).

En el acto gratuito, también llamado a título *lucrativo* (**art. 1962 N° 1**), solo una parte recibe la ventaja, sin dar nada equivalente a cambio: la donación, el testamento, el préstamo sin interés, el comodato. El Código recoge esta distinción para los contratos: es gratuito el que solo beneficia a una parte, quedando la otra con el gravamen, y oneroso el que beneficia a ambas, gravándose cada una en favor de la otra (**art. 1440**).

8.4. Actos de administración y actos de disposición

Un acto es de **disposición** si disminuye el patrimonio, y de **administración** si lo conserva. La distinción importa especialmente para quienes actúan por cuenta de otro: el tutor o curador, por ejemplo, puede y debe administrar los bienes de su pupilo (**art. 391**), pero necesita autorización judicial previa para enajenarlos, gravarlos con hipoteca, censo o servidumbre, o para vender o empeñar los muebles de valor o de afección (**art. 393**). Es común que la ley permita a estas personas administrar libremente, pero les exija requisitos adicionales para disponer.

8.5. Actos entre vivos y actos por causa de muerte

Un acto es **entre vivos** si no necesita de la muerte de su autor o de una de las partes para producir sus efectos, y es *mortis causa* si sí la necesita: el testamento (**art. 999**) o un mandato pensado para ejecutarse después de que muera el mandante.

8.6. Actos solemnes y actos no solemnes

Un acto es **solemne** cuando la ley, o en ciertos casos la propia voluntad de las partes, exige que se celebre de una forma determinada: la compraventa de un inmueble, por ejemplo, debe constar en escritura pública. Si esa formalidad no se cumple, el acto es nulo absolutamente cuando la solemnidad se exigía para su validez (**art. 1682**); cuando se exigía para su existencia, es inexistente o nulo absolutamente, según la postura que se adopte frente a la inexistencia (ver II.E.2.1 y IV.A). Un acto es **no solemne** cuando la ley no exige ninguna forma en particular.

También existen las solemnidades voluntarias: aunque la ley no exija formalidad alguna para cierto acto, las partes pueden decidir exigírsela ellas mismas, como ocurre en la compraventa de cosas muebles (**art. 1802**). La consecuencia de omitirla no es la misma en ambos casos: si la solemnidad

es legal, su omisión acarrea la sanción que corresponda según su clase (ver II.E.2.1); si es solo voluntaria, el acto puede igual producir efectos, si las partes actúan de un modo que implique renunciar a esa exigencia.

8.7. Actos consensuales y actos reales

Un acto es **consensual** si basta el solo consentimiento de las partes para que se perfeccione, sin importar cómo se exprese (de palabra, por escrito o por señas): la compraventa de un mueble, el arrendamiento, el mandato. El consentimiento, en este contexto, es el encuentro de dos voluntades que buscan un interés común. Un acto es **real** si, además de la voluntad, necesita la entrega de una cosa para perfeccionarse: el comodato, el mutuo, el depósito, la prenda. El **art. 1443** recoge esta distinción para los contratos.

8.8. Actos puros y simples y actos sujetos a modalidades

Un acto es **puro y simple** si sus efectos nacen de inmediato y duran indefinidamente, sin que nada los module. Es **sujeto a modalidad**, en cambio, si alguna cláusula retrasa, modifica o extingue esos efectos en algún momento determinado. Las modalidades más conocidas son la condición, el plazo y el modo (la carga que se impone a quien recibe algo a título gratuito), aunque la doctrina también trata como modalidades a la representación y la solidaridad, porque igualmente alteran el efecto normal del acto.

EJEMPLO

El modo como modalidad

La tía Chela le deja en su testamento al sobrino Joaco su casa de Valdivia, con la obligación de cuidar a sus tres gatos hasta que se mueran de viejos. Esa carga es un modo y no una condición: el Joaco se hace dueño de la casa desde ya, aunque le queden años de gatos por delante (**art. 1089**).

En síntesis: el acto puro y simple no está sujeto a modalidad alguna; el acto sujeto a modalidad tiene sus efectos condicionados a alguna circunstancia o cláusula restrictiva.

8.9. Actos causales y actos abstractos

Un acto es **causal** si la causa forma parte de sus elementos esenciales, de modo que su ausencia o ilicitud acarrea la nulidad absoluta: es el caso de la compraventa, el arrendamiento, el mutuo, el comodato. Un acto es **abstracto**, en cambio, si se perfecciona con independencia de su causa: si esta falta o es ilícita, el acto sigue siendo válido y produce sus efectos igual. Esta distinción se estudiará con más detalle al tratar la causa como elemento del acto jurídico.

8.10. Actos principales y actos accesorios

Un acto es **principal** si no necesita de otro para subsistir, como la compraventa. Es **accesorio** si sí lo necesita, y dentro de estos se distinguen los de *garantía*, llamados *cauciones* por el **art. 46** (la fianza, la hipoteca, la prenda), que aseguran el cumplimiento de una obligación principal, y los *dependientes*, que están subordinados a otro acto sin cumplir esa función de garantía, como las capitulaciones matrimoniales, que no valen si el matrimonio finalmente no se celebra (**art. 1716**).

Un acto accesorio puede existir incluso antes que el principal: así ocurre con las mismas capitulaciones matrimoniales, o con una hipoteca constituida para caucionar obligaciones que todavía no existen (**art. 2413**). La utilidad práctica de esta clasificación aparece, sobre todo, al momento de la extinción: lo accesorio sigue la suerte de lo principal, pero no al revés.

8.11. Actos constitutivos, declarativos y traslaticios

Un acto es **constitutivo** si crea un derecho o una situación jurídica que antes no existía: el matrimonio crea el estado civil de casado; los contratos crean la calidad de acreedor y deudor. Es **declarativo** si, en cambio, se limita a reconocer un derecho o situación que ya existía: la partición, por ejemplo, no transfiere nada entre los comuneros, solo transforma sus cuotas indivisas en partes concretas, como si cada uno hubiera tenido siempre, desde el origen de la comunidad, exactamente lo que terminó recibiendo. Por eso los actos declarativos suelen operar retroactivamente: sus efectos se retrotraen al momento en que nació la relación jurídica, no al momento en que se reconoció.

Es **traslativo**, por último, el acto que transfiere a alguien nuevo un derecho que ya existía: la cesión de un crédito, la tradición de un derecho real.

8.12. Actos de ejecución instantánea, de ejecución diferida y de tracto sucesivo

Según cuánto duren en el tiempo, los actos pueden ser de **ejecución instantánea**, si sus efectos se cumplen de una vez y de inmediato (con lo cual el vínculo se extingue apenas se cumple la prestación); de **ejecución diferida**, si sus efectos se van cumpliendo progresivamente dentro de un plazo pactado; o de **tracto sucesivo**, si las obligaciones nacen y se extinguen periódicamente mientras dure el acto, como en el arrendamiento, donde la relación se renueva, en la práctica, período tras período.

8.13. Actos típicos o nominados y actos atípicos o innominados

Un acto es **nominado o típico** si la ley lo configuró expresamente, dándole caracteres propios: el matrimonio, la adopción, el testamento, la compraventa, el arrendamiento, el mandato, la hipoteca. Es **innominado o atípico** si la ley no lo reguló, y surge, en cambio, de la creatividad de los particulares cuando ningún acto típico satisface lo que necesitan.

Que un acto tenga o no un nombre no es, en rigor, lo que decide esta clasificación; tampoco basta con que la ley lo mencione de pasada, sin darle un tratamiento propio. Un mismo acto puede ser tí-

pico en un país y atípico en otro, y un acto atípico puede volverse típico si el legislador, más adelante, decide regularlo: eso fue lo que ocurrió con el *leasing habitacional*, una mezcla de arrendamiento con promesa de compraventa que hoy tiene su propia regulación.

Mientras se ajusten a las normas generales sobre actos y declaraciones de voluntad, al orden público y a las buenas costumbres, los actos innominados valen tanto como cualquier otro, en aplicación del mismo principio de la autonomía de la voluntad.

II. REQUISITOS DE LOS ACTOS JURÍDICOS

Este capítulo revisa, uno por uno, los requisitos que el acto jurídico necesita para nacer y producir sus efectos: **la voluntad, la capacidad, el objeto, la causa y las formalidades**. Si cada uno de ellos es requisito de existencia, de validez o solo de eficacia es una discusión que ya se vio en el punto I.7.

A. LA VOLUNTAD

1. CONCEPTOS GENERALES

El punto de partida de todo acto jurídico es la **voluntad**, entendida como el libre querer interno de hacer o no hacer alguna cosa. El **art. 1444** la sitúa entre las cosas esenciales: si falta, el acto no produce efecto alguno. Qué significa exactamente esa falta de efectos se discute, porque algunos autores ven ahí inexistencia y otros nulidad absoluta, cuestión que se desarrolla en el capítulo IV.

Cuántas voluntades se necesitan depende de la clase de acto. Al acto unilateral le basta la de su autor; el bilateral requiere dos, y el plurilateral, más de dos. Cuando concurren dos o más voluntades que coinciden, ese acuerdo recibe el nombre de *consentimiento*.

Conviene advertir, eso sí, que la palabra también se usa en un sentido más amplio, como sinónimo de voluntad: se habla de consentimiento tanto para la voluntad única del acto unilateral como para las dos o más del bilateral y del plurilateral.

2. REQUISITOS DE LA VOLUNTAD

No cualquier voluntad interesa al Derecho. Para tomarla en cuenta exige dos cosas: que sea **seria** y que se **manifieste** o exteriorice.

2.1. Seriedad de la voluntad

Una voluntad es seria cuando quien la emite busca producir efectos jurídicos, es decir, un efecto práctico que el derecho sanciona.

Ese propósito falta en la voluntad expresada por mera cortesía, en broma o con otra intención parecida, y si lo hay o no es algo que decide el juez en cada caso. Por ejemplo, en el asado de cumpleaños de la Coni, el Benja le grita entre risas a su primo Matías que le vende su Yaris "por una pisco-la", y Matías responde "trato hecho". No hay compraventa: el Benja no quiso obligarse, y nadie en la mesa, empezando por Matías, lo entendió así. Su voluntad no era seria.

2.2. Manifestación de la voluntad

Mientras la voluntad se queda en el fuero interno de la persona, el Derecho no se ocupa de ella. Recién la considera cuando se proyecta hacia afuera, cuando se declara o manifiesta. Esa manifestación puede ser **expresa** o **tácita** y, en algunos casos, puede significarla incluso el **silencio**.

(i) **Manifestación de voluntad expresa**

Hay manifestación expresa cuando la persona usa, consciente y deliberadamente, un medio destinado a dar a conocer lo que quiere, sin que haga falta apoyarse en ninguna otra circunstancia. Lo normal es que sean palabras, habladas o escritas, pero también sirven gestos o indicaciones. Firmar en la notaría la escritura pública de compraventa de un departamento, o levantar la mano en la junta de vecinos para aprobar la cuota del portón eléctrico, son manifestaciones expresas.

Según la doctrina, quien declara su voluntad tiene el deber de hacerlo con claridad, sin ambigüedades. Ese deber nace de la buena fe contractual (**art. 1546**), y por eso es el declarante quien carga con las consecuencias de no haber sido claro: el **art. 1566** ordena interpretar en su contra las cláusulas ambiguas que él mismo extendió o dictó, siempre que la ambigüedad provenga de la falta de una explicación que él debió dar.

(ii) **Manifestación de voluntad tácita**

La manifestación es tácita cuando la voluntad se deduce de la conducta de la persona, a partir de un hecho positivo que debe ser **concluyente**, es decir, de significado irrefutable, e **inequívoco**, que no admita más de una interpretación.

Por ejemplo, don Lucho, en la feria, toma una malla de paltas, se la pasa al casero para que se la pese y saca la billetera. No ha dicho una palabra, pero nadie duda de que quiere comprar.

En el Código Civil, como regla general, la manifestación expresa y la tácita valen lo mismo. Así lo muestran las normas sobre la aceptación de una herencia (**art. 1241**) y la de un mandato (**art. 2124**), que admiten una y otra, y en el mismo sentido se pronuncia el Código de Comercio (**art. 103**).

Hay casos, sin embargo, en que la manifestación tácita no basta y la ley exige que la voluntad se declare expresamente: el testamento (**arts. 1060 y 1023**) y la solidaridad (**art. 1511**) son dos ejemplos. Las partes también pueden pactar, en ejercicio de la autonomía privada, que entre ellas la voluntad deba declararse siempre en forma explícita y directa.

NO OLVIDAR

Expresa y tácita valen lo mismo, salvo excepciones

Regla general: igual valor (**arts. 1241 y 2124; art. 103** del Código de Comercio). Debe ser **expresa** cuando la ley lo exige (testamento, **arts. 1060 y 1023**; solidaridad, **art. 1511**, inc. 3º) o cuando las partes lo pactan.

(iii) El silencio como manifestación de voluntad

En derecho, el silencio no es solo no hablar: es la ausencia de palabras y también de cualquier gesto o movimiento del cuerpo que signifique aceptar o rechazar.

La regla general es que el silencio, así entendido, nunca constituye por sí mismo y por sí solo una manifestación de voluntad. El adagio popular de que el que calla otorga no tiene cabida en el campo jurídico; lo que rige es el dicho romano según el cual "el que calla es cierto que no confiesa, pero también es verdad que no niega". Jurídicamente, quien guarda silencio no dice sí ni dice no.

NO CONFUNDIR

"El que calla otorga" no vale en derecho

No se puede dar por aceptada una propuesta solo porque el destinatario no respondió. Fuera de las tres excepciones que siguen (la ley, las partes y el juez), su silencio no significa nada: ni acepta ni rechaza.

Esa regla admite tres excepciones, según quién le atribuya al silencio el valor de manifestación de voluntad:

a) La ley

A veces es la propia ley la que le da al silencio ese valor. El caso típico es el de quienes, por su profesión u oficio, se encargan de negocios ajenos:

Art. 2125. "Las personas que por su profesión u oficio se encargan de negocios ajenos, están obligadas a declarar lo más pronto posible si aceptan o no el encargo que una persona ausente les hace; y transcurrido un término razonable, **su silencio se mirará como aceptación**. Aun cuando se excusen del encargo, deberán tomar las providencias conservativas urgentes que requiera el negocio que se les encomienda."

EJEMPLO**El abogado que no contestó el correo**

La señora Carmen, que vive en Punta Arenas, le escribe al estudio del abogado Rodrigo Fuentes, en Santiago, para pedirle que demande a un arrendatario que lleva meses sin pagarle. Rodrigo lee el correo, lo deja para después y no responde. Pasan tres semanas. Como encargarse de negocios ajenos es parte de su profesión y la señora Carmen está ausente, su silencio, transcurrido un término razonable, se mira como aceptación del encargo (**art. 2125**): quedó obligado como mandatario. Y si hubiera contestado que no tomaba el caso, igual habría tenido que adoptar las providencias conservativas urgentes que el asunto requería.

La ley también le da valor al silencio, aunque en sentido inverso, en el caso del asignatario que no se pronuncia sobre la herencia: si está constituido en mora de declarar si la acepta o la repudia, su silencio vale como repudio.

Art. 1233. "El asignatario constituido en mora de declarar si acepta o repudia, **se entenderá que repudia.**"

b) Las partes

También pueden ser las partes quienes, de común acuerdo, le den al silencio el valor de manifestación de voluntad. Es habitual en los contratos de arrendamiento, de trabajo o de sociedad pactar que el contrato se prorrogará por períodos sucesivos si ninguna de las partes, antes del vencimiento, manifiesta su voluntad de ponerle término.

Lo que esta excepción exige es un acuerdo. Ninguna de las partes puede, por su sola cuenta, decidir qué significará el silencio de la otra: por eso no vale la propuesta de contrato en que el proponente le advierte al destinatario que, si no contesta, se entenderá que acepta.

c) El juez

Por último, el juez puede reconocerle valor de manifestación de voluntad al silencio *circunstanciado*, que es el que va acompañado de circunstancias que lo vuelven elocuente. El silencio por sí mismo y por sí solo nunca alcanza; rodeado de esas circunstancias, sí puede hacerlo.

CONEXIONES

Manifestación de voluntad y silencio en otras materias

Derecho Sucesorio: aceptación expresa o tácita de la herencia (**art. 1241**) y mora del asignatario en aceptar o repudiar (**art. 1233**). Revisar apunte de Sucesorio, [FALTA: sección] (p. ____).

Contratos: aceptación del mandato (**arts. 2124 y 2125**) e interpretación de las cláusulas ambiguas (**art. 1566**). Revisar apunte de Contratos, [FALTA: sección] (p. ____).

Obligaciones: la solidaridad debe declararse expresamente (**art. 1511**). Revisar apunte de Obligaciones, [FALTA: sección] (p. ____).

3. LA VOLUNTAD EN LAS DIVERSAS CLASES DE ACTOS JURÍDICOS

3.1. La voluntad en los actos jurídicos unilaterales

Un acto unilateral se forma con una sola voluntad, la de su autor. Lo que sí varía entre ellos, como ya se adelantó, es si su perfección depende de que esa voluntad llegue a conocimiento de su destinatario.

Desde ese punto de vista, los actos unilaterales **no recepticios** quedan perfectos apenas la voluntad se declara en la forma que la ley prescribe; es lo que ocurre con el testamento. Los **recepticios**, en cambio, solo se perfeccionan cuando llegan a conocimiento de la persona a quien van dirigidos, como el desahucio del arrendamiento de una cosa sin plazo fijo, y desde ese momento ya no pueden revocarse.

3.2. La voluntad en los actos jurídicos bilaterales: el consentimiento

En los actos bilaterales, la voluntad pasa a llamarse **consentimiento**, y en los contratos consensuales basta por sí solo para que el contrato se forme.

La definición que le ha dado la doctrina es la de "el encuentro de dos declaraciones de voluntad que, emitidas por dos sujetos diversos, se dirigen a un fin común y se funden".

El Código Civil no describe cómo se forma el consentimiento: se limita a fijar las cualidades que debe reunir para que el acto exista y sea válido. El proceso de formación lo regula el Código de Comercio, en sus **arts. 97 a 108**.

Que esas normas estén en un código especial no impide aplicarlas en materia civil. El alcance de una disposición depende de su naturaleza y no del código o la ley en que se encuentre, y las reglas sobre formación del consentimiento son generales, no especiales ni excepcionales. Así lo entendió

también el Mensaje con que el Presidente de la República envió el proyecto de Código de Comercio al Congreso Nacional: ese documento, que forma parte de la historia de la ley, señala que en esta materia el nuevo código venía a llenar un "sensible vacío de nuestra legislación comercial y civil".

De esas normas se desprende que el consentimiento se forma con dos actos que se suceden: la **oferta** y la **aceptación**.

(i) La oferta

a) Concepto

La **oferta**, también llamada *policitación* o *propuesta*, es el acto jurídico unilateral mediante el cual una persona le propone a otra celebrar una convención determinada. Quien la formula es el *oferente*, *proponente* o *policitante*.

b) Requisitos

Por ser un acto jurídico, la oferta tiene que cumplir los requisitos de existencia y de validez de todo acto. Entre ellos, la voluntad del oferente debe ser seria: tiene que hacerla con la intención de obligarse.

Además, la oferta debe ser **completa**. Lo es cuando está formulada de manera que, para que la convención propuesta se perfeccione, basta con que el destinatario simplemente la apruebe. Si la Javi le escribe a Diego "te vendo mi bicicleta en \$120.000", a Diego le basta contestar "ya" para que haya compraventa.

Si la propuesta omite alguno de los elementos esenciales de la convención, es una *oferta incompleta*. Si la Javi le escribe, en cambio, "te vendo mi bicicleta a buen precio", falta el precio, que es un elemento esencial de la compraventa, y el "ya" de Diego no forma ningún contrato. Con ella, el oferente busca abrir una negociación o conversación preliminar que puede terminar en una oferta completa. Si el destinatario responde formulando a su vez una oferta, esa respuesta es una *contraoferta*; y si la contraoferta es completa y el oferente original la acepta, el consentimiento queda formado.

c) Clases de oferta

c.1) Oferta expresa

Manifiesta la voluntad de contratar en forma directa y explícita, ya sea verbalmente (con palabras o gestos) o por escrito.

c.2) Oferta tácita

Se deduce de un comportamiento que, sin lugar a dudas, revela la propuesta de celebrar una convención. Son ofertas tácitas, por ejemplo, la micro que se detiene en el paradero con el letrero de su recorrido, que ofrece celebrar el contrato de transporte; la vitrina de la panadería del barrio con

las empanadas de pino y su precio a la vista, y la máquina de snacks de la estación de metro, que entrega el producto apenas se pone la plata.

c.3) Oferta hecha a persona determinada

Se dirige a un sujeto debidamente individualizado, lo conozca o no el oferente.

Cuando esta oferta se hace por anuncios, el **art. 105** inc. 2° del Código de Comercio le agrega siempre una condición implícita: que al momento de la demanda (1) los efectos ofrecidos no hayan sido enajenados, (2) su precio no haya cambiado y (3) existan en el domicilio del oferente.

c.4) Oferta hecha a persona indeterminada

Se dirige al público en general y no a alguien en particular, en términos que permiten a cualquiera aceptarla; quien lo haga puede exigir el cumplimiento del contrato. Es lo que hace el casero de la Vega que grita "¡a luca el kilo de tomates!" a todo el que pasa. Lo mismo, en general, todo establecimiento comercial que ofrece sus mercancías o servicios con un precio fijado de antemano, como el supermercado con el precio marcado en la góndola: cualquiera que acepte puede exigir el cumplimiento del contrato que así se forma.

El Código de Comercio, sin embargo, resta fuerza obligatoria a una forma particular de oferta indeterminada. Según el **art. 105** inc. 1°, "las ofertas indeterminadas contenidas en circulares, catálogos, notas de precios corrientes, prospectos, o en cualquiera otra especie de anuncios impresos, no son obligatorias para el que las hace".

Algunos autores sostienen que esa regla quedó derogada para los contratos regidos por la Ley N° 19.496, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, cuyo **art. 12** dispone que "todo proveedor de bienes o servicios estará obligado a respetar los términos, condiciones y modalidades conforme a las cuales se hubiere ofrecido o convenido con el consumidor la entrega del bien o la prestación del servicio". Esa derogación, en todo caso, alcanza solo a los actos a los que se aplica esa ley.

NO CONFUNDIR

Oferta a persona indeterminada y oferta en anuncios impresos

La oferta a persona indeterminada, por regla general, **obliga**: quien la acepta puede exigir el cumplimiento del contrato, como ocurre con el comercio que exhibe sus productos con precio. La que va contenida en **anuncios impresos** (circulares, catálogos, prospectos), en cambio, **no obliga** a quien la hace (**art. 105** inc. 1° C. de Comercio), salvo que se trate de un acto regido por la ley del consumidor (**art. 12** Ley N° 19.496), según la opinión de quienes la entienden derogada en ese ámbito.

(ii) La aceptación

a) Concepto

La **aceptación** es el acto jurídico unilateral con que el destinatario de la oferta expresa que está completamente de acuerdo con ella. A quien acepta se le llama *aceptante*.

b) Clases de aceptaciónb.1) Aceptación expresa

La voluntad de aceptar se declara en términos explícitos, de palabra (incluidos los gestos) o por escrito, según lo exija la ley.

b.2) Aceptación tácita

Se deduce de un comportamiento que revela, sin lugar a dudas, que el destinatario asiente a la oferta. Tiene el mismo valor que la expresa: según el **art. 103** del Código de Comercio, "la aceptación tácita produce los mismos efectos y está sujeta a las mismas reglas que la expresa".

EJEMPLO**La Fran y el taxi del paradero**

La Fran sale de un carrete a las cuatro de la mañana, ve un taxi esperando en el paradero, abre la puerta, se sube y dice "a Ñuñoa, porfa". Ni se le pasó por la cabeza preguntarle al chofer si quería llevarla, ni hacía falta: el taxi estacionado en el paradero era una oferta a persona indeterminada, y al subirse ella la aceptó tácitamente. El contrato de transporte quedó celebrado en ese momento (**art. 103** C. de Comercio).

b.3) Aceptación pura y simple

El destinatario adhiere a la oferta exactamente en los términos en que fue formulada; en otras palabras, la aceptación es congruente con la oferta. Por ejemplo, la tía Mónica le escribe a Tomás: "Te vendo mis 100 libros de derecho en \$150.000 y te los dejo en tu casa". Tomás contesta "conforme". Su aceptación es expresa, pura y simple, y con ella el contrato quedó perfecto (**art. 101** C. de Comercio).

b.4) Aceptación condicionada

La aceptación es condicional cuando no coincide del todo con la oferta, porque le introduce reservas o modificaciones que alteran sus términos. El **art. 102** del Código de Comercio la trata como una contraoferta: "la aceptación condicional será considerada como una propuesta". Se invierten, entonces, los papeles: quien aceptó con condiciones pasa a ser el nuevo oferente, y si el oferente original acepta las modificaciones, queda como aceptante de la oferta modificada.

c) Aceptación parcial cuando la oferta comprende varias cosas

Puede pasar que la oferta incluya varias cosas y que el destinatario acepte solo algunas. Qué efecto tiene esa aceptación parcial depende de lo que quiso el proponente.

Si su intención era hacer una **oferta divisible**, se entiende que formuló varias ofertas distintas, y el consentimiento se forma respecto de las que el destinatario aceptó. Si en cambio quiso hacer una **oferta indivisible**, la aceptación parcial no sirve para formar el consentimiento y vale solo como contraoferta.

EJEMPLO

El comedor de don Patricio

Don Patricio le ofrece a la Cata su comedor de raulí con ocho sillas. Ella le contesta que le compra la mesa, pero que las sillas no, porque ya tiene unas de la abuela. Si para don Patricio la mesa y las sillas eran ventas separables, hay contrato por la mesa. Si lo que quería era deshacerse del juego completo, la respuesta de la Cata no forma el consentimiento: es una contraoferta, y él decide si la acepta (**art. 102** C. de Comercio).

d) Requisitos que debe reunir la aceptación para que se forme el consentimiento

Para que la aceptación forme el consentimiento debe cumplir tres requisitos: ser pura y simple, darse oportunamente y darse mientras la oferta siga vigente.

d.1) La aceptación debe ser pura y simple

Así lo exige el Código de Comercio:

Art. 101 C. de Comercio. "Dada la contestación, si en ella se aprobare **pura y simplemente** la propuesta, **el contrato queda en el acto perfeccionado** y produce todos sus efectos legales, a no ser que antes de darse la respuesta ocurra la retractación, muerte o incapacidad legal del proponente."

Complementa esta regla el **art. 102**, ya visto: si la aceptación es condicional, no forma el contrato y solo vale como nueva propuesta.

d.2) La aceptación debe darse en tiempo oportuno

Es oportuna la aceptación que se da dentro del plazo que fijó el oferente o, si este no fijó ninguno, dentro del plazo legal. Ese plazo legal lo regulan los **arts. 97 y 98** del Código de Comercio, que distinguen según la oferta sea verbal o escrita.

Oferta verbal. Debe aceptarse en el acto de ser conocida; si no, el proponente queda libre.

Art. 97 C. de Comercio. "Para que la propuesta verbal de un negocio imponga al proponente la respectiva obligación, se requiere que sea aceptada **en el acto de ser conocida** por la persona a quien se dirigiere; y no mediando tal aceptación, queda el proponente **libre de todo compromiso.**"

La doctrina entiende que "conocida" quiere decir aquí "comprendida": si la oferta verbal no fue comprendida, la regla no se aplica. También se entiende aplicable a la oferta hecha por teléfono, radio u otro medio electrónico que permita una comunicación verbal inmediata. Aunque oferente y destinatario no estén frente a frente, e incluso estén muy lejos uno del otro, esos medios le permiten al destinatario responder en el mismo acto en que conoce la oferta.

Oferta escrita. El plazo depende de dónde resida el destinatario:

Art. 98 C. de Comercio. "La propuesta hecha por escrito deberá ser aceptada o desechada **dentro de veinticuatro horas**, si la persona a quien se ha dirigido residiere en el mismo lugar que el proponente, o **a vuelta de correo**, si estuviere en otro diverso. Vencidos los plazos indicados, **la propuesta se tendrá por no hecha**, aun cuando hubiere sido aceptada. En caso de aceptación extemporánea, el proponente será obligado, bajo responsabilidad de daños y perjuicios, a dar pronto aviso de su retractación."

Si el destinatario reside o no en el mismo lugar que el proponente es una cuestión de hecho, que decide el juez. La expresión "a vuelta de correo", por su parte, no la define la ley, ni da elementos para precisar su naturaleza y extensión. Por eso la Corte Suprema ha resuelto que corresponde a los jueces del fondo apreciar prudencialmente, caso a caso, si la propuesta escrita se aceptó dentro de ese término. El diccionario de la RAE la define como "por correo inmediato, sin perder día".

Una vez vencidos esos plazos, la oferta caduca: se tiene por no hecha, aunque se haya aceptado. La aceptación que llega después es *extemporánea* y no da nacimiento al contrato. Aun así, el proponente tiene que avisar pronto de su retractación al aceptante tardío; si guarda silencio, responde de los daños y perjuicios que ese silencio le cause (**art. 98** incs. 2° y 3°).

NO OLVIDAR

Plazos para aceptar (arts. 97 y 98 C. de Comercio)

Oferta **verbal**: en el acto de ser conocida. Oferta **escrita**: dentro de **24 horas** si el destinatario reside en el mismo lugar; **a vuelta de correo** si reside en otro. Vencido el plazo, la propuesta se tiene por no hecha.

Por último, la aceptación no se presume. Si se discute que haya existido, debe probarla quien pretenda valerse de ella. Pero una vez probada, se presume que se dio dentro de plazo, salvo prueba en contrario.

d.3) La aceptación debe darse mientras la oferta esté vigente

Hay hechos que hacen perder vigencia a la oferta, y la aceptación que se da después de ocurridos no forma el consentimiento. Son tres: la **retractación** del proponente, su **muerte** y su **incapacidad legal sobreviniente**.

La muerte y la incapacidad legal sobreviniente impiden que se forme el contrato si ocurren antes de que se manifieste la aceptación (**art. 101** C. de Comercio).

La **retractación** consiste en que el proponente, arrepentido de su oferta, la revoca, la deja sin efecto o se desdice de ella. El Código de Comercio le reconoce ese derecho, con dos excepciones:

Art. 99 C. de Comercio. "El proponente **puede arrepentirse** en el tiempo medio entre el envío de la propuesta y la aceptación, salvo que al hacerla se hubiere comprometido a esperar contestación o a no disponer del objeto del contrato, sino después de desechada o de transcurrido un determinado plazo. **El arrepentimiento no se presume.**"

Los efectos de la retractación dependen de si fue tempestiva o intempestiva.

Retractación tempestiva. Es la que ocurre antes de que la oferta sea aceptada. Produce todos sus efectos: la oferta deja de existir y el consentimiento no se forma. Pero tiene un costo para el proponente, que debe indemnizar al destinatario.

Art. 100 C. de Comercio. "La retractación tempestiva **impone al proponente la obligación de indemnizar** los gastos que la persona a quien fue encaminada la propuesta hubiere hecho, y los daños y perjuicios que hubiere sufrido. Sin embargo, el proponente **podrá exonerarse** de la obligación de indemnizar, **cumpliendo el contrato propuesto.**"

La razón de esta indemnización es la seguridad del tráfico. Si el oferente pudiera retirar su oferta sin responder de nada, el destinatario viviría en la incertidumbre: no podría preparar su aceptación sin arriesgarse a perder dinero sin compensación alguna, y los negocios se volverían difíciles de llevar adelante. El proponente puede liberarse de indemnizar si deja sin efecto su retractación y cumple el contrato que propuso.

NO CONFUNDIR**Retractarse a tiempo no sale gratis**

Que la retractación sea tempestiva significa que impide la formación del contrato, no que el oferente quede libre de toda consecuencia. Debe indemnizar los gastos y los perjuicios del destinatario (**art. 100** C. de Comercio), salvo que opte por cumplir el contrato propuesto.

Retractación intempestiva. Lo es la que se hace después de aceptada la oferta. También lo es la que se hace antes de la aceptación, pero cuando el proponente se había comprometido a esperar la respuesta o a no disponer del objeto del contrato hasta que la oferta fuera rechazada o hasta que venciera un plazo. Esta retractación no produce ningún efecto: la oferta sigue en pie y, si la aceptación llega a tiempo, el contrato se forma y el proponente queda obligado a cumplirlo.

(iii) Momento en que se forma el consentimiento**a) Importancia de determinar ese momento**

Saber cuándo se formó el consentimiento tiene consecuencias prácticas. Entre otras, ese momento sirve:

- (1) Para decidir si las partes eran capaces de celebrar el contrato, porque la capacidad se exige al momento de contratar.
- (2) Para saber qué ley rige el contrato si la legislación cambia. El **art. 22** de la Ley sobre Efecto Retroactivo de las Leyes dispone que "en todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración".
- (3) Para juzgar la licitud del objeto, que debe ser lícito cuando se contrata.
- (4) Para saber desde cuándo el contrato produce sus efectos, ya que por regla general los produce desde que se perfecciona.

b) Teorías para determinar ese momento

Para fijar en qué momento queda perfecto el contrato consensual se han propuesto cuatro teorías principales.

b.1) Teoría de la declaración

El contrato queda perfecto en el momento en que se acepta la oferta, aunque el proponente todavía no lo sepa: cuando la Sofi escribe y firma su carta de aceptación, antes incluso de despacharla.

b.2) Teoría de la expedición

El contrato queda perfecto cuando el aceptante se desprende de su aceptación, sin que importe si el oferente ya la recibió. Si la Sofi acepta por carta la oferta de arriendo de una cabaña en Pucón, el

contrato queda perfecto cuando ella deja la carta en el correo.

b.3) Teoría de la recepción

El consentimiento se forma cuando la aceptación llega al domicilio del oferente, aunque este no se haya enterado. En el caso de la Sofi, cuando la carta llega a la casa del dueño de la cabaña, aunque esté de vacaciones y no la haya abierto.

b.4) Teoría de la información o del conocimiento

El contrato queda perfecto solo cuando el proponente conoce real y efectivamente la aceptación: cuando el dueño de la cabaña vuelve, abre la carta y lee el sí de la Sofi.

TEORÍA	EL CONTRATO SE PERFECCIONA CUANDO...	¿NECESITA EL OFERENTE CONOCER LA ACEPTACIÓN?
Declaración	El destinatario acepta la oferta. Regla general en Chile (arts. 99 y 101 C. de Comercio)	No
Expedición	El aceptante se desprende de su aceptación (por ejemplo, despacha la carta)	No
Recepción	La aceptación llega al domicilio del oferente	No, basta que llegue
Información o conocimiento	El oferente conoce real y efectivamente la aceptación. La sigue en Chile la donación entre vivos (art. 1412)	Sí

El derecho chileno adopta la **teoría de la declaración**. El **art. 101** del Código de Comercio dispone que, "dada la contestación", si aprueba pura y simplemente la propuesta, "el contrato queda en el acto perfeccionado y produce todos sus efectos legales"; y el **art. 99** solo permite la retractación antes de la aceptación. El contrato, por tanto, queda firme aun antes de que el proponente se entere de que su oferta fue aceptada.

Esta regla tiene dos excepciones. La primera la crean las propias partes: como la norma sobre el momento en que se perfecciona el contrato consensual no es de orden público, pueden pactar, en virtud de la autonomía de la voluntad, que el contrato se entienda concluido en otro momento.

La segunda es la donación entre vivos, que se perfecciona cuando la aceptación del donatario se notifica al donante: mientras eso no ocurra, el donante puede revocarla a su arbitrio (**art. 1412**). En este caso el Código sigue la teoría del conocimiento o de la información.

(iv) Lugar en que se forma el consentimiento

Cuando las partes residen en lugares distintos, la ley resuelve dónde se entiende celebrado el contrato:

Art. 104 C. de Comercio. "Residiendo los interesados en distintos lugares, se entenderá celebrado el contrato, para todos sus efectos legales, **en el de la residencia del que hubiere aceptado** la propuesta primitiva o la propuesta modificada."

Determinar ese lugar importa por dos razones. Primero, para fijar qué tribunal es competente, si el contrato no estableció un domicilio convencional. Segundo, para saber en qué país se celebró el contrato y, con ello, qué ley se le aplica, conforme al principio de que los actos jurídicos se rigen por la ley del país donde se celebran.

(v) Las negociaciones preliminares y la responsabilidad precontractual

La doctrina ha hecho notar que la regulación legal de la formación del consentimiento no refleja bien lo que ocurre en la práctica, porque antes de la oferta suele haber un período de negociación o tratativas preliminares.

La definición que le ha dado la doctrina a esta etapa es la siguiente: "se denomina etapa de negociación preliminar al período en que las partes desarrollan una multiplicidad de conductas tendientes a conocer sus puntos de vista respecto de un negocio que se proyecta, sin que por ello entiendan quedar obligadas".

Esta etapa ha sido analizada con mucho detalle para resolver si, antes de que exista el contrato, puede nacer responsabilidad para quienes negocian. Es la llamada **responsabilidad precontractual**.

Para responder hay que tener presente que en ese período todavía nadie quiere obligarse. Las partes son libres de negociar, de discutir posiciones distintas y de intercambiar información para evaluar si les conviene o no contratar.

Para la **doctrina tradicional**, en esta etapa manda la libertad de contratar. No hay obligaciones y, por lo mismo, retirarse unilateralmente de la negociación no merece reproche ni genera responsabilidad, aunque cause daños: quien se retira solo ejerce su derecho a desistirse de un contrato que todavía no existe. La **doctrina moderna**, en cambio, sostiene que sí puede haber responsabilidad.

Para **FAGGELLA**, responde quien se retira arbitrariamente de las negociaciones. El retiro es arbitrario cuando defrauda la confianza que se generó al aceptar negociar, o cuando infringe el *pacto de garantía* implícito en toda negociación, que asegura que las conversaciones seguirán su curso

normal hasta celebrarse el contrato o hasta fracasar porque los intereses económicos de las partes resultaron irreconciliables.

A esta tesis se le critica su rigidez: con ese estándar, nadie se atrevería a negociar. Por eso otros autores, como **SALEILLES**, sostienen que no hay responsabilidad sin culpa, y que la culpa existe cuando se infringen los usos y la equidad comercial.

En Chile, **ROSENDE** exige tres requisitos para que nazca la responsabilidad precontractual:

a) Que haya consentimiento en las tratativas preliminares, es decir, acuerdo en negociar

La libertad para negociar, que incluye decidir si se contrata o no, debe respetarse siempre, pero sin dañar el patrimonio ajeno. Esa libertad se ejerce dentro de la buena fe, que la modera.

Si una parte negocia de mala fe y causa daño con culpa, procede la indemnización, porque comete un ilícito civil; si además el hecho es ilícito, hay un delito civil. Y aunque el hecho sea lícito, podría igualmente haber responsabilidad precontractual, porque puede configurarse un enriquecimiento sin causa.

b) Que una de las partes haya hecho gastos con miras al contrato

Si las partes acordaron cómo se pagarían los gastos, accidentes y demás, se aplica ese acuerdo, y la responsabilidad es contractual.

Si no acordaron nada, hay que determinar quién soporta los gastos de la negociación, y para eso se distingue el momento en que se hicieron. Los gastos *anteriores* a la negociación, como la publicidad, son de cargo de quien los hizo, porque los hizo en su propio beneficio. La excepción es que otro también se haya aprovechado de ellos: entonces habría enriquecimiento sin causa, siempre que para quien se empobreció no fueran un motivo de lucro.

Para los gastos hechos *durante* las tratativas, se mira quién los hizo y a quién benefician. Los que una parte hizo por iniciativa propia y en su propio beneficio no se reembolsan. Los que hizo por iniciativa propia pero benefician a ambas, en cambio, pueden repetirse cuando hay enriquecimiento sin causa.

c) Que una de las partes se retire unilateralmente de las negociaciones, en forma contraria a la buena fe

El retiro es lo que convierte en certeza el riesgo de que el negocio no se haga. Pero retirarse no basta, por sí solo, para responder: si bastara, nadie negociaría. Hay que equilibrar la libertad para negociar con el respeto al patrimonio ajeno, y lo que da ese equilibrio es la buena fe.

CONEXIONES

Formación del consentimiento en otras materias

Responsabilidad Precontractual: FAGGELLA (B.3), SALEILLES (B.4), los requisitos comunes de la doctrina moderna (B.5) y las etapas del proceso de formación del contrato (C). Revisar manual de Responsabilidad Precontractual (p. ____).

Contratos: perfeccionamiento de la donación entre vivos (**art. 1412**) y arras (**arts. 107 y 108** C. de Comercio). Revisar apunte de Contratos, [FALTA: sección] (p. ____).

En este manual: la capacidad (II.B) y la licitud del objeto (II.C) se miden al momento en que se forma el consentimiento.

3.3. Casos especiales de formación del consentimiento

Las reglas del Código de Comercio están pensadas para dos personas que negocian, una que propone y otra que responde. Hay situaciones en que el consentimiento se forma de un modo particular: porque un procedimiento previo ordena quién ofrece y quién acepta, porque una de las partes no discute nada, porque una sola persona ocupa los dos lados del contrato o porque todo ocurre a través de una pantalla.

(i) El consentimiento en las licitaciones

Muchos contratos, celebrados tanto por entes públicos como privados, no se negocian directamente con un interesado. Antes de firmarlos se abre una **licitación**, un procedimiento que sirve para escoger con quién se va a contratar.

No es un acto aislado, sino un proceso: una cadena de etapas que se cumplen en orden. Parte con el llamado a licitación y termina con la firma del contrato definitivo. Entre medio, el licitante recibe las propuestas, las conoce y las evalúa para decidir a quién le adjudica el contrato.

La definición que le ha dado la doctrina es la de "un procedimiento de preparación de la voluntad contractual, por el que un ente público o privado en ejercicio de la función administrativa o de su autonomía de voluntad, invita a los interesados para que, sujetándose a las bases fijadas en el pliego de condiciones, formulen propuestas de entre las cuales se seleccionará la más conveniente".

Otras definiciones la miran desde su resultado: sería "un procedimiento relativo a la forma de celebración de ciertos contratos cuya finalidad es determinar la persona que ofrece condiciones más ventajosas", o "una serie de actos que constituyen un procedimiento tendiente a seleccionar la persona de co-contratante y al final del cual nace un vínculo contractual".

¿Quién ofrece y quién acepta en una licitación? Quien llama a licitar no le propone a nadie un contrato determinado: lo que busca es que otros le hagan propuestas. Por eso su llamado no es una oferta. Como lo ha dicho la doctrina, "el llamado a licitación o a concurso, no es una oferta de contrato, sino una invitación a ofertar, o pedido de propuestas a los eventuales interesados".

Los **oferentes** son, entonces, quienes responden al llamado, y a sus propuestas se les aplican las reglas de la oferta del Código de Comercio. Cuando la Municipalidad de Chillán llama a licitación para cambiar las luminarias de la plaza y tres empresas presentan propuestas, son esas empresas las que ofrecen; la municipalidad no queda amarrada a la primera que conteste.

El procedimiento se cierra con la **adjudicación**: el acto jurídico por el cual el licitante elige, entre las propuestas recibidas, la que le resulta más ventajosa y la acepta, con lo que termina la etapa precontractual. En el ejemplo, el contrato de las luminarias se forma recién cuando la municipalidad adjudica.

NO CONFUNDIR

El llamado a licitación y la oferta a persona indeterminada

Los dos se dirigen al público, pero no producen el mismo efecto. La oferta a persona indeterminada es una verdadera oferta y, por regla general, obliga: basta que alguien la acepte para que haya contrato (salvo la contenida en anuncios impresos, **art. 105 C. de Comercio**). El llamado a licitación, en cambio, es solo una invitación a ofertar: quien responde es el que ofrece, y el licitante queda libre hasta que adjudica.

(ii) El consentimiento en los contratos de adhesión

La definición que le ha dado la doctrina es la de aquel contrato "en que uno solo de los dos posibles contratantes preestablece las cláusulas, de modo que el otro no puede modificarlas, sino limitarse a aceptarlas o no celebrar el contrato".

Son de este tipo, entre muchos otros, los contratos de transporte, los de suministro de gas, electricidad y telefonía, los de correo, los de las instituciones de salud previsional, los de las administradoras de fondos de pensiones y los seguros.

Como una de las partes no negocia nada, se ha discutido si estos actos merecen el nombre de contrato. Para una postura serían actos unilaterales: el contenido lo crea una sola voluntad, y la otra se limita a plegarse. La opinión que se ha impuesto, sin embargo, es que sí son contratos. Para que haya contrato civil se exige que dos voluntades libres de vicios se encuentren sobre un objeto de interés jurídico, y la forma en que se fijaron las cláusulas no cambia esa conclusión.

Esa misma característica, la falta de una discusión libre de las cláusulas, es la que abre la puerta a los abusos. Quien redacta suele ser una gran empresa, y lo que ofrece suele ser algo de lo que la otra parte no puede prescindir. Por eso el legislador ha intervenido, con mayor o menor intensidad, para poner límites a lo que el redactor puede imponer.

La norma más importante es el **art. 16** de la Ley N° 19.496, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores (cuyo texto refundido fija el DFL N° 3 de 2021). Dispone que "no producirán efecto alguno en los contratos de adhesión" ciertas cláusulas: entre otras, las que permiten a una parte dejar sin efecto o modificar el contrato a su solo arbitrio, las que invierten la carga de la prueba en perjuicio del consumidor, las que limitan en forma absoluta la responsabilidad del proveedor, las que dejan espacios en blanco y, en general, las que en contra de las exigencias de la buena fe causan al consumidor "un desequilibrio importante en los derechos y obligaciones que para las partes se deriven del contrato".

(iii) El consentimiento en la autocontratación

La definición que le ha dado la doctrina es la de aquel contrato "en que la actividad y la declaración de una sola parte en dos calidades diversas basta para formar el contrato".

Se lo llama **autocontrato** o **contrato consigo mismo**. Lo característico es que una sola persona ocupa, en la misma operación, el lugar del que ofrece y el del que acepta.

Las legislaciones no lo tratan igual. El Código Civil alemán lo prohíbe, salvo que se haya autorizado (§ 181). El Código Civil chileno, en cambio, no tiene una regla general sobre el tema: tiene normas dispersas que, según el caso, lo admiten, lo sujetan a una autorización o lo prohíben derechamente.

Entre las que lo admiten están dos reglas del mandato:

Art. 2144. "No podrá el mandatario por sí ni por interpuesta persona, comprar las cosas que el mandante le ha ordenado vender, ni vender de lo suyo al mandante lo que éste le ha ordenado comprar, **si no fuere con aprobación expresa del mandante.**"

Art. 2145. "Encargado de tomar dinero prestado, **podrá prestarlo él mismo** al interés designado por el mandante, o a falta de esta designación, al interés corriente; pero facultado para colocar dinero a interés, no podrá tomarlo prestado para sí sin aprobación del mandante."

En los dos casos la ley acepta que una misma persona preste el consentimiento por ambos lados. El mandatario que compra lo que debía vender es, a la vez, vendedor (por el mandante) y comprador

(por sí mismo). El que presta su propio dinero cuando le encargaron conseguir un préstamo es, a la vez, mutuante (por sí mismo) y mutuario (por el mandante).

Si la Pame le encarga a su amigo Rodrigo vender su Suzuki Swift, y a Rodrigo le gusta tanto que se lo quiere quedar, firmaría la compraventa en las dos calidades. Puede hacerlo, pero solo con la aprobación expresa de la Pame.

Otras normas, en cambio, lo prohíben o lo someten a restricciones (**arts. 410, 412 y 1800**). El **art. 1800** extiende a los mandatarios, síndicos y albaceas la regla del **art. 2144** para la compra o venta de las cosas que pasen por sus manos. El **art. 410** exige la autorización de los otros tutores o curadores, o del juez, para que el guardador se pague con dineros del pupilo lo que anticipó en su beneficio. La regla más completa es la del **art. 412**, que en su inciso 1° pide autorización y en el 2° prohíbe del todo:

Art. 412. "Por regla general, ningún acto o contrato en que directa o indirectamente tenga interés el tutor o curador, o su cónyuge, o cualquiera de sus ascendientes o descendientes, o de sus hermanos, o de sus consanguíneos o afines hasta el cuarto grado inclusive, o alguno de sus socios de comercio, podrá ejecutarse o celebrarse sino con autorización de los otros tutores o curadores generales, que no estén implicados de la misma manera, o por el juez en subsidio. **Pero ni aun de este modo podrá el tutor o curador comprar bienes raíces del pupilo, o tomarlos en arriendo;** y se extiende esta prohibición a su cónyuge, y a sus ascendientes o descendientes."

Por eso, si don Arturo, curador de su sobrino Matías, quiere arrendarle la parcela de Olmué para sus asados de domingo, no hay autorización que lo salve: ni los otros curadores ni el juez pueden permitírselo.

SITUACIÓN	ARTÍCULOS	¿SE PUEDE?
El mandatario compra lo que debía vender, o le vende lo suyo al mandante (también síndicos y albaceas)	Arts. 2144 y 1800	Sí, con aprobación expresa del mandante
El mandatario encargado de tomar dinero prestado se lo presta él mismo	Art. 2145	Sí, al interés designado o, a falta de designación, al corriente
El mandatario facultado para colocar dinero a interés lo toma prestado para sí	Art. 2145	Sí, con aprobación del mandante
Actos o contratos en que tenga interés el tutor o curador, sus parientes o sus socios	Arts. 410 y 412 inc. 1°	Sí, con autorización de los otros guardadores o del juez
El tutor o curador (o su cónyuge, ascendientes o descendientes) compra o arrienda bienes raíces del pupilo	Art. 412 inc. 2°	No, nunca

Lo que hace posible el autocontrato es la representación. El representante puede actuar, en una misma operación, por cuenta propia y en su propio interés, y al mismo tiempo en nombre y por cuenta del representado, en interés de este. Como las dos voluntades que forman el consentimiento las declara una sola persona, se habla de *autoconsentimiento* del representante.

(iv) El consentimiento en los contratos electrónicos

La definición que le ha dado la doctrina es la de aquel contrato "en que la oferta y la aceptación, y por tanto, el consentimiento, se verifican mediante impulsos electrónicos o mensajes (estandarizados o no estandarizados) contenidos en soportes magnéticos o digitales, entre personas que deben o prefieren comunicarse por ese medio, sin recurrir al lenguaje verbal o escrito".

La doctrina ha calificado de escasa e incompleta la regulación chilena de la contratación electrónica. Las normas que suelen citarse son: el Decreto Supremo N° 81 de 1999, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, sobre firma digital y documentos electrónicos en la Administración del Estado, hoy derogado (lo derogó el Decreto N° 181 de 2002); la Ley N° 19.799, de 2002, sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación; la Ley N° 19.955, de 2004, que agregó a la Ley del Consumidor el **art. 12 A**, sobre formación del consentimiento; y la Ley N° 20.217, de 2007, que modificó el Código de Procedimiento Civil y la ley de firma electrónica en materia de prueba documental electrónica.

De ellas, la que más importa para los contratos es la Ley N° 19.799. Su **art. 3** dispone que los actos y contratos suscritos por medio de firma electrónica "serán válidos de la misma manera y producirán los mismos efectos que los celebrados por escrito y en soporte de papel", y que la firma

electrónica se mira como firma manuscrita. Exceptúa tres casos: los actos en que la ley exige una solemnidad que no puede cumplirse mediante documento electrónico, aquellos en que la ley requiere la concurrencia personal de alguna de las partes y los relativos al derecho de familia.

Como esas normas no cubren todo el proceso, para saber cómo se forma el consentimiento en un contrato electrónico hay que volver a las reglas generales, con los ajustes de la Ley del Consumidor cuando corresponde aplicarla. Conviene revisarlo etapa por etapa.

a) La oferta

Quien vende por internet normalmente no se dirige a nadie en particular: publica un catálogo en línea al que cualquiera puede entrar. Es una oferta a persona indeterminada y, en principio, quedaría sujeta al **art. 105** del Código de Comercio: como los anuncios impresos, no obligaría a quien la hace.

La Ley del Consumidor corrige en parte ese resultado, porque su **art. 12** obliga al proveedor a respetar las condiciones en que ofreció el bien o el servicio. Pero su alcance es limitado. Por regla general, la ley rige los actos que son mercantiles para el proveedor y civiles para el consumidor (**art. 2** letra a), además de otros que la propia norma enumera, y considera proveedor únicamente a quien desarrolla en forma habitual actividades de producción, distribución o comercialización de bienes, o de prestación de servicios, a consumidores, cobrando un precio o tarifa (**art. 1** N° 2; no lo son los profesionales que ejercen en forma independiente).

Dentro de ese ámbito, la oferta del proveedor tiene más fuerza que en el derecho común. En toda promoción u oferta debe informar sus bases y "el tiempo o plazo de su duración", y si después se niega a cumplir lo ofrecido, el consumidor puede pedirle al juez que ordene su cumplimiento forzado o, si no es posible cumplir en especie, una prestación equivalente (**art. 35**).

Además de ese cumplimiento forzado, la infracción se sanciona con multa (**art. 24**), y el consumidor tiene acciones para obtener la prestación incumplida y la indemnización de los perjuicios (**art. 50**).

Cuando la ley sí se aplica, agrega una exigencia propia de los contratos a distancia: el consentimiento "no se entenderá formado si el consumidor no ha tenido previamente un acceso claro, comprensible e inequívoco de las condiciones generales" del contrato y la posibilidad de almacenarlas o imprimirlas (**art. 12 A** inc. 1°).

b) La aceptación

Se puede aceptar por medios electrónicos de muchas maneras: completando un formulario en línea, apretando el botón de "comprar" o "acepto", o respondiendo a la oferta por correo electrónico, carta o fax. Lo que importa no es el medio, sino que la voluntad de aceptar quede de manifiesto sin lugar a dudas. En esa línea, el inciso 2° del **art. 12 A** aclara que entrar a un sitio web no obliga a nada al consumidor si no aceptó inequívocamente las condiciones del proveedor.

c) El momento

Rigen las reglas generales del Código de Comercio, que siguen la teoría de la declaración (ver 3.2 (iii)). El contrato queda perfecto apenas se acepta por vía electrónica, aunque el mensaje o impulso que lleva la aceptación todavía no haya llegado a conocimiento del oferente.

Formado el contrato, la Ley del Consumidor le impone al proveedor un deber adicional: enviar al consumidor una confirmación escrita con una copia íntegra, clara y legible del contrato, por vía electrónica o por otro medio que asegure que la conozca a tiempo y que se le haya indicado de antemano (**art. 12 A** inc. 3°). Es una obligación posterior a la formación del consentimiento, no un requisito para que se forme.

d) El lugar

También aquí se aplica la legislación común. Si las partes residen en lugares distintos, el **art. 104** del Código de Comercio da por celebrado el contrato en el lugar de residencia del aceptante. Si la Trini, que vive en Valdivia, compra unas botas en una tienda online de Santiago mientras espera un vuelo en el aeropuerto de Lima, el contrato se entiende celebrado en Valdivia.

NO CONFUNDIR

Residencia, no ubicación del aparato

El **art. 104** mira dónde **reside** el aceptante, no dónde estaba el computador o el celular desde el que hizo clic, ni dónde está el servidor del sitio.

CONEXIONES

Casos especiales de formación del consentimiento en otras materias

En este manual: La representación (V), base del autocontrato.

Contratos: mandato (**arts. 2144 y 2145**) y compraventa (**art. 1800**). Revisar apunte de Contratos, [FALTA: sección] (p. ____).

Familia: administración de los tutores y curadores (**arts. 410 y 412**). Revisar apunte de Familia, [FALTA: sección] (p. ____).

4. VICIOS DE LA VOLUNTAD

La voluntad puede faltar del todo o estar presente, pero viciada, y la doctrina no les asigna a las dos situaciones la misma consecuencia. Quienes distinguen entre requisitos de existencia y de validez sostienen que, si no hubo voluntad, el acto no llega a existir, y que si la hubo pero viciada, el acto existe y puede anularse. Esa distinción la leen en el propio **art. 1445 N° 2**, que pide primero que la persona consienta y, por separado, que su consentimiento no adolezca de vicio. Otro sector

no hace la diferencia: para él, una voluntad libre de vicios es siempre un requisito de eficacia, y tanto su ausencia como su vicio conducen a la nulidad.

Donde no hay discusión es en el efecto: para ser válido, el acto necesita una voluntad o un consentimiento sin vicios, y si los tiene queda expuesto a ser invalidado. El Código dice cuáles son:

Art. 1451. "Los vicios de que puede adolecer el consentimiento, son **error, fuerza y dolo.**"

Hay quienes alargan la lista y agregan la lesión en ciertos casos, cuestión discutida (ver 8). Otros la acortan: **COVIELLO** hace ver que los vicios podrían reducirse a dos, el error y el temor, porque el dolo opera provocando un error y el temor que le importa a la ley es el que nace de la violencia de otro.

Aunque el Código hable de vicios *del consentimiento*, sus reglas no quedan encerradas en los contratos. El consentimiento es el encuentro de dos voluntades, así que lo que vale para él vale también para la voluntad de quien otorga un acto unilateral.

5. EL ERROR

5.1. Concepto

Para **STOLFI**, el **error** es "la falsa representación de la realidad determinada por la ignorancia, es decir, por no haber tenido la parte conocimiento de todas las circunstancias que influyen en el acto concertado, o por la equivocación, es decir, por no haber valorado exactamente la influencia de dichas circunstancias".

Dicho en corto, es un desacuerdo entre lo que se piensa y lo que es: tener por verdadero lo falso, o por falso lo verdadero. Otros autores lo formulan de manera parecida. **GIORGI** habla de "una disconformidad entre las ideas de nuestra mente y el orden de las cosas", y **COVIELLO**, de "un falso juicio que se forma de una cosa o de un hecho, basado en la ignorancia o incompleto conocimiento de la realidad de la cosa o del hecho, o del principio de derecho que se presupone".

Nadie decide celebrar un acto en el vacío: lo hace a partir de lo que sabe, o cree saber, sobre la realidad. No se le exige conocerla entera; basta, en palabras de **PIETROBON**, que "posea una opinión en sí suficiente para explicar, como causa, su propia actuación". Si esa representación es falsa, la voluntad existe, pero se formó sobre una base equivocada. Por eso varios autores prefieren ver en el error un vicio del *conocimiento* más que del consentimiento: lo que falla es la información con la que se decide, y esa falla le resta eficacia a la declaración.

El concepto se entiende mejor si se compara el error con tres figuras vecinas.

(i) El error y la ignorancia

En el lenguaje de todos los días, ignorar y equivocarse son cosas distintas. La doctrina describe la ignorancia como "el estado de espíritu puramente negativo que consiste en la ausencia de todo conocimiento relativo a un objeto": el que ignora no tiene idea del asunto, mientras que el que se equivoca sí la tiene, pero errada. Para el derecho la diferencia no cambia nada, porque las dos terminan en una falsa representación de la realidad, y el legislador trata igual al ignorante y al equivocado. Como lo resume **CLARO SOLAR**, en derecho da lo mismo no conocer en absoluto una cosa que tener de ella un concepto errado.

(ii) El error y la duda

La duda, en cambio, sí deja fuera al error. Quien duda sabe que su idea de las cosas puede ser falsa y, aun así, decide actuar; quien yerra no tiene esa conciencia, porque está convencido de que acierta. **PIETROBON** saca la consecuencia: "quien emite una declaración a sabiendas de que no conoce con exactitud su contenido y efectos, no puede invocar posteriormente su propio error: él ha preferido conscientemente correr un riesgo, del que deberá soportar las consecuencias".

Hay contratos, sin embargo, en que la incertidumbre no está en la cabeza de las partes sino en la cosa misma. **VIAL** pone el caso de las obras de arte: el comprador puede encargarse de peritajes, pero siempre queda un margen de duda sobre su calidad. Esta **duda objetiva**, que viene de la naturaleza del contrato, no excluye el error ni sus efectos. Si don Hernán compra en la feria de Franklin un cuadro "atribuido a" un pintor chileno del siglo XIX, los dos saben que la autoría no es segura; esa incertidumbre propia del negocio no le cierra la puerta a alegar error si después aparece algo que cambia por completo lo que creyó comprar.

(iii) El error y la previsión

Para que haya error tiene que haber una realidad contra la cual comparar lo que se creyó, y la realidad está hecha de hechos presentes o pasados. Lo que todavía no existe no forma parte de ella, de modo que equivocarse sobre el futuro no es un error que vicie el consentimiento. Es el llamado **error de previsión**, que **PIETROBON** define como "una equivocación, un yerro de la mente al proyectarse hacia un futuro que, al hacerse realidad, lo pondrá o no de manifiesto".

EJEMPLO

El food truck de Pichilemu

La Feña compra un *food truck* en Pichilemu convencida de que va a vender 200 completos diarios. Llega el invierno y vende 40. No puede alegar error: el carro, el precio y todo lo que existía el día de la compra eran tal como ella creía. Se equivocó sobre lo que iba a pasar, y ese error de previsión no vicia su consentimiento.

NO CONFUNDIR**Error, ignorancia y duda**

El **error** y la **ignorancia** tienen el mismo efecto jurídico: los dos son una falsa representación de la realidad. La **duda** es distinta: quien duda sabe que puede estar equivocado y asume el riesgo, así que después no puede alegar error. La excepción es la **duda objetiva**, propia de ciertos negocios, que no excluye el error.

5.2. Error de derecho y error de hecho

Al regular el error como vicio del consentimiento, el Código distingue según recaiga sobre el derecho o sobre los hechos. No es el único lugar donde se ocupa del error: también tiene reglas propias para el error en el nombre o calidad del asignatario testamentario (**art. 1057**), el error en el título de la tradición (**art. 677**) y la transacción celebrada sin saber que el litigio ya estaba terminado por sentencia firme (**art. 2455**).

(i) El error de derecho

La definición que le ha dado la doctrina es la de "la ignorancia o el concepto equivocado que se tiene de una norma jurídica, en cuanto a su existencia, alcance, inteligencia o permanencia en vigor".

VIAL distingue los supuestos posibles: se ignora que la norma existe; se sabe que existe, pero no qué dice; o se sabe que existe y qué dice, pero se entiende mal su significado.

La regla del Código es tajante:

Art. 1452. "El error sobre un punto de derecho **no vicia el consentimiento.**"

Descansa en otra norma, que da por supuesto que todos conocen la ley:

Art. 8. "**Nadie podrá alegar ignorancia de la ley** después que ésta haya entrado en vigencia."

Si se supone que todos conocen las normas, tampoco cabe equivocarse sobre ellas. Quien celebró un acto con una idea errada de la ley que lo rige, o sin saber de alguna de sus disposiciones, queda obligado de todos modos: su error no le sirve para dejar de cumplir ni para pedir la nulidad. Si el Nacho vende su parcela de Paine por escritura pública, convencido de que puede arrepentirse mientras la venta no se inscriba en el Conservador, se equivoca: la venta de un inmueble está per-

fecta desde la escritura (**art. 1801** inc. 2º) y el contrato no se deshace por la voluntad de uno solo (**art. 1545**). Su error es de derecho y no le permite anular la venta.

La ficción llega tan lejos que, en materia posesoria, "el error en materia de derecho constituye una presunción de mala fe, que no admite prueba en contrario" (**art. 706** inc. final).

La regla tiene una larga historia. En Roma se separaba con nitidez el *error iuris*, que no tenía excusa, del *error facti*, que sí podía tenerla. El Código Napoleón conservó esa tradición siguiendo a **POTHIER**, aunque **DOMAT** admitía excusar el error de derecho cuando hubiera sido "la única causa de la convención". El **art. 1452** sigue a Pothier y al Código francés. Otras legislaciones tomaron el camino opuesto: el Código Civil italiano de 1942 acepta que el error de derecho vicie el consentimiento cuando fue la razón única, o al menos la principal, del contrato (**art. 1429 N° 4**).

Frente a una regla tan estricta, se suelen citar dos normas del pago de lo no debido, que es un cuasicontrato. Las dos responden a la misma idea: evitar un enriquecimiento sin causa.

a) El art. 2297

Art. 2297. "Se podrá repetir aun lo que se ha pagado por error de derecho, cuando el pago no tenía por fundamento ni aun una obligación puramente natural."

Quien paga lo hace porque cree que hay una obligación que se lo exige. Si esa obligación existe, sea civil o natural, el pago la extingue y quien lo recibe puede quedarse con lo pagado. Si no existe, el pago no tiene fundamento, y quien lo hizo puede *repetir*, es decir, exigir que se le devuelva. La dificultad aparece cuando la creencia equivocada es jurídica: alguien paga porque cree, sin razón, que una ley lo obliga. Aplicado al pie de la letra, el **art. 1452** lo dejaría sin remedio. El **art. 2297**, como norma especial, se impone a la general y le permite recuperar lo que pagó.

b) El art. 2299

Art. 2299. "Del que da lo que no debe, **no se presume que lo dona**, a menos de probarse que tuvo perfecto conocimiento de lo que hacía, tanto en el hecho como en el derecho."

Quien entrega algo que no debe puede hacerlo por dos razones opuestas: porque cree, equivocadamente, que lo debe, o porque quiere hacer una liberalidad, por gratitud, por beneficencia o por costumbre social. El **art. 2299** impide que quien recibe se quede con la cosa alegando que se la regalaron: la donación no se presume, salvo que se pruebe que quien dio sabía perfectamente, en el hecho y en el derecho, que no debía nada. Basta, entonces, un error de derecho para descartar la intención de donar. Por eso, concluye **VIAL**, la donación motivada por un error de derecho no produce los efectos de una donación, sino los del pago de lo no debido.

Si la tía Gladys le transfiere \$300.000 a la junta de vecinos creyendo que la ley la obliga a pagar una "cuota de pavimentación", la junta no puede quedarse con la plata diciendo que fue una donación: tendría que probar que la tía sabía perfectamente que no debía nada. Como no lo sabía, puede pedir que se la devuelvan (**art. 2297**).

c) ¿Son realmente excepciones?

Aun cuando tradicionalmente se citan los **arts. 2297 y 2299** como "excepciones" a la regla del **art. 1452** (el error de derecho no vicia el consentimiento), en rigor no lo son: se trata de instituciones con un ámbito de aplicación distinto, aunque ambas aludan al error de derecho. El **art. 1452** opera en sede de vicios del consentimiento, es decir, respecto de la validez del acto jurídico. Los **arts. 2297 y 2299**, en cambio, operan en sede del cuasicontrato del pago de lo no debido: no vician el consentimiento ni afectan la validez del pago como acto, sino que determinan si existe o no fundamento jurídico para que el *accipiens* retenga lo recibido. El error de derecho, en este último caso, no invalida nada; es el presupuesto que permite repetir lo pagado, incluso cuando el pago no tuvo por base ni siquiera una obligación natural (**art. 2297**), salvo que se acredite que quien pagó tuvo perfecto conocimiento de hecho y de derecho de que nada debía, caso en el cual se entiende que hubo ánimo de donar (**art. 2299**).

La doctrina ha leído estas normas de maneras distintas. Para **LEÓN HURTADO** sí son una excepción expresa al **art. 1452**, pero justamente por eso se interpretan en forma restrictiva: solo rigen el pago, no otros modos de extinguir obligaciones, y solo cuando quien pagó invoca el error, no otro vicio. Rechaza, además, que de ellas se desprenda una regla general según la cual el error de derecho no sirve para ganar, pero sí para evitar una pérdida (el principio romano *damno vitando, lucro captando*): el Código aplicó esa idea solo al pago indebido, y fuera de él "el art. 1452 rige sin contrapeso". A su juicio, la ley no quiere que quien recibió el pago lo retenga "asilándose en el error de derecho del que pagó", porque sería darle una causa a una obligación que solo existía en apariencia.

VIAL admite que se trata de una excepción a la irrelevancia del error de derecho, pero no a la regla de que este no vicia el consentimiento. Si el error de derecho viciara el pago, la víctima pediría su nulidad relativa; lo que la ley le da es otra cosa: la posibilidad de sustraerse legítimamente a las consecuencias de una declaración que no habría hecho si se hubiera representado bien la realidad jurídica.

JURISPRUDENCIA

GACETA DE LOS TRIBUNALES, 1928, SENTENCIA 191, P. 883

La acción de pago de lo no debido compete exclusivamente al que paga sólo por error lo que no debe y no al que lo efectúa por temor a dificultades ulteriores. Es el fallo que cita **LEÓN HURTADO** para sostener que los **arts. 2297 y 2299** solo se aplican cuando se invoca el error, y no otro vicio.

NO CONFUNDIR**Repetir no es anular**

Es un error típico de examen decir que, gracias a los **arts. 2297 y 2299**, el error de derecho permite pedir la **nulidad** de un contrato. Lo que permiten es **repetir** lo pagado sin fundamento. Fuera del pago de lo no debido, el **art. 1452** se aplica sin excepciones.

(ii) El error de hecho

La definición que le ha dado la doctrina es la de "la ignorancia o el concepto equivocado que se tiene de una persona, de una cosa, de un acto o, en general, de una circunstancia material cualquiera".

Los romanos no construyeron una teoría general del error de hecho: agruparon bajo el nombre de *error facti* ciertos casos concretos en que el error afectaba la validez del acto, como el error sobre la cosa (*in re*), sobre la persona (*in persona*) o sobre el negocio (*in negotio*). El Código chileno regula las hipótesis que considera relevantes en tres artículos (**arts. 1453, 1454 y 1455**), que se estudian en 5.3. Antes conviene revisar tres ideas que la doctrina usa para ordenarlas.

a) Error obstáculo y error vicio

En la mayoría de los casos, lo que la persona declaró no coincide con lo que habría querido de haber conocido la verdad: la Cami compra unos aros que cree de plata y resultan ser de alpaca. Hubo acuerdo, pero un acuerdo que no está sano: es el **error vicio**. En el **error obstáculo** u obstativo, en cambio, cada parte declara exactamente lo que quiere, pero lo que quiere una no tiene nada que ver con lo que quiere la otra: una entiende que presta y la otra, que recibe una donación. El desajuste no está dentro de ninguna de ellas, sino entre las dos; como dice **VIAL**, son "dos voluntades que no se unen y que marchan por caminos separados". Por eso se dice que este error no vicia el consentimiento, sino que impide que se forme.

b) Criterio objetivo y criterio subjetivo

Si cualquier error permitiera anular, la voluntad quedaría muy protegida, pero la seguridad y certeza de las relaciones jurídicas, en palabras de **VIAL**, "se tambalearían peligrosamente". Por eso la ley escoge cuáles errores de hecho son relevantes, y puede hacerlo de dos maneras. Con el **criterio objetivo** describe tipos de error y los aplica a todo caso que calce en ellos, sin preguntarse cuánto influyó el error en quien lo sufrió. Con el **criterio subjetivo** considera relevante todo error que haya sido determinante para que la persona actuara.

A primera vista, el Código eligió el criterio objetivo: no hay más errores de hecho relevantes que los descritos en los **arts. 1453 a 1455**. **VIAL** sostiene, sin embargo, que además exige que el error

haya sido determinante. Lo da por supuesto en el inciso 1° del **art. 1454** y lo dice expresamente en su inciso 2° ("el principal motivo") y en el **art. 1455** ("la causa principal del contrato").

c) El Código no recoge la distinción

Aunque la doctrina separe con precisión el error obstáculo del error vicio, el Código no lo hace. Trata el error obstáculo como un vicio más: el **art. 1453**, que lo regula, empieza diciendo que "El error de hecho vicia el consentimiento...". Esa opción del legislador es el punto de partida de la discusión sobre la sanción del error esencial (5.3).

NO OLVIDAR

Error de derecho y error de hecho

Error de derecho: no vicia el consentimiento (**art. 1452**). Error de hecho relevante: **arts. 1453, 1454 y 1455**.

CONEXIONES

El error de derecho y de hecho en otras materias

En este manual: IV.B Nulidad relativa (**art. 1682** inc. final), sanción del error que vicia el consentimiento.

Bienes: V.4 La tradición (error en el título, **art. 677**) y la buena fe posesoria (**art. 706**). Revisar apunte de Bienes, [FALTA: sección de la posesión] (p. ____).

Obligaciones: pago de lo no debido (**arts. 2295 y siguientes**). Revisar apunte de Obligaciones, [FALTA: sección] (p. ____).

Contratos: transacción (**art. 2455**). Revisar apunte de Contratos, [FALTA: sección] (p. ____).

5.3. Diversas clases de error de hecho y sus efectos

El Código describe los errores de hecho relevantes en tres artículos seguidos, y de ellos salen cuatro clases: el error esencial u obstáculo (**art. 1453**), el error sustancial (**art. 1454** inc. 1°), el error sobre las calidades accidentales (**art. 1454** inc. 2°) y el error en la persona (**art. 1455**). Cada una tiene su propio supuesto y su propia sanción.

(i) **Error esencial u obstáculo**

Art. 1453. "El error de hecho vicia el consentimiento cuando recae sobre la especie de acto o contrato que se ejecuta o celebra, como si una de las partes entendiese empréstito y la otra donación; o sobre la identidad de la cosa específica de que se trata, como si en el contrato de venta el vendedor entendiese vender cierta cosa determinada, y el comprador entendiese comprar otra."

Se habla de error esencial cuando la distancia entre lo que una parte quiso y lo que se declaró es, mirada objetivamente, tan grande que lleva a pensar que esa parte no habría celebrado el acto si hubiera sabido cómo eran las cosas en realidad. Ojo con el nombre: en Chile "error esencial" designa solo esta hipótesis, mientras que la doctrina extranjera, advierte **VIAL**, llama "esencial" a todo error de hecho relevante.

El artículo viene de **POTHIER**, para quien, según recuerda **CLARO SOLAR**, el error que recae en la naturaleza del acto o en su objeto "no es un simple vicio del consentimiento, sino un óbice, un obstáculo para que se forme el consentimiento". De ahí el nombre de error obstáculo, y de ahí también el problema, porque el Código, como se vio (5.2 (ii) a) y c)), no recoge esa idea y lo trata como un vicio más. El artículo contempla dos supuestos.

a) Error sobre la especie de acto o contrato

Las partes se representan mal el acto mismo que están celebrando: cada una cree estar en un negocio distinto. El Martín le pasa su guitarra a su prima, la Isi, para la peña del colegio; él entiende que se la presta y ella entiende que se la regaló. No hay un préstamo ni una donación en los que ambos estén de acuerdo.

b) Error sobre la identidad de la cosa específica

Las partes coinciden en el tipo de acto, pero no en la cosa sobre la que recae. Don Iván vende "el departamento 302" de un condominio en Viña: él piensa en el 302 de la torre A, con vista a los cerros, y el comprador cree estar comprando el 302 de la torre B, con vista al mar. Cada uno quiere una cosa distinta.

EJEMPLO**Los dos kayaks del tío Pepe**

El tío Pepe tiene dos kayaks en su casa de Algarrobo: uno rojo, de dos plazas, y uno amarillo, individual y lleno de parches. Le escribe a la Fran: "Te vendo el kayak en \$250.000". La Fran, que solo conoce el rojo por las fotos que el tío sube todos los veranos, responde feliz que sí. El tío pensaba en el amarillo, porque el rojo no lo vende ni muerto. Ninguno de los dos se confundió sobre lo que él mismo quería: cada uno dijo exactamente lo que pensaba. El problema es que nunca pensaron en lo mismo, y por eso no hay acuerdo ni sobre el rojo ni sobre el amarillo: hay un error sobre la identidad de la cosa específica (**art. 1453**).

Cambiamos la historia: los dos hablan del rojo, pero la Fran cree que es de fibra de carbono y resulta ser de plástico. Ahora sí se pusieron de acuerdo en el acto y en la cosa, y el error está solo en la cabeza de la Fran, sobre la materia del kayak. Ya no es error obstáculo, sino error sustancial (**art. 1454**, en (ii)).

c) Sanción del error esencial

Es una de las discusiones clásicas del capítulo, y la doctrina nacional está dividida en tres opiniones. Como hace notar **VIAL**, las dos primeras parten de la misma base, que el error obstáculo impide que se forme el consentimiento; solo discrepan en la sanción que se sigue de eso.

c.1) Inexistencia

Si el error impide el acuerdo de voluntades, falta un requisito sin el cual el acto ni siquiera nace, y la conclusión es que el acto es jurídicamente inexistente. Es la consecuencia natural de la idea de Pothier: no hay nada que anular porque no llegó a haber consentimiento.

c.2) Nulidad absoluta

Otros comparten el punto de partida, pero estiman que la inexistencia es una sanción de origen doctrinario, que el Código no recoge. Como la sanción más grave que la ley sí contempla, incluso para los actos en que falta el consentimiento, es la nulidad absoluta, esa sería la sanción del error esencial. Es la posición de **ALESSANDRI BESA**, y en el mismo sentido se cita el fallo de la Corte Suprema *Torres con Fisco* (4 de abril de 1945, RDJ t. 42, 2ª parte, secc. 1ª, p. 551).

c.3) Nulidad relativa

Un tercer grupo, con **LEÓN HURTADO** a la cabeza, se queda con la letra de la ley. El **art. 1453** dice que este error "vicia el consentimiento", y según el **art. 1682** inc. final todo vicio que no esté sancionado con nulidad absoluta "produce nulidad relativa". El artículo siguiente confirma la lectura: el error sustancial, sancionado con nulidad relativa, vicia "asimismo" el consentimiento, es decir, del mismo modo que el error esencial. Además, la nulidad absoluta protege el interés general y la moral, mientras que el error esencial solo afecta el interés particular de los contratantes.

León Hurtado agrega dos razones prácticas. No se ve por qué impedir que las partes, una vez aclarado el malentendido, ratifiquen el acto si quieren mantenerlo, cosa que la nulidad absoluta no permite. Y no es razonable que la acción dure diez años en vez de cuatro: con el tiempo, probar un error se vuelve casi imposible, y la estabilidad de los negocios sale perjudicada.

(ii) Error sustancial

Art. 1454. "El error de hecho vicia asimismo el consentimiento cuando la sustancia o calidad esencial del objeto sobre que versa el acto o contrato, es diversa de lo que se cree; como si por alguna de las partes se supone que el objeto es una barra de plata, y realmente es una masa de algún otro metal semejante.

El error acerca de otra cualquiera calidad de la cosa no vicia el consentimiento de los que contratan, **sino cuando esa calidad es el principal motivo de una de ellas para contratar, y este motivo ha sido conocido de la otra parte.**"

Aquí las partes sí se ponen de acuerdo en el acto y en la cosa, pero quien yerra le atribuye a esa cosa una sustancia o una calidad esencial que no tiene. Por eso, dice **LEÓN HURTADO**, el error sustancial es "sin discusión" un vicio del consentimiento: hay consentimiento, pero formado sobre un falso concepto. La dificultad está en saber qué es la sustancia y qué es la calidad esencial.

a) Sustancia y calidad esencial

a.1) Son sinónimos

Una parte de la doctrina nacional lee las dos expresiones como equivalentes, porque el artículo las une con la conjunción "o". Para este sector ambas tienen un sentido objetivo, más precisamente material, que es el que sugiere el ejemplo de la barra de plata.

a.2) Son conceptos distintos

Para **VIAL**, la sustancia es "la materia específica que constituye la cosa", algo que se aprecia en forma estrictamente objetiva: cree comprar vino quien compra vinagre. La calidad esencial, en cambio, "es eminentemente subjetiva y guarda relación con la intención de las partes": es la cualidad por la cual se contrata y sin la cual no se habría contratado. El ejemplo de la barra de plata es el típico de la doctrina francesa de la época del Código Napoleón, que solo hablaba de sustancia; **BELLO** se apartó de ese modelo y, siguiendo a **POTHIER**, agregó la calidad esencial. Tan convencido está Vial de que lo determinante es esta última que propone eliminar la palabra "sustancia" en una futura reforma. La doctrina moderna ya no habla de error sustancial, sino de error sobre las **cualidades relevantes** de la cosa, y ese concepto calza con el del **art. 1454**.

a.3) La lectura de Boetsch

BOETSCH también cree que son cosas distintas, y lo prueba el hecho de que el redactor del Código se separó a sabiendas del modelo francés. Pero las distingue de otra manera: la sustancia es la composición material de la cosa, y la calidad esencial son sus características inmateriales, como la autoría de una obra de arte, las particularidades jurídicas de un bien (un fundo que está en proceso de expropiación) o los caracteres más apreciados de una cosa (que el pan esté blando). Muchas veces esas características importan más que la materia.

De ahí saca una diferencia con la postura anterior: para calificar algo como calidad esencial **no hace falta** que su importancia venga de los motivos personales de las partes. Su argumento es el inciso 2° del **art. 1454**, que distingue calidades esenciales y no esenciales, y solo respecto de estas últimas pregunta si fueron el principal motivo de una de las partes. El elemento subjetivo sirve, entonces, para decidir si una calidad accidental puede viciar el consentimiento, no para saber si una calidad es esencial.

EJEMPLO

El bulldog francés que creció demasiado

La Vale paga \$1.500.000 en un criadero de Colina por el Bruno, un cachorro "bulldog francés con pedigrí". A los seis meses el Bruno pesa 28 kilos, tiene las orejas caídas y el veterinario le confirma lo que ya sospechaba todo el pasaje: es un quiltro de buen corazón. En la sustancia no hubo error: la Vale quería un perro y tiene un perro. El error está en una calidad esencial, la raza, sin la cual nadie paga ese precio. Para **VIAL** es esencial porque fue la cualidad por la que la Vale compró; para **BOETSCH**, porque el pedigrí es una característica imaterial que define a la cosa, aunque la Vale nunca hubiera dicho para qué lo quería. Por cualquiera de los dos caminos, su consentimiento está viciado (**art. 1454** inc. 1°). Otra cosa es que, a estas alturas, la Vale quiera devolverlo.

b) La materia se presume relevante

Para **VIAL**, la mención expresa de la sustancia y el ejemplo de la barra de plata muestran que el artículo contiene una **presunción simplemente legal**: se presume que la materia de la cosa fue lo que llevó a contratar. Quien alega haber comprado algo creyéndolo de otra materia no tiene que probar que eso le importaba; le basta el hecho objetivo de que la materia era distinta. La otra parte, eso sí, puede destruir la presunción probando que la materia le era indiferente a quien alega el error.

La Maite compra en una joyería del centro una cadena "de oro 18 kilates", a precio de oro, y resulta ser bronce bañado: su consentimiento está viciado sin más prueba que esa. Distinto es el caso del Joaco, coleccionista, que compra la camiseta autografiada por el plantel de Colo-Colo campeón de la Copa Libertadores de 1991 creyendo que es de algodón, y resulta ser de tela sintética. Al Joaco lo único que le importan son las firmas, y si el vendedor lo prueba, el error sobre la materia es irrelevante.

c) La labor del juez

No hay una regla que diga en abstracto qué es la calidad esencial de una cosa, y las partes casi nunca dejan constancia de ella en el contrato. Le toca determinarla al juez, a la luz de las circunstancias del caso y de lo que, en esas circunstancias, deba tenerse objetivamente por calidad esencial. **VIAL** describe el razonamiento en tres pasos. Primero, el juez deduce qué cualidades habría considerado esenciales la mayoría de las personas en una situación parecida, al punto de no contratar si faltaban. Segundo, si esa deducción coincide con lo que alega quien sufrió el error, su consentimiento está viciado, salvo que la otra parte pruebe que igual habría contratado. Tercero, por exclusión, todas las demás cualidades son accidentales.

La Cote compra en una tienda de antigüedades de calle Italia un sillón "art déco original", pagando precio de pieza de época, y resulta ser una réplica reciente. El lugar y el precio permiten al juez presumir que, para cualquiera en su situación, ser original era la calidad esencial del sillón. Otra cosa sería si lo hubiera comprado en el Persa Biobío, a \$40.000, entre muebles nuevos y usados.

d) ¿Es calidad esencial que la cosa sea del vendedor?

La pregunta tiene interés porque en Chile "la venta de cosa ajena vale" (**art. 1815**), de modo que el contrato no puede anularse por el solo hecho de que el vendedor no fuera dueño. ¿Puede el comprador, entonces, pedir la nulidad alegando que para él era calidad esencial que la cosa perteneciera al vendedor? Para **VIAL** no hay una respuesta en abstracto: si nada se dijo en el contrato, el juez podría presumir que el dominio era calidad esencial cuando las circunstancias lo permitan. Si don Ernesto compra una camioneta en una automotora establecida, a precio de mercado, y resulta que no era del vendedor, el juez puede razonar así. Si la hubiera comprado por una red social, a la mitad de su valor y sin papeles, no.

e) Sanción

El error sustancial vicia el consentimiento (**art. 1454**) y, como no está entre las causales de nulidad absoluta, el acto en que incide adolece de **nulidad relativa** (**art. 1682** inc. final).

JURISPRUDENCIA

IZQUIERDO CON MINISTROS DE LA ADUANA DE VALPARAÍSO, CORTE SUPREMA, 4 DE NOVIEMBRE DE 1859, GACETA DE LOS TRIBUNALES, 1859, N° 1.635, P. 1012

Rufino Izquierdo remató en la Aduana de Valparaíso cuarenta cajones de tarros de conservas, sin que se abriera ninguno como muestra. Los tarros resultaron contener zanahorias en agua y caldo, y no las sopas, pescados, carnes o guisos que los asistentes creían rematar. La Aduana se defendió diciendo que, al fin y al cabo, eran conservas. El tribunal razonó que, aunque unas y otras sean conservas, *deben reputarse de calidad esencialmente diversa, atendida la notable diferencia de su valor*, y que el comprador podía excusarse de abrir un tarro confiando en el avalúo previo. Declaró nulo el remate por el error de hecho del **art. 1454**, y la Corte Suprema aprobó la sentencia.

(iii) Error sobre las calidades accidentales

Las calidades accidentales de una cosa se encuentran por descarte: primero hay que fijar cuáles son las esenciales, y todas las demás son accidentales. Así lo sugiere el propio inciso 2° del **art. 1454** cuando habla de "otra cualquiera calidad". Como pasa con las esenciales, no hay una fórmula para identificarlas, y es el juez quien lo decide a partir de las circunstancias del caso.

Por regla general, el error sobre ellas **no vicia el consentimiento**: son cualidades que normalmente no deciden a nadie a contratar. Si el Rorro compra un vino creyendo que la botella trae corcho y viene con tapa rosca, su error es irrelevante. Para **LEÓN HURTADO**, son también errores accidentales el que recae en la identidad de los propietarios colindantes y el que recae en el valor de la cosa, que solo excepcionalmente importa, a través de la lesión. Son detalles del contrato, no su contenido.

La excepción está en el mismo inciso: el error sobre una calidad accidental vicia el consentimiento si concurren dos requisitos.

- a) Que esa calidad haya sido el principal motivo de una de las partes para contratar
- b) Que ese motivo haya sido conocido de la otra parte

Cumplidos los dos, la calidad accidental queda elevada a la categoría de esencial. No es necesario que quien sufre el error haya declarado su motivo: como observa **LEÓN HURTADO**, la ley solo pide que haya "sido conocido de la otra parte", y eso puede ocurrir por cualquier medio. Lo que sí debe hacer la víctima, explica **VIAL**, es probar ambos requisitos, porque respecto de las calidades accidentales opera la presunción contraria a la de la materia: se presume que no fueron el motivo para contratar.

Si el Rorro compra ese mismo vino porque es de la cosecha 2018, el año en que nació su hija, y así se lo cuenta al dueño de la botillería, y la botella resulta ser de 2019, su error vicia el consen-

miento. En ese caso, como en el del error sustancial, la sanción es la **nulidad relativa** (**art. 1682** inc. final).

NO CONFUNDIR

Calidad esencial y calidad accidental elevada a esencial

Si la calidad es **esencial** (inc. 1°), el error vicia el consentimiento aunque la otra parte no su-
ciera nada: basta que una sola parte yerre. Si la calidad es **accidental** (inc. 2°), además de ser
el principal motivo de quien yerra, ese motivo tiene que haber sido **conocido** por la otra par-
te. Conocer el motivo no es compartir el error: la otra parte puede saber perfectamente que la
cosa no tiene esa calidad.

(iv) Error en la persona

Art. 1455. "El error acerca de la persona con quien se tiene intención de contratar **no vicia el consentimiento, salvo que la consideración de esta persona sea la causa principal del contrato.**

Pero en este caso la persona con quien erradamente se ha contratado, **tendrá derecho a ser indemnizada de los perjuicios en que de buena fe haya incurrido** por la nulidad del contrato."

Quien sufre este error se equivoca sobre la identidad de una persona o sobre alguna de sus cualidades personales, porque no la conoce o la conoce mal. Las **cualidades** son, para VIAL, "aquellas notas o caracteres objetivos de índole estable o permanente que configuran la personalidad", como la capacidad laboral, los títulos profesionales o grados académicos o la solidez patrimonial, que deben apreciarse caso a caso.

La regla general es que este error **no importa**, porque en la mayoría de los actos la persona da lo mismo: se habrían celebrado igual sin el error. A la señora del almacén de la esquina le da lo mismo si quien le compra pan al contado es el alcalde o un turista; solo le interesa que le paguen.

a) Los actos *intuitu personae*

El error en la persona solo es relevante en los actos *intuitu personae*, los que se celebran en consideración a una o más personas determinadas. **LEÓN HURTADO** sostiene que, cuando el acto tiene ese carácter, debe presumirse que el error vicia el consentimiento. Para saber cuáles son, la doctrina da algunas pautas.

a.1) Los actos de familia

Por regla general se celebran en atención a la persona: el matrimonio, la adopción, el reconocimiento de un hijo.

a.2) Los actos patrimoniales gratuitos

Los actos patrimoniales normalmente miran a las cosas o prestaciones y no a las personas, así que no son *intuitu personae*. Se exceptúan los gratuitos que se suponen hechos en consideración a alguien: la donación, el depósito, el comodato y, agrega León Hurtado, el mutuo sin interés. Incluso una donación hecha a un grupo indeterminado puede mirar a la persona de manera genérica: si se dona a los pobres de una parroquia, ser pobre es la cualidad determinante.

a.3) Los actos patrimoniales onerosos de confianza

Que un contrato sea oneroso no excluye que mire a la persona. Lo son los que suponen confianza en alguien específico: el mandato, la sociedad civil y el arrendamiento de servicios. León Hurtado suma la sociedad colectiva, el mutuo con interés, el contrato de trabajo y, en general, los contratos cuyas obligaciones se van cumpliendo durante un tiempo, porque de quién sea la otra parte depende el cumplimiento.

a.4) Los casos que la ley señala

A veces es la ley la que dice que el acto mira a la persona. Así, "la transacción se presume haberse aceptado por consideración a la persona con quien se transige. Si se cree pues transigir con una persona y se transige con otra, podrá rescindirse la transacción" (**art. 2456** incs. 1° y 2°).

b) La doctrina moderna

PIETROBON, citado por Vial, propone dejar de lado la categoría de los contratos *intuitu personae* y preguntarse, en cualquier tipo de negocio, si la persona del otro contratante fue el motivo principal para celebrarlo. Habría que probarlo en cada caso con criterios objetivos: el tipo de contrato, las cualidades de la otra parte, los intereses en juego, la confianza que inspira esa persona. En una donación la prueba sobra, por la naturaleza del contrato; en un comodato no sería difícil; en una compraventa, donde importa sobre todo el intercambio, la regla es la irrelevancia del error, salvo casos excepcionales.

c) El error en la persona en el matrimonio

Por mucho tiempo se discutió si el error en la identidad del otro contrayente se limitaba a la persona física o alcanzaba también a la persona civil o social, es decir, a cualidades que la individualizan. La jurisprudencia se quedaba con lo primero. **LEÓN HURTADO**, con la doctrina francesa, defendió lo segundo, y su propuesta fue acogida por la Ley N° 19.947, de Matrimonio Civil (2004). Su **art. 8** considera que falta el consentimiento libre y espontáneo si ha habido error acerca de la identidad de la persona del otro contrayente (N° 1), o acerca de alguna de sus cualidades personales que, atendida la naturaleza o los fines del matrimonio, ha de ser estimada como determinante para otorgar el consentimiento (N° 2).

La opinión dominante, explica **VIAL**, entiende estas cualidades con un criterio restrictivo, por la naturaleza del matrimonio. No bastaría equivocarse sobre el carácter, la profesión, la inteligencia, la belleza o la situación económica del otro. Sí serían relevantes, según **PIETROBON**, "desconocer que uno de los contrayentes ha sufrido condenas penales, pensando que se trata de una persona que nunca cometió un delito" o "reputar sano al cónyuge que padece de enfermedad contagiosa trasmisible a los descendientes".

JURISPRUDENCIA

BUTCHER CON PLAZA, CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO, 6 DE JULIO DE 1943, RDJ T. 41, 2ª PARTE, SECC. 2ª, P. 17

Leslie Butcher pidió la nulidad de su matrimonio porque se había equivocado en el nombre de su mujer, en el de sus suegros, en su estado civil (ella se declaró soltera y era casada) y en su edad (dijo tener 32 años y tenía 49). Sostuvo que el error en la identidad de la persona debía comprender a la persona civil o social. El tribunal lo rechazó: siguiendo la definición de persona del **art. 55**, la ley se refería *a la identidad del individuo humano físicamente considerado*, con abstracción de sus cualidades o atributos civiles y sociales. La Corte confirmó. **Ojo:** el fallo aplicó el art. 33 N° 1 de la antigua Ley de Matrimonio Civil de 1884, que solo hablaba de la identidad. Hoy el **art. 8** N° 2 de la Ley 19.947 incluye el error en las cualidades personales determinantes.

d) Efectos

Cuando la consideración de la persona es la causa principal del contrato, el error vicia el consentimiento y el acto adolece de **nulidad relativa** (**art. 1682** inc. final). Pero la persona con quien se contrató por error no tiene la culpa, y por eso, declarada la nulidad, puede pedir que se la indemnice de los perjuicios en que haya incurrido de buena fe (**art. 1455** inc. 2°). La Flo contrata para su matrimonio a "Vicente Lagos, fotógrafo", porque vio su trabajo en Instagram, y resulta que se comunicó con un homónimo que recién empieza. Puede anular el contrato, pero el fotógrafo homónimo, que actuó de buena fe, tiene derecho a ser indemnizado.

CLASE DE ERROR	ARTÍCULO	¿CUÁNDO VICIA EL CONSENTIMIENTO?	SANCIÓN
Esencial u obstáculo	Art. 1453	Siempre que recaiga sobre la especie de acto o contrato o sobre la identidad de la cosa específica	Discutida: inexistencia, nulidad absoluta o nulidad relativa
Sustancial	Art. 1454 inc. 1°	Siempre que la sustancia o calidad esencial sea distinta de lo que se cree; basta el error de una parte	Nulidad relativa
Calidad accidental	Art. 1454 inc. 2°	Por regla general no vicia; sí, si fue el principal motivo de una parte y ese motivo era conocido de la otra	Nulidad relativa (si vicia)
En la persona	Art. 1455	Por regla general no vicia; sí, si la consideración de la persona es la causa principal del contrato	Nulidad relativa (si vicia), con indemnización a la otra parte de buena fe

5.4. El error en los actos bilaterales

En un acto bilateral no hace falta que las dos partes estén equivocadas para que el error vicie el consentimiento. El propio **art. 1454** lo muestra con su ejemplo: basta que "por alguna de las partes" se suponga que el objeto es una barra de plata. Lo mismo vale para el error sobre una calidad accidental (inc. 2°): también ahí yerra una sola parte. Lo que la ley agrega en ese caso es que la otra parte **conozca** el motivo principal de quien yerra, no que comparta su error. Algunos autores afirman que en este supuesto el error debe ser compartido por ambas partes, pero el artículo no dice eso, y tanto **LEÓN HURTADO** como **VIAL** leen la norma como un requisito de conocimiento del motivo, que puede obtenerse por cualquier medio.

5.5. El error en los actos unilaterales

Aunque el Código regule el error a propósito del consentimiento, sus reglas no se limitan a los contratos. Todos los actos, unilaterales o bilaterales, se rigen en lo subjetivo, dice **PIETROBON**, por "un principio unitario: el concepto de volición consciente". Por eso el error relevante puede invocarse para anular cualquier acto, entre vivos o por causa de muerte. Los ejemplos más claros están en el testamento:

Art. 1058. "La asignación que pareciere motivada por un error de hecho, de manera que sea claro que sin este error no hubiera tenido lugar, **se tendrá por no escrita.**"

Art. 1057. "El error en el nombre o calidad del asignatario **no vicia la disposición, si no hubiere duda acerca de la persona.**"

La aceptación de una herencia es otro caso. El **art. 1234** permite rescindirla por fuerza, por dolo y por lesión grave a causa de disposiciones testamentarias que el asignatario no conocía al aceptar. No nombra el error, pero, como observa **VIAL**, la lesión lo supone siempre: quien acepta ignorando esas disposiciones se representó falsamente la realidad.

5.6. Error común

Para **FIGUEROA**, "el error común es aquel error en el que todos de buena fe incurren".

Es el error que comparten todos los habitantes de un lugar, o la inmensa mayoría de ellos. Cuando cumple ciertos requisitos, no vicia la voluntad de quien lo sufre y el acto es válido, porque se trata de un error del que nadie podía escapar. La idea se resume en la máxima *error communis facit ius*: el error común constituye derecho.

La máxima se atribuye a Roma, pero, como precisa **CLARO SOLAR**, su formulación es obra de los glosadores. La tomaron del caso de Barbarius Philippus, un esclavo fugitivo que se hizo pasar por hombre libre y llegó a ser nombrado pretor. Cuando se descubrió la verdad, se discutió si debían anularse todos los actos en que había intervenido, y Ulpiano, siguiendo a Pomponio, resolvió mantenerlos para no perjudicar a quienes habían litigado ante él, "pues esto es lo más humano". Para Claro Solar el principio se justifica en la equidad y en el interés social: es "un principio de buen orden en la sociedad, una regla protectora de la seguridad social", que dejaría de existir si no se protegiera a quien actuó con toda la prudencia necesaria.

El ejemplo clásico es el del funcionario público nombrado sin cumplir algún requisito legal, que ya cesó en el cargo o que estaba suspendido. Los actos que autorizó valen, porque las partes no tienen por qué conocer ni averiguar las causas que le impedían ejercer: les basta confiar en la apariencia de que quien desempeña públicamente un cargo reúne las condiciones para hacerlo. **FIGUEROA** agrega otro caso: el principio permitiría salvar los matrimonios celebrados ante un oficial del Registro Civil que no fue designado legalmente.

Para que el error común no vicie el consentimiento se requiere:

(i) Que lo comparta la generalidad

Debe ser un error de todos o de la inmensa mayoría de los habitantes del lugar: no solo de los contratantes, sino del público. Según **CLARO SOLAR**, que sea común crea una **presunción de invencibilidad**: a quien lo alega le basta probar que el error era casi general, y es la contraparte quien debe probar que podía evitarse.

(ii) Que tenga un justo motivo

Debe haber un fundamento razonable para tener por verdadera una situación falsa. Claro Solar habla de un "título colorado": una apariencia que da a quien la lleva el carácter que se atribuye, como el nombramiento hecho por la autoridad.

(iii) Que quien lo invoca esté de buena fe

Reunidos los tres, el error se considera invencible: quienes celebraron el acto no pudieron sustraerse a él. **FIGUEROA** reduce los requisitos a dos, porque entiende el justo motivo como parte de la buena fe; el contenido es el mismo.

El Código no tiene una norma general que acoja el error común, pero varias disposiciones se inspiran en él. La más citada es la del testigo inhábil:

Art. 1013. "Si alguna de las causas de inhabilidad expresadas en el artículo precedente no se manifestare en el aspecto o comportamiento de un testigo, y se ignorare generalmente en el lugar donde el testamento se otorga, fundándose la opinión contraria en hechos positivos y públicos, **no se invalidará el testamento por la inhabilidad real del testigo**. Pero la habilidad putativa no podrá servir sino a uno solo de los testigos."

En Pichidegua todos conocen a don Lalo como un vecino respetado, y nadie sabe que una sentencia lo inhabilitó para ser testigo (**art. 1012** N° 8). Si firma como testigo el testamento de la señora Rosa, el testamento vale, siempre que don Lalo sea el único testigo inhábil.

Otra aplicación está en la sociedad:

Art. 2058. "La nulidad del contrato de sociedad no perjudica a las acciones que **corresponden a terceros de buena fe** contra todos y cada uno de los asociados por las operaciones de la sociedad, si existiere de hecho."

Y una tercera en la muerte presunta: si se rescinde el decreto de posesión definitiva, los bienes se recobran en el estado en que se encuentren, "subsistiendo las enajenaciones, las hipotecas y demás derechos reales constituidos legalmente en ellos" (**art. 94** regla 4ª).

Queda la pregunta de si el error común opera solo en los casos que la ley señala o en cualquiera que reúna los requisitos. Algunos autores lo limitan a los primeros: si el legislador tuvo que mencionarlo expresamente cada vez que quiso aplicarlo, es porque no lo acepta como regla general, y sin una norma excepcional y expresa no cabe invocarlo. Otros ven en esas normas la expresión de una idea general, que debe aplicarse aunque el caso no esté previsto. Es la opinión de **CLARO SOLAR**, para quien, reunidas las condiciones y "tratándose de casos análogos a los que la ley contempla", la máxima "tiene aplicación, aunque no aparezca expresamente reconocida en una disposición del Código", y también la de **FIGUEROA**.

CONEXIONES

Las clases de error en otras materias

En este manual: IV.A.4 ¿Distingue el Código Civil chileno la inexistencia y la nulidad absoluta? (sanción del error esencial) y IV.B Nulidad (**art. 1682** inc. final).

Familia: error en la identidad y en las cualidades del otro contrayente (Ley 19.947, **art. 8**). Revisar apunte de Familia, [FALTA: sección] (p. ____).

Sucesorio: error en las asignaciones (**arts. 1057 y 1058**), testigo putativo (**art. 1013**) y rescisión de la aceptación (**art. 1234**). Revisar apunte de Sucesorio, [FALTA: sección] (p. ____).

Contratos: venta de cosa ajena (**art. 1815**), sociedad de hecho (**art. 2058**) y transacción (**art. 2456**). Revisar apunte de Contratos, [FALTA: sección] (p. ____).

6. EL DOLO

6.1. Concepto

El Código define el dolo al final del **art. 44**, después de las tres especies de culpa: "El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro". "Inferir injuria" significa aquí causar daño. Lo que caracteriza al dolo, entonces, es que siempre hay alguien que quiere, deliberadamente, perjudicar a otro. Esa definición es una sola, pero el dolo aparece en el Derecho Civil en tres escenarios distintos, y en cada uno cumple una función diferente.

(i) **Los tres ámbitos del dolo**

a) En la celebración del acto o contrato

Es el que interesa en este capítulo. Una persona recurre a trampas, mentiras u otros artificios para que otra celebre un acto que, sin ese engaño, no habría celebrado. Aquí el dolo es un **vicio de la voluntad** (**arts. 1451, 1458 y 1459**) y actúa antes de la celebración del acto o al mismo tiempo.

La definición que le ha dado la doctrina al dolo en este ámbito es la de "la maquinación fraudulenta destinada a que una persona preste su consentimiento para la celebración de un acto o contrato".

b) En el cumplimiento del contrato

El contrato ya se celebró sin vicios, y es el deudor quien recurre a maniobras ilícitas para no cumplir. Ya no hay un vicio del consentimiento, sino una circunstancia que **agrava su responsabilidad**: si el deudor actuó con dolo, responde no solo de los perjuicios que se previeron o pudieron preverse al contratar, sino de todos los que fueron consecuencia inmediata o directa del incumplimiento.

miento (**art. 1558**). Al mismo ámbito pertenece el **art. 1546**: los contratos deben ejecutarse de buena fe, y quien no lo hace incurre en dolo.

c) En la responsabilidad extracontractual

El dolo es el elemento que convierte un hecho ilícito en **delito civil**: la acción u omisión ejecutada con la intención de dañar a la persona o los bienes de otro. Es el sentido que mejor calza con la letra del **art. 44**.

(ii) **Otras definiciones doctrinales**

Los autores han ido afinando el concepto. Para **VON TUHR**, el dolo es la "voluntad dirigida a obtener efectos contrarios al derecho"; para **PESCIO**, el "empleo de medios engañosos, ilícitos e indebidos, destinados a perjudicar a otra persona"; y para **LEÓN HURTADO**, los "artificios o acechanzas, destinados a inducir o a mantener en el error, para determinar a una persona a consentir en el acto jurídico". Todas apuntan a lo mismo: un ardid con un solo propósito, confundir a la víctima para obtener su declaración de voluntad en términos que la perjudican, y que benefician a quien fraguó el engaño o a un tercero.

(iii) **Elementos del dolo**

a) Elemento psicológico

La intención de engañar a otro y de defraudarlo.

b) Elemento material

La forma concreta que toma el engaño. Puede consistir en maniobras o maquinaciones, en una mentira o en la reticencia, que es callar lo que la otra parte debía conocer.

¿Basta una simple mentira, la mera afirmación de algo falso? Una doctrina casi uniforme responde que, **por regla general, no**. Para que la mentira sea dolo tiene que ir acompañada de otras circunstancias: la intención de dañar de quien miente, que lo dicho sea verosímil para quien lo escucha, y que la víctima haya puesto al menos una vigilancia mediana en defender sus intereses.

El dolo y el error tienen algo en común: en ambos la víctima se representa la realidad de manera falsa. La diferencia está en el origen de esa falsa representación. En el error, la persona se equivoca sola; en el dolo, alguien la hace equivocarse.

6.2. Clases de dolo

(i) **Dolo bueno y dolo malo**

El **dolo bueno** no busca perjudicar a nadie: son los elogios, las exageraciones y las alabanzas con que cualquier vendedor intenta convencer al comprador. Cuando el casero de la feria de Temuco grita que sus frutillas son "las más dulces del sur de Chile", nadie entiende que esté engañando. El

dolo malo, en cambio, es el del **art. 44**: lleva la intención positiva de causar daño, y es el único que importa como vicio de la voluntad.

(ii) Dolo positivo y dolo negativo. La reticencia

La distinción mira a la forma del engaño, si consiste en hacer algo o en abstenerse; ambas especies se rigen por los mismos principios. El **dolo positivo** es el engaño activo: hacer pasar por verdaderas circunstancias falsas, o suprimir o alterar las verdaderas. Don Raúl vende su auto por Marketplace y, antes de publicarlo, retrocede el cuentakilómetros de 180.000 a 90.000 km. El **dolo negativo** consiste en ocultar con astucia hechos verdaderos.

La forma más importante de dolo negativo es la **reticencia**: guardar silencio sobre circunstancias que se tenía la obligación de dar a conocer. Si ese silencio lleva a la otra parte a celebrar un acto que no habría celebrado, o que habría celebrado en otras condiciones, su consentimiento queda viciado. La señora Juana vende su casa en Valdivia sabiendo que el subterráneo se inunda todos los inviernos, y no se lo dice al Gaspar, que la visita en enero. Si el Gaspar no habría comprado de haberlo sabido, hay dolo negativo.

A veces la ley impone expresamente el deber de informar. En la compraventa, el vendedor que conocía los vicios de la cosa y no los declaró, o que debía conocerlos por su profesión u oficio, debe además indemnizar perjuicios (**art. 1861**). En el seguro, el asegurado debe declarar sinceramente las circunstancias **que le solicite el asegurador** para identificar la cosa y apreciar el riesgo, e informar, si se lo piden, de otros seguros sobre el mismo objeto (**art. 524** N°s 1 y 2 C. de Comercio). Este caso tiene reglas propias: si el asegurador no pidió la declaración, no puede alegar después las reticencias del contratante, y si sí la pidió, la sanción no es la del Código Civil, sino que el asegurador puede rescindir el contrato o queda liberado de pagar la indemnización (**art. 525** C. de Comercio).

Pero no hace falta que la ley lo diga para que el silencio sea doloso: la vida diaria ofrece muchos casos. En una tienda que solo anuncia "repuestos originales" le venden al Seba un alternador genérico, sin advertírsele. Su consentimiento está viciado, porque es lógico que espere comprar ahí lo que el local ofrece, y si por excepción una pieza no es original, el vendedor tiene que decirlo.

(iii) Dolo principal y dolo incidental

El **dolo principal**, también llamado determinante o inductivo, es el que lleva a la persona a celebrar el acto: sin él, no lo habría celebrado. Como es la causa de la decisión, tiene que existir antes de que se manifieste la voluntad o al mismo tiempo. El **dolo incidental** no decide la celebración del acto, que se habría celebrado igual, pero sí sus condiciones: sin el engaño, la víctima habría contratado en términos más favorables para ella.

El Nico quiere un auto 100% eléctrico para no gastar más en bencina, y el vendedor le entrega un híbrido asegurándole que es eléctrico: sin ese engaño no habría comprado, y el dolo es principal. Distinto es el caso de la Pía, que iba a comprarle a la Dani su bicicleta de todas maneras. La Dani

le dice que tiene un año de uso (tiene cuatro) y le cobra \$100.000 más: la Pía habría comprado igual, pero más barato, y el dolo es incidental.

6.3. Cuándo el dolo vicia el consentimiento

Art. 1458. "El dolo no vicia el consentimiento sino cuando es obra de una de las partes, y cuando además aparece claramente que sin él no hubieran contratado.

En los demás casos el dolo da lugar solamente a la acción de perjuicios contra la persona o personas que lo han fraguado o que se han aprovechado de él; contra las primeras por el total valor de los perjuicios, y contra las segundas hasta concurrencia del provecho que han reportado del dolo."

(i) En los actos bilaterales

El inciso 1° exige dos requisitos copulativos:

- a) Que sea obra de una de las partes
- b) Que sea principal

Si falta cualquiera de los dos, el acto es válido. El Mati compra el departamento de don Jaime en Ñuñoa porque un amigo de don Jaime, por su cuenta y sin que este lo sepa, le inventa que la Línea 7 tendrá una estación al frente. El engaño fue determinante, pero no vino de la otra parte: el consentimiento del Mati no está viciado y solo puede demandar perjuicios (ver 6.6).

(ii) En los actos unilaterales

El Código no tiene una regla general, pero varias disposiciones muestran que el dolo también importa en estos actos. Quien obtuvo por dolo una disposición testamentaria es indigno de suceder (**art. 968** N° 4); la renuncia a los gananciales puede rescindirse si la mujer o sus herederos fueron inducidos a ella por engaño (**art. 1782** inc. 2°); y la aceptación o la repudiación de una herencia pueden rescindirse si se obtuvieron por fuerza o dolo (**arts. 1234 y 1237**). De estas normas se desprende que basta que el dolo sea **principal**. No tiene sentido exigir que sea obra de "una de las partes", porque hay una sola, y da igual que el engaño provenga de quien se beneficia con el acto o de un tercero.

La Marce acepta la herencia de su papá porque un acreedor del difunto le muestra balances falsos que esconden las deudas. El engaño viene de un tercero, pero fue determinante: puede pedir que se rescinda la aceptación (**art. 1234**).

En suma: en los actos unilaterales, el dolo vicia la voluntad si es principal; en los bilaterales, si además es obra de una de las partes.

6.4. Prueba del dolo

Art. 1459. "El dolo no se presume sino en los casos especialmente previstos por la ley. En los demás debe probarse."

La razón es que la ley presume lo contrario, la buena fe: "La buena fe se presume, excepto en los casos en que la ley establece la presunción contraria. En todos los otros la mala fe deberá probarse" (**art. 707**). Aunque está en el título de la posesión, se entiende que es una regla general, por tres razones: sus términos son amplios, no tendría sentido presumir la buena fe solo en la posesión, y el alcance de una norma depende de su naturaleza y no del lugar donde está ubicada. Los tribunales la han aplicado incluso en Derecho de Familia, en el matrimonio putativo.

Quien alega el dolo puede probarlo por cualquier medio. No rigen a su respecto las limitaciones a la prueba de testigos de los **arts. 1708 y 1709**.

Excepcionalmente, la ley presume el dolo o la mala fe. Algunos casos:

a) Bienes familiares

Quienes adquieren derechos sobre un inmueble que es bien familiar, sin la voluntad del cónyuge no propietario, "estarán de mala fe" para las restituciones que origine la nulidad (**art. 143** inc. 2°).

b) Error de derecho en la posesión

El error en materia de derecho constituye una presunción de mala fe "que no admite prueba en contrario" (**art. 706** inc. final).

c) Ocultación del testamento

Es indigno de suceder quien dolosamente detuvo u ocultó el testamento del difunto, "presumiéndose dolo por el mero hecho de la detención u ocultación" (**art. 968** N° 5).

d) El mero tenedor que pretende prescribir

En la prescripción adquisitiva extraordinaria, la existencia de un título de mera tenencia hace presumir mala fe (**art. 2510** regla 3ª).

e) El albacea

El albacea que cumple una disposición del testador contraria a las leyes es considerado "culpable de dolo" (**art. 1301**).

f) La muerte presunta

Rescindido el decreto de posesión definitiva, "el haber sabido y ocultado la verdadera muerte del desaparecido, o su existencia, constituye mala fe" (**art. 94** regla 6ª).

g) Las medidas prejudiciales precautorias

Quien obtuvo una medida prejudicial precautoria y no presenta su demanda a tiempo, o no pide en ella que se mantenga la medida, o el tribunal no la mantiene, responde de los perjuicios causados, "considerándose doloso su procedimiento" (**art. 280 C.P.C.**).

En otros casos la ley no presume el dolo, sino que exige probarlo. En el giro de cheques sin fondos o contra una cuenta cerrada, por ejemplo, el pago del cheque, los intereses y las costas permite el sobreseimiento, salvo que aparezca en forma clara que el imputado lo giró "con ánimo de defraudar" (**art. 22** de la Ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques).

6.5. Condonación o renuncia del dolo

Art. 1465. "El pacto de no pedir más en razón de una cuenta aprobada, no vale en cuanto al dolo contenido en ella, si no se ha condonado expresamente. **La condonación del dolo futuro no vale.**"

Renunciar de antemano a reclamar por el dolo que la otra parte pueda cometer adolece de **objeto ilícito**. Si se permitiera, esas cláusulas se volverían de estilo en todos los contratos y el dolo quedaría sin sanción. Si el contrato de arriendo de una bodega dice que "el arrendador no responderá de ningún perjuicio, aunque actúe con dolo", esa cláusula es nula. El dolo solo puede perdonarse **después de cometido** y una vez conocido por la víctima, y en el caso de una cuenta aprobada, ese perdón tiene que ser expreso.

6.6. Sanción del dolo

(i) **Dolo que vicia el consentimiento: nulidad relativa**

Cuando el dolo es principal y, en los actos bilaterales, además es obra de una de las partes, el acto adolece de **nulidad relativa** (**arts. 1458 y 1682** inc. final). Es la situación del Nico y su auto "eléctrico".

(ii) **Dolo que no vicia: indemnización de perjuicios**

Cuando el dolo es incidental, o es principal pero no proviene de una de las partes, el acto es válido, pero la víctima puede demandar perjuicios. El **art. 1458** inc. 2º distingue a quiénes. A quienes **fracuaron** el dolo, por el total de los perjuicios. A quienes solo **se aprovecharon** de él, hasta el monto del provecho que obtuvieron. La Pía puede cobrarle a la Dani lo que pagó de más. El Mati puede demandar al amigo de don Jaime por todos los perjuicios, y a don Jaime solo si se benefició del engaño, y únicamente hasta lo que ganó con él.

(iii) **Responsabilidad solidaria**

Si el dolo lo cometieron dos o más personas, todas responden solidariamente: "Todo fraude o dolo cometido por dos o más personas produce la acción solidaria del precedente inciso" (**art. 2317** inc. 2°).

(iv) Sanciones especiales

A veces la ley agrega una sanción propia. El cónyuge, o sus herederos, que dolosamente oculta o distrae una cosa de la sociedad conyugal pierde su porción en ella y debe restituirla doblada (**art. 1768**).

6.7. Acción de dolo

La acción rescisoria por dolo la tiene la víctima del engaño, y se dirige contra quien lo cometió. Puede hacerse valer como acción, demandando la rescisión, o como excepción, defendiéndose de quien le exige cumplir. Quien cometió el dolo no puede pedir la rescisión, porque nadie puede aprovecharse de su propio dolo.

El plazo es de **cuatro años**, contados desde el día de la celebración del acto o contrato (**art. 1691** inc. 2°), salvo que una ley especial fije otro (**art. 1691** inc. final). Así, la rescisión de la renuncia a los gananciales prescribe en cuatro años contados desde la disolución de la sociedad (**art. 1782** inc. 3°).

La acción procede no solo en los contratos, sino en otros actos jurídicos. En la aceptación de una herencia (**art. 1234**) y en la partición, que se rige por las reglas generales de la rescisión (**art. 1352**). Incluso el partícipe que enajenó su cuota, y que por eso pierde la acción de nulidad de la partición, la conserva si la partición adoleció de error, fuerza o dolo que lo perjudique (**art. 1351**).

7. LA FUERZA

7.1. Concepto

La definición que le ha dado la doctrina es la siguiente: la fuerza o violencia consiste en "los apremios físicos o morales que se ejercen sobre una persona destinados a que preste su consentimiento para la celebración de un acto jurídico".

El error y el dolo atacan el **conocimiento**: la víctima decide mal porque no sabe cómo son las cosas. La fuerza ataca la **libertad**: la víctima sabe perfectamente lo que hace, pero no lo hace porque quiera.

7.2. Clases

Según la naturaleza de la presión, la fuerza puede ser física o moral.

(i) **Fuerza física**

También llamada material o absoluta. Por medios violentos se fabrica una apariencia de consentimiento: dos sujetos le sujetan la mano a don Sergio, sedado en una clínica, y le hacen poner la huella en un poder. Aquí no hay una voluntad viciada, porque **no hay voluntad** alguna de la víctima, solo su apariencia. Por eso la fuerza física no es propiamente un vicio de la voluntad, y para una parte de la doctrina el acto es inexistente.

(ii) **Fuerza moral**

También llamada psíquica o compulsiva. La víctima sí manifiesta su voluntad, pero bajo la amenaza actual de un mal futuro contra su vida, su integridad física, su honor o su patrimonio. Siente miedo y, entre dos males, elige el que le parece menor: someterse. Su voluntad es consciente, pero no es libre. "Si no firmas, publicamos tus fotos" es fuerza moral.

Solo esta segunda clase es un verdadero vicio de la voluntad, y es la que se estudia en los puntos que siguen.

7.3. Cuándo la fuerza vicia el consentimiento

Art. 1456. "La fuerza no vicia el consentimiento, sino cuando es capaz de producir una impresión fuerte en una persona de sano juicio, tomando en cuenta su edad, sexo y condición. Se mira como una fuerza de este género todo acto que infunde a una persona un justo temor de verse expuesta ella, su consorte o alguno de sus ascendientes o descendientes a un mal irreparable y grave.

El temor reverencial, esto es, el solo temor de desagradar a las personas a quienes se debe sumisión y respeto, no basta para viciar el consentimiento."

Del **art. 1456** sale que la fuerza debe ser **grave**; del **art. 1457**, que se haya empleado "con el objeto de obtener el consentimiento", es decir, que sea **determinante**. La doctrina agrega un tercer requisito que el Código no menciona: que sea **injusta**.

(i) Que sea injusta

El mal con que se amenaza tiene que ser ilegítimo, contrario a derecho. Amenazar con ejercer un derecho no es fuerza. La Clau le prestó plata al Polo, que no le paga, y le escribe: "si no me pagas esta semana, te demando". Si el Polo paga, el pago es plenamente válido, porque exigir el pago es justamente lo que el crédito le permite hacer a la Clau.

La doctrina moderna amplía la idea: la fuerza también es injusta cuando el mal amenazado es lícito en sí mismo, pero se usa para obtener una ventaja desproporcionada. El Rodrigo sabe que su deudor manejaba curado cuando chocó, y lo amenaza con denunciarlo si no le transfiere su moto, que vale el triple de la deuda. Denunciar un delito es lícito; usarlo para sacar esa ventaja, no.

(ii) Que sea grave

Es grave la fuerza capaz de producir una impresión fuerte en una persona de sano juicio, "tomando en cuenta su edad, sexo y condición" (**art. 1456** inc. 1°).

a) Es un concepto relativo

Lo que se mide, en realidad, es el temor que la amenaza produce, y ese temor depende de quién amenaza y de quién es amenazado. La misma frase no pesa igual en todos. Si un desconocido llama a un abogado joven y le dice que, si no firma un documento, le cortarán la luz y el agua de su casa para siempre, probablemente se ría. Si llama con la misma amenaza a la señora Elba, de 82 años, que vive sola en Coyhaique, la impresión puede ser muy fuerte. El juez tiene que ponerse en el lugar de la víctima concreta.

b) La amenaza debe ser verosímil

Como la ley habla de una persona "de sano juicio", la amenaza tiene que tener posibilidades reales de cumplirse. Una amenaza absurda no impresiona a nadie sensato.

c) A quién puede afectar el mal

No es necesario que la amenaza recaiga sobre la propia víctima. El artículo menciona también a su consorte, sus ascendientes y sus descendientes, y respecto de ellos se presume que el mal amenazado infundió un justo temor. ¿Y si se amenaza a otra persona muy querida, que el artículo no nombra? La doctrina admite que también puede haber fuerza, pero sin presunción: la víctima tiene que probar que la amenaza le produjo un justo temor. Si amenazan a la Kathy con dañar a su tía Chela, que la crió, y así la hacen firmar, la Kathy deberá acreditar ese temor.

Algunos autores exigen además que la fuerza sea **actual**: que exista al momento de manifestarse la voluntad, aunque el mal amenazado sea futuro. No es un requisito distinto, porque va incluido en la gravedad: una amenaza que ya pasó no puede impresionar a nadie.

(iii) Que sea determinante

El consentimiento tiene que ser el resultado directo e inmediato de la amenaza: sin ella, la víctima no habría celebrado el acto. Es lo que el **art. 1457** expresa al exigir que la fuerza se emplee "con el objeto de obtener el consentimiento".

7.4. Indiferencia de la persona que ejerce la fuerza

Art. 1457. "Para que la fuerza vicie el consentimiento **no es necesario que la ejerza aquel que es beneficiado por ella; basta que se haya empleado la fuerza por cualquiera persona** con el objeto de obtener el consentimiento."

Aquí está la gran diferencia con el dolo. Si el hermano del comprador, sin que este sepa nada, amenaza al vendedor para que venda, la venta está viciada igual, aunque el comprador sea completamente inocente. Hay dos razones para tratar distinto a la fuerza:

a) Es más difícil defenderse de la fuerza que del dolo

Con más prudencia y atención, la víctima del dolo podría descubrir el engaño. La víctima de la fuerza, en cambio, no tiene cómo sustraerse a ella.

b) Quien quiere presionar suele valerse de otro

La ley supone que lo normal es que quien busca forzar a alguien a contratar no lo haga personalmente, sino a través de un tercero.

En el matrimonio la regla es todavía más amplia. La Ley 19.947, de Matrimonio Civil, considera que falta el consentimiento libre y espontáneo si hubo fuerza, en los términos de los **arts. 1456 y 1457**, "ocasionada por una persona **o por una circunstancia externa**", que haya sido determinante para contraer el vínculo (**art. 8** N° 3). No es necesario, entonces, que la presión venga de alguien.

NO CONFUNDIR

El dolo y la fuerza de un tercero

El dolo de un tercero **no anula** un acto bilateral: solo da acción de perjuicios (**art. 1458**). La fuerza de un tercero **sí lo anula** (**art. 1457**). Y el plazo para pedir la rescisión corre, en el dolo, **desde la celebración** del acto; en la fuerza, **desde que cesó** la violencia (**art. 1691** inc. 2°).

7.5. Prueba de la fuerza

Debe probarla quien la alega. Como se trata de acreditar un hecho, puede usar cualquier medio de prueba que la ley admita, incluidos los testigos.

7.6. Efectos de la fuerza

La fuerza moral injusta, grave y determinante vicia el consentimiento, y el acto adolece de **nulidad relativa** (**art. 1682** inc. final). La fuerza física es otra cosa: como en ella no hay voluntad, el acto es **inexistente** para quienes aceptan esa sanción en nuestro derecho, o **nulo absolutamente** para quienes creen que el Código no recoge la inexistencia (ver IV.A).

7.7. Prescripción de la acción de nulidad

La acción rescisoria por fuerza prescribe en **cuatro años**, pero no se cuentan desde la celebración, sino "desde el día en que ésta hubiere cesado" (**art. 1691** inc. 2º). La razón es evidente: mientras dura la amenaza, la víctima no está en condiciones de demandar.

7.8. Temor reverencial

El temor reverencial es "el solo temor de desagradar a las personas a quienes se debe sumisión y respeto", y no basta para viciar el consentimiento (**art. 1456** inc. 2º). Si el Agustín firma como aval del almacén de su papá solo para no desagradarlo, la fianza es válida. La palabra clave es "solo": si además del respeto hay una violencia injusta, grave y determinante, el consentimiento sí queda viciado, venga de quien venga.

Por regla general el temor reverencial no produce efectos, pero el Código lo toma en cuenta en la indignidad para suceder. Es indigno quien, sabiendo que alguien es incapaz de suceder, prometió al difunto hacerle llegar a esa persona sus bienes. Pero esta causal "no podrá alegarse contra ninguna persona de las que por temor reverencial hubieren podido ser inducidas a hacer la promesa al difunto; a menos que hayan procedido a la ejecución de la promesa" (**art. 972**).

CRITERIO	ERROR	DOLO	FUERZA
Qué afecta	El conocimiento: la víctima se equivoca sola	El conocimiento: alguien la hace equivocarse	La libertad: la víctima sabe lo que hace, pero lo hace presionada
Artículos	Arts. 1452 a 1455	Arts. 1458 y 1459	Arts. 1456 y 1457
Cuándo vicia	Según la clase de error (ver la tabla de 5.3)	Bilaterales: obra de una de las partes y principal. Unilaterales: principal	Injusta, grave y determinante
¿Importa quién lo causa?	No hay un causante	Sí, en los bilaterales: el de un tercero no anula, solo indemniza	No: vicia aunque la ejerza un tercero
Prueba	Quien lo alega	Quien lo alega; no se presume, salvo casos legales	Quien la alega
Sanción	Nulidad relativa (el error esencial es discutido)	Nulidad relativa; si no vicia, perjuicios	Nulidad relativa (la fuerza física: inexistencia o nulidad absoluta)
Plazo de 4 años desde	La celebración	La celebración	Que cesó la violencia

8. LESIÓN Y SIMULACIÓN: REMISIÓN

Muchos autores estudian la lesión y la simulación inmediatamente después de los vicios del consentimiento, como parte de la voluntad. **BOETSCH** rompe con esa costumbre, y este manual lo sigue, porque ninguna de las dos tiene que ver realmente con el consentimiento como requisito del acto.

La **lesión** es el perjuicio que sufre una persona al celebrar ciertos actos, por la desproporción entre lo que obtiene y lo que entrega. Como mira al equilibrio de las prestaciones, se relaciona más bien con el *objeto* del acto. Además, la mayoría de la doctrina nacional no la considera un vicio del consentimiento: en los casos que regula el Código basta un desequilibrio objetivo, sin que se exija nada en la mente de la víctima, salvo en la aceptación de una herencia (**art. 1234**). Esa discusión se desarrolla en IV.C.2.

La **simulación** existe cuando las partes, a sabiendas y de común acuerdo, declaran algo distinto de lo que realmente quieren: celebran un acto que no quieren celebrar (simulación absoluta) o disfrazan de un acto otro distinto (simulación relativa). Hay autores y fallos que hablan aquí de falta de consentimiento, pero eso podría sostenerse a lo más en la simulación absoluta. La mayoría la vin-

cula con la *causa*: en la absoluta no hay causa real y en la relativa la causa sería ilícita. Las clases de simulación se ven en IV.D.4.2.

Por eso, y por las particularidades que ambas presentan como causales de ineficacia, se estudian en el capítulo IV.

CONEXIONES

El dolo y la fuerza en otras materias

En este manual: IV.A La inexistencia jurídica (fuerza física), IV.B La nulidad (nulidad relativa y plazo del **art. 1691**), IV.C La lesión y IV.D La simulación.

Responsabilidad Contractual: E.4.1 El dolo contractual (**art. 1558**) y H.2.5 La condonación del dolo o de la culpa grave futuros (**art. 1465**).

Responsabilidad Extracontractual: H.2 El dolo (el dolo como elemento del delito civil).

Familia: fuerza en el matrimonio (Ley 19.947, **art. 8** N° 3), bienes familiares (**art. 143**) y ocultación de bienes sociales (**art. 1768**). Revisar apunte de Familia, [FALTA: sección] (p. ____).

Sucesorio: indignidades (**arts. 968** N° 4 y 5 y **972**) y rescisión de la aceptación o repudiación (**arts. 1234 y 1237**). Revisar apunte de Sucesorio, [FALTA: sección] (p. ____).

Obligaciones: el dolo en la acción pauliana (**art. 2468**). Revisar apunte de Obligaciones, [FALTA: sección] (p. ____).

B. LA CAPACIDAD

1. CONCEPTO

La definición que le ha dado la doctrina es la de "la aptitud para adquirir derechos y ejercitarlos".

La definición junta dos aptitudes distintas, y de ahí salen las dos clases de capacidad: la de **goce**, también llamada capacidad jurídica, que mira a la adquisición de los derechos, y la de **ejercicio**, también llamada capacidad de obrar, que mira a su ejercicio.

2. CLASES DE CAPACIDAD

2.1. Capacidad de goce

La doctrina le ha dado a la capacidad de goce, también llamada adquisitiva o jurídica, el siguiente concepto: "la idoneidad o aptitud para adquirir, gozar y ser titular de un derecho".

Dicho de otro modo, es la aptitud para ser sujeto de derechos y obligaciones. Todo ser humano la tiene, sin excepción, desde que nace. No siempre fue así: en la antigüedad, los esclavos eran seres humanos que el derecho trataba como cosas, objetos de derechos ajenos y no sujetos de derechos propios.

Por eso la capacidad de goce y la personalidad terminan siendo lo mismo: ser persona es poder ser titular de derechos. Si la ley le negara a alguien toda capacidad de goce, en el fondo le estaría negando la calidad de persona. De ahí que no exista, en nuestro derecho, ningún ser humano completamente privado de ella.

Lo que sí existen son **incapacidades de goce especiales**: la ley impide a ciertas personas adquirir uno o más derechos determinados, nunca todos. Son las llamadas *incapacidades particulares*, prohibiciones impuestas a ciertas personas para celebrar algunos actos o contratos (por ejemplo, **arts. 402, 412, 963, 965, 1061 y 1796 a 1800**). Cada una se estudia en la materia donde aparece, como las incapacidades para suceder en el Derecho Sucesorio.

La capacidad de ejercicio funciona distinto. Como no es un atributo de la personalidad, una persona puede carecer de ella por completo sin dejar de ser persona: es titular de sus derechos, pero no puede hacerlos valer por sí misma. A esas personas se les llama, en sentido propio, *incapaces*. El Vicho, de 9 años, hereda la casa de su abuela en Chillán: es dueño, porque tiene capacidad de goce, pero no puede venderla él. Si la casa se vende, actúan por él sus representantes legales.

2.2. Capacidad de ejercicio

El Código la llama *capacidad legal* y la define en el inciso final del art. 1445:

Art. 1445. "Para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad es necesario: 1° que sea legalmente capaz; 2° que consienta en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de vicio; 3° que recaiga sobre un objeto lícito; 4° que tenga una causa lícita.

La capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí misma, y sin el ministerio o la autorización de otra."

También se la describe como la idoneidad del sujeto para celebrar actos jurídicos por sí solo, sin que otra persona tenga que intervenir por él o autorizarlo. Quien no puede ejercer sus derechos de esa manera es un *incapaz de ejercicio*.

Ser capaz es la **regla general**: "Toda persona es legalmente capaz, excepto aquellas que la ley declara incapaces" (**art. 1446**). El Código, siguiendo al francés, dejó esta regla en el título de las obligaciones y los contratos, casi de pasada. Pero su alcance es general y se aplica a todos los actos jurídicos.

3. LAS INCAPACIDADES DE EJERCICIO

Si la capacidad es la regla, la incapacidad es la excepción y solo existe cuando la ley la declara **expresamente**. Por eso no tiene sentido preguntarse quiénes son capaces: lo que se estudia es quiénes son incapaces. La incapacidad de ejercicio puede ser absoluta, relativa o particular, y las tres están en el mismo artículo:

Art. 1447. "Son **absolutamente incapaces** los dementes, los impúberes y los sordos o sordomudos que no pueden darse a entender claramente.

Sus actos no producen ni aun obligaciones naturales, y no admiten caución.

Son también incapaces los menores adultos y los disipadores que se hallen bajo interdicción de administrar lo suyo. Pero **la incapacidad de las personas a que se refiere este inciso no es absoluta**, y sus actos pueden tener valor en ciertas circunstancias y bajo ciertos respectos, determinados por las leyes.

Además de estas incapacidades hay otras **particulares** que consisten en la prohibición que la ley ha impuesto a ciertas personas para ejecutar ciertos actos."

3.1. Incapacidad absoluta

(i) **Concepto**

Quien es absolutamente incapaz no puede celebrar por sí solo ningún acto jurídico, cualquiera sea el acto y cualesquiera sean las circunstancias.

(ii) **Quiénes son absolutamente incapaces**

El **art. 1447** inciso 1° nombra tres categorías.

a) Los dementes

La palabra no se toma en su sentido médico. Los tribunales han entendido que el Código la usa en un sentido amplio, como sinónimo de enfermedad mental, y para llegar ahí se han apoyado en la

parte final del **art. 21**: las palabras técnicas se toman en el sentido que les dan los que profesan la ciencia respectiva, "a menos que aparezca claramente que se han tomado en sentido diverso".

JURISPRUDENCIA

CORTE DE CONCEPCIÓN, 1896

"Es indudable que designa con esta denominación, dados el motivo y objeto por que los somete a curatela, no solo a los que por debilidad o desórdenes intelectuales, de carácter habitual, carecen en absoluto de razón, sino también a los que, por las mismas causas, no pueden dirigirse a sí mismos o administrar competentemente sus negocios".

CORTE DE CONCEPCIÓN, 2008

"La interpretación que debe darse a la expresión demencia no es en su significado científico o técnico, sino que debe tomarse claramente en un sentido más amplio, más diverso, esto es, en sentido de enfermedad mental".

Para ser incapaz, al demente no le hace falta estar declarado en interdicción, es decir, privado por sentencia judicial de la administración de sus bienes: basta que tenga perturbadas sus facultades mentales. Lo que la interdicción cambia es la prueba. Según el **art. 465**, lo que el demente hace **después** del decreto de interdicción es nulo, aunque se alegue que lo hizo en un intervalo lúcido; lo que hace **sin** interdicción previa es válido, a menos que se pruebe que estaba demente al momento de hacerlo.

Don Washington vende su parcela en Pirque. Si no tenía interdicción, la venta vale, y a su familia le tocará probar que ese día ya no estaba en sus cabales. Si ya tenía decreto de interdicción, la venta es nula aunque la haya firmado en un día de total lucidez.

b) Los impúberes

Son el varón que no ha cumplido 14 años y la mujer que no ha cumplido 12 (**art. 26**).

c) Los sordos o sordomudos que no pueden darse a entender claramente

Lo que los hace incapaces no es la sordera, sino no tener cómo expresar cabalmente lo que quieren. Quien puede darse a entender claramente, por escrito, con lengua de señas o de cualquier otro modo, es capaz.

La redacción actual viene de la Ley N° 19.904, de 2003. Antes, el Código declaraba incapaces a los sordomudos "que no pueden darse a entender por escrito", y con eso dejaba como incapaz absoluto al sordomudo que no sabía leer ni escribir, aunque se comunicara perfectamente por señas. La reforma corrigió esa situación.

(iii) **Cómo actúan los absolutamente incapaces**

Dada la naturaleza de su incapacidad, solo pueden actuar **representados**: es su representante legal quien celebra el acto, en nombre y en lugar del incapaz. Son representantes legales "uno o ambos progenitores, el adoptante y su tutor o curador" (**art. 43**). La representación se estudia en el capítulo V.

(iv) Sanción de sus actos

Los actos de los absolutamente incapaces no producen ni siquiera obligaciones naturales, y no admiten caución (**art. 1447** inc. 2º). El Código los sanciona con **nulidad absoluta** (**art. 1682** inc. 2º, ver IV.B). En estricto rigor, sin embargo, serían actos **inexistentes**: el absolutamente incapaz no tiene voluntad, y sin voluntad no hay acto jurídico (ver IV.A).

3.2. Incapacidad relativa

(i) Concepto

El relativamente incapaz sí puede celebrar actos jurídicos válidos, pero solo en ciertas circunstancias y cumpliendo las formas que la ley exige. Es lo que dice el **art. 1447** inc. 3º: sus actos "pueden tener valor en ciertas circunstancias y bajo ciertos respectos, determinados por las leyes".

(ii) Quiénes son relativamente incapaces

Hoy son dos categorías: los menores adultos y los disipadores bajo interdicción de administrar lo suyo (**art. 1447** inc. 3º).

Hasta 1989 había una tercera: la mujer casada en sociedad conyugal. Su incapacidad no se debía a ser mujer ni a estar casada, sino al régimen mismo, porque se pensaba que la unidad de la sociedad conyugal lo exigía. La Ley Nº 18.802, vigente desde el 8 de septiembre de 1989, la eliminó.

a) Los menores adultos

Son el varón mayor de 14 años y la mujer mayor de 12 que todavía no cumplen 18 (**art. 26**). Sus actos valen en dos situaciones: cuando los celebran con autorización de su representante legal, y cuando se refieren a su *peculio profesional o industrial*, es decir, a lo que ganan con su trabajo. Para administrar y gozar ese peculio, la ley los mira como mayores de edad (**art. 251**), con un límite: sus bienes raíces, aunque pertenezcan al peculio, no se pueden enajenar ni gravar sin autorización del juez con conocimiento de causa (**art. 254**).

La Coti tiene 16 años y vende ilustraciones por Instagram. Con lo que gana se compra un notebook, y para eso no necesita el permiso de nadie: respecto de su peculio, la ley la trata como mayor de edad.

b) Los disipadores bajo interdicción de administrar lo suyo

El **art. 445** no define al disipador, pero describe cómo se prueba la disipación: por "hechos repetidos de dilapidación que manifiesten una falta total de prudencia", como el juego habitual en que se

arriesgan porciones considerables del patrimonio, las donaciones cuantiosas sin causa adecuada y los gastos ruinosos. Otra definición, más breve, lo describe como el sujeto que "gasta habitualmente en forma desproporcionada a sus haberes y sin finalidad lógica alguna".

Ser disipador no basta: solo es incapaz el disipador que ha sido declarado en **interdicción** por decreto judicial. Mientras eso no ocurra, conserva toda su capacidad. Declarada la interdicción, se le nombra un curador, que administra sus bienes y actúa como su representante legal. La Moni se está gastando la herencia de su papá en apuestas en línea, pero mientras nadie pida y obtenga su interdicción, todo lo que firma es plenamente válido.

JURISPRUDENCIA
CORTE DE CONCEPCIÓN, 2008

La interdicción "es el estado de una persona que ha sido declarada, por sentencia judicial, incapaz de ejercitar actos jurídicos, privándola de la administración de sus bienes, previo el juicio correspondiente. Esta institución está establecida en interés del propio interdicto, de su familia y de la sociedad, y para aquellas personas que, por distintas circunstancias, no pueden actuar por sí mismas en los actos de la vida civil, debido a su falta de capacidad intelectual, que los coloca en situación de inferioridad respecto de las demás personas, ya que no pueden proveer eficazmente a la administración de sus intereses".

NO CONFUNDIR

La interdicción del demente y la del disipador

El **demente** es incapaz aunque nadie lo haya declarado en interdicción: la interdicción solo decide quién tiene que probar qué (**art. 465**). El **disipador**, en cambio, solo es incapaz si está bajo interdicción (**art. 1447** inc. 3°): sin decreto judicial, es plenamente capaz.

(iii) Cómo actúan los relativamente incapaces

Según lo que disponga la ley para cada acto, actúan **representados** o **autorizados**. Representados, cuando el representante legal celebra el acto en nombre y en lugar del incapaz. Autorizados, cuando el propio incapaz celebra el acto, con la anuencia de su representante expresada en la forma que la ley prescribe.

(iv) Sanción de sus actos

La ley fija los requisitos que estas personas deben cumplir para celebrar actos jurídicos. Se les llama *formalidades habilitantes*, porque se exigen en consideración al estado o calidad de las personas. Si se cumplen, el acto es plenamente válido. Si se omiten, el acto es nulo de **nulidad relativa**,

que es la sanción del **art. 1682** para la omisión de los requisitos exigidos en atención a la calidad o estado de las personas.

Además, a diferencia de lo que pasa con los absolutamente incapaces, los actos de los relativamente incapaces sí generan **obligaciones naturales**, que son las que no dan derecho a exigir su cumplimiento, pero que, una vez cumplidas, autorizan a retener lo que se dio o pagó en razón de ellas. El **art. 1470** N° 1 incluye entre ellas a las contraídas por quienes, "teniendo suficiente juicio y discernimiento, son, sin embargo, incapaces de obligarse según las leyes, como los menores adultos". Si también quedan incluidos los actos de los disipadores interdictos es discutido, y se estudia en Obligaciones.

3.3. Incapacidades particulares o especiales

Junto a la incapacidad absoluta y la relativa, el inciso final del **art. 1447** reconoce las incapacidades particulares: prohibiciones que la ley impone a ciertas personas para celebrar ciertos actos. Las razones son de moralidad, de orden público o de orden privado. Algunos casos del Código:

El tutor o curador no puede comprar los bienes raíces de su pupilo ni tomarlos en arriendo, y la prohibición alcanza también a su cónyuge, ascendientes y descendientes (**art. 412** inc. 2°, transcrito en II.A.3.3). Los cónyuges no separados judicialmente no pueden celebrar entre sí el contrato de compraventa, y tampoco el padre o la madre con el hijo sujeto a patria potestad (**art. 1796**). Al empleado público le está prohibido comprar los bienes públicos o particulares que se vendan por su ministerio, y a los jueces, abogados, procuradores o escribanos (hoy, notarios), los bienes en cuyo litigio han intervenido y que se vendan a consecuencia del litigio, aunque la venta se haga en pública subasta (**art. 1798**).

La abogada Macarena patrocinó el juicio ejecutivo en que se embargó un departamento en Ñuñoa. Cuando el departamento sale a remate, no puede comprarlo, aunque ofrezca más que nadie y la subasta sea pública.

Lo que distingue a estas incapacidades de la absoluta y la relativa es su alcance. Aquellas son **generales**: inhabilitan para una serie indeterminada de actos. Estas se reducen a **ciertos actos**, por la situación en que se encuentran las partes entre sí o respecto del objeto. Por lo mismo, cuando el Código habla aquí de "prohibición" no lo hace en el sentido técnico de ley prohibitiva, sino en el de un impedimento para que una persona determinada celebre un acto que, en general, puede celebrar cualquiera que tenga capacidad.

La sanción depende de la forma que tome la incapacidad en cada caso:

(i) **Nulidad absoluta**

Cuando la incapacidad particular consiste en una prohibición absoluta de celebrar el acto. Es el caso de la compraventa entre cónyuges no separados judicialmente, o entre el padre o la madre y el hijo sujeto a patria potestad. Si el Joaquín le vende su auto a la Tere, su señora, con quien vive en Valdivia, la compraventa es nula de nulidad absoluta.

(ii) Nulidad relativa

Cuando la incapacidad no prohíbe del todo el acto, sino que impide a la persona celebrarlo por sí sola, sin el ministerio o la autorización de otra. Así ocurre con los actos en que tenga interés el tutor o curador, que solo pueden celebrarse con autorización de los otros tutores o curadores generales no implicados de la misma manera, o del juez en subsidio (**art. 412** inc. 1°). Y así ocurre también con los bienes raíces propios de la mujer casada en sociedad conyugal: el marido no puede enajenarlos ni gravarlos sin la voluntad de ella (**art. 1754**), y si lo hace, el acto adolece de nulidad relativa (**art. 1757**).

(iii) Otras sanciones

A veces la ley no sanciona con nulidad, sino de otra manera. El ejemplo clásico era el del antiguo **art. 114**: el menor de 18 años que se casaba sin el asenso del ascendiente que debía darlo podía ser desheredado, no solo por ese ascendiente, sino por todos los demás, y si alguno de ellos moría sin testamento, recibía solo la mitad de lo que le habría correspondido en su sucesión. Ese artículo fue derogado por la Ley N° 21.515, de 2022.

Un caso vigente es el del arriendo de bienes raíces en la sociedad conyugal. Sin autorización de la mujer, el marido no puede dar en arriendo los predios urbanos, sociales o propios de ella, por más de cinco años, ni los rústicos por más de ocho, contadas las prórrogas (**arts. 1749** inc. 4° y **1756**). Si lo hace, el contrato no es nulo: "regirá sólo por el tiempo señalado" en esos artículos, y el exceso es inoponible a la mujer (**art. 1757**). Si el marido arrienda por diez años el fundo de su señora en Paillaco sin su autorización, el arriendo vale, pero solo por ocho.

CRITERIO	INCAPACIDAD ABSOLUTA	INCAPACIDAD RELATIVA	INCAPACIDAD PARTICULAR
Quiénes	Dementes, impúberes y sordos o sordomudos que no pueden darse a entender claramente	Menores adultos y disipadores bajo interdicción	Las personas a quienes la ley prohíbe ciertos actos
Alcance	General: ningún acto por sí solo	General, pero sus actos pueden valer en ciertas circunstancias	Solo ciertos actos
Cómo actúan	Solo representados	Representados o autorizados	Según el caso: no pueden celebrar el acto, o solo con autorización de otro
Sanción	Nulidad absoluta (en estricto rigor, inexistencia)	Nulidad relativa	Nulidad absoluta, nulidad relativa u otra sanción, según el caso
Obligaciones naturales	No producen	Sí (art. 1470 N° 1); discutido para el disipador	No hay una regla común
Artículos	Art. 1447 incs. 1° y 2°	Art. 1447 inc. 3°	Art. 1447 inc. final

CONEXIONES

La capacidad en otras materias

En este manual: V. La representación (representantes legales), IV.A La inexistencia jurídica (actos de los absolutamente incapaces) y IV.B La nulidad (nulidad absoluta y relativa).

Responsabilidad Extracontractual: E. La capacidad delictual (sus reglas no coinciden con las del **art. 1447**).

Familia: patria potestad y peculio profesional o industrial (**arts. 251 y 254**), tutelas y curadurías e interdicción (**arts. 412, 445 y 465**), administración de la sociedad conyugal (**arts. 1749, 1754, 1756 y 1757**). Revisar apunte de Familia, [FALTA: sección] (p. ____).

Sucesorio: incapacidades para suceder (**arts. 963, 965 y 1061**). Revisar apunte de Sucesorio, [FALTA: sección] (p. ____).

Contratos: incapacidades especiales en la compraventa (**arts. 1796 a 1800**). Revisar apunte de Contratos, [FALTA: sección] (p. ____).

Obligaciones: obligaciones naturales (**art. 1470**). Revisar apunte de Obligaciones, [FALTA: sección] (p. ____).

C. EL OBJETO

1. CONCEPTO

El tercer requisito del **art. 1445** es que el acto recaiga sobre un objeto lícito (el artículo está transcrito en II.B). El Código no define el objeto, pero el **art. 1460** dice en qué consiste:

Art. 1460. "Toda declaración de voluntad debe tener por objeto una o más cosas que se trata de dar, hacer o no hacer. El mero uso de la cosa o su tenencia puede ser objeto de la declaración."

La doctrina no se pone de acuerdo sobre qué es el objeto. Hay tres respuestas:

(i) Los derechos y obligaciones que el acto genera

Es la respuesta de quienes conciben el acto jurídico como una manifestación de voluntad dirigida a crear, modificar o extinguir derechos subjetivos. Si eso es lo que el acto busca, su objeto son esos mismos derechos y obligaciones.

(ii) La prestación

Para otros, el objeto es la cosa que hay que dar o el hecho que hay que ejecutar o dejar de ejecutar. Esta postura no separa el objeto del contrato del objeto de la obligación: para ella son lo mismo.

(iii) La materia sobre la que recae la voluntad

La doctrina más moderna lo entiende como la materia, las utilidades o las relaciones que las partes someten a su voluntad.

En Chile se sigue en general la segunda. El **art. 1460** habla de cosas que se trata de dar, hacer o no hacer, y eso es la **prestación**: la cosa que debe darse o entregarse, o el hecho que debe ejecutarse o no ejecutarse.

Con todo, en rigor son cuatro objetos distintos, que el Código no separa. El del **acto jurídico** son los efectos jurídicos que produce; el del **contrato**, los derechos y obligaciones que nacen de él; el de la **obligación**, la prestación o conducta que el deudor debe cumplir a favor del acreedor; y el de la **prestación**, la cosa que hay que dar o el hecho o abstención a que el deudor se sujeta. *Don Tito le vende a la Chepa su casa en Quintay: el objeto del contrato son los derechos y obligaciones que nacen de la venta; el de la obligación de don Tito, entregar la casa; y el de su prestación, la casa misma.* Como al final todo acto se traduce en cosas que darse o hechos que ejecutarse, que el Código los confunda tiene poca importancia práctica.

Para fijar los requisitos del objeto, el Código distingue según la prestación recaiga sobre una cosa o sobre un hecho.

2. REQUISITOS QUE DEBE REUNIR EL OBJETO QUE RECAE SOBRE UNA COSA

Sea material o inmaterial, la cosa tiene que cumplir tres requisitos: ser real, comerciable y determinada (**art. 1461**).

2.1. Cosa real

Es real la cosa que existe o que se espera que exista: el **art. 1461** admite como objeto tanto las cosas que existen como las que se espera que existan.

Si la cosa no existe al celebrarse el acto, el acto se queda sin objeto. Por eso la venta de una cosa que al perfeccionarse el contrato se supone existente y no existe "no produce efecto alguno" (**art. 1814**). Según la doctrina que se siga, ese acto será inexistente o, a lo menos, nulo de nulidad absoluta (ver IV.A).

Si la cosa todavía no existe pero se espera que exista, el acto vale. En la compraventa, el **art. 1813** obliga a distinguir qué se vendió:

La cosa futura misma. La venta se entiende hecha bajo la **condición suspensiva** de que la cosa llegue a existir. *Don Kike, pisquero del Elqui, le vende a una destilería toda la uva de la próxima vendimia a tanto el kilo. Si una helada arrasa con la viña, la venta se mira como no hecha: falló la condición.* Las partes pueden pactar lo contrario, y la venta será entonces pura y simple.

La suerte. Cuando por la naturaleza del contrato aparece que lo que se compró fue la suerte, es decir, la posibilidad de que la cosa llegue a existir, la venta es pura y simple. Es además un contrato **aleatorio**: lo que una parte recibe depende de un hecho incierto, y no se puede valorar mientras ese hecho no ocurra.

EJEMPLO

Comprar la suerte: el lance de Caleta Portales

Marcelo le paga \$80.000 a un pescador de Caleta Portales por todo lo que salga en el lance de la madrugada, salga lo que salga. Compró la suerte (**art. 1813**): si salen tres cajas de reineta, hizo un negocio redondo; si sale una jaiba y una bota, igual debe pagar los \$80.000, porque la venta es pura y simple y no quedó sujeta a que hubiera pesca.

2.2. Cosa comerciable

No basta con que la cosa exista: también tiene que estar en el comercio (**art. 1461**). Es **comerciable** la cosa que puede ser objeto de propiedad o posesión privada.

Casi todas las cosas lo son. Quedan fuera dos grupos:

(i) Las que no se pueden apropiar por su naturaleza

Son las cosas comunes a todos los hombres, como la alta mar o el aire, que nadie puede hacer suyas (**art. 585**).

(ii) Las que no se pueden apropiar por su destino

Son los bienes nacionales de uso público: su dominio es de la nación y su uso de todos sus habitantes, como las calles, plazas, puentes y caminos, el mar adyacente y sus playas (**art. 589**). Quedan fuera del comercio mientras conserven ese destino.

2.3. Cosa determinada

La cosa tiene que estar determinada, por lo menos en cuanto a su género (**art. 1461** inc. 1º). Se puede determinar de dos maneras:

En especie, cuando se señala un individuo concreto de un género también determinado. **En género**, cuando se señala un individuo cualquiera, sin precisar cuál, de un género determinado. *La Panchita se obliga a entregar "el Rucio", su caballo chilote: la cosa está determinada en especie. Si se obliga a entregar "un caballo chilote", está determinada en género, y cumple entregando cualquiera, con tal que sea de calidad a lo menos mediana (**art. 1509**).*

El género tiene que ser limitado. Si alguien se obliga a dar "un animal", sin más, no se sabe si debe un hámster o un caballo, y no hay una declaración seria de voluntad.

Cuando la cosa se determina por su género, también hay que fijar la cantidad. Esta puede quedar incierta, siempre que el mismo acto fije reglas o contenga datos para determinarla (**art. 1461** inc. 2º). *Por ejemplo, se vende toda la avena que coseche este verano el potrero de atrás del fundo de Coke.* Los datos para calcularla tienen que estar en el propio acto, no fuera de él.

Si la cosa no está determinada en la forma que exige la ley, el acto **no tiene objeto**.

¿Y si en una obligación de género nada se dijo sobre la calidad? Responde el **art. 1509**: el acreedor no puede exigir un individuo determinado, y el deudor se libera entregando cualquiera del género, "con tal que sea de una calidad a lo menos mediana".

3. REQUISITOS DEL OBJETO QUE RECAE SOBRE UN HECHO

La prestación puede consistir en hacer algo o en abstenerse de hacerlo. En los dos casos el objeto es un hecho, positivo en el primero y negativo en el segundo, y debe cumplir tres requisitos: ser determinado, físicamente posible y moralmente posible (**art. 1461** inc. 3°).

3.1. Hecho determinado

El deudor tiene que saber qué debe hacer o de qué debe abstenerse, y el acreedor qué puede exigirle. Si no, no hay una declaración seria de voluntad. *Así, si Valentina le dice a Pancho que le paga si "hace algo que la sorprenda", sin precisar qué hecho, ninguno de los dos puede exigir judicialmente el cumplimiento de lo pactado: falta un hecho determinado.*

3.2. Hecho físicamente posible

Es físicamente imposible el hecho contrario a la naturaleza (**art. 1461** inc. 3°). Para que la imposibilidad cuente, tiene que ser **absoluta**: el hecho debe ser irrealizable para cualquier persona.

Si solo el deudor no puede hacerlo, la imposibilidad es **relativa** y la obligación vale. *Coke se compromete a cocinar las empanadas para el matrimonio de la Trinidad, aunque no sabe ni freír un huevo. La obligación es válida, porque otro sí podría hacerlas; si Coke no cumple, deberá indemnizar los perjuicios.* En cambio, si la imposibilidad es absoluta, no nace obligación alguna: a lo imposible nadie está obligado.

Lo que es imposible cambia con el tiempo, y también de un lugar a otro.

EJEMPLO

Ayer imposible, hoy posible: Rapa Nui en el día

En 1900, quien se obligaba a ir de Santiago a Rapa Nui y volver en el mismo día se obligaba a un hecho físicamente imposible: no había cómo hacerlo. Hoy basta tomar un avión. Si alguien asume hoy esa obligación y no la cumple, no puede excusarse diciendo que el hecho es imposible.

3.3. Hecho moralmente posible

Es moralmente imposible el hecho prohibido por las leyes, o contrario a las buenas costumbres o al orden público (**art. 1461** inc. 3°). Hay que leerlo junto al **art. 10**: los actos que la ley prohíbe son nulos y de ningún valor, salvo que la propia ley les asigne expresamente otro efecto.

Como depende de lo que prohíbe cada ordenamiento, lo moralmente imposible también varía de un país a otro. *Vender marihuana en un coffee shop de Ámsterdam es un negocio tolerado; en Chi-*

le, vender marihuana es un delito, y el contrato tendría objeto ilícito (**arts. 1461 y 1466**) y sería nulo de nulidad absoluta (**art. 1682**).

EJEMPLO

Hecho moralmente imposible: dar el examen por otro

Valeria le ofrece a Sebastián 40 lucas para que rinda el examen de grado en su lugar, haciéndose pasar por ella. El hecho prometido es moralmente imposible: constituye suplantación de identidad y atenta contra la fe pública, por lo que hay objeto ilícito. **Consecuencia:** el pacto no genera obligación para ninguna de las partes: ni Sebastián puede cobrar los \$40.000, ni Valeria exigir que dé el examen, porque el objeto ilícito afecta el hecho mismo que ambos prometieron, no una condición accesoria a otro acto válido.

4. EL OBJETO ILÍCITO

Hay que separar dos planos. Que el acto **tenga** objeto es un requisito de existencia: sin objeto, el acto no existe. Que ese objeto sea **lícito** es un requisito de validez (**art. 1445** N° 3). Por eso el acto con objeto ilícito sí existe, pero nace viciado, y puede ser anulado de nulidad absoluta (**art. 1682**, ver IV.B).

El Código no define el objeto ilícito. La explicación es histórica: la noción de objeto lícito solo aparece en el Proyecto Inédito.

La definición que le ha dado la doctrina es la de "aquel que versa sobre hechos prohibidos por las leyes o contrarios a las buenas costumbres o al orden público".

Se refiere a hechos, no a cosas. Quienes la siguen toman las mismas palabras con que el Código define la causa ilícita: "la prohibida por ley, o contraria a las buenas costumbres o al orden público" (**art. 1467** inc. 2°, ver II.D).

Los autores, de todos modos, no coinciden. Para **CLARO SOLAR**, objeto lícito es el que se ajusta a la ley y goza de su amparo. **SOMARRIVA** agrega las buenas costumbres y el orden público. Para **ALESSANDRI**, lícito es lo mismo que comerciable.

VELASCO LETELIER lo vincula con el **art. 1461**: objeto lícito es el que reúne todas las cualidades que ese artículo exige (realidad, comerciabilidad y determinación, y si es un hecho, posibilidad física y moral). Para él, el Código solo usa la expresión *objeto ilícito* en su sentido propio en los **arts. 1445, 1468 y 1682**. En otras normas, como los **arts. 1462, 1464 y 1466**, la emplea en un sentido impropio.

En vez de una definición, el Código enumera los casos en que hay objeto ilícito. Son los que siguen.

4.1. Actos que contravienen el derecho público chileno

Según el **art. 1462**, hay objeto ilícito en todo lo que contraviene el derecho público chileno. El derecho público es el conjunto de normas que, atendiendo a un interés preponderantemente colectivo, organizan al Estado y a los demás entes públicos (las municipalidades, por ejemplo), regulan su actividad y sus relaciones entre sí y con los particulares, cuando actúan revestidos de poder público. Ojo: la norma habla de *derecho público*, no de *orden público*, que es otra cosa.

Aplicando esta regla, se ha fallado que tiene objeto ilícito, y es nulo absolutamente, el contrato que se apoya en un acto administrativo afectado por nulidad de derecho público.

El ejemplo del propio artículo es la promesa de someterse en Chile a una jurisdicción no reconocida por las leyes chilenas. Por eso algunos autores dudaron de las cláusulas que entregan a tribunales extranjeros las disputas de un contrato. Hoy se pactan con frecuencia, por tres razones: el Código de Procedimiento Civil reconoce las jurisdicciones extranjeras (regula incluso cómo se cumplen en Chile sus sentencias); el Código de Derecho Internacional Privado valida estas cláusulas (art. 318); y el arbitraje internacional se ha expandido, regulado en Chile por la Ley N° 19.971, de 2004.

Distinto es si quien contraviene el derecho público no es un particular sino un órgano del Estado. Entonces no rige el **art. 1462**: la sanción es la **nulidad de derecho público del art. 7 de la Constitución**, que estudia el Derecho Administrativo.

4.2. Pactos sobre sucesiones futuras

Art. 1463. "El derecho de suceder por causa de muerte a una persona viva no puede ser objeto de una donación o contrato, aun cuando intervenga el consentimiento de la misma persona.

Las convenciones entre la persona que debe una legítima y el legitimario, relativas a la misma legítima o a mejoras, están sujetas a las reglas especiales contenidas en el título De las asignaciones forzosas."

a) Qué es un pacto sobre sucesión futura

Es la convención que recae sobre el derecho a heredar a una persona viva, sea como heredero o como legatario. Esa persona puede ser una de las partes o un tercero. Ningún acto jurídico puede tener ese derecho por objeto.

Si la persona ya murió, el problema desaparece: los actos sobre su herencia son válidos, y el Código regula expresamente la cesión de derechos hereditarios (**arts. 1909 y siguientes**). *La Trinidad le vende a su primo, en \$5 millones, lo que le toque en la herencia de su papá, que está vivo y sano: hay objeto ilícito y la venta es nula de nulidad absoluta. Si el papá hubiera muerto, sería una cesión de derechos hereditarios perfectamente válida.*

b) Comprende actos unilaterales y bilaterales

El artículo solo nombra la donación y el contrato, pero la prohibición alcanza también a los actos unilaterales. Una asignación solo se puede aceptar o repudiar una vez muerta la persona (**arts. 956 y 1226**). Si alguien acepta en vida del testador lo que este le dejó en su testamento, esa aceptación es nula por objeto ilícito.

c) "Donación o contrato"

La fórmula es redundante, porque la donación es un contrato: necesita que el donatario la acepte (**art. 1386**). Lo que el Código quiso decir es que el derecho a suceder a una persona viva no puede ser objeto de ninguna convención, ni gratuita ni onerosa.

d) La excepción: el pacto de no mejorar

El inciso 2° del **art. 1463** anuncia una excepción, que está en el **art. 1204**. Una persona puede prometer, por **escritura pública** entre vivos, a su cónyuge o a alguno de sus descendientes o ascendientes que a esa fecha sea legitimario, que no donará ni asignará por testamento parte alguna de la cuarta de mejoras. Si después no cumple, los asignatarios de esa cuarta deben enterarle al favorecido lo que le habría valido el cumplimiento de la promesa, a prorrata de lo que la infracción les aprovechó.

Fuera de este pacto, el mismo **art. 1204** declara nulas "cualesquiera otras estipulaciones sobre la sucesión futura, entre un legitimario y el que le debe la legítima". Algunos autores, sin embargo, aceptan otros pactos sobre legítimas y mejoras, como las donaciones irrevocables hechas en razón de ellas, que se acumulan al primer acervo imaginario (**art. 1185**).

4.3. Enajenación de las cosas enumeradas en el art. 1464

Art. 1464. "Hay un objeto ilícito en la enajenación:

- 1°. De las cosas que no están en el comercio;
- 2°. De los derechos o privilegios que no pueden transferirse a otra persona;
- 3°. De las cosas embargadas por decreto judicial, a menos que el juez lo autorice o el acreedor consienta en ello;
- 4°. De especies cuya propiedad se litiga, sin permiso del juez que conoce en el litigio."

Antes de ver cada número hay que aclarar tres cosas: qué es enajenar, si la adjudicación lo es, y si se pueden vender estas cosas.

Qué es enajenar. Se enajena haciendo la tradición, que sirve para transferir el dominio o para constituir otro derecho real. De ahí los dos sentidos de la palabra. En sentido estricto, enajenar es solo transferir el dominio.

En sentido amplio, la definición que le ha dado la doctrina es la de "la transferencia del dominio o la constitución de cualquier otro derecho real".

Quienes leen el **art. 1464** en sentido estricto se apoyan en que el Código suele separar ambas cosas ("enajenar o gravar"). Pero la mayoría, y también la jurisprudencia, lo leen en **sentido amplio**: enajena tanto quien hace la tradición del dominio como quien constituye una hipoteca, un usufructo o una servidumbre.

La adjudicación no es enajenación. Cuando una cosa pertenece a varios comuneros, la adjudicación es el acto por el que el derecho de uno de ellos, que estaba repartido en toda la cosa común, se radica en exclusiva sobre un bien. La jurisprudencia la considera **declarativa** y no traslativa de dominio: el adjudicatario se mira como dueño exclusivo desde siempre (**arts. 718, 1344 y 2417**). Por eso no le alcanza el **art. 1464**, y es válida la adjudicación de una cosa embargada o litigiosa.

¿Se pueden vender estas cosas? En Chile, para adquirir un derecho real se necesitan un título (por ejemplo, una compraventa) y un modo (por ejemplo, la tradición). La compraventa sola no transfiere nada; solo obliga a hacer la tradición. Mirado solo el **art. 1464**, entonces, vender estas cosas no sería enajenarlas. El problema lo plantea el **art. 1810**: "pueden venderse todas las cosas corporales o incorporeales, cuya enajenación no esté prohibida por ley". Hay tres respuestas.

(i) Hay objeto ilícito en la venta de las cuatro clases de cosas

Es la opinión mayoritaria: la de **ALESSANDRI** y **SOMARRIVA**, recogida por la mayor parte de las sentencias. **VIAL** la explica así: el **art. 1464** por sí solo castiga la tradición, no el contrato. Pero el **art. 1810** solo permite vender lo que se puede enajenar, de modo que la venta de estas cosas es un contrato prohibido por la ley, y el **art. 1466** declara que hay objeto ilícito en todo contrato prohibido. La sanción es la nulidad absoluta (**art. 1682**).

(ii) Solo hay objeto ilícito en la venta de las cosas de los N°s 1 y 2

Es la tesis de **VELASCO LETELIER**. Una enajenación está prohibida cuando no se puede hacer de ningún modo, bajo ninguna circunstancia. Eso ocurre con las cosas inenajenables y con los derechos personalísimos (N°s 1 y 2). Las cosas embargadas y las litigiosas (N°s 3 y 4), en cambio, sí se pueden enajenar si el juez lo autoriza o el acreedor consiente. Esas normas no prohíben: imponen requisitos. El **art. 1810**, entonces, solo se remite a los N°s 1 y 2, y la venta de una cosa embargada o litigiosa es válida.

Sus partidarios agregan dos argumentos. Primero, que no hay razón para prohibir esa venta, porque el impedimento puede desaparecer: las partes pueden querer cerrar el negocio desde ya, sabiendo que la tradición tendrá que esperar a que se alce la prohibición. Segundo, que el comprador no queda desprotegido: si el vendedor le ocultó el embargo o el litigio, puede pedir la nulidad por dolo negativo (ver II.A.6).

La diferencia práctica es importante. Con la tesis mayoritaria, la venta es nula, y alzado el embargo queda en duda la validez de la tradición. Con la de Velasco, la venta vale: alzada la prohibición, la tradición se hace sobre un título válido y el comprador adquiere el dominio. Eso sí, si la tradición se hace antes de que se alce, es esa tradición la que tiene objeto ilícito.

(iii) El art. 1810 no se refiere al art. 1464

Para ITURRA, cuando el **art. 1810** habla de enajenación prohibida por ley, piensa en leyes especiales, no en una norma general como el **art. 1464**. Si hubiera querido incluirlo, lo habría dicho de otro modo.

JURISPRUDENCIA
CORTE SUPREMA, ROL N° 3671-1998

La Corte Suprema acogió la tesis de Velasco respecto de las cosas embargadas: "*el artículo 1810 se refiere 'a las cosas corporales o incorporales cuya enajenación esté prohibida por ley'. Se debe tratar, entonces, de una enajenación prohibida, vale decir que no puede realizarse en caso alguno*". Como las cosas embargadas pueden enajenarse con autorización del juez o consentimiento del acreedor, el N° 3 del art. 1464 "no es una norma prohibitiva", y "el artículo 1810 resulta inaplicable a los contratos de compraventa de cosas embargadas por decreto judicial". Lo refuerza así: "la venta de las cosas cuya enajenación está prohibida jamás podrá producir algún efecto; en cambio, la venta de cosas embargadas puede llegar a tener plenos efectos si la enajenación es autorizada por el juez o consentida por el acreedor". Aplicó el mismo criterio a una compraventa impugnada por los N°s 3 y 4, porque ese contrato, "por sí mismo, tampoco constituye un acto de enajenación".

CRITERIO	TESIS MAYORITARIA	TESIS DE VELASCO	TESIS DE ITURRA
Quiénes	Alessandri, Somarriva, Vial; la mayor parte de la jurisprudencia	Velasco Letelier; Corte Suprema, rol N° 3671-1998	Iturra
Fundamento	El art. 1810 remite a todo el art. 1464 ; venta prohibida, objeto ilícito por el art. 1466	Solo es prohibida la enajenación que no puede hacerse de ningún modo	El art. 1810 mira a leyes especiales, no al art. 1464
Venta de cosas de los N°s 1 y 2	Objeto ilícito, nulidad absoluta	Objeto ilícito, nulidad absoluta	No le alcanza el art. 1810
Venta de cosas de los N°s 3 y 4	Objeto ilícito, nulidad absoluta	Válida	No le alcanza el art. 1810
Si se alza el embargo	La venta sigue siendo nula; se duda de la tradición	Se hace la tradición sobre un título válido	Se hace la tradición sobre un título válido

PREGUNTA CLÁSICA

¿Hay objeto ilícito en la compraventa de las cosas del art. 1464?

Partir por lo seguro: el **art. 1464** castiga la enajenación, es decir, la tradición, y la compraventa no es enajenación. La pregunta se resuelve por el **art. 1810**. Para la tesis mayoritaria (ALESSANDRI, SOMARRIVA, VIAL), el **art. 1810** convierte en prohibida la venta de las cuatro clases de cosas, y hay objeto ilícito por el **art. 1466**. Para VELASCO LETELIER, solo en las de los N°s 1 y 2, porque las embargadas y litigiosas pueden enajenarse con autorización; así lo resolvió la Corte Suprema (rol N° 3671-1998). Cerrar con la consecuencia práctica: con Velasco, alzado el embargo, la tradición se hace sobre una venta válida.

(i) Cosas que no están en el comercio (N° 1)

Son las que no admiten propiedad ni posesión privada: unas por su naturaleza, como el aire y la alta mar; otras por su destino, como las calles, las plazas, los puentes, el mar adyacente y sus playas (ver 2.2).

Aquí hay una contradicción. Según el **art. 1461**, la comerciabilidad es un requisito del objeto; si falta, el acto no tiene objeto y es inexistente. Pero el N° 1 del **art. 1464** supone que el objeto existe y que es ilícito, lo que lleva a la nulidad absoluta (**art. 1682**).

Para CLARO SOLAR, el N° 1 muestra una confusión del legislador entre requisitos de existencia y de validez. VIAL adhiere: si la cosa está fuera del comercio, falta una cualidad esencial del obje-

to, y el acto, sea cual sea, no produce efecto alguno. Tratarlo como nulidad lleva a resultados absurdos: quien "vende" el cerro Santa Lucía quedaría obligado a hacer la tradición, el comprador a pagar el precio, cualquiera podría pedir la resolución por incumplimiento, y si nadie alega la nulidad en diez años el contrato se sanearía (**art. 1683**).

Vial reconoce que el texto del Código es claro, pero hace notar que solo la venta y la enajenación de cosas inenajenables tienen objeto ilícito por ley. Los demás actos sobre ellas, como el arriendo o el comodato, serían inexistentes (**arts. 1444 y 1461**), y lo atribuye a un error del Código. Otros autores explican la diferencia de otro modo: el **art. 1461** hablaría de las cosas inenajenables por naturaleza, y el N° 1 del **art. 1464** de las que el legislador saca del comercio por un tiempo (los peces en veda, por ejemplo). Contra ambas posturas pesa el texto expreso: el Código no distingue, y el **art. 1682** sanciona el objeto ilícito con nulidad absoluta.

(ii) Derechos y privilegios que no pueden transferirse a otra persona (N° 2)

Son los derechos **personalísimos**, como los de uso y habitación (**art. 819**) o el de pedir alimentos (**art. 334**).

Hay quienes dicen que el N° 2 sobra, porque estos derechos estarían fuera del comercio y ya los cubre el N° 1. No es así: estos derechos sí pueden ser objeto de dominio o posesión de particulares, luego están en el comercio. Lo que tienen de especial es que son **inalienables**: su titular no puede traspasarlos. El Código sigue en esto la distinción romana: toda cosa inenajenable es inalienable, pero no toda cosa inalienable es inenajenable.

(iii) Cosas embargadas por decreto judicial (N° 3)

a) Qué es el embargo

La ley no lo define. Es una institución del juicio ejecutivo, y la Corte Suprema lo ha caracterizado así:

"La aprehensión compulsiva que el juez de la causa hace de determinado bien del deudor, y desde el momento en que se verifica, tales bienes quedan sujetos a la autoridad del referido juez".

Pero en el N° 3 la palabra se entiende en un **sentido amplio**. Doctrina y jurisprudencia incluyen todas las medidas que buscan asegurar el resultado de un juicio y que congelan la facultad del dueño de disponer de la cosa: las precautorias de prohibición de gravar y enajenar, el secuestro, la retención y, para la mayoría, la prohibición judicial de celebrar actos y contratos sobre bienes determinados (**art. 296 C.P.C.**).

Esta última plantea un problema. El **art. 1464** habla de enajenación, y vender o arrendar no es enajenar. Si se viola una prohibición judicial de vender o de arrendar, por la letra de la ley no habría objeto ilícito ni sanción. **VELASCO LETELIER** rechaza ese resultado, que dejaría impune la infracción, y concluye que el **art. 296 C.P.C.** amplió los N°s 3 y 4 del **art. 1464**: infringir una

prohibición judicial de celebrar actos y contratos produce objeto ilícito, aunque no sea una prohibición de enajenar.

b) Desde cuándo una cosa está embargada

Hay que distinguir entre las partes del juicio y los terceros.

Entre las partes, el embargo y la prohibición existen desde que se notifica al deudor la resolución que los ordena. Desde ese momento no puede alegar que no los conocía.

Respecto de terceros, hay que subdistinguir. Si la medida recae sobre **muebles**, los afecta solo desde que la conocen. Si recae sobre **inmuebles** o derechos reales sobre ellos, solo desde que se inscribe en el registro del conservador donde están situados (**arts. 297 y 453 C.P.C.**).

Ojo con un matiz que destaca **VIAL**: la enajenación de un inmueble embargado tiene objeto ilícito **aunque el embargo no esté inscrito**, porque el Código Civil no exige la inscripción para que la cosa se considere embargada. La inscripción solo decide si la sentencia que declara la nulidad alcanza a terceros.

EJEMPLO

El embargo que no se alcanzó a inscribir

En el juicio ejecutivo que le sigue un banco, a don Tito le embargan su parcela en Olmué. Antes de que el embargo se inscriba, don Tito se la vende a la Chepa y la inscribe a su nombre. La tradición tiene objeto ilícito igual (**art. 1464 N° 3**), y el banco puede pedir su nulidad absoluta. Pero como a la fecha de la tradición el embargo no estaba inscrito, la sentencia de nulidad no afecta a la Chepa (**art. 453 C.P.C.**).

c) Cuándo debe existir el embargo

Al momento de la enajenación. Si el embargo es posterior, la enajenación no tiene objeto ilícito.

d) La enajenación forzada de una cosa embargada

Supongamos que dos acreedores embargan el mismo bien en dos juicios distintos, y el segundo juicio avanza más rápido y se remata el bien. ¿Tiene objeto ilícito ese remate, dado que el bien estaba embargado en el primer juicio?

Para **CLARO SOLAR** y **LEÓN HURTADO**, la enajenación forzada es válida. El N° 3 castiga la conducta del deudor que, pese a la prohibición, traspasa voluntariamente la cosa; en el remate, en cambio, enajena el juez, incluso contra la voluntad del deudor. Así se desprende también del **art. 528 C.P.C.**, que admite que haya dos o más ejecuciones sobre los mismos bienes. El acreedor que embargó primero no queda desprotegido: puede hacer valer sus derechos conforme al mismo **art. 528 C.P.C.** y, en general, mediante las tercerías.

Otros sostienen lo contrario: como la ley no distingue entre enajenación voluntaria y forzada, ambas tendrían objeto ilícito, y eso protege mejor a los acreedores. La jurisprudencia ha fallado en los dos sentidos. **VIAL** adhiere a la primera postura.

e) Las prohibiciones voluntarias de enajenar

Son las que pactan las partes en un contrato, o las que una persona asume frente a otra, normalmente por un tiempo (sujetas a un plazo o a una condición). Infringirlas no produce objeto ilícito: el N° 3 exige que la medida venga de un decreto judicial. Lo que hay es un incumplimiento contractual, que se sanciona con las reglas de la responsabilidad contractual.

f) Las prohibiciones legales de enajenar

Algunas leyes prohíben enajenar ciertos bienes. Por ejemplo, las leyes orgánicas de algunas instituciones, como el SERVIU, prohíben enajenar los inmuebles con operaciones pendientes con ellas mientras no se liquiden. La prohibición es de la ley, y el contrato solo la reproduce para facilitar su inscripción. Violarla sí produce nulidad por objeto ilícito.

g) Cómo se enajena válidamente una cosa embargada

La misma ley da dos caminos: la **autorización del juez** o el **consentimiento del acreedor**.

La autorización debe darla el mismo juez que decretó el embargo, porque es quien conoce los antecedentes del juicio y puede medir si la enajenación deja al acreedor sin garantía. La da con conocimiento de causa. Si varios jueces embargaron la cosa, todos deben autorizar; si falta uno, subsiste el objeto ilícito.

El consentimiento del acreedor se explica porque el embargo está establecido en su exclusivo beneficio, y el **art. 12** permite renunciar a los derechos que solo miran al interés de quien renuncia. Al consentir, el acreedor renuncia tácitamente a sus derechos de embargante. Si los acreedores embargantes son varios, todos deben consentir. Como la ley no exige formalidades, el consentimiento puede ser expreso o tácito: hay consentimiento tácito, por ejemplo, si el comprador es el propio acreedor embargante, o si el acreedor sabe que el bien se rematará en otro juicio y no se opone. Una vez dado, según **LEÓN HURTADO**, no puede retractarse en perjuicio de los terceros que adquirieron confiando en él.

La autorización y el consentimiento tienen que ser **anteriores** a la enajenación. Darlos después sería sanear una nulidad absoluta por ratificación, y eso no cabe (**art. 1683**, ver IV.B).

(iv) **Especies cuya propiedad se litiga (N° 4)**

Son los cuerpos ciertos, muebles o inmuebles, cuyo dominio se discute en un juicio. Es el caso típico del que demanda la restitución de una cosa que dice ser suya y el demandado se defiende alegando que el dueño es él.

NO CONFUNDIR**Especie litigiosa y derecho litigioso**

Enajenar una **especie cuya propiedad se litiga** es traspasar la cosa misma que se disputa en el juicio, y sin permiso del juez tiene objeto ilícito (**art. 1464** N° 4). Ceder un **derecho litigioso** es otra cosa: lo que se traspasa es el evento incierto de la litis, la chance de ganar o perder el juicio, y el cedente no responde del resultado (**art. 1911**). La cesión de un derecho litigioso es válida y el Código la regula en los **arts. 1911 y siguientes**.

No basta con que exista el juicio. El **art. 296 C.P.C.** agrega un requisito: "para que los objetos que son materia del juicio se consideren comprendidos en el número 4° del artículo 1464 del Código Civil, será necesario que el tribunal decrete prohibición respecto de ellos". Según **VIAL**, esta norma modifica el N° 4.

El **art. 297 C.P.C.**, en cambio, no lo modifica. Dispone que la prohibición sobre inmuebles debe inscribirse en el conservador, y sin eso no afecta a terceros; y que la prohibición sobre muebles solo afecta a los terceros que la conocían al contratar, aunque el demandado responde de fraude si actuó a sabiendas. La inscripción no es un requisito para que la cosa sea litigiosa: igual que en el embargo, solo sirve para oponer la nulidad a terceros. Si la prohibición sobre un inmueble no se inscribe, su enajenación sigue siendo el acto que la ley prohíbe.

Como el N° 4 exige la prohibición judicial, y la jurisprudencia ya incluye esas prohibiciones dentro de las "cosas embargadas" del N° 3, para algunos el N° 4 está de más: las especies litigiosas quedarían comprendidas en el N° 3.

La especie litigiosa se puede enajenar válidamente con **permiso del juez** que conoce del litigio, y rige lo dicho para el embargo. El Código no dice nada del **consentimiento de la parte** a cuyo favor se decretó la prohibición. Algunos concluyen que, al no estar previsto, no sirve. La doctrina mayoritaria, apoyada en los **arts. 296 y 297 C.P.C.**, lo admite, y **VIAL** da dos razones: esa parte es la única beneficiada por la prohibición, de modo que al consentir renuncia a ella; y si el acreedor puede consentir en el embargo, no hay motivo para negárselo a quien obtuvo la prohibición.

4.4. Condonación del dolo futuro

Art. 1465. "El pacto de no pedir más en razón de una cuenta aprobada, no vale en cuanto al dolo contenido en ella, si no se ha condonado expresamente. **La condonación del dolo futuro no vale.**"

El artículo trae dos reglas, ambas sobre el perdón del dolo. Las dos son casos de objeto ilícito, y se sancionan con nulidad absoluta (**art. 1682**).

Primera regla: el dolo de una cuenta ya aprobada. Quien recibe una rendición de cuentas y otorga el finiquito puede perdonar el dolo de quien la rindió, pero solo si lo hace en forma expresa y sabiendo perfectamente qué dolo está perdonando. Un finiquito genérico no cubre el dolo, ni tampoco la culpa grave, que en materias civiles equivale al dolo (**art. 44**). La regla no se limita a las rendiciones de cuentas: alcanza a cualquier finiquito contractual. Y quien aprobó la cuenta o firmó el finiquito sin perdonar expresamente el dolo puede igual demandar lo que se le deba o los perjuicios: la contraparte no puede defenderse con la cuenta aprobada o el finiquito, porque en esa parte son nulos.

Segunda regla: el dolo futuro. Es de alcance general: no vale perdonar por anticipado el dolo que una parte pueda cometer, porque sería aceptar de antemano un actuar ilícito. De aquí se sigue que en Chile no valen las **cláusulas de irresponsabilidad** en cuanto liberen a una parte de sus incumplimientos dolosos, ni de los cometidos con culpa grave (**art. 44**).

Como toda nulidad absoluta, la de estos pactos puede alegarla cualquiera que tenga interés, salvo quien celebró el acto sabiendo o debiendo saber el vicio, y no se sana por ratificación ni por un plazo menor de diez años (**art. 1683**, ver IV.B).

4.5. Deudas contraídas en juego de azar

La primera parte del **art. 1466** declara que hay objeto ilícito en las deudas contraídas en juegos de azar. El Código regula el juego y la apuesta en los **arts. 2259 a 2263**, y de ellos resulta que hay juegos lícitos e ilícitos. El **art. 2259** se remite al **art. 1466** para los de azar y aclara que las normas siguientes se aplican a los lícitos.

Juegos lícitos. Son de dos clases. En los de fuerza o destreza corporal, como las carreras de caballos, el que gana tiene acción para cobrar, siempre que no se infrinjan las leyes o los reglamentos de policía (**art. 2263**). En los de destreza intelectual, como el ajedrez, el que gana no puede exigir el pago; pero si el que perdió paga, no puede pedir que se le devuelva, salvo que se haya ganado con dolo (**art. 2260**).

Juegos ilícitos. Son los de azar, cuyo resultado depende única o principalmente de la suerte. Los actos sobre ellos son nulos por objeto ilícito. Hay excepciones que la ley autoriza, como la Polla Chilena de Beneficencia, la Lotería de Concepción y los casinos de juego (Ley N° 19.995).

4.6. Venta de libros prohibidos, objetos inmorales e impresos abusivos de la libertad de prensa

Según la segunda parte del **art. 1466**, hay objeto ilícito en la venta de libros cuya circulación prohíbe la autoridad competente, de láminas, pinturas y estatuas obscenas, y de impresos condenados como abusivos de la libertad de prensa.

Los impresos abusivos se conectan con dos garantías de la Constitución: el respeto y la protección de la vida privada y la honra de la persona y su familia (**art. 19 N° 4 CPR**) y la libertad de opinar e

informar sin censura previa, respondiendo de los delitos y abusos que se cometan (**art. 19 N° 12 CPR**). Las desarrolla la Ley N° 19.733, sobre libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo (Ley de Prensa).

Además de la nulidad de la venta, quien abusa de la libertad de opinión puede enfrentar tres responsabilidades, que se pueden sumar:

Penal, si la opinión constituye un delito, como la injuria o la calumnia. En los medios de comunicación se considera también autor al director, salvo que pruebe que no hubo negligencia de su parte.

Civil, por los daños causados al ofendido. Se rige por las reglas generales, y en la injuria y la calumnia comprende el daño emergente, el lucro cesante y el daño moral.

Comunicacional, por llamarla de algún modo: el medio debe difundir gratis la aclaración o rectificación de quien fue ofendido o aludido injustamente.

4.7. Actos prohibidos por la ley

El **art. 1466** termina con una regla general: hay objeto ilícito "generalmente en todo contrato prohibido por las leyes". Calza con el **art. 1461**, que llama moralmente imposible al objeto prohibido por las leyes.

Leída junto al **art. 10**, la regla es que todo acto prohibido por la ley es nulo, salvo que la propia ley establezca otra sanción. Un ejemplo de esa otra sanción es el usufructo: el **art. 769** prohíbe constituir usufructos sucesivos o alternativos, pero no los anula; si de hecho se constituyen, los usufructuarios posteriores se consideran sustitutos, para el caso de que falten los anteriores.

CONEXIONES**El objeto en otras materias**

En este manual: II.A.6 El dolo (dolo negativo; condonación del dolo), II.B La capacidad (**art. 1445**), II.D La causa (causa ilícita, **arts. 1467 y 1468**), IV.A La inexistencia jurídica (falta de objeto) y IV.B La nulidad (**arts. 1682 y 1683**).

Responsabilidad Contractual: H. Cláusulas que modifican la responsabilidad (el límite del **art. 1465** y la culpa grave).

Bienes: II.9 Bienes comerciables e in comerciables (**arts. 585 y 589**).

Contratos: compraventa (**arts. 1810, 1813 y 1814**), cesión de derechos litigiosos (**art. 1911**), juego y apuesta (**arts. 2259 a 2263**). Revisar apunte de Contratos, [FALTA: sección] (p. ____).

Sucesorio: pacto de no mejorar (**art. 1204**), acervo imaginario (**art. 1185**), aceptación y repudio de asignaciones (**arts. 956 y 1226**), cesión de derechos hereditarios (**art. 1909**). Revisar apunte de Sucesorio, [FALTA: sección] (p. ____).

Obligaciones: obligaciones de género (**art. 1509**). Revisar apunte de Obligaciones, [FALTA: sección] (p. ____).

Procesal: embargo, medidas precautorias y tercerías (**arts. 296, 297, 453 y 528 C.P.C.**). Revisar apunte de Procesal, [FALTA: sección] (p. ____).

D. LA CAUSA

1. GENERALIDADES

Nadie actúa conscientemente sin perseguir algo: detrás de cada acto hay un fin que la persona se representó antes de obrar. El problema que abre la causa es si ese fin debe importarle al derecho, al punto de que el acto jurídico no exista o no valga sin él. Los **causalistas** responden que sí: además de la voluntad y el objeto, el acto necesita una causa para existir, y esa causa tiene que ser lícita para que el acto sea válido. Los **anticausalistas** responden que no: con una voluntad manifestada que recae sobre un objeto, el acto ya está completo, y exigirle además una causa es agregar un requisito artificial, del que se puede prescindir.

La discusión se enreda porque la palabra *causa* se usa, al menos, en tres sentidos distintos:

(i) Causa eficiente

Es el antecedente que hace nacer algo que antes no existía. En este sentido, la causa eficiente de una obligación es su fuente, el hecho jurídico del que proviene: la obligación del vendedor de entregar la cosa tiene su causa eficiente en el contrato de compraventa.

(ii) Causa final

Es el fin directo e inmediato que la parte persigue con el acto, el mismo en todos los actos de una misma especie, sin importar qué movió a cada contratante en particular. **CLARO SOLAR** la describe como el fin o propósito inmediato e invariable de un acto, y **VELASCO** agrega que siempre es posible encontrarla en la estructura misma del contrato. Así, en cualquier compraventa, el comprador busca hacerse de la cosa y el vendedor, del dinero.

(iii) Causa ocasional

Son los motivos personales que llevaron a cada uno a celebrar el acto. Para **VELASCO** es "el fin lejano y variable de un acto", de carácter "estrictamente personal y psicológico", y de ahí que "una misma especie de acto pueda tener infinitas causas, según sean los fines que hayan perseguido las partes".

EJEMPLO

Las tres causas de la citroneta de don Rigo

La Vero le compra a don Rigo su citroneta del 78. La **causa eficiente** de la obligación de don Rigo de entregársela es el contrato de compraventa que acaban de celebrar. La **causa final** es la de cualquier compraventa: la Vero quiere quedarse con la citroneta y don Rigo quiere el precio. La **causa ocasional** es solo de ellos: la Vero sueña con llegar en la citroneta a su matrimonio en Pichilemu, y don Rigo necesita la plata para operar a su perro.

2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA NOCIÓN DE CAUSA

Los romanos no construyeron una teoría general de la causa, pero sí la tuvieron en cuenta en casos concretos. El más conocido: todo enriquecimiento debía tener una justa causa, y quien se empobrecía sin ella podía pedir la devolución de lo dado mediante la *condictio sine causa*.

La teoría nace con los **canonistas medievales**. Para ellos, el acuerdo de las partes no bastaba para que una convención obligara: además, tenía que responder a un motivo lícito y moral. Por eso permitían al juez investigar qué había movido realmente a las partes, aunque el contrato se viera, por fuera, libre de todo vicio. Era la forma de impedir que la voluntad se pusiera al servicio de un fin reprobable.

El paso a una construcción técnica lo da el jurista francés **DOMAT** (1625-1697), autor de la llamada teoría clásica. Su atención está puesta solo en la causa de la *obligación* que nace del contrato, y deja de lado la causa del contrato mismo y los móviles de quienes lo celebran. **POTHIER** (1699-1772) la completa en su *Tratado de las Obligaciones* (1761), y por esa vía la teoría llega al Código Civil francés, del que Pothier es considerado el padre espiritual. El Código francés exigió la causa

sin definirla; los códigos que lo siguieron la recibieron con mayor o menor variación, y el chileno, a diferencia de su modelo, sí la definió.

3. DOCTRINAS ELABORADAS EN RELACIÓN CON LA CAUSA

Hoy el debate enfrenta a dos bandos. Del lado **causalista** están, entre otros, **CAPITANT, JOSSE-RAND** y **RIPERT** en Francia, y **FERRARA, SANTORO PASSARELLI** y **BETTI** en Italia. No todos entienden la causa de la misma manera: unos la miran con un criterio **objetivo**, igual para todos los actos de una especie (la doctrina clásica y los italianos modernos), y otros con un criterio **subjetivo**, atento a lo que movió a cada contratante (la doctrina del móvil o motivo determinante).

Del lado **anticausalista** están **PLANIOL, GIORGI, LAURENT** y **DABIN**, para quienes la causa es una noción falsa e inútil. Cada uno la disuelve en otro elemento: para **PLANIOL**, la causa no es más que el objeto; para **DABIN**, queda absorbida por el consentimiento.

Con todo, la mayoría de los códigos siguen exigiendo una causa, como el italiano y el español (y el francés, hasta 2016). La razón de fondo es el principio de causalidad, que no es exclusivo del derecho: todo lo que ocurre obedece a algún antecedente, y un acto jurídico no es la excepción. Si la voluntad se pone en movimiento, algo la empuja, y ese algo es la causa.

La tendencia, sin embargo, empieza a cambiar. Algunos ordenamientos ya abandonaron la exigencia de causa, como el Código Civil de Quebec y los códigos escandinavos. El caso más reciente es Francia: la reforma del derecho de los contratos aprobada el 10 de enero de 2016 suprimió las normas que pedían expresamente una causa. Aun así, **MAZEAUD** advierte que no es exacto decir que la causa desapareció del todo: dejó de ser un requisito general, pero sobrevive en ciertos casos.

3.1. Doctrina tradicional o clásica

Es la de **DOMAT**, completada por **POTHIER**. No le interesa la causa del contrato, sino la de cada obligación que nace de él, y la busca con una sola pregunta: *¿por qué se obligó esta parte?* La respuesta a esa pregunta es la causa. Como la respuesta no depende de lo que cada contratante tuviera en la cabeza, sino del tipo de contrato, el criterio es **objetivo**: la teoría agrupa los contratos en tres categorías, y dentro de cada una la causa de la obligación es siempre la misma.

a) Contratos bilaterales

Son aquellos en que ambas partes se obligan recíprocamente, como la compraventa, el mandato, el arrendamiento o la permuta. Aquí la obligación de cada parte tiene por causa la obligación de la otra: el vendedor se obliga a entregar la cosa porque el comprador se obligó a pagar el precio, y el comprador se obliga a pagar porque el vendedor se obligó a entregar. De ahí salen dos consecuencias. Si una de esas obligaciones no llega a nacer, la otra queda sin causa y no puede exigirse. Y como los motivos personales no cuentan, en todas las compraventas, y en general en todos los contratos bilaterales, la causa es la misma: la obligación recíproca de la contraparte.

b) Contratos reales

Son los que se perfeccionan con la entrega de la cosa, como el mutuo, el comodato, el depósito y la prenda, y en ellos queda obligada a restituir la parte que la recibió. La causa de esa obligación de restituir es la entrega previa: el comodatario debe devolver la cosa porque se la entregaron en comodato. Si la entrega no se hizo, la obligación de restituir no tiene causa y es ineficaz.

c) Contratos gratuitos

Son los que se celebran en utilidad de una sola de las partes, mientras la otra soporta el gravamen, como la donación. **DOMAT** ubicaba la causa de la obligación del que da en un motivo racional y justo, como un servicio que le prestó el donatario o el simple placer de hacer el bien. **POTHIER** corrigió la idea: la causa es la *intención liberal*, el propósito de hacer una liberalidad. El cambio importa, porque al separar esa intención de los móviles concretos de cada donante (gratitud, cariño, vanidad), Pothier consigue una regla objetiva, común a todos los contratos gratuitos: el donante se obliga porque quiere beneficiar al donatario, y no hace falta preguntar más.

3.2. Doctrina italiana

Los autores italianos contemporáneos comparten con la doctrina clásica dos puntos: que la causa es necesaria y que se aprecia con un criterio **objetivo**. Pero cambian el lugar donde la buscan: la causa es un requisito del **acto o contrato**, no de la obligación que este genera, y consiste en la función que cumple ese tipo de negocio en la vida económica y social.

Para **BETTI**, "la causa del negocio es, propiamente, la función económico-social que caracteriza al tipo de negocio como acto de autonomía privada (típica en este sentido) y determina su contenido mínimo necesario".

CARIOTA FERRARA lo explica por contraste: la causa que el derecho exige no es el fin subjetivo que cada contratante persigue en el caso concreto (con ese criterio, ningún negocio carecería de causa), sino la función que el derecho considera relevante. Aplicado a los tipos de contrato: en todo negocio oneroso, la función es intercambiar una prestación por otra; en la compraventa, cambiar una cosa por un precio; en la donación, enriquecer al donatario; en el testamento, destinar los propios bienes para después de la muerte.

3.3. Doctrina del móvil o motivo determinante

También llamada doctrina de la causa ocasional o impulsiva, se separa de las dos anteriores porque mira la causa con un criterio **subjetivo**. Como la italiana, la refiere al acto o contrato y no a la obligación; pero para ella la causa es el móvil o motivo determinante que llevó al autor o a las partes a celebrarlo. Uno de sus autores más conocidos es el francés **MAURY**.

De ahí se siguen dos ideas. La primera: no hay un concepto de causa válido para toda una especie de actos, porque lo que lleva a una persona a vender puede ser completamente distinto de lo que lleva a otra a celebrar el mismo contrato. La segunda: no basta con que exista un motivo determinante, sino que además debe ajustarse al derecho, porque si es ilícito el acto puede anularse. Aquí la doctrina distingue según el tipo de acto. En los **gratuitos**, basta que el móvil ilícito exista en quien hace la liberalidad, aunque el beneficiario no lo conozca ni lo comparta. En los **onerosos**, el móvil ilícito de una parte debe ser, si no compartido, al menos **conocido** por la otra: si esta lo ignoraba, el contrato no puede anularse por esa razón.

3.4. Doctrina anticausalista

PLANIOL le hace dos cargos a la teoría clásica: es *falsa* y, además, *inútil*. Los prueba en cada una de las tres categorías de contratos.

a) Por qué sería falsa

En los **bilaterales**, porque las dos obligaciones nacen en el mismo instante, y si la causa debe ir antes que su efecto, ninguna puede ser causa de la otra. En los **reales**, porque la entrega de la cosa no es la causa de la obligación de restituir, sino el requisito para que el contrato se perfeccione: decir que la causa es la entrega equivale a decir que la causa es el contrato mismo. En los **gratuitos**, porque mezcla la causa con los motivos: en la práctica es imposible separar la intención de hacer una liberalidad de las razones que tuvo el donante para hacerla.

b) Por qué sería inútil

En los **bilaterales**, porque lo que la teoría llama causa de la obligación de una parte es, en realidad, el objeto de la obligación de la otra. Si la cosa vendida no existe, no hace falta decir que la obligación del comprador carece de causa: basta constatar que la del vendedor carece de objeto. En los **reales**, porque si la cosa no se entregó, el contrato ni siquiera se perfeccionó, y no hay obligación alguna a la que buscarle causa. En los **gratuitos**, porque si falta la intención liberal, lo que en verdad falta es el consentimiento. Y en el terreno de la ilicitud tampoco aportaría nada: la inmoralidad del acto ya queda cubierta por el objeto ilícito, con el que la causa ilícita terminaría confundándose.

CRITERIO	CLÁSICA	ITALIANA	MÓVIL O MOTIVO DETERMINANTE	ANTICAUSALISTA
Qué debe tener causa	La obligación	El acto o contrato	El acto o contrato	Nada: la causa sobra
Criterio	Objetivo	Objetivo	Subjetivo	No se plantea
Qué es la causa	La razón por la que se obliga cada parte, según la categoría de contrato	La función económico-social del tipo de negocio	El motivo concreto que impulsó a las partes	Se confunde con el objeto (Planiol) o con el consentimiento (Dabin)
¿Es igual en todos los actos de una especie?	Sí	Sí	No, varía caso a caso	No se plantea
Autores	Domat, Pothier	Betti, Cariota, Ferrara	Maury	Planiol, Giorgi, Laurent, Dabin

4. LA TEORÍA DE LA CAUSA EN EL CÓDIGO CIVIL CHILENO

El Código Civil se ocupa de la causa en tres artículos. El **art. 1445** N° 4 la pone entre los requisitos para que una persona se obligue por un acto o declaración de voluntad (el artículo completo está en II.B). El **art. 1468** impide pedir la devolución de lo que se dio o pagó a sabiendas por una causa ilícita (ver 6). Y el **art. 1467** es la norma central:

Art. 1467. "No puede haber obligación sin una causa real y lícita; pero no es necesario expresarla. La pura liberalidad o beneficencia es causa suficiente.

Se entiende por causa el motivo que induce al acto o contrato; y por causa ilícita la prohibida por ley, o contraria a las buenas costumbres o al orden público.

Así la promesa de dar algo en pago de una deuda que no existe, carece de causa; y la promesa de dar algo en recompensa de un crimen o de un hecho inmoral, tiene una causa ilícita."

Leídas juntas, estas normas abren dos preguntas que la doctrina chilena no responde de una sola manera.

4.1. ¿Qué es lo que debe tener causa: el acto o la obligación?

Las dos respuestas se apoyan en el texto del Código.

(i) Lo que debe tener causa es la obligación

Es lo que parece decir la letra de la ley: el **art. 1467** parte diciendo que no puede haber *obligación* sin causa, y el **art. 1445** exige la causa lícita para que una persona *se obligue*. Además, el Código se redactó cuando la doctrina clásica, que pone la causa en la obligación, estaba en su apogeo.

(ii) Lo que debe tener causa es el acto o contrato

Si se lee el **art. 1445** completo, lo que debe tener causa lícita es el acto o declaración de voluntad *por el cual* la persona se obliga, no la obligación: así lo muestra la propia construcción de la frase. La definición del **art. 1467** despeja la duda, porque la causa es el motivo que induce *al acto o contrato*. Y el **art. 2057** lo confirma: habla de sociedades nulas "por lo ilícito de la causa u objeto", y lo que tiene una causa ilícita en ese caso es el contrato de sociedad.

4.2. ¿Criterio objetivo o subjetivo?

(i) El Código sigue el criterio objetivo de la doctrina clásica

Se dan cuatro argumentos. Primero, el histórico: al dictarse el Código dominaba la doctrina clásica, y el Código francés, su modelo, sigue fielmente a Domat y Pothier, en quienes se habría inspirado **BELLO**. Segundo, si el **art. 1467** exige una causa *real* es porque admite que una obligación pueda no tenerla, algo que solo cabe en la teoría clásica: con un criterio subjetivo la exigencia no tendría sentido, porque nadie actúa sin algún motivo psicológico, salvo un enajenado.

Tercero, los ejemplos del propio **art. 1467**. Para **LEÓN HURTADO**, la promesa de pagar una deuda inexistente carece de causa porque la obligación del que promete no se apoya en ninguna obligación de la otra parte, ni en una entrega, ni en una intención liberal; y la frase "la pura liberalidad o beneficencia es causa suficiente" reproduce lo que Pothier decía de los contratos gratuitos. Cuarto, si la definición habla de "motivo" sin aclarar que se trata del motivo jurídico o abstracto, es por una simple omisión del legislador: el contexto muestra que ese es el sentido.

(ii) El Código se apartó de la doctrina clásica y siguió un criterio subjetivo

Se responde, primero, que la idea de causa-motivo no era ninguna novedad: venía de los canonistas, y **BELLO** la conocía. Segundo, que el Código chileno, a diferencia del francés, definió la causa, y la definió como el *motivo*, palabra que en su sentido natural y obvio designa los móviles psicológicos, individuales y subjetivos. El propio Código la usa así: el **art. 1454** habla del "principal motivo" para contratar y el **art. 1455**, de la "causa principal" del contrato, tratando motivo y causa como sinónimos. Tercero, que decir que la pura liberalidad basta como causa no significa adherir a Pothier, sino que, en los actos gratuitos, el motivo suficiente es la intención de beneficiar a otro.

Cuarto, que exigir una causa *real* y *lícita* autoriza al juez a buscar el motivo que de verdad llevó a contratar, porque la licitud solo puede juzgarse sobre ese motivo verdadero; por eso el Código pone ambas exigencias juntas. Y quinto, que la promesa de pagar una deuda que no existe no carece de causa por falta de motivo (el que promete tiene uno muy claro: cree que debe), sino porque ese motivo es equivocado.

4.3. Doctrina dual de la causa

La distinción entre causa del contrato y causa de la obligación tiene un antecedente en Francia. Aunque el Código Napoleón solo pide causa para la obligación, la doctrina y la jurisprudencia francesas notaron que la teoría clásica dejaba sin respuesta ciertos contratos inmorales. Pasa, por ejemplo, con un arriendo celebrado para destinar el inmueble a una actividad ilícita que el arrendador conoce y de cuyas ganancias participa (ver el ejemplo de 6): ni la obligación de entregar ni la de pagar la renta tienen nada de ilícito, y como cada una es causa de la otra, la teoría clásica no encuentra ilicitud alguna. Lo ilícito está en el contrato, no en las obligaciones. La salida fue buscar la causa del contrato en el móvil determinante de las partes, de modo que si ese móvil es ilícito, el contrato es anulable. Para la causa de la obligación siguió rigiendo la teoría clásica.

Sobre esa base, **LEÓN HURTADO** y **VIAL** sostienen que el Código chileno también distingue, al menos implícitamente, dos causas:

(i) **Causa del acto o contrato**

Es la que define el **art. 1467**: el motivo que induce a celebrarlo, entendido en su sentido corriente, es decir, los móviles psicológicos, individuales y subjetivos que la persona se representó y que la llevaron a actuar.

(ii) **Causa de la obligación**

Varias disposiciones del Código dejan ver que no solo el contrato debe tener causa, sino también las obligaciones que crea. Para estas rige la teoría clásica: la causa se analiza con criterio objetivo y es abstracta, la misma para todos los contratos de una categoría.

VIAL destaca lo que esto revela del Código chileno. En Francia, la causa del contrato tuvo que construirse sin apoyo en ningún texto; aquí, en cambio, el intérprete cuenta con la definición del **art. 1467**, con la que el redactor se adelantó a la teoría de los motivos psicológicos antes de que esta se formulara. Esta tesis dual es la **opinión más aceptada** en Chile.

PREGUNTA CLÁSICA**¿Qué concepto de causa sigue el Código Civil chileno?**

Partir por las normas: el **art. 1445** N° 4 y el **art. 1467**, que define la causa como el motivo que induce al acto o contrato. Luego exponer las dos discusiones de texto: si la causa la debe tener la obligación o el acto (la letra de los **arts. 1445 y 1467** inc. 1° frente a la definición y al **art. 2057**) y si el criterio es objetivo o subjetivo. Responder con la opinión más aceptada, la tesis dual de **LEÓN HURTADO** y **VIAL**: el acto tiene una causa subjetiva, su motivo, y la obligación, una causa objetiva, la de la teoría clásica. Cerrar con la crítica de **ALCALDE** (ver 4.4), para quien la distinción no tiene importancia práctica.

4.4. Doctrina unitaria de la causa

ALCALDE rechaza la tesis dual. Apoyándose en la doctrina italiana moderna y en una lectura propia del Código, propone un concepto **unitario** de causa, para el cual distinguir entre la causa del contrato y la de la obligación no tiene, en la práctica, ninguna importancia. Su razonamiento avanza en cuatro pasos:

(i) Las teorías tradicionales tienen un concepto demasiado estrecho

Sea que partan de la causa eficiente, de la final o de la ocasional, la doctrina clásica y la mayoría de los autores chilenos refieren la causa solo al contrato o a la obligación que nace de él. Así dejan fuera muchas otras instituciones que solo se entienden a partir de la causa. Y, a la vez, algunas de esas posiciones han estirado la causa hasta terrenos que no le corresponden.

(ii) Lo común a todos los casos es una justificación legal

En todas las situaciones en que surge la pregunta por la causa (un contrato, la obligación que genera, una atribución patrimonial) hay un hecho al que la ley le reconoce el efecto de crear o extinguir una obligación eficaz, o de permitir que alguien conserve un incremento de su patrimonio. Eso ocurre porque existe una razón que justifica esa atribución, y esa razón coincide con el interés que el derecho protege en el caso. De ahí su definición:

Para **ALCALDE**, la causa es "aquel supuesto de hecho legalmente suficiente para justificar un determinado efecto jurídico".

La voluntad (con su solemnidad, cuando se exige) y el objeto también deben concurrir, pero son otra cosa: son presupuestos del acto y no explican por qué el derecho le da a esa voluntad, recaída sobre ese objeto, la fuerza de producir efectos. Esa explicación es lo propio de la causa.

(iii) La ilicitud de la causa no depende de los motivos

Según el Código, la causa ilícita no tiene que ver con los móviles personales del autor o de las partes, sino con que el acto se desvíe del interés que la norma protege.

(iv) La causa explica más que el contrato

Así entendida, la causa explica también el pago, la adquisición de derechos sobre una cosa propia, la condición suspensiva meramente potestativa, el fraude a la ley y el derecho a conservar (o el deber de restituir) un incremento patrimonial. Y, en sentido inverso, hay instituciones que tradicionalmente se explicaban por la causa y que en realidad nada tienen que ver con ella, como la condición resolutoria tácita y la excepción de contrato no cumplido.

5. CAUSA REAL

El **art. 1467** exige que la causa sea **real**, pero no obliga a expresarla. Para **VIAL**, eso se explica porque la ley **presume** que todo acto tiene una causa: la formada por los motivos que habitualmente llevan a celebrar ese tipo de acto. En una compraventa, por ejemplo, se presume que el vendedor quería procurarse dinero y el comprador, hacerse de la cosa. La ley presume, además, que ese motivo es **lícito**. Como lo normal es que haya causa, quien alega que falta debe probarlo, y lo mismo quien alega que es ilícita.

Es raro que un acto no tenga causa, pero puede pasar. Se mencionan la donación hecha sin ánimo de liberalidad y la compraventa en que no se pactó precio. **VIAL** identifica dos casos:

(i) **Los actos simulados**

La simulación tiene dos momentos, que pueden darse casi a la vez: el acuerdo de las partes para ocultar su voluntad real y la celebración del contrato aparente. El acuerdo sí tiene un motivo, engañar a terceros; el contrato aparente, en cambio, no tiene ninguno, porque las partes no quieren de verdad lo que declaran. En la simulación **absoluta** no hay motivo real para ningún contrato. En la **relativa** sí lo hay, pero para el contrato oculto, el que las partes realmente quieren, y no para el que muestran. Por eso **VIAL** concluye que todo contrato simulado es inexistente por falta de causa. Es una opinión propia: en IV.D 4.3 se expone la lectura según la cual la simulación absoluta deja al acto sin causa real y la relativa con causa u objeto ilícito, y en ambos casos el acto simulado es absolutamente nulo.

(ii) **Los actos cuyo único motivo es creer, por error, que existe una obligación**

Es el ejemplo que da el propio **art. 1467**: la promesa de dar algo en pago de una deuda que no existe carece de causa. Quien promete tiene un motivo, la creencia de que debe; pero como esa creencia es falsa, la causa también lo es, y una causa falsa equivale a no tener causa real. Para **VIAL**, esa declaración es inexistente.

EJEMPLO**El cordero que no se debía**

El Chalo está convencido de que le debe \$300.000 a su compadre, el Toño, por el cordero del 18, sin acordarse de que ese año el Toño se lo regaló. Le firma una promesa de pagárselos en marzo. La promesa no tiene causa (**art. 1467** inc. 3°): el Chalo se obligó para pagar una deuda que nunca existió.

¿Qué pasa con el acto sin causa? Para quienes aceptan la inexistencia, el acto no llega a nacer, porque le falta un requisito de existencia. **CLARO SOLAR** lo dice así: "si todo acto o declaración de voluntad requiere esencialmente una causa, la falta de causa se opone al perfeccionamiento jurídico del acto, por lo mismo, no existe; no es un acto nulo, sino un acto que no ha podido nacer a la vida jurídica". Quienes niegan que el Código recoja la inexistencia lo sancionan con la **nulidad absoluta** (ver IV.A).

6. LICITUD DE LA CAUSA

No basta que la causa exista: además debe ser **lícita**. El **art. 1467** llama causa ilícita a la prohibida por ley o contraria a las buenas costumbres o al orden público (inc. 2°), y da como ejemplo la promesa de dar algo en recompensa de un crimen o de un hecho inmoral (inc. 3°). El acto con causa ilícita es **absolutamente nulo** (**art. 1682**), sanción que, a diferencia de la que corresponde a la falta de causa, nadie discute. Y quien dio o pagó algo por una causa ilícita, sabiendo que lo era, no puede pedir que se lo devuelvan (**art. 1468**).

EJEMPLO**La bodega de Quilicura**

Don Pato le arrienda su bodega de Quilicura al Maicol, sabiendo que ahí va a funcionar una cocina de pasta base, y pacta que, además de la renta, se lleva un porcentaje de las ganancias. Mirada sola, ninguna de las dos obligaciones tiene nada de ilícito: entregar una bodega y pagar una renta son cosas que se hacen todos los días. Lo ilícito es el motivo que llevó a contratar, y que los dos conocían. El contrato es absolutamente nulo (**arts. 1467 y 1682**), y lo que el Maicol pagó a sabiendas no lo puede pedir de vuelta (**art. 1468**).

¿Cómo se sabe si el motivo es ilícito? **VIAL** responde desde la presunción de causa. Al legislador no le interesa, en principio, el motivo concreto que tuvo cada contratante: le basta el motivo típico que se desprende de la naturaleza del contrato, que siempre es lícito, y por eso no exige expresar la causa. Que el motivo real no coincida con el típico, por lo general, no tiene importancia. La cosa cambia cuando alguien alega que la causa es ilícita: entonces el juez debe averiguar cuál fue el mo-

tivo individual y determinante que llevó a contratar, porque solo ese motivo real puede ser lícito o ilícito.

Para encontrarlo no basta con lo que diga el contrato sobre por qué se celebró, ya que esa mención puede no ser cierta (menos todavía si la causa era ilícita), ni con deducirlo de la naturaleza del contrato. El juez debe llegar al motivo real con las pruebas rendidas en el juicio, entre ellas las presunciones, y solo entonces decidir si es contrario a la ley, a la moral, a las buenas costumbres o al orden público.

Una forma particular de causa ilícita es el **fraude a la ley**. Para la doctrina que exige en el fraude la intención de burlar la norma, ese propósito es, precisamente, una causa ilícita. Se estudia en IV.F.

7. ACTOS CAUSALES Y ACTOS ABSTRACTOS

7.1. Conceptos

Según si la causa cuenta o no para que el acto se forme, los actos jurídicos se dividen en causales y abstractos.

(i) **Actos causales**

En ellos, la causa es un elemento esencial para que el acto se perfeccione. Si falta o es ilícita, el acto es absolutamente nulo y no produce efecto alguno. Son la regla general: la compraventa, el arrendamiento, el mutuo y el comodato, por ejemplo.

(ii) **Actos abstractos**

En ellos, la causa no forma parte de lo que se necesita para constituir el acto: se perfeccionan y funcionan separados de ella. Por eso, aunque la causa falte o sea ilícita, el acto vale y produce sus efectos.

El nombre puede engañar: un acto abstracto no es un acto sin causa. Un acto que no sirviera a ningún fin ni cumpliera ninguna función sería absurdo. La diferencia es otra: en el acto abstracto la causa existe, pero el derecho no la toma en cuenta para constituirlo ni para que produzca sus efectos.

7.2. La relación fundamental y subyacente del acto abstracto

Detrás de todo acto abstracto hay una obligación o relación jurídica que ese acto viene a cumplir o a reforzar. Se la llama relación **fundamental**, porque es la base de toda la operación, y **subyacente**, porque queda por debajo del acto abstracto, tapada por él. Si se gira una letra de cambio para pagar el precio de una compraventa, la obligación de pagar ese precio es la relación fundamental y subyacente de la letra.

Que esa relación no exista o sea ilícita equivale a que el acto abstracto no tenga causa o la tenga ilícita. Para **BOETSCH**, eso solo puede alegarse entre quienes son parte de la relación subyacente y frente a terceros de mala fe, nunca frente a terceros de buena fe, porque se rompería la seguridad que el acto abstracto existe para proteger. La Ley N° 18.092, sobre letras de cambio y pagarés, recoge esa idea: el demandado en virtud de una letra no puede oponerle al demandante excepciones fundadas en sus relaciones personales con portadores anteriores (**art. 28**), y la regla se aplica también al pagaré (**art. 107**).

EJEMPLO

El pagaré del auto con el motor fundido

La Pili le compra un auto usado a una automotora y lo paga con un pagaré. La automotora lo endosa a una financiera, que nada tiene que ver con la venta. Al mes, la Pili descubre que el auto tenía el motor fundido y la venta termina en tribunales. Si la financiera la demanda para cobrar el pagaré, la Pili no puede defenderse con los problemas de la compraventa: son excepciones fundadas en su relación personal con la automotora, un portador anterior (**arts. 28 y 107 Ley N° 18.092**). Esas defensas solo puede hacerlas valer contra la automotora.

7.3. Razón de ser de los actos abstractos

Los actos abstractos responden a necesidades prácticas. La principal es dar seguridad a quien adquiere ciertos derechos y facilitar que estos circulen: el deudor no puede frenar esa adquisición ni esa circulación alegando que la causa falta o es ilícita. Cuando se le pide al juez que haga cumplir un acto abstracto, le basta comprobar que el deudor se obligó a pagar; no tiene por qué indagar la causa.

Tienen, además, otra ventaja: como funcionan con la causa en blanco, sirven para los fines más variados. Una misma letra de cambio puede usarse para pagar una deuda, para garantizarla, para donar o para prestar dinero. En suma, los actos abstractos son títulos indiscutibles de los derechos que contienen, porque el deudor no puede oponer defensas ajenas al título mismo, y eso hace más ágil el tráfico.

7.4. Solo la ley puede establecer actos abstractos

En algunos ordenamientos, como el belga, se discute si los particulares pueden crear actos abstractos en ejercicio de la autonomía de la voluntad. En Chile la respuesta es no: solo el legislador puede hacerlo. La causa es un requisito del acto o declaración de voluntad (**art. 1445** inc. 1°), un elemento que forma parte de su estructura, y su omisión se sanciona con la inexistencia o, al menos, con la nulidad absoluta (**art. 1682**), la misma sanción de la causa ilícita. Una sanción de esa gravedad muestra que la causa, como los demás elementos constitutivos del acto, es de orden público:

los particulares no pueden prescindir de ella. Separar el acto de su causa queda, entonces, fuera de su alcance, y solo la ley puede, por excepción, crear actos abstractos.

7.5. Actos abstractos en la legislación chilena

Suelen mencionarse como actos abstractos en el derecho chileno la **delegación**; la **estipulación a favor de otro**; la **fianza** y los demás contratos que garantizan una deuda ajena; y algunos **títulos de crédito**, como la letra de cambio.

8. RELACIÓN DE LA CAUSA CON EL ERROR Y CON LA FUERZA O EL DOLO

La causa se cruza con el **error**. En los casos de error que vician el consentimiento, lo que llevó a la víctima a contratar, su motivo determinante, fue justamente una creencia equivocada: que la cosa tenía cierta sustancia o calidad, o que la otra parte era cierta persona (**arts. 1454 y 1455**). Es lo que se llama **error-motivo**: la persona no se equivoca sobre sus razones para contratar, sino sobre un dato de la cosa o de la persona que, después, se convierte en su razón principal para hacerlo.

El **error sobre los motivos** es otra cosa: la persona se representa mal hechos ajenos al contrato, sus propias razones o expectativas para celebrarlo. La Mane se compra un reloj porque cree que perdió el suyo, que aparece a la semana debajo del asiento del auto: la compra vale igual. La regla general es que este error es **irrelevante**. La excepción, para cierta doctrina, son los actos gratuitos, en que alguien se desprende de algo sin recibir nada a cambio movido por una razón equivocada. El Código Civil italiano, por ejemplo, permite impugnar la disposición testamentaria y la donación cuando el error recae sobre el motivo único y determinante.

NO CONFUNDIR

Error-motivo y error sobre los motivos

En el **error-motivo**, la persona se equivoca sobre la sustancia o calidad de la cosa o sobre la otra parte, y ese dato equivocado es lo que la lleva a contratar: vicia el consentimiento si se cumplen los requisitos de los **arts. 1454 y 1455**. En el **error sobre los motivos**, la equivocación está en las razones personales que tuvo para celebrar el acto, ajenas a su estructura: por regla general, no afecta su validez.

VIAL agrega una precisión: en la mayoría de los actos gratuitos que la doctrina permite impugnar por error sobre los motivos, lo que hay en realidad es un error en la persona. Don Memo le dona su lancha a la Rocío porque cree que ella lo sacó del agua en Reñaca, cuando quien lo salvó fue su hermana. El motivo de la donación, la gratitud, es real; el error está en quien la recibe, que no tiene

la cualidad que don Memo le atribuye. En una donación así, la persona del donatario es la causa principal del contrato, y el error sobre ella vicia el consentimiento (**art. 1455**).

La causa también se cruza con la **fuerza** y el **dolo**. Ambos vician el consentimiento cuando son determinantes, es decir, cuando son el motivo principal que llevó a la víctima a contratar. Pero si son el motivo principal, son también la causa del acto, y una causa contraria al derecho: una causa ilícita. ¿Qué reglas se aplican, entonces? La pregunta importa, porque los vicios del consentimiento se sancionan con nulidad relativa y la causa ilícita con nulidad absoluta, y cada una tiene reglas distintas sobre quién puede pedirla y cómo se sana. **VIAL** responde que la víctima no puede elegir: priman las normas sobre vicios del consentimiento, porque son especiales frente a las de la causa ilícita.

CONEXIONES

La causa en otras materias

En este manual: II.A.5 El error (**arts. 1454 y 1455**), II.A.6 El dolo y II.A.7 La fuerza (vicios determinantes), II.B La capacidad (**art. 1445**), II.C El objeto (objeto ilícito, con los mismos términos que la causa ilícita; **art. 1468**), IV.A La inexistencia jurídica (falta de causa), IV.B La nulidad (**arts. 1682, 1683 y 1687**), IV.D La simulación (sanción de la simulación ilícita), IV.F El fraude a la ley y VI.A La condición (la condición meramente potestativa).

Obligaciones: pago de lo no debido (**arts. 2295 y 2297**), condición resolutoria tácita y excepción de contrato no cumplido. Revisar apunte de Obligaciones, [FALTA: sección] (p. ____).

Contratos: donación, contratos reales, sociedad nula por causa u objeto ilícito (**art. 2057**). Revisar apunte de Contratos, [FALTA: sección] (p. ____).

Comercial: letra de cambio y pagaré (**arts. 28 y 107 Ley N° 18.092**). Revisar apunte de Comercial, [FALTA: sección] (p. ____).

E. LAS FORMALIDADES

1. CONCEPTO

En algunos actos no basta con que la voluntad exista: la ley exige, además, que se exteriorice de cierta manera, o que se cumplan ciertos trámites para que el acto valga, se pruebe o pueda hacerse valer contra otros. Esas exigencias de forma son las formalidades.

La definición que le ha dado la doctrina es la de "ciertos requisitos que dicen relación con la forma o aspecto externo que deben revestir ciertos actos jurídicos, exigidas por la ley para la existencia de ellos, su validez, su prueba u otro efecto determinado".

La parte final de la definición es la clave del tema: lo que la ley busca con cada formalidad decide qué le pasa al acto cuando se omite.

2. CLASES DE FORMALIDADES

Atendiendo a ese fin, se distinguen cuatro especies de formalidades, cada una con su propia sanción: **(i) las solemnidades, (ii) las formalidades habilitantes, (iii) las formalidades de prueba y (iv) las medidas de publicidad.**

En cuanto a su materialidad, la forma exigida puede ser muy variada: un instrumento público o privado, la intervención de un funcionario público o de testigos, la publicación de avisos en un diario o la inscripción en un registro público, entre otras.

FORMALIDAD	¿PARA QUÉ SE EXIGE?	EJEMPLO	SANCIÓN SI SE OMITE
Solemnidad de existencia	Es el único medio por el que la voluntad puede manifestarse	Escritura pública en la venta de un inmueble (art. 1801 inc. 2º)	Discutida: inexistencia o nulidad absoluta
Solemnidad de validez	Es requisito de validez del acto, en atención a su naturaleza	Testigos del testamento solemne (art. 1014)	Nulidad absoluta
Habilitante	Proteger a los incapaces, integrando su voluntad o el poder de su representante	Autorización judicial para enajenar los inmuebles del hijo (art. 254)	Nulidad relativa
De prueba	Acreditar el acto y su contenido	Constancia escrita de los actos sobre cosas de más de dos unidades tributarias (art. 1709)	El acto vale, pero pierde un medio de prueba
Publicidad de simple noticia	Informar a los terceros en general	Avisos del decreto de interdicción (art. 447)	Indemnización de perjuicios (art. 2314)
Publicidad sustancial	Precaver a los terceros interesados	Notificación al deudor de la cesión de un crédito (art. 1902)	Inoponibilidad

2.1. Las solemnidades (formalidades propiamente tales)

Las solemnidades son las formalidades en sentido estricto. Según para qué las exija la ley, pueden condicionar la existencia del acto o solo su validez.

(i) Solemnidades requeridas para la existencia del acto

Son requisitos externos que la ley impone para celebrar ciertos actos, y que pasan a ser el único medio por el que el autor o las partes pueden manifestar su voluntad. Fuera de esa forma, para el derecho no hay voluntad manifestada. Por eso estas solemnidades se cuentan entre los requisitos de existencia del acto, al lado de la voluntad, el objeto y la causa. Hay quienes matizan esta conclusión: la solemnidad no sería un requisito distinto de la voluntad, sino solo el modo en que, en esos actos, la voluntad debe expresarse.

No siempre fueron la excepción. En los derechos antiguos la voluntad desnuda no producía efectos: tenía que revestirse de ritos y fórmulas, a veces complicados y simbólicos, y casi todos los actos eran solemnes. El derecho moderno invirtió la regla con el **consensualismo**: en la mayoría de

los casos el acto queda formado con la sola manifestación de voluntad, cualquiera sea la forma que esta adopte. El consensualismo es una de las caras de la autonomía de la voluntad (ver I.5), que permite a los particulares regular sus relaciones como quieran, pactar las cláusulas que les parezcan y elegir las formas que prefieran, con los únicos límites de la ley, el orden público y las buenas costumbres.

El Código chileno sigue esa línea: los actos consensuales son la regla y los solemnes, la excepción. La ley reserva las solemnidades para actos de especial trascendencia, para que las partes reparen en lo que están haciendo. Así, la venta de bienes raíces, servidumbres y censos, y la de una sucesión hereditaria, no se reputan perfectas mientras no se otorgue escritura pública (**art. 1801** inc. 2°), y la promesa de celebrar un contrato solo obliga si consta por escrito (**art. 1554 N° 1**).

Que un acto sea solemne lo decide la ley. Las partes también pueden imponerse una solemnidad que la ley no exige, pero esa solemnidad voluntaria funciona de otra manera: si después actúan de un modo que implica renunciarla, el acto produce efectos igual (**art. 1802**; ver I.8.6). Las solemnidades legales, en cambio, son de **derecho estricto**, porque se apartan del derecho común, y se interpretan de forma restrictiva: no se extienden por analogía a un acto parecido, ni se exigen otras que las que la ley señala expresamente. Solo son solemnes los actos que la ley declara tales.

¿Qué pasa si falta una solemnidad de existencia? La respuesta depende de la posición que se tome frente a la inexistencia (ver IV.A).

a) El acto es inexistente

Quienes aceptan la inexistencia responden que el acto es **inexistente**: si la solemnidad es el único medio que la ley admite para manifestar la voluntad, sin ella no hay voluntad, y sin voluntad no hay acto. Encuentran apoyo en el **art. 1701** inc. 1° (transcrito en IV.A): cuando la ley exige instrumento público como solemnidad, su falta no puede suplirse por otra prueba, y el acto se mira "como no ejecutado o celebrado", aunque las partes se hayan comprometido a reducirlo a instrumento público dentro de cierto plazo bajo una cláusula penal, que tampoco produce efecto.

b) El acto es nulo absolutamente

Otro sector sostiene que la sanción es la **nulidad absoluta**. Primero, porque el Código no reconocería la inexistencia como una sanción distinta de la nulidad. Y segundo, porque el **art. 1682** sanciona expresamente con nulidad absoluta la omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos en consideración a su naturaleza, y no a la calidad o estado de quienes los celebran.

PREGUNTA CLÁSICA

¿Qué sanción tiene la omisión de una solemnidad exigida para la existencia del acto?

Partir por el concepto: en ciertos actos, la solemnidad es el único medio que la ley admite para manifestar la voluntad (por ejemplo, la escritura pública del **art. 1801** inc. 2°). Exponer luego las dos respuestas. Para unos, el acto es inexistente, porque sin la forma no hay voluntad, y se apoyan en el **art. 1701**, que manda mirar esos actos "como no ejecutados o celebrados". Para otros, la sanción es la nulidad absoluta, porque el Código no recogería la inexistencia y el **art. 1682** sanciona así la omisión de las formalidades exigidas en atención a la naturaleza del acto. Cerrar distinguiendo la solemnidad de validez, cuya omisión se sanciona sin discusión con nulidad absoluta, y conectar con la discusión general de IV.A.

(ii) Solemnidades requeridas para la validez del acto

Otras veces la solemnidad no condiciona el nacimiento del acto, sino su validez: si se omite, el acto existe, pero puede ser anulado. Es lo que ocurre con los testigos del testamento solemne abierto, que debe otorgarse ante escribano y tres testigos, o ante cinco testigos (**art. 1014**): el testamento en que se omite alguna de sus formalidades "no tendrá valor alguno" (**art. 1026**). También lo es la insinuación de las donaciones entre vivos, es decir, la autorización del juez competente: la donación no insinuada solo vale hasta el valor de dos centavos y es nula en el exceso (**art. 1401**).

Como estas solemnidades miran a la naturaleza o especie del acto, su omisión se sanciona con **nulidad absoluta** (**art. 1682**). Aquí no hay discusión: el acto nació, pero nació inválido.

EJEMPLO**El testamento de don Lalo**

Don Lalo otorga testamento abierto en una notaría de Curicó. Llegan el notario y dos de los tres testigos; el tercero avisa que no alcanza, porque juega Rangers. Don Lalo, apurado, firma igual. El testamento existe, pero le falta uno de los testigos que exige el **art. 1014**: no tiene valor alguno (**art. 1026**), y la sanción es la nulidad absoluta (**art. 1682**).

2.2. Formalidades habilitantes

Cuando el acto toca los intereses de un incapaz, la ley agrega otro tipo de formalidad, pensada para protegerlo.

La definición que le ha dado la doctrina es la de "requisitos que la ley, velando por los intereses de los incapaces, exige para la validez o eficacia de ciertos actos jurídicos que los afectan y que tienden a integrar la voluntad de aquéllos o el poder de sus representantes legales y, consecuentemente, a remover la incapacidad o la falta de poder".

La doctrina distingue tres especies:

(i) La autorización

Es el permiso previo que se da para que otro celebre un acto. Puede darlo el representante legal de un incapaz o el juez, o bien la persona capaz a quien otro administra sus bienes. Así, los actos que el hijo sujeto a patria potestad celebra sin autorización de su padre o madre solo lo obligan en su peculio profesional o industrial (**art. 260**), y el curador que confía al pupilo la administración de una parte de sus bienes debe autorizar los actos que este ejecute en ella (**art. 440** inc. 2°).

Otras veces quien necesita la autorización es el propio representante. Los bienes raíces del hijo no pueden enajenarse ni gravarse en caso alguno sin autorización del juez con conocimiento de causa (**art. 254**). Esa autorización suple la falta de legitimación del padre o la madre para disponer de esos bienes: los habilita para hacerlo.

EJEMPLO

El departamento de la Isi

La abuela de la Isi, de doce años, le dejó un departamento en Viña. La Javi, su mamá, que tiene la patria potestad, lo vende para comprar uno en Santiago, sin pedirle autorización al juez. Faltó la formalidad habilitante del **art. 254**, exigida en atención a la calidad de la persona: la venta adolece de nulidad relativa (**art. 1682**).

(ii) La asistencia

Aquí no hay un permiso previo, sino presencia: el representante legal concurre al acto que celebra el incapaz y se pone jurídicamente a su lado, o la persona capaz concurre al acto que celebra quien administra sus bienes. Con la autorización solo hay una diferencia de momento: la autorización se da antes del acto; la asistencia, al tiempo de celebrarlo. En la práctica, ambas significan lo mismo, la conformidad de quien interviene con el acto que otro celebra. Así, la autorización de la mujer casada en sociedad conyugal puede darse "interviniendo expresa y directamente de cualquier modo" en el acto del marido (**art. 1749** inc. 7°).

(iii) La homologación

Es la aprobación judicial de un acto que otros ya celebraron, después de controlar su legitimidad; solo con esa aprobación el acto pasa a ser eficaz. El caso típico es la partición en que tienen interés

personas ausentes que no han nombrado apoderado, o personas bajo tutela o curaduría: una vez terminada, debe someterse a la aprobación del juez (**art. 1342**). El juez revisa si se respetaron las exigencias que la ley establece para proteger a esas personas. Si se respetaron, aprueba el laudo, la sentencia final del partidor; si no, lo modifica como estime adecuado. Mientras el laudo no quede confirmado por resolución ejecutoriada, la partición no está firme ni produce efectos.

¿Y si se omite una formalidad habilitante? Como la ley la exige en atención a la calidad o estado de las personas que celebran el acto, y no a su naturaleza, la sanción es la **nulidad relativa** (**art. 1682**).

2.3. Las formalidades de prueba

La definición que le ha dado la doctrina es la de "formas que sirven como prueba de la realización de los actos jurídicos y de su contenido".

A diferencia de la solemnidad, esta forma no se exige para que el acto exista o valga, sino para acreditarlo: por eso se habla de forma *ad probationem*. Si se omite, el acto sigue siendo existente y válido; lo único que pierde es un medio de prueba. La regla más importante está en el **art. 1709**:

Art. 1709. "Deberán constar por escrito los actos o contratos que contienen la entrega o promesa de una cosa que valga más de dos unidades tributarias.

No será admisible la prueba de testigos en cuanto adicione o altere de modo alguno lo que se exprese en el acto o contrato, ni sobre lo que se alegue haberse dicho antes, o al tiempo o después de su otorgamiento, aun cuando en algunas de estas adiciones o modificaciones se trate de una cosa cuyo valor no alcance a la referida suma.

No se incluirán en esta suma los frutos, intereses u otros accesorios de la especie o cantidad debida."

Si el acto no consta por escrito, no puede probarse por testigos (**art. 1708**), salvo las excepciones del **art. 1711**: cuando hay un principio de prueba por escrito, cuando fue imposible obtener una prueba escrita y en los demás casos que la ley exceptúa. El Pipe le vende de palabra su moto al Cote en \$1.500.000. La venta vale, porque es consensual; pero si el Cote después niega haberla comprado, el Pipe no podrá probarla con testigos.

NO CONFUNDIR**Solemidad y formalidad de prueba**

Las dos pueden consistir en lo mismo, por ejemplo un escrito, pero cumplen funciones distintas. La **solemnidad** (*ad solemnitatem*) es la forma en que la voluntad debe manifestarse: sin ella el acto es inexistente o nulo, y ninguna otra prueba puede suplirla (**art. 1701**). La **formalidad de prueba** (*ad probationem*) solo sirve para acreditar el acto: si falta, el acto vale igual, pero no puede probarse por testigos (**arts. 1708 y 1709**) y habrá que recurrir a otros medios.

2.4. Las medidas de publicidad

Las medidas de publicidad miran hacia afuera del acto: buscan proteger a los terceros a quienes el acto puede alcanzar. Se clasifican en dos grupos.

a) Medidas de publicidad de simple noticia

Su fin es poner en conocimiento de los terceros en general las relaciones jurídicas que pueden interesarles. Es el caso de los decretos de interdicción provisoria o definitiva del disipador y del demente, que deben inscribirse en el Registro del Conservador y notificarse al público por medio de tres avisos en un diario (**arts. 447 y 461**). Si quien debía cumplir el trámite lo omite, la única sanción es su responsabilidad: debe indemnizar a quien sufrió un perjuicio por la omisión, conforme a la regla general de los cuasidelitos (**art. 2314**).

b) Medidas de publicidad sustanciales

Además de divulgar el acto, buscan precaver a los *terceros interesados*, es decir, a quienes están o estarán en relaciones jurídicas con las partes. Por eso su omisión tiene una sanción más severa: el acto no puede hacerse valer contra esos terceros; les es **inoponible** (ver IV.E). El ejemplo clásico es la notificación al deudor de la cesión de un crédito:

Art. 1902. "La cesión no produce efecto contra el deudor ni contra terceros, mientras no ha sido notificada por el cesionario al deudor o aceptada por éste."

EJEMPLO**El crédito de la Kathy**

La Kathy le cede a la Fran el crédito de \$2.000.000 que tiene contra don Beto, su ex jefe. Ninguna de las dos le avisa a don Beto, y él tampoco ha aceptado la cesión. La cesión no es nula, pero contra don Beto todavía no produce efecto: mientras no se le notifique o la acepte, le es inoponible (**art. 1902**).

CONEXIONES**Las formalidades en otras materias**

En este manual: I.8.6 Actos solemnes y actos no solemnes (solemnidad voluntaria, **art. 1802**), II.B La capacidad (incapaces protegidos por las formalidades habilitantes), IV.A La inexistencia jurídica (**art. 1701**; sociedad anónima nula de pleno derecho), IV.B La nulidad (**arts. 1682 y 1694**; nulidad refleja), IV.B.4.5 La conversión (**art. 1701** inc. 2º, conversión formal), IV.E La inoponibilidad (inoponibilidad por falta de publicidad), V La representación (representantes legales).

Familia: patria potestad (**arts. 254 y 260**), curaduría (**art. 440**), sociedad conyugal (**art. 1749**) e interdicción (**arts. 447 y 461**). Revisar apunte de Familia, [FALTA: sección] (p. ____).

Sucesorio: testamento solemne (**arts. 1014 y 1026**) y partición (**art. 1342**). Revisar apunte de Sucesorio, [FALTA: sección] (p. ____).

Contratos: compraventa (**arts. 1801 y 1802**), donación (**art. 1401**) y promesa (**art. 1554**). Revisar apunte de Contratos, [FALTA: sección] (p. ____).

Obligaciones: prueba de las obligaciones (**arts. 1708, 1709 y 1711**) y cesión de créditos (**art. 1902**). Revisar apunte de Obligaciones, [FALTA: sección] (p. ____).

III. LOS EFECTOS DE LOS ACTOS JURÍDICOS

1. GENERALIDADES

Un acto jurídico se celebra para algo: su autor o sus partes persiguen con él un resultado práctico. Para cierta doctrina, los efectos del acto son precisamente la forma en que la ley traduce ese resultado práctico en términos jurídicos.

La definición que le ha dado la doctrina es la de "los derechos y obligaciones que de él emanan".

Siguiendo la distinción del **art. 1444** entre las cosas de la esencia, de la naturaleza y accidentales de un contrato (ver I.6), los efectos se clasifican en tres:

(i) **Efectos esenciales**

La ley los impone como consecuencia obligada de la celebración del acto, y las partes no pueden descartarlos ni sustraerse a ellos. En la compraventa, la obligación del vendedor de entregar la cosa y la del comprador de pagar el precio.

(ii) **Efectos naturales**

También los establece la ley, pero las partes pueden eliminarlos mediante una cláusula especial. En la compraventa, la obligación del vendedor de sanear la evicción y los vicios redhibitorios.

(iii) **Efectos accidentales**

Son los que las partes, en ejercicio de la autonomía privada, deciden incorporar al acto: la ley no los prevé, pero tampoco los prohíbe. En la compraventa, el pacto comisorio.

2. PERSONAS RESPECTO DE LAS CUALES SE PRODUCEN LOS EFECTOS DE LOS ACTOS JURÍDICOS

¿A quiénes alcanzan esos efectos? La regla general es que solo a quienes celebraron el acto, y no a los terceros: es el **principio de la relatividad** de los actos jurídicos, que admite algunas excepciones (ver 3). Para aplicarlo hay que saber primero quién es parte y quién es tercero.

2.1. Concepto de parte

La definición que le ha dado la doctrina es la de "las personas que, personalmente o representadas, concurren a la formación del acto".

Una parte no es necesariamente una sola persona: cada parte es un centro de intereses, y varias personas que comparten un mismo interés forman una sola parte. Para las partes, el acto produce todos sus efectos, como lo dice el Código respecto del contrato:

Art. 1545. "Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales."

En rigor, quien genera con su voluntad un acto unilateral es su *autor*, y quienes forman un acto bilateral son sus *partes*, pero en la práctica ambas palabras se usan indistintamente. Lo que define a la parte es haber generado el acto con su voluntad, no haber estado presente cuando se celebró u otorgó. Cuando don Hugo le vende su casa a la Cami, el notario autoriza la escritura, pero no es parte: no quiso vender ni comprar. Lo mismo vale para los testigos de un acto.

2.2. Concepto de tercero

Tercero se define por oposición a parte. En general, es tercero toda persona que no participó en la generación del acto, ni por sí ni válidamente representada. Pero no todos los terceros están en la misma situación frente al acto:

(i) Terceros absolutos

Son completamente ajenos: no participaron en la formación del acto y no están ni estarán en relaciones jurídicas con las partes. Para ellos el acto no produce efectos, lo que no es más que la otra cara del **art. 1545**: el contrato es ley solo para los contratantes.

(ii) Terceros relativos

La definición que le ha dado la doctrina es la de "los terceros que están o estarán en relaciones jurídicas con las partes, sea por su propia voluntad o la de la ley".

También se les llama terceros interesados. Los principales son:

a) Los herederos o causahabientes a título universal

Son aquellos a quienes se transmiten todos los derechos y obligaciones transmisibles del causante, o una cuota de ellos (**arts. 951 y 1097**). Solo se sucede a título universal por causa de muerte, nunca por acto entre vivos. Como el **art. 1097** dice que los herederos representan la persona del testador, algunos autores sostienen que no son realmente terceros: continúan la personalidad del causante y asumen su calidad de parte en los actos que celebró.

b) Los causahabientes a título singular

Son aquellos a quienes se transfieren derechos determinados, sea por causa de muerte, como el legatario (**arts. 951 y 1104**), sea por acto entre vivos, como quien adquiere por tradición (**art. 671**). Pueden verse alcanzados por los actos que su antecesor celebró sobre el bien o derecho que reciben; por ejemplo, por una hipoteca constituida sobre el bien antes de transferirlo.

c) Los acreedores de las partes

Son terceros sin discusión, pero lo que haga su deudor les importa: el patrimonio del deudor responde de sus deudas (el llamado derecho de prenda general), y cada bien que sale de él reduce lo que podrán cobrar. Si un deudor con muchas deudas enajena uno de sus pocos bienes, sus acreedores se ven perjudicados por un acto en que no participaron. Por eso la ley les da los llamados *derechos auxiliares*, que sirven para conservar íntegro o aumentar el patrimonio del deudor: las medidas cautelares, la acción pauliana, la acción subrogatoria y el beneficio de separación, entre otros.

NO CONFUNDIR

Tercero absoluto y tercero relativo

Los dos son ajenos a la formación del acto; la diferencia está en su relación con las partes. El **tercero absoluto** no tiene ni tendrá un vínculo jurídico con ellas, y el acto no le produce efectos. El **tercero relativo** sí lo tiene o lo tendrá, por su voluntad o por la ley, y por eso el acto puede alcanzarlo: el heredero que sucede al causante en sus obligaciones, quien adquiere un bien con la hipoteca que lo grava, el acreedor que ve salir bienes del patrimonio de su deudor. Las excepciones al efecto relativo (ver 3.2) se refieren a los terceros absolutos.

3. EL EFECTO RELATIVO DE LOS ACTOS JURÍDICOS Y SUS EXCEPCIONES

3.1. Generalidades

La doctrina tradicional enuncia la regla así: los actos jurídicos producen efectos solo entre las partes, sin beneficiar ni perjudicar a quienes no contribuyeron a generarlos. La razón es la autonomía de la voluntad: si las obligaciones nacen de la voluntad, solo queda obligado quien la manifestó, y los terceros, extraños a la formación del acto, no pueden quedar ligados por él.

En su formulación actual, la regla se enuncia respecto de los contratos: generan derechos y obligaciones solo para los contratantes, y un tercero no puede resultar acreedor ni deudor de un contrato ajeno. Pero ha perdido rigidez por dos vías: la ley ha establecido excepciones en que un contrato sí crea derechos u obligaciones para terceros (ver 3.2), y se ha empezado a reconocer el llamado efecto absoluto o expansivo de los contratos (ver 3.3).

3.2. Excepciones al efecto relativo de los contratos

Hay excepción al efecto relativo cuando un contrato ajeno crea un derecho o una obligación para un tercero absoluto. Se suelen discutir tres casos.

El primero es la **estipulación a favor de otro** (**art. 1449**, transcrito en V). Las partes son el estipulante y el promitente; el beneficiario no es parte, pero solo él puede demandar lo estipulado, aunque no la resolución del contrato. Habría aquí un tercero acreedor de un contrato ajeno. Algunos autores niegan que sea una verdadera excepción: el beneficiario siempre debe aceptar, y al hacerlo pasa a ser parte.

EJEMPLO

El refrigerador del Benja

La tía Mirna compra un refrigerador en una tienda de Maipú y acuerda con la tienda que lo entreguen en el departamento de su sobrino, el Benja, que se acaba de ir a vivir solo. El Benja no firmó nada, pero solo él puede exigir la entrega (**art. 1449**). Y mientras no acepte, expresa o tácitamente, la tía y la tienda pueden dejar sin efecto el contrato por su sola voluntad.

El segundo es la **promesa de hecho ajeno** (**art. 1450**, transcrito en V), que tampoco es una excepción: el tercero no contrae obligación alguna sino en virtud de su ratificación, y al ratificar deja de ser un tercero absoluto.

El tercero sí es una excepción clara, y está en las reglas de la novación: "La novación liberta a los codeudores solidarios o subsidiarios, que no han accedido a ella" (**art. 1645**). Si el acreedor nova la obligación con uno de los deudores solidarios, los demás quedan libres, aunque no fueron parte de la novación ni consintieron en ella.

3.3. El efecto absoluto, indirecto o erga omnes

Que un contrato no cree derechos ni obligaciones para terceros no significa que, para ellos, no exista. Una vez perfeccionado, el contrato es un **hecho social**, y como tal existe para todos: sus efectos reflejos alcanzan incluso a los terceros absolutos. No porque los haga acreedores o deudores, sino porque un tercero puede invocarlo en su favor, puede oponérsele en su contra o puede servir de base para una preferencia.

No es una excepción al efecto relativo. Lo que muestra es que el contrato sí es oponible a terceros como hecho social, aunque no como fuente de obligaciones. Así, en un procedimiento concursal de liquidación (la antigua quiebra), los demás acreedores no pueden desconocer el crédito que otro verificó alegando que nace de un contrato que no les afecta.

El contrato ajeno alcanza a terceros también en otras situaciones. Los acreedores pueden pedir, mediante la **acción pauliana**, que se revoquen los contratos que su deudor celebró con terceros en

su perjuicio. Y en la responsabilidad extracontractual, un tercero puede invocar un contrato celebrado entre otros para determinar contra quién debe dirigir su demanda de indemnización de perjuicios.

Esta última forma de responsabilidad da lugar a la teoría de la **interferencia en contratos ajenos**, que la Ley de Competencia Desleal recogió al calificar como acto de competencia desleal, en su art. 4 letra f), toda conducta que persiga inducir a proveedores, clientes u otros contratantes a infringir los deberes contractuales contraídos con un competidor. Los sistemas que más han desarrollado este ilícito, el estadounidense, el alemán y el francés, no lo tratan igual, pero la doctrina mayoritaria exige dos requisitos para que el tercero responda:

(i) Que conozca el contrato ajeno

El tercero debe saber que el contrato existe.

(ii) Que actúe con dolo

No basta el conocimiento: el tercero debe actuar con la intención de causar un daño, sea porque lo quiso (dolo directo), sea porque lo previó y actuó de todos modos (dolo eventual). Esto vale tanto si se demanda conforme a la Ley de Competencia Desleal, que habla de la conducta que "persiga" inducir al incumplimiento, como si se demanda conforme al derecho común. Y como el dolo no se presume, debe probarlo quien demanda (**art. 1459**).

CONEXIONES

Los efectos del acto en otras materias

En este manual: I.5 El principio de la autonomía de la voluntad (fundamento del efecto relativo), I.6 Estructura y elementos constitutivos del acto jurídico (**art. 1444**), IV.E La inoponibilidad, V La representación (partes que actúan representadas; **arts. 1449 y 1450**), VI Modalidades (efectos accidentales).

Obligaciones: derechos auxiliares de los acreedores (acción pauliana y acción subrogatoria) y novación (**art. 1645**). Revisar apunte de Obligaciones, [FALTA: sección] (p. ____).

Contratos: estipulación a favor de otro y promesa de hecho ajeno (**arts. 1449 y 1450**). Revisar apunte de Contratos, [FALTA: sección] (p. ____).

Sucesorio: herederos y legatarios (**arts. 951, 1097 y 1104**). Revisar apunte de Sucesorio, [FALTA: sección] (p. ____).

Responsabilidad extracontractual: interferencia en contratos ajenos y prueba del dolo (**art. 1459**). Revisar apunte de Responsabilidad Extracontractual, [FALTA: sección] (p. ____).

IV. INEFICACIA DE LOS ACTOS JURÍDICOS

Para **BOETSCH**, la **ineficacia** de los actos jurídicos es "la reacción del ordenamiento jurídico en cuya virtud se priva de efectos a aquel acto que no cumple con los requisitos de eficacia y validez del acto jurídico, o bien que por un hecho o causa posterior eliminan, reducen o perturban los efectos propios de un acto válido".

Un acto ineficaz es el que no genera sus efectos propios o deja de producirlos. La causa puede estar dentro del acto o fuera de él:

(i) **Causa intrínseca: la invalidez**

Cuando lo que priva de efectos al acto es un defecto de su propia estructura, hay **invalidez**. Según qué requisito se haya omitido, la doctrina distingue:

a) **Inexistencia**: para parte de la doctrina, es la ineficacia por omisión de un requisito esencial para la *existencia* del acto, omisión que impide que nazca a la vida del derecho. Otros autores sostienen que esa omisión solo puede sancionarse con nulidad absoluta.

b) **Nulidad**

Es la ineficacia por omisión de un requisito que la ley exige para la *validez* del acto. A diferencia de lo que ocurre con la inexistencia, el acto nulo produce todos sus efectos hasta que la nulidad se declara judicialmente. Es **absoluta** si el requisito omitido se exige en consideración al acto mismo, y no a la calidad o estado de quienes lo ejecutan o acuerdan; es **relativa** si se exige en atención a la calidad o estado de esas personas.

(ii) **Causa posterior: la ineficacia en sentido estricto**

A diferencia de la invalidez, que afecta al acto en su íntima constitución, la **ineficacia en sentido estricto** supone, en palabras de **BOETSCH**, un "acto jurídico existente y válidamente formado y, por consiguiente, susceptible de ejecución, pero que no produce efectos o queda privado de ellos por causa de un hecho posterior y ajeno al acto mismo".

Algunos autores incluyen aquí no solo los hechos posteriores, sino también las circunstancias *coetáneas* a la celebración, siempre que el acto esté válidamente formado. Sus causas son variadas y protegen intereses diversos. Las hipótesis que suelen estudiarse son la suspensión, la resolución, la revocación, la caducidad y la inoponibilidad, tratadas más adelante en este capítulo.

A. LA INEXISTENCIA JURÍDICA

1. CONCEPTOS GENERALES

¿Reconoce el Código Civil chileno una sanción distinta de la nulidad para el acto al que le falta un requisito de existencia? Es una de las discusiones que más debate doctrinal ha generado en la teoría del acto jurídico, y sigue abierta hasta hoy: la discusión sobre la **teoría de la inexistencia jurídica**.

Según **BOETSCH**, la **inexistencia jurídica** es "la sanción que tienen los actos jurídicos celebrados con omisión de uno de los requisitos necesarios para su existencia en el mundo del Derecho".

En la práctica, esto significa que al acto le falta uno de cuatro ingredientes: *voluntad, objeto, causa o solemnidades*, cuando la ley las exige para su existencia. Otra manera de verlo: le falta un elemento tan central que el acto ya no encaja en la definición legal de lo que dice ser; le falta, como quien dice, un órgano vital. *Así, si Diego y Sebastián firman una "sociedad" para abrir una sanguchería en Ñuñoa, pero ninguno pone nada en común, ni plata, ni trabajo, ni el local, lo que firmaron no calza con la definición legal: el art. 2055 dice que "no hay sociedad, si cada uno de los socios no pone alguna cosa en común".*

La inexistencia supone que el acto sí ocurrió en los hechos: existe material o físicamente, pero no para el Derecho. De esa carencia total de existencia jurídica, quienes sostienen la teoría derivan tres consecuencias:

- (i) Opera de pleno derecho, *ipso iure*.
- (ii) No es susceptible de **saneamiento** alguno.
- (iii) La acción para pedir su constatación sería **imprescriptible**.

2. ORIGEN DE LA TEORÍA DE LA INEXISTENCIA JURÍDICA

Esta teoría no nació pensando en los contratos, sino en el **matrimonio**. La formuló a principios del siglo XIX el jurisconsulto alemán **K. S. ZACHARIAE**, comentando el Código de Napoleón, para resolver un problema muy concreto del derecho francés de la época.

Ese derecho partía de un axioma casi absoluto: "no hay nulidad sin texto" (*pas de nullité sans texte*). Trasladado al matrimonio, el axioma implicaba que solo eran nulos los matrimonios que la ley declaraba expresamente nulos, y ninguno más.

Ahí apareció el problema: la ley francesa nunca dijo expresamente que fuera nulo el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Aplicando el axioma al pie de la letra, ese matrimonio habría sido válido, algo inaceptable para la época. Zachariae resolvió el nudo sin tocar el axioma: sostuvo que, para que un matrimonio exista siquiera, la ley presupone el acuerdo entre un hombre y una mujer. Faltando ese acuerdo, no hay un matrimonio nulo que declarar, sencillamente no hay matrimonio, y por eso no hacía falta ningún texto legal que lo declarara nulo.

Más tarde, la idea de inexistencia jurídica se extendió a los actos patrimoniales.

CONEXIONES

Origen de la teoría de la inexistencia jurídica

Derecho de Familia: la teoría nació a propósito del matrimonio. Revisar apunte de Familia, [FALTA: sección] (p. ____).

3. DIFERENCIAS ENTRE LA INEXISTENCIA Y LA NULIDAD

Quienes sostienen la teoría señalan entre ambas sanciones diferencias que no son de detalle: muestran que el debate tiene la mayor relevancia jurídica y práctica.

Paralelo entre la inexistencia y la nulidad:

CRITERIO	INEXISTENCIA	NULIDAD
Requisito omitido	Un requisito de <i>existencia</i> : voluntad, objeto, causa, solemnidades	Un requisito de <i>validez</i> : voluntad no viciada, capacidad de las partes, objeto lícito, causa lícita
Producción de efectos	No produce efecto alguno: no hay ningún efecto que deba destruirse mediante una acción, y las partes deben ser retrotraídas al estado en que se encontraban antes de celebrar el acto	Produce todos sus efectos mientras el vicio no se declare judicialmente; esa producción es efímera o caduca, porque puede desaparecer con la declaración
Forma de operar	De pleno derecho, <i>ipso iure</i> . El juez puede reconocerla o constatarla si hay controversia, pero el acto es inexistente desde antes de esa constatación	Debe ser declarada por los tribunales. Como su objeto es volver a las partes al estado anterior a la celebración del acto, primero hay que obtener la declaración y, en virtud de ella, pedir esa vuelta
Saneamiento por el tiempo	No puede sanearse, esto es, adquirir existencia, por el transcurso del tiempo	Sí puede; el plazo depende de si la nulidad es absoluta o relativa
Ratificación	No puede ratificarse: la nada confirmada continúa siendo la nada	La relativa puede sanearse por la ratificación de las partes (art. 1684). La absoluta no, pero por un motivo distinto del de la inexistencia: es una institución de orden público, establecida en interés de la moral y de la ley, y no de las partes
Quiénes pueden alegarla	Todo el mundo	La relativa , solo aquellos en cuyo beneficio la han establecido las leyes, o sus herederos o cesionarios (art. 1684). La absoluta , todo el que tenga interés en ello, excepto el que ejecutó el acto o celebró el contrato sabiendo o debiendo saber el vicio que lo invalidaba (art. 1683)
Alcance de la declaración	A juicio de la doctrina, una vez constatada o comprobada judicialmente, cualquier interesado puede aprovecharse de ella	Sea absoluta o relativa, solo produce efectos respecto de las partes en cuyo favor se decretó (art. 1690)
Efecto respecto de terceros	Nadie puede oponer un acto inexistente, ni siquiera un tercero que esté de buena fe	Se estudia en B.4, Los efectos de la nulidad

Sobre quiénes pueden invocar cada sanción hay, en resumen, una gradación: la **nulidad relativa** es la que menos personas pueden alegar; la **absoluta**, casi todas las que tengan interés; y la **inexistencia**, absolutamente todas.

El alcance limitado de la declaración de nulidad está en el art. 1690:

Art. 1690. "Cuando dos o más personas han contratado con un tercero, la nulidad declarada a favor de una de ellas no aprovechará a las otras."

Para la doctrina, esta regla no puede extenderse a la inexistencia.

4. ¿DISTINGUE EL CÓDIGO CIVIL CHILENO LA INEXISTENCIA Y LA NULIDAD ABSOLUTA?

Sobre esta pregunta existe un intenso debate doctrinal. Ambas doctrinas usan, en buena medida, los mismos argumentos en sentido inverso:

ARGUMENTO	SÍ DISTINGUE CLARO SOLAR	NO DISTINGUE ALESSANDRI
Redacción del Código	El art. 1444 dice que sin una cosa esencial el contrato <i>no produce efecto alguno</i> , sin llamarlo nulo; el art. 1681 declara nulo el acto al que falta un requisito <i>para el valor</i> , no para la existencia. Otras normas dicen que el acto <i>se mirará como no ejecutado</i> o que <i>no habrá venta</i>	El art. 10 declara que los actos prohibidos son <i>nulos y de ningún valor</i> : para el legislador, <i>nulidad, ningún valor y no producir efectos</i> significan lo mismo. Y el art. 1682 , al hablar de <i>algún requisito</i> , abarca tanto los de existencia como los de validez
Incapaces absolutos	Que sus actos tengan nulidad absoluta no refuta la tesis: como pueden aparentemente consentir, la ley debió declararlo expresamente	Sus actos carecen de voluntad y, aun así, el art. 1682 inc. 2° los declara nulos de nulidad absoluta: la nulidad absoluta comprende los actos inexistentes
Falta de objeto, causa o consentimiento	El art. 1682 no las menciona y las nulidades absolutas son de derecho estricto: sin la inexistencia, esos actos caerían en la nulidad relativa, lo que sería una aberración	El art. 1682 inc. 1° sí las comprende. Y el art. 1461 equipara el hecho físicamente imposible, la falta de objeto más radical, con el ilícito
Regulación de la sanción	El Código regula la nulidad como modo de extinguir las obligaciones; no podía referirse ahí a la inexistencia, porque el acto inexistente no engendra obligaciones	El Código no contempla la inexistencia como sanción ni reglamenta sus consecuencias; en cambio, reglamenta detalladamente la nulidad absoluta
Origen francés	El Mensaje dice que en materia de nulidad se siguió de cerca el Código francés, cuya doctrina y jurisprudencia acogen la inexistencia	El axioma <i>pas de nullité sans texte</i> , que dio origen a la teoría, no tiene acogida en Chile: los problemas que la motivaron se resuelven con la nulidad absoluta
Otras leyes	El antiguo art. 6° de la Ley N° 18.046 distinguía expresamente la sociedad que <i>no existe</i> de la nula; y la Ley N° 19.499, al reemplazarlo, creó una <i>nulidad de pleno derecho</i> que se asimila a la inexistencia y, lejos de desvanecerla, fortalece ese concepto	Ninguna ley de la República reconoce la inexistencia como sanción autónoma; el Código de Procedimiento Civil, al enumerar las excepciones del juicio ejecutivo, solo menciona <i>la nulidad de la obligación</i> (art. 464 N° 14 CPC)

En la jurisprudencia predomina la tesis que no distingue: la mayoría de los fallos de la Corte Suprema no reconoce la inexistencia como sanción autónoma (ver 4.4).

4.1. Doctrina que afirma que sí distingue

Los autores que ven la teoría de la inexistencia dentro del Código, con **CLARO SOLAR** entre ellos, dan cuatro argumentos:

(i) La letra de los arts. 1444 y 1681

Dos preceptos mostrarían claramente que el legislador distingue la inexistencia de la nulidad. El **art. 1444** dice que son de la esencia de un contrato "aquellas cosas sin las cuales o no produce efecto alguno, o degenera en otro contrato diferente": no declara *nulo* el contrato al que falta un requisito esencial. El otro es el art. 1681:

Art. 1681. "Es nulo todo acto o contrato a que falta alguno de los requisitos que la ley prescribe para el **valor** del mismo acto o contrato, según su especie y la calidad o estado de las partes. La nulidad puede ser absoluta o relativa."

La norma no dice que sea nulo el acto al que falta un requisito exigido para su *existencia*: se refiere a los requisitos prescritos para el *valor*, es decir, para la validez.

La distinción aparecería también en muchos otros artículos (**arts. 1701, 1801, 1802, 1809, 1814, 2027, 2055, 2057**, entre otros). El más claro es el art. 1701:

Art. 1701. "La falta de instrumento público no puede suplirse por otra prueba en los actos y contratos en que la ley requiere esa solemnidad; y se mirarán como no ejecutados o celebrados aun cuando en ellos se prometa reducirlos a instrumento público dentro de cierto plazo, bajo una cláusula penal: esta cláusula no tendrá efecto alguno. Fuera de los casos indicados en este artículo, el instrumento defectuoso por incompetencia del funcionario o por otra falta en la forma, valdrá como instrumento privado si estuviere firmado por las partes."

Cuando la ley exige instrumento público como solemnidad, el acto celebrado sin él no queda en tierra de nadie entre lo nulo y lo defectuoso: la ley lo trata derechamente **como si no se hubiera ejecutado**. Ni siquiera sirve haberse comprometido a reducirlo a escritura pública dentro de un plazo, con cláusula penal incluida para forzar el cumplimiento: esa cláusula tampoco vale nada, porque no hay forma de garantizar algo que, jurídicamente, nunca llegó a existir.

En todos estos casos la ley habla de la existencia del acto: dice que no llegó a perfeccionarse y no lo califica de nulo, porque lo que no existe no es válido ni nulo, sino **la nada**.

EJEMPLO**El precio que nadie fijó**

Valentina le vende a Matías su colección de vinilos de Los Prisioneros, y acuerdan que el precio lo fije Pancho, el amigo que sabe de discos. Pancho parte de mochilero al sur, nunca fija el precio, y Valentina y Matías no logran ponerse de acuerdo en otra persona. Para la tesis que distingue, esa compraventa no es nula: no existe, porque el **art. 1809** dice que, en ese caso, "no habrá venta".

(ii) Los actos de los absolutamente incapaces

La tesis contraria dice que, si el Código hubiera aceptado la inexistencia, habría sancionado con ella los actos de los absolutamente incapaces, y no con nulidad absoluta. Para esta doctrina, ese argumento se refuta sin dificultad. En palabras de **CLARO SOLAR**: "la incapacidad absoluta o natural de los dementes, los impúberes y los sordomudos que no pueden darse a entender por escrito, proviene de su falta de discernimiento e imposibilidad de tener y manifestar una voluntad consciente. En el hecho, estas clases de personas no consienten en el acto o contrato que ejecutan, no pueden dar a conocer su verdadera voluntad y podría decirse que falta en el acto o contrato el consentimiento y no puede perfeccionarse; pero como pueden aparentemente consentir, la ley expresamente declara que adolece de nulidad absoluta el acto o contrato de las personas absolutamente incapaces, y había dicho ya que sus actos no producen ni aun obligaciones naturales y no admiten caución (art. 1447)".

(iii) La falta de objeto, de causa o de consentimiento

El **art. 1682** no sanciona expresamente la falta de objeto, de causa ni de consentimiento. Como las nulidades absolutas son **de derecho estricto**, habría que concluir que esos actos quedan sancionados con la nulidad relativa, que es la regla general: una aberración. A esa conclusión no se llega si se admite la inexistencia.

Este argumento se rebate con el texto del mismo artículo: al sancionar con nulidad absoluta "la omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos en consideración a la naturaleza de ellos, y no a la calidad o estado de las personas que los ejecutan o acuerdan" (**art. 1682** inc. 1°), incluye la falta de objeto, de causa y de consentimiento.

(iv) La nulidad como modo de extinguir las obligaciones

Es cierto que el Código habla especialmente de la nulidad de los actos jurídicos al tratar de su declaración y de la rescisión como **modo de extinguir las obligaciones**. Pero eso no significa que los actos inexistentes queden comprendidos entre los nulos: como no producen obligaciones, no tiene sentido tratar de la extinción de obligaciones respecto de actos que no las generan. Es la ré-

plica de **CLARO SOLAR** al argumento de que el Código no contempla ni reglamenta la inexistencia.

En síntesis, aunque el legislador no formuló en términos explícitos la distinción entre requisitos de existencia y de validez, la hace de manera implícita: el **art. 1444** dice que la omisión de una cosa de la esencia impide que el contrato produzca efecto alguno, y eso se vincula con los requisitos de existencia, porque el acto al que falta un requisito de validez sí produce efectos.

Hay, además, un antecedente en la legislación de sociedades anónimas. El antiguo art. 6° de la Ley N° 18.046 disponía que "no existe la sociedad en cuya constitución se haya omitido el otorgamiento de la escritura social o la oportuna inscripción o publicación de su extracto", y sancionaba con la nulidad absoluta del pacto social las omisiones en la escritura de constitución o en el extracto: una distinción textual entre inexistencia y nulidad.

La Ley N° 19.499, de 1997, modificó esa disposición: eliminó la referencia a la inexistencia y estableció la nulidad absoluta como sanción general. Pero agregó el art. 6° A: "no obstante lo dispuesto en el Art. anterior, la S.A. que no conste de escritura pública, ni de instrumento reducido a escritura pública, ni de instrumento protocolizado, es nula de pleno derecho y no podrá ser saneada".

La **nulidad de pleno derecho** es una sanción que el Código Civil desconoce y que ni siquiera puede inferirse de sus normas, a diferencia de la inexistencia. Aquí la solemnidad es un elemento de la esencia específico de la sociedad anónima: si falta, la sociedad es nula de pleno derecho, lo que significa que, sin necesidad de una sentencia judicial, se mira como si nunca hubiera existido, y por eso no puede sanearse.

La nulidad del Código Civil, en cambio, jamás opera *ipso iure*: antes de su declaración el acto existe y produce sus efectos, y por eso puede sanearse. Estas diferencias permiten asimilar la nulidad de pleno derecho a la inexistencia. La conclusión es que la nulidad de pleno derecho **no desvanece el concepto de inexistencia, sino que lo fortalece**.

NO CONFUNDIR

¿Es lo mismo la nulidad de pleno derecho que la nulidad del Código Civil?

No. La **nulidad de pleno derecho** de la Ley N° 19.499 opera sin sentencia judicial: la sociedad se mira como si nunca hubiera existido y no puede sanearse. La **nulidad del Código Civil** nunca opera *ipso iure*: mientras no se declara, el acto produce sus efectos y puede sanearse. Criterio: si necesita o no una sentencia que la declare.

4.2. Doctrina que niega la distinción

Para esta tesis, que sostiene **ALESSANDRI**, el Código conoce solo dos sanciones, la nulidad absoluta y la relativa, y la máxima es la nulidad absoluta: lo que la doctrina contraria llama inexistencia es, en Chile, un caso de nulidad absoluta. Sus argumentos son siete:

(i) El axioma francés no rige en Chile

La teoría de la inexistencia surgió para resolver el problema que planteaba el axioma francés "no hay nulidad sin texto". Ese axioma no tiene acogida ni reconocimiento en el ordenamiento chileno, de modo que, en general, los problemas que dieron origen a la teoría, como el del matrimonio entre personas del mismo sexo, están debidamente sancionados con la nulidad absoluta.

(ii) El art. 1682 cubre la existencia y la validez

Art. 1682. "La nulidad producida por un objeto o causa ilícita, y la nulidad producida por la omisión de **algún requisito o formalidad** que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos en consideración a la naturaleza de ellos, y no a la calidad o estado de las personas que los ejecutan o acuerdan, son nulidades absolutas. Hay asimismo nulidad absoluta en los actos y contratos de personas absolutamente incapaces. Cualquiera otra especie de vicio produce nulidad relativa, y da derecho a la rescisión del acto o contrato."

Con la fórmula "algún requisito o formalidad", el Código engloba todos los requisitos que se exigen, tanto para la validez como para la existencia de los actos jurídicos.

(iii) Los actos de los absolutamente incapaces

El legislador declara absolutamente incapaces a "los dementes, los impúberes y los sordos o sordomudos que no pueden darse a entender claramente" (**art. 1447** inc. 1°). Con eso manifiesta que, en su concepto, esas personas están totalmente privadas de razón, de modo que en los actos que celebran no existe el requisito de la voluntad: serían actos inexistentes por falta de voluntad. Sin embargo, el **art. 1682** inc. 2° declara que hay nulidad absoluta en los actos y contratos de los absolutamente incapaces. Tan rotunda declaración demuestra que el legislador comprende los actos inexistentes dentro de la nulidad absoluta.

(iv) La falta de objeto se sanciona con nulidad absoluta

Aunque el **art. 1682** no señala la falta de objeto como causa de nulidad absoluta, y solo menciona el objeto ilícito, la sanción es la misma. El **art. 1461** equipara el hecho físicamente imposible con el moralmente imposible, es decir, el prohibido por las leyes o contrario a las buenas costumbres o al orden público. Y el hecho imposible no solo no existe, sino que no puede existir: es la falta de objeto más radical y absoluta, y aun así la ley lo trata igual que al hecho ilícito.

Otras normas sobre el objeto llevan a la misma conclusión. El **art. 1461** exige que la cosa objeto del acto sea comerciable; si es in comerciable, falta un requisito del objeto y, en rigor, "no hay objeto", lo que debería hacer inexistente el acto. Pero para la venta y la enajenación de cosas in comerciables

ciables, el Código declaró expresamente que hay **objeto ilícito** y, por lo tanto, nulidad absoluta (**arts. 1464 N° 1 y 1810**).

(v) El art. 10 usa esas expresiones como sinónimos

Las normas que cita la tesis contraria, que dicen que el acto "no produce efectos" u otras expresiones similares, olvidan que el **art. 10** señala que "los actos que prohíbe la ley son nulos y de ningún valor". Para el legislador, *nulidad*, *ningún valor*, *no producir efectos* y frases similares significan lo mismo, y siempre aluden a la nulidad, no a otra cosa.

(vi) El Código de Procedimiento Civil

Al enumerar taxativamente las excepciones que pueden oponerse en el juicio ejecutivo, el Código de Procedimiento Civil menciona "la nulidad de la obligación" (**art. 464 N° 14 CPC**) y no la inexistencia, lo que debe entenderse en el sentido de que la comprende.

(vii) Ninguna norma la reconoce como sanción autónoma

En el Código Civil no hay disposición alguna que considere la inexistencia como sanción autónoma, de modo que queda incluida en la nulidad absoluta, que el Código reglamenta detalladamente. De hecho, pese a la trascendencia que se le atribuye, ninguna ley de la República reconoce la inexistencia como una sanción de ineficacia.

PREGUNTA CLÁSICA

Discusión inexistencia: Luis Claro Solar y Arturo Alessandri

Depende de la tesis. Para **CLARO SOLAR**, el Código sí distingue: el acto al que falta un requisito de existencia no es nulo, es la nada (**arts. 1444, 1681 y 1701**). Para **ALESSANDRI**, no: la sanción máxima del Código es la nulidad absoluta, que cubre los requisitos de existencia y de validez, incluidos los actos de los absolutamente incapaces (**art. 1682**). La historia fidedigna del **art. 1683** y la mayoría de la jurisprudencia de la Corte Suprema se inclinan por la segunda.

4.3. Análisis desde la historia fidedigna del establecimiento del Código

Las dos posturas tienen argumentos bien fundados. Para una visión integral del problema hay que mirar la historia fidedigna del establecimiento del Código.

El Mensaje del Código señala que "sobre la nulidad y rescisión de los contratos y demás actos voluntarios que constituyen derechos, se ha seguido de cerca el código francés ilustrado por sus más hábiles expositores". En principio, eso daría pie para sostener que el Código acoge la inexistencia, porque la doctrina y la jurisprudencia francesas la aceptan de modo bastante uniforme. Pero las no-

tas de **BELLO** sobre la materia no remiten al *Code*: el único autor que citan es **DELVINCOURT**. El argumento, entonces, no es decisivo.

Lo que sí es indiscutible es que **BELLO** conocía perfectamente la teoría de la inexistencia y tenía un acabado conocimiento del *Code*. Por eso importa verificar si efectivamente siguió el modelo francés.

Paralelo entre el Código francés y el Código chileno en materia de nulidad:

CRITERIO	CÓDIGO FRANCÉS	CÓDIGO CIVIL CHILENO
Clases de nulidad en el Código	Una sola, la <i>anulabilidad</i> (art. 1304 del <i>Code</i>), por error, fuerza, dolo o lesión: equivale a nuestra nulidad relativa. Se sana por ratificación y por el tiempo, y solo pueden demandarla determinadas personas	Dos: la nulidad absoluta y la relativa
Sanción para los casos más graves	Sin texto expreso, la doctrina elaboró una sanción más radical: la inexistencia, también llamada nulidad radical, nulidad de pleno derecho o nulidad absoluta, términos sinónimos	La nulidad absoluta, establecida por la ley (art. 1682)
Casos que comprende	Los actos contrarios al orden público y a las buenas costumbres (art. 6 del <i>Code</i>), los de causa ilícita (art. 1131 del <i>Code</i>) y los de los absolutamente incapaces	Los mismos: lo contrario a la ley, a las buenas costumbres o al orden público, que da lugar a objeto ilícito (art. 1461) o a causa ilícita (art. 1467), y los actos de los absolutamente incapaces (art. 1682)
Efectos	Opera de pleno derecho, no admite saneamiento y su acción es imprescriptible	No se sana por la ratificación de las partes, pero sí por el transcurso de diez años (art. 1683)

BELLO, conocedor del *Code* y de sus comentaristas, se apartó de él en esta materia. La nulidad absoluta chilena coincide con la inexistencia de la doctrina francesa en sus causales, pero es diametralmente opuesta en sus efectos, porque el art. 1683 dispuso expresamente que se sana con el tiempo:

Art. 1683. "La nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el juez, aun sin petición de parte, cuando aparece de manifiesto en el acto o contrato; puede alegarse por todo el que tenga interés en ello, excepto el que ha ejecutado el acto o celebrado el contrato, sabiendo o debiendo saber el vicio que lo invalidaba; puede asimismo pedirse su declaración por el ministerio público en el interés de la moral o de la ley; y no puede sanearse por la ratificación de las partes, ni por un lapso de tiempo que no pase de **diez años**."

La historia fidedigna de esta disposición refrenda que, en nuestro ordenamiento, nulidad absoluta e inexistencia son lo mismo. La norma pasó por tres etapas:

- (i) Proyecto de 1842: siguiendo a la doctrina francesa, disponía que "La nulidad absoluta [...] no puede sanearse ni por el lapso del tiempo ni por la ratificación de las partes".
- (ii) Proyecto de 1853: mantuvo esa regla, pero agregó un inciso: "No podrá, sin embargo, alegarse [la nulidad absoluta] contra una posesión pacífica que haya durado treinta años".
- (iii) Proyecto Inédito: eliminó ese inciso y modificó el primero, que quedó así: "La nulidad absoluta [...] no puede sanearse por la ratificación de las partes, ni por un lapso de tiempo que no pase de treinta años". Esta fue la disposición que llegó al Código, y se mantiene hasta hoy, salvo la reducción del plazo de treinta a diez años dispuesta por la Ley N° 16.952, de 1968.

Es evidente, entonces, que el codificador se apartó conscientemente del modelo francés y estableció que la nulidad absoluta, que para la doctrina francesa es la inexistencia, no puede alegarse transcurrido un plazo: primero treinta años, después diez. En la doctrina nacional se ha discutido si el plazo del art. 1683 es de **saneamiento**, de **prescripción** o de **caducidad** de la acción, pero en la práctica es indiferente: en cualquier caso, ni la inexistencia ni la nulidad absoluta pueden alegarse pasados diez años. La conclusión de esta lectura es que en Chile **nulidad absoluta e inexistencia son la misma institución**, regida en todo por el **art. 1683**.

NO CONFUNDIR

¿La inexistencia es imprescriptible e insaneable en Chile?

Es un error trasladar sin más a Chile los caracteres que la doctrina francesa atribuye a la inexistencia. Según la lectura que se apoya en la historia fidedigna del art. 1683, el codificador se apartó conscientemente de ese modelo: en Chile, ni la inexistencia ni la nulidad absoluta pueden alegarse transcurridos diez años.

NO OLVIDAR**Plazo del art. 1683**

La nulidad absoluta no se sana por ratificación, pero sí por un lapso de **diez años** (treinta hasta la Ley N° 16.952, de 1968).

4.4. Jurisprudencia sobre la materia

El debate se ha planteado en un sinnúmero de casos, pero la jurisprudencia ha sido fluctuante. Los fallos más recientes, que pueden buscarse por su rol, son:

(i) Rechazan la teoría de la inexistencia

- a) Corte Suprema, 28 de noviembre de 2012, rol 4537-10. [FALTA: extracto del fallo]
- b) Corte Suprema, 31 de mayo de 2011, rol 271-2010. [FALTA: extracto del fallo]
- c) Corte de Santiago, 2 de mayo de 1997, rol 2153-1995. [FALTA: extracto del fallo]

(ii) Acogen la teoría de la inexistencia

- a) Corte de Santiago, 18 de noviembre de 2011, rol 5168-2010. [FALTA: extracto del fallo]
- b) Corte de Concepción, 11 de abril de 1995, rol 315-1994. [FALTA: extracto del fallo]

El apunte de **BOETSCH** cita, además, otros trece fallos más antiguos en ambos sentidos, entre 1914 y 1991, publicados en revistas (RDJ, Gaceta de los Tribunales, Gaceta Jurídica y Fallos del Mes) y sin rol.

En líneas generales, la mayoría de los fallos de la Corte Suprema **no reconoce la inexistencia como sanción autónoma**, con los caracteres que le atribuyen sus defensores: operar *ipso iure*, ser insaneable y dar lugar a una acción imprescriptible. Y cuando la reconoce, suele hacerlo en términos retóricos, aplicándole en definitiva las mismas reglas de la nulidad absoluta.

[FALTA: jurisprudencia reciente sobre la inexistencia, con rol; la busca Laura]

CONEXIONES

¿Distingue el Código Civil chileno la inexistencia y la nulidad absoluta?

Compraventa (**arts. 1801, 1802, 1809 y 1814**): normas que la tesis de la inexistencia cita como casos en que el acto no se perfecciona. Revisar apunte de Compraventa, [FALTA: sección] (p. ____).

Sociedades (Ley N° 18.046, art. 6° A): nulidad de pleno derecho de la sociedad anónima. Revisar apunte de [FALTA: materia y sección] (p. ____).

Derecho Procesal Civil (**art. 464 N° 14 CPC**): la nulidad de la obligación como excepción en el juicio ejecutivo. Revisar apunte de Procesal Civil, [FALTA: sección] (p. ____).

B. NULIDAD

B.1 ASPECTOS GENERALES

1. REGLAS DEL CÓDIGO CIVIL SOBRE LA NULIDAD

Las reglas generales sobre la nulidad de los actos y contratos están en el Título XX del Libro IV del Código Civil (**arts. 1681 a 1697**), sin perjuicio de otras disposiciones que la tratan en casos particulares. Estas reglas tienen tres rasgos:

- (i) Alcance general: rigen para cualquier acto jurídico, unilateral o bilateral, a menos que una disposición expresa consulte una sanción distinta de la nulidad.
- (ii) Orden público: son de aplicación estricta y las partes no pueden derogarlas.
- (iii) Derecho privado: se aplican también en las demás ramas del derecho privado si no hay una norma especial en contrario, pero no se extienden al derecho público, que tiene reglas propias y distintas en cada rama (la nulidad en el derecho administrativo no es la misma que en el derecho procesal).

2. CONCEPTO GENERAL DE NULIDAD

La doctrina suele definir la **nulidad** como "la sanción legal establecida por la omisión de los requisitos y formalidades que se prescriben para el valor de un acto según su especie y la calidad o estado de las partes".

Es la definición que se desprende del **art. 1681** inc. 1º, transcrito en A.4.1: "es nulo todo acto o contrato a que falta alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato, según su especie y la calidad o estado de las partes".

3. ESPECIES DE NULIDAD: ABSOLUTA Y RELATIVA

"La nulidad puede ser absoluta o relativa" (**art. 1681** inc. 2º):

Hay **nulidad absoluta** cuando el requisito omitido se exige en consideración a la *naturaleza o especie* del acto. Hay **nulidad relativa** cuando el requisito omitido se exige en atención a la *calidad o estado de las partes* que lo celebran.

El calificativo de cada una se explica por dónde está el vicio. En la absoluta, el acto está mal formado en sí mismo, con independencia de quién lo celebre: por eso su nulidad es **objetiva** y alcanza a todos, *erga omnes*. En la relativa, el acto no tiene nada de reprochable en su estructura; lo que falla es una exigencia pensada para proteger a cierta persona que intervino en él, y por eso su vicio es **subjetivo** y su nulidad solo opera respecto de esas personas.

Esta distinción no mide cuán grave es la ineficacia. La nulidad absoluta no es un grado más severo de invalidez, ni la relativa deja al acto apenas "medio nulo": declaradas judicialmente, las dos producen exactamente los mismos efectos, volver a las partes al estado anterior a la celebración del acto nulo (ver B.4). Donde sí hay diferencias es en las causales, en quién puede pedir cada una y en el plazo en que se sanan.

4. TERMINOLOGÍA

La doctrina reserva, por lo general, la palabra **nulidad** para la absoluta, y habla de **anulabilidad** o **rescisión** cuando se refiere a la relativa; de ahí que el título del Código se llame "de la nulidad y la rescisión" (**arts. 1681 a 1697**). El propio Código, sin embargo, no respeta esa división con rigor: llama "nulidad" indistintamente a cualquiera de las dos especies, y solo a veces usa alguna otra expresión que permite identificar de cuál se trata.

¿Son lo mismo "nulidad relativa" y "rescisión"? El **art. 1682** inc. final parece sugerirlo cuando dice que "cualquiera otra especie de vicio produce nulidad relativa, y da derecho a la rescisión del acto o contrato", pero un sector de la doctrina lo niega, por tres razones:

(i) La norma no las iguala

Lo que el artículo dice no es que ambos conceptos sean lo mismo, sino que uno da derecho al otro: la nulidad relativa da derecho a pedir la rescisión.

(ii) Rescindir es dejar sin efecto

"Rescindir", según el Diccionario de la Real Academia Española, significa "dejar sin efecto un contrato, una obligación, etc."; por eso, pedir la rescisión es simplemente pedir que el tribunal deje sin efecto el contrato. Ese efecto no es exclusivo de la nulidad relativa: según sus propias reglas, lo produce cualquiera de las dos nulidades. Cuando la ley habla de rescisión, entonces, no necesariamente apunta a la relativa, sino al derecho genérico a pedir que el acto quede sin efecto por el vicio que lo afecte, sea cual sea.

Esto explica, de paso, los casos en que el legislador usa la palabra rescisión para vicios de nulidad absoluta: no es un error del legislador, como cree la doctrina que confunde ambos términos, sino el mismo uso genérico recién descrito.

(iii) La sinonimia lleva a un absurdo

Basta reemplazar un término por el otro para verlo: el art. 1682 inc. final terminaría diciendo que "la nulidad relativa da derecho a pedir la nulidad relativa", una fórmula sin sentido.

De estas tres razones se sigue que la **rescisión no es un sinónimo de la nulidad relativa, sino su efecto**: el derecho a pedir que un acto o contrato quede sin efecto, cualquiera sea la causa, absoluta o relativa, que lo invalide.

5. ESPECIE DE NULIDAD QUE CONSTITUYE LA REGLA GENERAL

El **art. 1682** inc. final cierra la enumeración de las causales de nulidad absoluta con una cláusula residual: "cualquiera otra especie de vicio produce nulidad relativa". Por construcción, entonces, la regla general no es la absoluta sino la **relativa**: todo vicio que la ley no sancione expresamente de otro modo cae ahí.

6. DIFERENCIAS ENTRE LA NULIDAD ABSOLUTA Y LA RELATIVA

Comparando los **arts. 1683 y 1684** aparecen, lado a lado, estas diferencias:

CRITERIO	NULIDAD ABSOLUTA	NULIDAD RELATIVA
Fundamento	El interés de la moral y de la ley	El interés de ciertas y determinadas personas
Declaración de oficio	Puede y debe declararla el juez, aun sin petición de parte, cuando aparece de manifiesto en el acto o contrato	Solo a petición de parte interesada
Quiénes pueden pedirla	Todo el que tenga interés en ello, y el ministerio público en el interés de la moral o de la ley	Solo aquellos en cuyo beneficio la han establecido las leyes, o sus herederos o cesionarios; no el ministerio público en el solo interés de la ley
Saneamiento por el tiempo	Diez años desde la celebración del acto o contrato	Cuatro años, contados desde la celebración en caso de error o dolo, y desde que cesa la fuerza o termina la incapacidad en esos casos
Saneamiento por ratificación	No puede sanearse por la ratificación de las partes	Puede sanearse por la confirmación o ratificación del acto rescindible, que emana de la persona en cuyo beneficio la ley establece la nulidad, o de sus herederos o cesionarios

En cambio, en cuanto a sus **efectos** no hay diferencia: una vez declaradas, ambas vuelven a las partes al estado anterior al acto (ver B.4).

7. PRINCIPIOS APLICABLES A AMBAS CLASES DE NULIDAD

Sea absoluta o relativa, la nulidad se rige por seis principios comunes:

(i) Es de derecho estricto

La nulidad es una sanción, y las sanciones no se presumen ni se aplican por analogía: solo son nulos los actos que la ley, de alguna de estas dos formas, declara nulos. Primera forma, cuando la ley dice expresamente que un acto determinado es nulo. Segunda forma, cuando la ley prohíbe un acto y no fija ninguna sanción distinta de la nulidad para quien lo contraviene (**art. 10**). Fuera de esos dos casos, no hay nulidad que valga.

(ii) No puede renunciarse anticipadamente

Si la nulidad pudiera renunciarse por anticipado, bastaría una cláusula para vaciar de contenido la protección que busca dar a los intereses de la colectividad. Por eso el **art. 1469** lo impide: "los actos o contratos que la ley declara inválidos, no dejarán de serlo por las cláusulas que en ellos se in-

troduzcan y en que se renuncie la acción de nulidad". Ni las partes, actuando de común acuerdo, pueden validar por su sola voluntad un acto que la ley declaró nulo.

(iii) El vicio debe existir al celebrarse el acto

El vicio tiene que estar presente al momento mismo en que el acto se celebra o se realiza; uno que surge después no cuenta. Es el principio de que **no hay nulidad por causa sobreviniente**: si el acto nació válido, ningún hecho posterior puede volverlo nulo.

(iv) Solo aprovecha a quien la obtiene

Si varias personas contrataron con un mismo tercero, que el juez declare nula la relación de una de ellas no beneficia automáticamente a las demás (**art. 1690**): cada cual debe obtener su propia declaración.

(v) Se hace valer como acción o como excepción

En juicio, la nulidad puede invocarse de dos maneras: como demanda, o como defensa frente a la demanda de otro.

(vi) Requiere sentencia judicial

Ninguna nulidad, absoluta o relativa, opera por sí sola: necesita una sentencia judicial firme, con autoridad de cosa juzgada, que la declare. Hasta que eso ocurra, el acto sigue produciendo todos sus efectos, amparado en una **presunción de validez**; recién con la sentencia que acoge la acción o la excepción de nulidad deducida en el juicio, la declaración opera **hacia atrás** y borra los efectos que el acto ya había producido.

No toda la doctrina acepta esta exigencia tratándose de la nulidad absoluta. Para quienes discrepan, su gravedad (piénsese en un acto contrario a la ley o al orden público) hace que opere **de pleno derecho**, sin que haga falta ningún pronunciamiento judicial; y si eso es así, lo que el **art. 1683** llama "saneamiento" por el paso de diez años no sería tal, sino más bien la caducidad de la acción para impugnar el acto.

8. NULIDAD TOTAL Y NULIDAD PARCIAL DEL ACTO JURÍDICO

Según a cuánto del acto alcance el vicio, la nulidad es:

(i) **Total**: cuando el vicio afecta todas las partes y cláusulas del acto jurídico.

(ii) **Parcial**: cuando afecta solo una parte o una cláusula del acto, o una parte o un elemento de una cláusula, y el resto subsiste con plena validez.

No toda cláusula viciada contagia al resto: hay disposiciones o cláusulas cuya nulidad deja intacta la validez de las demás, y el acto subsiste con ellas. Determinar hasta dónde llega la nulidad es, en cada caso, un ejercicio de ponderación: hay que preguntarse si lo viciado toca la **esencia** del acto,

o si es apenas un **accidente** tan secundario que, aun sabiendo que era nulo, las partes de todos modos lo habrían celebrado.

El propio Código ofrece varios ejemplos de esta ponderación ya resuelta. En materia de testamentos, el **art. 1061** declara que "no vale disposición alguna testamentaria en favor del escribano que autorizare el testamento": esa asignación puntual al notario no tiene nada que ver con lo esencial de un testamento, que es nombrar herederos, así que su nulidad no arrastra al resto. Algo parecido ocurre con el error: el **art. 1057** ("el error en el nombre o calidad del asignatario no vicia la disposición, si no hubiere duda acerca de la persona") y el **art. 1058** ("la asignación que pareciere motivada por un error de hecho, de manera que sea claro que sin este error no hubiera tenido lugar, se tendrá por no escrita") limitan el vicio a la cláusula errada, dejando válido el resto del testamento.

EJEMPLO

La colección de Condorito del notario

En su testamento, la tía Valeria deja su departamento en Ñuñoa a sus sobrinos y, en otra cláusula, su colección de Condorito autografiada al notario que autoriza el testamento. La cláusula del notario no vale (**art. 1061**), pero los sobrinos heredan igual el departamento: la nulidad es parcial.

CONEXIONES

Nulidad total y nulidad parcial del acto jurídico

Derecho Sucesorio (**arts. 1057, 1058 y 1061**): error en las asignaciones testamentarias e incapacidad del escribano para recibir por testamento. Revisar apunte de Sucesorio, [FALTA: sección] (p. ____).

9. NULIDAD CONSECUCIONAL Y NULIDAD REFLEJA

Fuera de los casos en que la ley acoge expresamente la nulidad parcial, surge la pregunta: ¿se contagia todo el acto con la nulidad de lo que contraviene la ley, o puede considerarse válido una vez "podado" de la parte ilegal? El criterio es que si la cláusula nula contiene la **estipulación principal** del acto, o si el acto no puede subsistir sin ella, su nulidad acarrea la de todo el acto. Por eso se habla de **nulidad consecucional o de resultado**: un acto es nulo consecucionalmente cuando depende de otro que es nulo.

Lo mismo ocurre con los **actos accesorios**, en aplicación del principio de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal: la nulidad del acto principal acarrea la del accesorio, pero no a la inversa. Así, según el **art. 1536**, "la nulidad de la obligación principal acarrea la de la cláusula penal, pero

la nulidad de ésta no acarrea la de la obligación principal"; e igual ocurre en la fianza, que se extingue "por la extinción de la obligación principal en todo o parte" (**art. 2381 N° 3**).

La **nulidad refleja**, por su parte, se produce en los **actos solemnes**, en que la ley manda cumplir una forma como único medio idóneo de expresar la voluntad, normalmente el otorgamiento de escritura pública. Nunca debe confundirse la *forma* con el *contenido*: la forma es la escritura; el contenido, el acto del cual ella da cuenta. Como la escritura, en cuanto instrumento, está sujeta a su vez a requisitos de validez, puede ocurrir que se omita alguno: la escritura es nula y, por consecuencia, también lo es el acto contenido en ella. Por estar viciada la forma del acto solemne, el acto mismo pasa a ser nulo.

Distinto es el caso, frecuente, en que un mismo instrumento contiene varios actos independientes entre sí: la nulidad de uno no afecta a los demás, y esa independencia no se altera por constar todos en el mismo documento. *Así, si en una misma escritura Diego le vende su auto a Sebastián y, además, le presta plata para la bencina del primer viaje al sur, la nulidad de la compraventa no arrastra al préstamo.*

NO CONFUNDIR

¿Arrastra la nulidad de la escritura a todo lo que contiene?

Depende de qué esté viciado. En la **nulidad refleja**, el vicio está en la forma de un acto solemne: la escritura nula arrastra al acto que ella misma constituye. Cuando una escritura contiene **varios actos independientes** y uno de ellos es nulo, los demás siguen valiendo. Criterio: si la escritura es la forma exigida para el acto, o solo el documento donde constan actos distintos.

CONEXIONES

Nulidad consecuencial y nulidad refleja

Obligaciones (art. 1536): la cláusula penal sigue la suerte de la obligación principal. Revisar apunte de Obligaciones, [FALTA: sección] (p. ____).

Contratos (art. 2381 N° 3): la fianza se extingue con la obligación principal. Revisar apunte de Contratos, [FALTA: sección] (p. ____).

B.2 LA NULIDAD ABSOLUTA

1. CONCEPTO

El **art. 1681** permite extraer, para la **nulidad absoluta**, una fórmula más precisa que la definición general de B.1.2: es la sanción a todo acto o contrato al que falte alguno de los requisitos que la ley exige para su valor, *según la especie* del acto o contrato.

2. CAUSALES

Según el **art. 1682** (transcrito en A.4.2), las causales de nulidad absoluta son cuatro:

- (i) El **objeto ilícito**.
- (ii) La **causa ilícita**.
- (iii) La **incapacidad absoluta**.
- (iv) La omisión de requisitos o formalidades que las leyes prescriben para el *valor* de ciertos actos o contratos, en consideración a la naturaleza de ellos.

Quienes rechazan la tesis de la inexistencia (A.4.2) agregan, además, estas cinco causales:

- (v) La falta de **voluntad**.
- (vi) La falta de **objeto**.
- (vii) La falta de **causa**.
- (viii) El **error esencial**, sin perjuicio de que algunos lo sancionen con nulidad relativa.
- (ix) La omisión de requisitos o formalidades que las leyes prescriben para la *existencia* de ciertos actos o contratos, en consideración a la naturaleza de ellos.

3. FUNDAMENTO Y CARACTERES DE LA NULIDAD ABSOLUTA

La nulidad absoluta no protege a nadie en particular: su fundamento está en el **interés de la moral y de la ley**, y busca precisamente eso, amparar la primera y hacer respetar la segunda. De ahí nacen sus características propias (quién puede declararla, quién puede pedirla, cómo se sana por ratificación de las partes y por el transcurso del tiempo), que se examinan en los puntos siguientes.

4. DECLARACIÓN DE NULIDAD ABSOLUTA

El **art. 1683** (transcrito en A.4.3) contempla tres caminos para que se declare la nulidad absoluta:

(i) De oficio por el juez

La nulidad absoluta "puede y debe ser declarada por el juez, aun sin petición de parte, cuando *aparece de manifiesto en el acto o contrato*". El Diccionario de la Lengua reserva la palabra *manifiesto* para lo que no exige más prueba que leer el propio instrumento donde consta el acto o contrato, sin acudir a ningún otro antecedente del proceso: solo así puede darse el vicio por establecido. Y, naturalmente, esa obligación del juez supone que exista un juicio donde se invoque ese acto o contrato.

(ii) A petición de todo el que tenga interés

La nulidad absoluta "puede alegarse por todo el que tenga interés en ello, excepto el que ha ejecutado el acto o celebrado el contrato, sabiendo o debiendo saber el vicio que lo invalidaba". Que la ley use la fórmula "todo el que tenga interés" no es casual: habilita tanto a las partes como a **terceros** para pedirla. Tiene sentido, porque el vicio radica en el acto mismo, sin mirar a quiénes lo celebraron, así que cualquier interesado puede alegarla, sea o no parte.

Esa habilitación exige, eso sí, acreditar un **interés** real: la posibilidad de reparar los perjuicios que causó el acto viciado, prueba que corresponde a quien la invoca. Y ese interés tiene que ser de **carácter pecuniario**; el interés puramente moral queda reservado para la intervención del ministerio público, que se examina más abajo.

Hay, sin embargo, una excepción: queda fuera quien ejecutó el acto o celebró el contrato **sabiendo o debiendo saber** el vicio. "Sabiendo" apunta a un conocimiento personal, real y efectivo. "Debiendo saber" no es el conocimiento presunto de la ley: es el que la propia situación le exigía tener a quien actuó, porque ni las circunstancias del acto ni la condición de los intervinientes permitían razonablemente ignorar el vicio; la jurisprudencia lo trata como una obligación de conocer deducible de otros preceptos legales o de los hechos mismos.

Ese conocimiento debe ser real y efectivo, nunca el presunto o ficto del **art. 8º**. La Corte de Pedro Aguirre Cerda lo dejó así establecido en enero de 1988: "En el artículo 1683 del Código Civil no se trata de la presunción de conocimiento de la ley establecida en el artículo 8º del mismo Código. Por el contrario, se trata del conocimiento material, real y efectivo del vicio que afecta al acto o contrato. Esto es tan evidente que, de no ser así, nunca podrían los que ejecutan o celebran un acto o contrato alegar por su parte la nulidad absoluta, ya que siempre la ley los consideraría como sabedores del vicio que contaminaría al negocio jurídico" (Repertorio, Tomo VI, pág. 234). La ley admite aquí, entonces, el error de derecho: no para relevar del cumplimiento de las normas, sino para restablecer su imperio declarando la nulidad.

El **art. 1468** recoge la misma lógica: "no podrá repetirse lo que se haya dado o pagado por un objeto o causa ilícita a sabiendas". La expresión "a sabiendas" exige, otra vez, conocimiento real y

efectivo de la ilicitud, no el presunto que da la ley.

La razón de fondo es que nadie puede sacar provecho de su propia mala fe: es el principio *nemo auditur propriam suam turpitudinem allegans*, "nadie puede ser oído cuando alega su propia torpeza".

JURISPRUDENCIA

CORTE SUPREMA, 29 DE ABRIL DE 2008, ROL N° 1.969-2006

"A nadie le es lícito hacer valer un derecho civil o procesal en contradicción con su anterior conducta jurídica [...]. Esta doctrina, conocida como 'de los actos propios', ha sido recogida en diversas disposiciones de nuestro Código Civil, como los artículos 1683, 1481, 1546 y, en forma de expresión conocida como buena fe, informa en carácter de principio general todo el referido cuerpo de leyes. Ella permite al sentenciador ponderar la actitud lógica del actor o de su contraparte, que puede incidir en la acción misma o en un simple incidente [...]. Así, se impide jurídicamente el que una persona afirme o niegue la existencia de un hecho determinado, en virtud de haber antes ejecutado un acto, hecho una afirmación o formulado una negativa en el sentido precisamente opuesto, pues de acuerdo a este principio, nadie puede contradecir lo dicho o hecho por él mismo, con perjuicio de un tercero."

Esta excepción abre dos preguntas que doctrina y jurisprudencia no resuelven igual: ¿alcanza al **representado** cuando fue el representante quien sabía o debía saber el vicio, sin que el representado lo supiera ni debiera saberlo? ¿Y alcanza a los **herederos** de quien celebró el acto a sabiendas? Sobre la primera pregunta, los tribunales se han pronunciado en ambos sentidos. Así argumenta cada postura:

PREGUNTA	PUEDE ALEGAR LA NULIDAD	NO PUEDE ALEGARLA
¿El representado?	El dolo es una determinación personalísima de la voluntad, y el representante solo está autorizado para ejecutar actos lícitos, no ilícitos	Según la ley, lo hecho por el representante se estima hecho por el representado (art. 1448)
¿Los herederos?	La prohibición es una verdadera inhabilidad y, como regla de excepción, debe interpretarse restrictivamente: si la letra de la ley no comprende a los herederos, no puede extenderse a ellos	No han podido adquirir por sucesión un derecho que su causante no tenía, y que la ley expresamente le vedaba. Además, si cuando el dolo es imputable a un incapaz la ley no permite alegar la nulidad ni a él ni a sus herederos (art. 1685), con mayor razón la prohibición debe comprender a los herederos y cesionarios de las personas capaces

En la pregunta del representado se impone hoy la primera columna: la prohibición alcanza a quien intervino directamente en el acto o contrato, no a quien actuó representado convencional o legalmente, salvo que se acredite de modo inequívoco que su propia voluntad concurrió en el vicio.

(iii) Por el ministerio público

También puede pedirla el ministerio público: el art. 1683 dice que "puede asimismo pedirse su declaración por el ministerio público en el interés de la moral o de la ley". Se trata del organismo auxiliar de la administración de justicia que regula el **art. 350 COT**, integrado por el fiscal de la Corte Suprema y los fiscales de las Cortes de Apelaciones, y no del organismo del mismo nombre que participa en el proceso penal.

5. LA NULIDAD ABSOLUTA NO PUEDE SANEARSE POR LA RATIFICACIÓN DE LAS PARTES

El propio **art. 1683**, en su parte final, lo descarta expresamente. Ratificar supone validar lo que no es válido, es decir, renunciar a pedir que se declare la nulidad del acto viciado; y esa renuncia es precisamente lo que la nulidad absoluta no tolera, porque protege el **interés general**, no uno disponible por la sola voluntad de las partes.

6. SANEAMIENTO DE LA NULIDAD ABSOLUTA POR EL TRANCURSO DEL TIEMPO

El **art. 1683** fija un tope de **diez años** para alegar la nulidad absoluta, lectura que comparte la doctrina mayoritaria: superado ese plazo, la acción o la excepción de nulidad ya no proceden, porque en algún momento hay que consolidar los derechos adquiridos.

El cómputo parte el día de la celebración del acto nulo, momento desde el cual ya era posible ejercer la acción. Es el mismo criterio que, para la prescripción extintiva, cuenta el plazo desde que la obligación se vuelve exigible (**art. 2514** inc. final).

Hay quienes dudan de que el art. 1683, pese a sus propias palabras, consagre un verdadero "saneamiento": dogmáticamente, el simple paso del tiempo no puede convertir en válido lo que nunca lo fue. En ese sentido, **BARAONA** sostiene que se trata de una **caducidad** de derechos respecto de quienes podían impugnar el acto: el juez, las partes, los terceros interesados y el ministerio público. Su efecto es consolidar los desplazamientos patrimoniales: al no ser impugnado durante diez años, el acto pasa de título injusto a título justo, y permite que opere la prescripción adquisitiva. Por eso el **art. 705** habla de la validación del título "por otro medio legal", que en este caso es el transcurso del tiempo del **art. 1683**.

CONEXIONES

Saneamiento de la nulidad absoluta por el transcurso del tiempo

Bienes (art. 705): validación del título que en su principio fue nulo, justo título y prescripción adquisitiva. Revisar apunte de Bienes, V.5.A.2 Clases de posesión (p. ____).

7. LA NULIDAD ABSOLUTA NO SE PRODUCE DE PLENO DERECHO

Para la doctrina tradicional, la nulidad absoluta no opera de pleno derecho: necesita ser declarada por el juez. Lo deduce de varias normas que hablan de la nulidad judicialmente *declarada* o *pronunciada* (**arts. 1683, 1687 y 1689 del Código Civil** y **art. 37 de la Ley de Matrimonio Civil**). Mientras esa sentencia no exista, el acto nulo absolutamente sigue produciendo todos sus efectos.

Otros autores, entre ellos **BARAONA**, afirman que la sentencia cumple otra función: si declara absolutamente nulo un acto, hace actuales tanto el derecho a exigir la restitución como el deber de practicarla.

B.3 LA NULIDAD RELATIVA

1. DEFINICIÓN Y FUNDAMENTO

Según el **art. 1681**, la **nulidad relativa** es la sanción legal que recae sobre los actos a los que falta un requisito exigido en consideración a la *calidad o estado de las partes*.

A diferencia de la absoluta, no mira al interés general: busca amparar a **personas determinadas**, y es precisamente en beneficio de ellas que el legislador la estableció.

2. CAUSALES

Después de enumerar los casos de nulidad absoluta, el Código dice: "cualquiera otra especie de vicio produce nulidad relativa, y da derecho a la rescisión del acto o contrato" (**art. 1682**). Aquí, **rescisión equivale a anulación** (sobre el debate terminológico, ver B.1.4). Hay nulidad relativa en los siguientes casos:

- (i) Los actos de los **relativamente incapaces**.
- (ii) El **error sustancial**.
- (iii) El **error en la calidad accidental**, cuando esa calidad haya sido el principal motivo de una parte para contratar y ese motivo haya sido conocido por la otra.
- (iv) El **error en la persona**, en los casos en que es relevante.
- (v) La **fuerza** grave, injusta y determinante.
- (vi) El **dolo** determinante, que en los actos bilaterales debe ser además obra de una de las partes.
- (vii) La omisión de **formalidades** exigidas en consideración al estado o calidad de las personas que celebran o ejecutan el acto.
- (viii) La **lesión**, en los casos previstos por la ley en que la sanción es la rescisión.

3. CARACTERÍSTICAS

Estas tres características se desprenden, todas, de un mismo origen: que la nulidad relativa protege a personas determinadas, no a la colectividad.

- (i) Solo pueden alegarla aquellos en cuyo beneficio la han establecido las leyes.
- (ii) Puede sanearse por el transcurso del tiempo.

- (iii) Puede sanearse por la ratificación de las partes.

4. PERSONAS LEGITIMADAS PARA ALEGAR LA NULIDAD RELATIVA

4.1. Regla general

Art. 1684. "La nulidad relativa no puede ser declarada por el juez sino a pedimento de parte; ni puede pedirse su declaración por el ministerio público en el solo interés de la ley; ni puede alegarse sino por aquellos en cuyo beneficio la han establecido las leyes o por sus herederos o cesionarios; y puede sanearse por el lapso de tiempo o por la ratificación de las partes."

De ahí se sigue que pueden alegarla:

(i) El beneficiado

La regla general beneficia solo a quien sufrió el vicio: si hubo error, fuerza o dolo en un contrato, la rescisión solo puede pedirla la parte afectada, nunca la otra; y si quien contrató fue un incapaz, el derecho a pedir la nulidad es suyo, no de la contraparte.

(ii) Sus herederos

Ese derecho no se extingue con la muerte del titular: si quien podía pedir la rescisión falleció sin hacerlo, sus herederos pueden alegarla en su lugar, porque le suceden en todos sus derechos y obligaciones transmisibles, entre ellos, precisamente, el de pedir la rescisión.

(iii) Sus cesionarios

También puede transferirse en vida: cuando el beneficiado con la nulidad relativa cede, por acto entre vivos, los derechos que emanan del acto o contrato nulo, el cesionario recibe junto con ellos el derecho a demandar la rescisión.

4.2. Situación excepcional del incapaz que no podría demandar la rescisión

Hay, sin embargo, un caso en que la ley le cierra esa puerta al incapaz relativo: lo regula el **art. 1685**.

Art. 1685. "Si de parte del incapaz ha habido dolo para inducir al acto o contrato, ni él ni sus herederos o cesionarios podrán alegar nulidad. Sin embargo, la aserción de mayor edad, o de no existir la interdicción u otra causa de incapacidad, no inhabilitará al incapaz para obtener el pronunciamiento de nulidad."

La norma distingue dos situaciones:

(i) La simple aserción

Que el incapaz, para celebrar el contrato, se haya limitado a decir que era mayor de edad o que no estaba interdicto no le cierra la puerta a la nulidad: pese a ese engaño, puede pedirla más tarde. La razón está del otro lado: fue el otro contratante quien actuó con negligencia, al conformarse con la sola palabra del incapaz sin cerciorarse de su verdadero estado.

(ii) El dolo

Distinto es si el incapaz empleó dolo para inducir el acto o contrato: ahí ni él ni sus herederos o cesionarios pueden alegar la nulidad, porque ya no hay negligencia que reprochar al otro contratante, que no está obligado a presumir la mala fe ajena.

EJEMPLO

La guitarra eléctrica

Matías, de 16 años, quiere comprarle a Pancho su guitarra eléctrica. Si solo le dice "tengo 18", después igual podrá pedir la nulidad: Pancho debió cerciorarse (**art. 1685**, segunda parte). Si en cambio le muestra una cédula adulterada, ni Matías ni sus herederos podrán alegarla (**art. 1685**, primera parte).

5. LA NULIDAD RELATIVA PUEDE SANEARSE POR EL TRANCURSO DEL TIEMPO

Así lo dice expresamente el **art. 1684**. El plazo y su cómputo están en el **art. 1691**:

Art. 1691. "El plazo para pedir la rescisión durará **cuatro años**. Este cuadrienio se contará, en el caso de violencia, desde el día en que ésta hubiere cesado; en el caso de error o de dolo, desde el día de la celebración del acto o contrato. Cuando la nulidad proviene de una incapacidad legal, se contará el cuadrienio desde el día en que haya cesado esta incapacidad. Todo lo cual se entiende en los casos en que leyes especiales no hubieren designado otro plazo."

Transcurridos los cuatro años sin que la persona legitimada alegue la nulidad, el vicio se extingue y el acto queda sano, como si nunca hubiera adolecido de un defecto.

¿Qué pasa si fallece quien podía demandar la rescisión? El **art. 1692** distingue según la edad de los herederos: si son **mayores de edad**, el plazo no se suspende y gozan del cuadrienio entero si no había empezado a correr, o de lo que reste en caso contrario; si son **menores**, el cuadrienio o su residuo empieza a correr solo desde que llegan a la mayoría de edad, con un tope de diez años desde la celebración del acto o contrato, pasados los cuales ya no puede pedirse la nulidad. El tema se retoma al estudiar la acción de nulidad (B.4).

NO OLVIDAR

Plazos para alegar la nulidad

Absoluta: diez años desde la celebración (**art. 1683**). **Relativa:** cuatro años, desde la celebración si hubo error o dolo, y desde que cesa la fuerza o la incapacidad (**art. 1691**). **Herederos menores:** desde su mayoría de edad, con tope de diez años desde la celebración (**art. 1692**).

6. LA NULIDAD RELATIVA PUEDE SANEARSE POR LA RATIFICACIÓN O CONFIRMACIÓN DE LAS PARTES

6.1. Concepto

La palabra **ratificación** no siempre significa lo mismo en derecho: tiene dos acepciones distintas.

- (i) Ratificación de lo hecho por otro: una persona hace suyo, por su propia cuenta, lo que otra ejecutó a su nombre sin tener poder para hacerlo.
- (ii) Confirmación del acto nulo: la que interesa en este punto, que equivale a confirmar el acto que es nulo relativamente.

Confirmar un acto nulo relativamente es que quien tiene derecho a pedir su nulidad declare su voluntad de no ejercer ese derecho: con esa sola declaración, el vicio que afectaba al acto desaparece.

En el fondo, confirmar no es más que **renunciar al derecho a pedir la nulidad**: no vuelve a celebrarse el acto viciado, solo deja de poder atacarse. El propio Código usa la palabra "ratificación" para esto (**arts. 1683, 1684 y 1693** y siguientes), uso que la doctrina critica: para ella, "ratificación" debe reservarse para el acto por el cual alguien aprueba lo que otro hizo en su nombre sin estar facultado, como en el **art. 2160** a propósito del mandato, y prefiere hablar de "confirmación" cuando lo que se sana es la nulidad.

¿Por qué puede confirmarse un acto nulo relativamente? Porque la nulidad relativa protege solo a personas determinadas: es un derecho que mira a su interés particular, y por eso cae dentro de la regla general que permite renunciar a los derechos que solo interesan a quien renuncia, mientras esa renuncia no esté prohibida (**art. 12**). Al ser así, la confirmación es un acto unilateral: basta la voluntad de quien está legitimado para pedir la nulidad, y por eso mismo solo cabe cuando la nulidad es relativa.

NO CONFUNDIR

¿Ratificar es lo mismo que confirmar?

No siempre. **Confirmar** es sanear un acto nulo relativamente renunciando a pedir su nulidad. **Ratificar**, en sentido estricto, es hacer propio lo que otro ejecutó a nuestro nombre sin poder, como el mandante que ratifica lo obrado por el mandatario (**art. 2160**). El Código usa "ratificación" para ambos. **Criterio**: si se sana un vicio del acto o se asume un acto ajeno.

6.2. Clases

"La ratificación necesaria para sanear la nulidad cuando el vicio del contrato es susceptible de este remedio, puede ser expresa o tácita" (**art. 1693**):

(i) **Ratificación expresa**

Hay ratificación expresa cuando quien tiene derecho a pedir la rescisión lo dice sin rodeos: declara, en términos explícitos y directos, que quiere validar el acto, y con eso el vicio que lo afectaba desaparece.

(ii) **Ratificación tácita**

"La ratificación tácita es la ejecución voluntaria de la obligación contratada" (**art. 1695**). La ejecución voluntaria, sin embargo, deja abiertas tres preguntas:

- a) ¿Qué es ejecución voluntaria?: hay quienes creen que basta con que se ejecute libre y espontáneamente, sin vicios en la voluntad. Otros exigen más: que el confirmante conozca el motivo de anulabilidad, no solo que actúe sin vicios. Esta segunda lectura convence más, porque actuar voluntariamente supone conocer la realidad tal como es, y aquí esa realidad incluye el vicio de nulidad relativa.
- b) ¿Basta otro comportamiento?: la mayoría de la doctrina responde que no, que solo la ejecución voluntaria de la obligación cuenta como confirmación tácita; pedir, por ejemplo, un plazo para pagar lo que se debe por el acto rescindible no equivale a confirmarlo.
- c) ¿Es necesario ejecutar el acto entero?: el Código no lo exige, de modo que aunque queden obligaciones pendientes, la ratificación tácita ya se produjo.

6.3. Características de la ratificación

- (i) Unilateral: basta con la voluntad de quien confirma, nadie más interviene.
- (ii) Accesoria y dependiente: depende por completo del acto o contrato que convalida: sin él, no tiene dónde sostenerse.
- (iii) Irrevocable: una vez confirmado el acto, quien lo hizo no puede volver atrás y pedir después la rescisión de lo que ya convalidó.
- (iv) Retroactiva: la ley finge que el acto confirmado fue válido desde siempre, como si el vicio de nulidad relativa nunca hubiera existido.

Esto tiene sentido porque el acto solo es nulo una vez que el juez lo declara: antes de esa declaración ya existe una situación de hecho, y es esa situación la que la confirmación deja **firme**, cerrando la puerta a que el acto pueda verse afectado más adelante.

6.4. Requisitos de la ratificación

- (i) Opera únicamente frente a un vicio sancionado con **nulidad relativa**, nunca frente a uno de nulidad absoluta.
- (ii) Solo la puede otorgar válidamente quien tiene derecho a alegar la nulidad, sea en forma expresa o tácita: "ni la ratificación expresa ni la tácita serán válidas, si no emanan de la parte o partes que tienen derecho de alegar la nulidad" (**art. 1696**).
- (iii) Exige **capacidad de contratar** en quien ratifica: "no vale la ratificación expresa o tácita del que no es capaz de contratar" (**art. 1697**), salvo que actúe debidamente representado o autorizado.
- (iv) Tiene un límite **temporal**: solo cabe antes de que se declare la nulidad, nunca después.
- (v) Supone que **la causa de invalidez ya haya cesado**: si la confirmación estuviera afectada por el mismo vicio que hace rescindible el acto, no sería eficaz; además, exige conocer el vicio y el de-

recho a pedir la nulidad, y querer efectivamente confirmar.

(vi) Si la confirmación es expresa, debe respetar la misma **solemnidad** que la ley exige para el acto que se confirma: "deberá hacerse con las solemnidades a que por la ley está sujeto el acto o contrato que se ratifica" (**art. 1694**). Esa exigencia solo rige para la vía expresa; nada impide que un acto solemne se confirme en forma tácita.

B.4 LOS EFECTOS DE LA NULIDAD

1. CONCEPTOS GENERALES

Entre la nulidad absoluta y la relativa hay varias diferencias: quién puede pedir las, si el juez puede declararlas de oficio, cómo se sanean. Pero en sus **efectos** son exactamente iguales, y las mismas normas (**arts. 1687 y 1689**) rigen para ambas sin distinción. Esos efectos, además, dependen siempre de una **sentencia judicial firme**: mientras no exista, el acto sigue produciendo todos sus efectos normales, aunque corra el riesgo de que lo invaliden.

2. EFECTOS DE LA NULIDAD RESPECTO DE LAS PARTES

Art. 1687. "La nulidad pronunciada en sentencia que tiene la fuerza de cosa juzgada, da a las partes derecho para ser **restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo**; sin perjuicio de lo prevenido sobre el objeto o causa ilícita. En las restituciones mutuas que hayan de hacerse los contratantes en virtud de este pronunciamiento, será cada cual responsable de la pérdida de las especies o de su deterioro, de los intereses y frutos, y del abono de las mejoras necesarias, útiles o voluptuarias, tomándose en consideración los casos fortuitos, y la posesión de buena o mala fe de las partes; todo ello según las reglas generales y sin perjuicio de lo dispuesto en el siguiente artículo."

El efecto retroactivo de la nulidad es lo que explica esto: al declararse, se considera que el acto jamás existió, y por eso el **art. 1567 N° 8** la cuenta entre los modos de extinguir las obligaciones. Para calcular qué debe devolver cada parte, el Código remite a las mismas reglas de las prestaciones mutuas que rigen la reivindicación (**arts. 904 a 915**).

EJEMPLO**Las cuentas entre Felipe y la Coty**

Declarada nula la compraventa del auto que Felipe le vendió a la Coty, ella debe devolverle el auto y él, la plata que ya le había pagado. Si Felipe se demoró en entregarlo y la Coty alcanzó a usarlo un tiempo, además deben ajustar cuentas por los frutos, por ejemplo, la bencina que gastó, el desgaste de los neumáticos, si le cambió el aceite, o cualquier otro provecho que le haya sacado al auto, como lo que ganó manejando para Uber, y por el deterioro, según quién estaba de buena o mala fe.

Hay un criterio clásico para distinguir estos efectos entre las partes: si el contrato **no fue cumplido por ninguna** de las dos, basta la declaración de nulidad para extinguir las obligaciones (**art. 1567 N° 8**), sin que haya nada que restituir; si fue **cumplido por una o por ambas**, entra a regir el **art. 1687**. VIAL cuestiona que este criterio sea tan nítido: en los *contratos reales*, que precisamente generan la obligación de restituir, aplicarlo llevaría a un resultado absurdo, que esa obligación se extinga sola si la nulidad se declara antes de restituir la cosa, contradiciendo el art. 1687.

Esta regla tiene **cuatro excepciones**:

(i) El poseedor de buena fe.

No devuelve los frutos que percibió mientras estuvo en ese estado; la buena fe se presume hasta que se contesta la demanda (**art. 907**).

(ii) Objeto o causa ilícita a sabiendas.

Quien pagó o entregó algo sabiendo que el objeto o la causa eran ilícitos no puede pedirlo de vuelta (**art. 1468**): es la sanción a quien infringió la ley a sabiendas.

(iii) El contrato con un incapaz.

Si el contrato se anuló por la incapacidad de una de las partes, quien contrató con el incapaz solo puede exigirle la devolución de lo pagado si prueba que el incapaz se hizo **más rico** con ello (**arts. 1687 inc. 2° y 1688**), sea porque lo gastado le era *necesario*, sea porque, sin serlo, *aún conserva esas cosas y quiere quedarse con ellas*. Si en cambio sí se enriqueció, debe restituir según la regla general, para no dar lugar a un enriquecimiento sin causa. Esta protección es exclusiva de la incapacidad: no se extiende a otras causales de nulidad.

(iv) El poseedor que adquiere por prescripción.

Aunque la tradición sea nula o anulada, de todos modos sirve como título posesorio para que quien la recibió gane el dominio por prescripción extraordinaria.

3. EFECTOS DE LA NULIDAD RESPECTO DE TERCEROS

Declarada la nulidad, sea absoluta o relativa, el dueño original recupera una **acción reivindicatoria** contra quien posea la cosa, sin importar si es un tercero (**art. 1689**). La razón es el efecto **retróactivo**: como se reputa que el dominio jamás salió de su patrimonio, ninguno de los que adquirieron después de él llegó a ser dueño, y por lo mismo ninguno pudo transmitir a otros más derechos de los que tenía. En esto la nulidad es más exigente que la **resolución**, que solo afecta a los terceros de mala fe (**arts. 1490 y 1491**): la nulidad alcanza a todos, de buena o mala fe. Y si en vez de vender la cosa el poseedor la *gravó con una hipoteca, una servidumbre u otro derecho real*, o *ejecutó cualquier acto que despojara al dueño de alguno de sus atributos*, el verdadero dueño también puede pedir que esos gravámenes caduquen, porque quien los constituyó nunca tuvo derecho a hacerlo.

Sin embargo, hay tres situaciones en que, pese a declararse la nulidad, no procede la acción reivindicatoria contra terceros:

(i) La rescisión por lesión enorme.

Cuando se rescinde una compraventa por lesión enorme, los gravámenes que pesan sobre la cosa no caducan: antes de restituirla, el comprador debe primero purificarla de ellos (**art. 1895**). Y si el comprador ya enajenó la cosa, la propia acción de rescisión se pierde (**art. 1893**).

(ii) El tercero que adquirió por prescripción.

Cuando el tercero ganó el dominio por prescripción, tampoco hay reivindicación posible: de los **arts. 682, 683 y 717** se desprende que los defectos del título de quienes lo antecedieron en la posesión no se transmiten a él.

EJEMPLO

Por qué la señora Pilar se salva de la reivindicación

Doña Marta le vende un sitio en Los Andes a don Waldo, sabiendo ambos que el terreno tiene un problema de deslindes con la Municipalidad (objeto ilícito); don Waldo se lo vende de inmediato a la señora Pilar, con sus respectivas tradiciones. A los ocho años, doña Marta demanda la nulidad de su venta a don Waldo (la acción está vigente, pues la nulidad absoluta se sanea en diez) y entabla, a la vez, acción reivindicatoria contra la señora Pilar. El contrato entre doña Marta y don Waldo se anula, pero doña Marta no puede reivindicar de la señora Pilar: aunque la tradición no le dio el dominio (porque don Waldo no lo tenía), la ley le permitió ganarlo por prescripción ordinaria de cinco años dada su posesión regular, y la acción reivindicatoria se extingue por la prescripción adquisitiva del mismo derecho (**art. 2517**).

Cuando es el propio poseedor quien, por un acto suyo, deja de estar en condiciones de restituir (por ejemplo, porque se la vendió a un cuarto), se aplican las reglas sobre el poseedor que dejó de po-

seer (**arts. 898 y 900**): se le puede exigir que entregue lo que obtuvo a cambio de la cosa, y si sabía que no era suya al momento de venderla, además responde de todo perjuicio causado.

(iii) El heredero indigno que enajena bienes de la herencia.

Cuando un heredero o legatario es declarado judicialmente indigno, debe restituir lo heredado o legado; pero si ya lo había enajenado, los demás herederos solo pueden perseguir esos bienes en manos de terceros de **mala fe** (**art. 974**).

4. ACCIONES A QUE DA ORIGEN LA NULIDAD

De un acto nulo nacen, por regla general, dos acciones distintas: la de nulidad, **personal**, contra los demás contratantes; y la reivindicatoria, **real**, contra quien hoy posea la cosa. En estricto orden lógico habría que ganar primero la de nulidad y recién después entablar la reivindicatoria, pero los **arts. 17 y 18 C.P.C.** permiten demandar ambas juntas en el mismo juicio, sujetando la segunda a que se acoja la primera. Un sector de la doctrina agrega todavía una tercera acción posible, de indemnización de perjuicios.

(i) La acción de nulidad.

Es una acción **personal**. Si la entabla uno de los contratantes, se dirige contra el otro; si la entabla un tercero por tratarse de nulidad absoluta, debe dirigirse contra todos los que celebraron el acto. La **acción de nulidad absoluta** prescribe en diez años desde la celebración del acto; la de **nulidad relativa**, en cuatro años, contados desde la celebración salvo en los casos de fuerza o incapacidad legal, en que corren desde que cesa la violencia o la incapacidad (**art. 1691**).

En ambos casos se trata de prescripción **extintiva**: si nadie ejerce la acción durante el plazo, simplemente se pierde. La de nulidad relativa tiene además la particularidad de ser una prescripción **de corto tiempo**, y estas, por regla general, corren igual contra cualquier persona salvo que una ley diga lo contrario (**art. 2524**); la acción rescisoria es, justamente, una de esas pocas excepciones a esa regla general.

Esta es la única hipótesis de **suspensión** en toda esta materia, y opera a favor de los **herederos menores** de quien tenía el derecho a pedir la rescisión: el cuadrienio, o lo que quede de él, no empieza a correrles desde la muerte del causante sino desde que cumplen la mayoría de edad (**art. 1692**). Si los herederos son mayores, no hay suspensión alguna: gozan del cuadrienio completo si aún no había empezado a correr, o de lo que reste si ya corría. Por ser una regla excepcional, no puede extenderse por analogía a otros incapaces que no sean menores de edad, aunque lo sean por otro motivo: el art. 1692 solo beneficia a los menores. Y hay un tope absoluto: el propio **art. 1692** inciso final dice que, pese a la suspensión, nunca puede pedirse la rescisión pasados diez años desde la celebración del acto, aplicación del mismo principio que hace que, transcurridos diez años, dejen de considerarse las suspensiones establecidas a favor de ciertas personas (**art. 2520 inc. 2°**).

(ii) La acción reivindicatoria.

A diferencia de la anterior, esta es una acción **real**: no importa quién posea la cosa, sea el propio contratante o un tercero, contra él se dirige (**art. 1689**), porque el efecto retroactivo de la nulidad devuelve el dominio a quien lo tenía antes del acto nulo.

La **reivindicación o acción de dominio** es la que tiene el dueño de una cosa singular, de que no está en posesión, para que el poseedor de ella sea condenado a restituírsela (**art. 889**).

Se pierde cuando quien resiste la acción gana, a su vez, el mismo derecho por prescripción adquisitiva (**art. 2517**).

(iii) La acción de indemnización de perjuicios.

Es un terreno que la doctrina chilena casi no ha explorado. No se trata de cobrar las obligaciones del contrato nulo, que también quedaron sin efecto, sino de algo distinto: preguntarse si de la celebración del acto, o de la propia declaración de nulidad, puede nacer otra responsabilidad. Lo que busca esta acción es dejar indemne a quien sufrió un perjuicio con la celebración del acto nulo, y para eso necesita, como cualquier indemnización, un daño que alguien causó por su culpa o dolo.

No hay una norma general sobre esto en el Código, solo disposiciones sueltas: los **arts. 1353** (indemnización como alternativa a la nulidad o rescisión en una partición) y **1813** (venta de cosa futura) la mencionan de paso, y tres casos la desarrollan más. El **art. 1455** le da acción a quien, de buena fe, contrató por error con la persona equivocada. El **art. 1814** obliga al vendedor que sabía que la cosa no existía, del todo o en parte, a resarcir al comprador de buena fe. Y el **art. 1458** inciso 2° da acción de perjuicios por el dolo que no alcanza a viciar el consentimiento, el llamado dolo incidental (**BARAONA** sostiene que la palabra *solamente* de esa norma sugiere que también está disponible cuando el dolo sí es determinante y da derecho a la rescisión).

Para las demás causales, sin norma expresa que las regule, es la doctrina la que distingue causal por causal:

a) La fuerza

Como por definición es siempre injusta, quien la sufre tiene derecho a que la indemnicen: se trata de un acto ilícito que, al causar daño, cae derecho en el **art. 2314**.

b) El error en cualidades accidentales

Si el error lo sufrieron ambas partes, las culpas se compensan y no hay indemnización: mal puede reclamarla quien tampoco se cercioró de que no había error. Pero si una sola de ellas erró y la otra lo sabía sin advertírselo, ahí sí hay una reticencia capaz de fundar una indemnización.

c) El error sustancial o esencial

La doctrina se divide. **RODRÍGUEZ** niega la indemnización, porque en estas clases de error las padecen normalmente ambas partes, de modo que las culpas también se compensan. **BARAONA** la admite cuando solo una incurrió en el error, exigiendo que quien se equivocó no haya sido inducido dolosamente y que su error se explique por una negligencia inadmisibles, y que quien pide la indemnización esté de buena fe.

d) La incapacidad relativa

Si hubo inducción dolosa de la contraparte, procede la indemnización; pero no si fue el propio incapaz quien indujo con dolo a contratar, caso en que además pierde el derecho a pedir la nulidad (**art. 1685**). Si el incapaz actuó sin dolo, conserva su derecho a la nulidad, y entonces es la contraparte la que no puede pedir indemnización, por no haber verificado bien las condiciones de quien contrataba: aquí solo hay dos escenarios posibles, el menor de edad, que se identifica con solo pedir la cédula, y el pródigo interdicto, cuya condición exige revisar los registros públicos.

e) La omisión de formalidades habilitantes

Por regla general no procede indemnización, porque cuidar que se cumplan es carga de ambas partes; solo cabe si una de ellas actuó con dolo.

f) La falta de objeto

BARAONA extiende por analogía el **art. 1814** a la falta o ilicitud de objeto o causa; **RODRÍGUEZ** lo niega para toda nulidad absoluta, porque en ella ambas partes infringieron normas de orden público.

g) La incapacidad absoluta

El incapaz absoluto jamás responde por sus propios actos. Distinto es el caso de quien se aprovechó de él, o actuó con negligencia al no percatarse de su incapacidad: a ese sí se le puede exigir indemnización.

h) La omisión de una solemnidad

Nadie puede reclamar perjuicios en este caso, porque a nadie le sirve alegar que ignoraba la ley: se presume conocida por todos.

Pedir indemnización no es incompatible con demandar la nulidad, sea absoluta o relativa, siempre que se cumplan dos mínimos: que quien la pide esté de buena fe respecto del vicio, y que a la contraparte se le pueda atribuir culpa, ya sea por inducción dolosa, por reticencia o por simple negligencia. Y el camino también puede recorrerse al revés: quien debe soportar la nulidad puede, a su vez, reconvenir pidiendo que lo indemnicen, según cuál haya sido la causal invocada y las circunstancias en que se celebró el contrato.

Falta precisar de qué **naturaleza** es esta responsabilidad. El punto de partida es que entre quienes negociaron un acto que terminó siendo nulo sí hubo un vínculo, un contacto, y de ese contacto nacen deberes de lealtad que no son los mismos que los de un contrato ya perfeccionado (eso sería

responsabilidad contractual) ni los del deber general de no dañar a nadie (responsabilidad extracontractual). La doctrina mayoritaria descarta de entrada la vía contractual: lo que se reprocha ocurrió antes del contrato, y la sentencia que declara la nulidad precisamente borra ese contrato del mundo jurídico.

RODRÍGUEZ sostiene que es una responsabilidad legal: "la obligación de indemnizar perjuicios, cuando se declara la nulidad de un acto o contrato, nace de la ley, aun cuando es efectivo que esta responsabilidad supone culpa o dolo de parte de quien causa el daño; pero las normas de responsabilidad extracontractual no son aplicables íntegramente en este evento, especialmente atendiendo a que sólo en algunos casos es posible concebir el derecho indemnizatorio que emana de la nulidad judicialmente declarada". Frente a eso, la mayoría de los autores, **BARAONA** incluido, sostiene que es responsabilidad extracontractual, aunque con un matiz: la culpa de cada parte se aprecia tomando en cuenta si actuó de buena o de mala fe.

5. LA CONVERSIÓN

Eduardo Court define la **conversión** del acto nulo como "un fenómeno que consiste en que, declarada la nulidad de un acto jurídico, éste desaparece en su sentido primitivo, dando origen a otro acto civilmente válido entre las partes".

ALESSANDRI la define de forma semejante, como una "transformación producida por el imperio de la ley, en virtud de la cual un acto jurídico ineficaz, tal como los agentes lo han operado, es sustituido por otro acto jurídico de distinta naturaleza, y con lo cual se cumplen las miras económicas que tuvieron en vista los agentes al realizar el primero". El propio Código anticipa la idea: el **art. 1444** admite que, al faltarle un elemento esencial, un contrato "degenere en otro contrato diferente". Detrás de la figura está el principio de **conservación del negocio jurídico**: hasta donde sea posible, conviene mantener vigente lo que las partes quisieron, para que puedan alcanzar el resultado práctico que buscaban.

NO CONFUNDIR

¿El art. 1444 es un caso de conversión?

VIAL cree que no: a su juicio, cabe analizarlo más bien como un problema de **error**, generalmente de derecho, en que las partes le dan a un acto una calificación equivocada. El contrato que las partes llaman compraventa y que para la ley es una permuta no se perfecciona como compraventa ni produce sus efectos: desde el primer momento es una permuta. Ahí no hay una compraventa con un vicio de nulidad que se convierte en otro contrato, sino un solo contrato, la permuta, que no adolece de vicio alguno.

La doctrina distingue tres clases de conversión:

CRITERIO	CONVERSIÓN FORMAL	CONVERSIÓN MATERIAL (O VERDADERA Y PROPIA)	CONVERSIÓN LEGAL
Qué cambia	Nada en el negocio jurídico mismo: solo su documentación	El acto nulo pasa a valer como el negocio jurídico distinto cuyos requisitos sí cumple	El acto nulo pasa a tener, por mandato directo de la ley, los efectos de un negocio distinto
Cuándo opera	Las partes usan una forma más exigente que la que pide la ley; esa forma falla, pero de todos modos se cumplen los requisitos de la forma más simple que bastaba	Cuando concurren un requisito objetivo y uno subjetivo (ver recuadro)	Solo cuando existe una norma legal expresa que así lo ordene; al ser una regla imperativa, la única salida de las partes que no quieran quedar sujetas al nuevo negocio es ponerse de acuerdo para dejarlo sin efecto (art. 1545)
Ejemplo	Don Hugo le promete por escritura pública venderle su departamento a la Sofía, pero el notario que autoriza la escritura resulta incompetente: la escritura es nula, pero la promesa de todos modos vale, porque la ley solo exige que conste por escrito (art. 1554 N° 1). La misma lógica explica el art. 1701 : el instrumento público nulo por un defecto de forma vale como instrumento privado si las partes lo firmaron, salvo que la ley haya exigido justamente el instrumento público como solemnidad del acto, caso en que no hay instrumento privado que valga	Un ejemplo clásico: Nacho le extiende una letra de cambio a la Camila para dejar constancia de una deuda, pero el documento queda mal extendido y no cumple los requisitos de forma de una letra de cambio. Aun así, no queda en nada: vale como un simple reconocimiento abstracto de deuda. La misma idea explica que una aceptación condicional se trate como una nueva oferta (art. 102 C. de Comercio)	La donación irrevocable entre cónyuges, que la ley entiende siempre revocable (arts. 1137 y 1138)

Sobre el caso de la donación entre cónyuges, **VIAL** precisa que una donación de este tipo, ineficaz como irrevocable, se convierte en revocable y produce los efectos propios de esta última.

La conversión material no se agota en los ejemplos legales: también opera por vía jurisprudencial. **ALESSANDRI** cita un caso típico: un convenio extrajudicial nulo, invocado como título ejecutivo, no vale como tal, pero la Corte Suprema le ha reconocido eficacia en cuanto da testimonio y acredita un reconocimiento de deuda del ejecutado a favor del ejecutante. El convenio no valía como tal, pero se "convirtió" en otro acto, eficaz jurídicamente.

NO OLVIDAR

Los dos requisitos de la conversión material

Como explica **COVIELLO**, para que opere la conversión es necesario "un elemento objetivo y uno subjetivo". **Objetivo:** que en el negocio nulo se encuentren todos los elementos para que se tenga un negocio de diversa naturaleza. **Subjetivo:** que ese negocio pueda reputarse querido por las partes, lo que se mide por su voluntad *hipotética*: la que habrían tenido de saber que el acto era nulo, nunca por su voluntad real, porque la conversión solo tiene cabida mientras las partes ignoran el vicio que afecta al acto que celebraron.

Sobre este elemento subjetivo hay matices entre los autores. **STOLFI**, a diferencia de Coviello, exige lo contrario: que las partes tengan conocimiento de la ineficacia del acto, porque la conversión supone la certeza de que existen todos los requisitos del nuevo negocio salvo uno, el consentimiento, y en cuanto a ese consentimiento la ley se conforma con una hipótesis razonable, prefiriendo atribuirle una eficacia más limitada que la querida antes que darlo por no prestado. Con este criterio, Stolfi cita como posibles casos de conversión una compraventa de inmuebles que, constando solo por instrumento privado, no vale como tal, pero podría tener eficacia como promesa de compraventa; o un mutuo ineficaz por no haberse entregado la cosa o la suma prestada, que podría producir los efectos de una promesa de mutuo.

La conversión, en general, tiene dos límites. El primero toca sobre todo a la conversión material, que descansa en esa voluntad hipotética: si son las propias partes las que la prohíben, no es posible presumir que su voluntad hipotética habría aceptado el nuevo negocio, y la conversión no opera. El segundo ya se adelantó al hablar del **art. 1701**: cuando la ley exige el instrumento público como solemnidad del acto, sin admitir que se pruebe de otro modo, no hay instrumento privado que valga; así, una compraventa de un inmueble celebrada sin escritura pública no vale ni como compraventa ni como promesa, porque la ley exigía esa forma sin alternativa.

JURISPRUDENCIA

CORTE SUPREMA, 2012, ROL N° 3.557-2010

El contrato entre el demandante y el demandado exigía escritura pública como solemnidad, no solo como medio de prueba. La Corte descartó que pudiera aplicarse la conversión del **art. 1701** inciso 2°, reservada a los casos en que el instrumento público se exige *ad probationem*: aquí regía el inciso 1°, que hace mirar el acto como no celebrado, sin que pueda subsistir ni siquiera como instrumento privado. La Corte fue categórica: "las hipótesis de conversión del acto nulo son de aplicación estricta".

Queda, eso sí, una pregunta abierta en la doctrina sobre la conversión material: si no hay una norma legal expresa que la autorice, ¿puede igual operar, por el solo cumplimiento de sus dos requisitos? **ALESSANDRI**, de acuerdo con **VIAL**, sostiene que no: como el Código no tiene ninguna disposición que permita la conversión del acto nulo en términos generales, la posibilidad de convertirlo se restringe exclusivamente a los casos particulares en que la ley la permite expresamente. Otro sector de la doctrina opina lo contrario: que sería una institución de aplicación general, que opera siempre que se cumplan sus requisitos, en virtud del mismo principio de conservación del negocio jurídico.

El Código trae más ejemplos de conversión legal, además de la donación irrevocable entre cónyuges ya vista. Algunos cambian la naturaleza misma de un bien o un derecho: los fideicomisos perpetuos que terminan convertidos en capitales acensuados (**arts. 747 y 2044**), las deudas del causante sin respaldo escrito que se tratan como legados (**arts. 1062 y 1133**), las donaciones revocables que valen como legados (**arts. 1141 y 1142**), los desembolsos que el testador no quiso imputar a la legítima y que pasan a contarse como mejora (**art. 1203**), y los censos inscritos que, para efectos de prelación de créditos, se cuentan como hipotecas (**art. 2480**). Otros, en cambio, le dan valor a un acto al que le faltaron formalidades: la donación con causa onerosa que no se probó por escritura, que igual vale como donación gratuita (**art. 1404**), y lo mismo le pasa a la donación remuneratoria que no logró probarse (**art. 1433**).

COVIELLO advierte, eso sí, que no hay que confundir la conversión con un simple error de **nombre**: si las partes, por desconocer el derecho, le dan a su acto un nombre equivocado, pero de hecho cumplen todos los requisitos del acto que realmente querían celebrar, no hace falta convertir nada, porque ese acto ya es válido bajo su verdadero nombre. No hubo un acto nulo que transformar, solo una imprecisión terminológica.

JURISPRUDENCIA

CORTE SUPREMA, 3 DE DICIEMBRE DE 1921

Una causante dictó su testamento ante notario y tres testigos sin que hubiera entonces ninguna señal de que su muerte fuera inminente, pero falleció de improviso antes de que el notario llegara a leerle las disposiciones y ella pudiera firmar. El testamento solemne, al quedar sin firma, no podía valer como tal; la Corte igual le dio valor, como testamento verbal, menos solemne o privilegiado.

NO CONFUNDIR

¿Es esto conversión?

No, según **COVIELLO**: "es evidente que aquí no puede hablarse de conversión, ya que es idéntico el negocio que se hace valer y el querido por las partes". El testamento abierto y el verbal son dos formas del mismo acto, el testamento; cuando uno falla por faltarle una solemnidad, basta con que se cumplan los requisitos de la forma menos exigente para que valga como tal, sin necesidad de indagar la voluntad de las partes. La conversión verdadera, en cambio, exige que el acto cambie de **naturaleza**, como la letra de cambio que pasa a valer como reconocimiento de deuda: aquí la naturaleza no cambia, el acto sigue siendo un testamento, solo que de una especie menos solemne.

C. LA LESIÓN

1. CONCEPTO DOCTRINAL

La doctrina define la **lesión** a partir de un desequilibrio: el sacrificio que hace una persona al celebrar ciertos actos jurídicos resulta mayor que la ventaja que obtiene a cambio. Así se explican, por ejemplo, el interés excesivo cobrado en un préstamo, el precio exorbitante o irrisorio de una venta, la ganancia societaria que no guarda relación con el aporte del socio, o la indemnización desproporcionada al derecho que se renuncia en una transacción.

Precisando ese concepto general, lo que define técnicamente a la lesión es el perjuicio pecuniario que sufre una de las partes de un **contrato oneroso conmutativo** (**arts. 1440 y 1441**), porque las prestaciones que la ley mira como equivalentes no lo son en realidad. De ahí que, para la doctrina, la institución quede fuera de dos terrenos: los actos gratuitos, porque en ellos el gravamen recae desde el inicio en una sola parte, y los contratos aleatorios, porque en ellos lo que se promete a cambio es precisamente una contingencia incierta, no una prestación medible con la que comparar.

No todas las legislaciones se conforman con ese desequilibrio objetivo. El Código Civil alemán (**art. 138**) y el Código Suizo de las Obligaciones (**art. 21**), por ejemplo, exigen además un elemento subjetivo: que quien se benefició haya explotado la penuria, la ligereza o la inexperiencia del contratante lesionado. Otros ordenamientos, en cambio, prescinden de ese requisito y sancionan la sola desproporción.

2. LA LESIÓN EN EL CÓDIGO CIVIL CHILENO: ¿CONSTITUYE UN VICIO DEL CONSENTIMIENTO?

Que el **art. 1451** no incluya a la lesión entre los vicios del consentimiento abre una pregunta sobre su verdadera naturaleza jurídica, que la doctrina responde de tres maneras distintas según el criterio que adopte: subjetivo, objetivo o mixto.

(i) Criterio subjetivo.

Para quienes adoptan este criterio, la lesión sí es un vicio del consentimiento, aunque no se ponen de acuerdo en qué clase de vicio: una parte lo ve como un vicio autónomo, propio de la necesidad imperiosa de dinero que presiona al contratante hacia un arbitrio ruinoso; otra, como una simple manifestación del error, la fuerza o el dolo. La principal objeción que recibe es que resta certeza a las relaciones jurídicas, porque obliga a fijar el valor efectivo de cada prestación, un dato que no siempre es objetivo.

(ii) Criterio objetivo.

El criterio objetivo, en cambio, prescinde por completo del consentimiento y de sus eventuales defectos: para que opere la lesión basta acreditar que la desigualdad entre las prestaciones supera el margen que la ley tolera.

(iii) Criterio mixto.

El criterio mixto combina ambos: exige la desproporción objetiva de las prestaciones, pero solo la sanciona cuando además es consecuencia del estado de necesidad, miseria, ligereza o inexperiencia de la víctima.

Con esa única excepción de la aceptación de una herencia, la doctrina nacional coincide ampliamente en que la lesión **no es un vicio del consentimiento**, y da para ello varias razones. La primera es histórica: el Proyecto de 1853 sí la trataba como vicio general del consentimiento en los contratos conmutativos, exigiendo que fuera *enorme* (que lo dado por una parte no alcanzara la mitad de lo dado por la otra), pero el **art. 1451** finalmente no la recogió; en el mismo sentido, **BELLO** se apartó aquí de **POTHIER**, quien la consideraba un defecto del consentimiento. La segunda es estructural: en Chile la lesión opera con criterios puramente objetivos, se extiende incluso a contratos que no son onerosos conmutativos y a actos que ni siquiera son contratos, y solo existe en los casos que la ley señala expresamente, sin que todos ellos reciban la sanción propia de los vicios del consentimiento, que es la nulidad relativa.

Los derechos italiano y alemán toman el camino inverso: allí la lesión sí es, en general, un vicio del consentimiento, aunque bajo el criterio mixto, de modo que no basta la desproporción de las prestaciones sino que se exige también el estado de necesidad, ligereza o inexperiencia de la víctima. Por eso en esos ordenamientos la institución se acerca al error, la fuerza o el dolo: en el fondo, sanciona que un contratante se aproveche de la debilidad del otro.

En una posición minoritaria, **DUCCI** sostiene que la lesión sí puede considerarse un vicio del consentimiento, incluido dentro del error sustancial: si la magnitud de las prestaciones es esencialmente distinta de lo creído, de forma que una no pueda mirarse como equivalente de la otra, habría error sobre la *calidad esencial* del objeto (**art. 1454**), entendido el objeto como la prestación (**art. 1460**). Invoca a su favor el **art. 1348**, que somete la partición a las reglas de los contratos y admite su rescisión por lesión, y el **art. 2458**, que en la transacción excluye de la nulidad solo el *error de cálculo*, lo que sugeriría que el error de magnitud (la lesión) sí formaría parte, como regla general, del error sustancial.

3. CASOS DE LESIÓN REGULADOS EN EL CÓDIGO CIVIL CHILENO

Nuestro Código no trató la lesión como una institución general y orgánica, sino que la reconoció caso por caso: no existe una causal genérica que permita rescindir cualquier contrato oneroso conmutativo por desproporción, sino una lista **taxativa** de hipótesis en que la ley la sanciona.

(i) **Compraventa de bienes raíces.**

Procede solo en las compraventas voluntarias de inmuebles que no sean pertenencias mineras (**arts. 1888, 1897 y art. 77 Código de Minería**). El art. 1889 define cuándo hay lesión enorme:

Art. 1889. "El vendedor sufre lesión enorme, cuando el precio que recibe **es inferior a la mitad del justo precio** de la cosa que vende; y el comprador a su vez sufre lesión enorme, cuando el justo precio de la cosa que compra **es inferior a la mitad del precio que paga** por ella. El justo precio se refiere al tiempo del contrato."

Ese justo precio se mide al momento de celebrarse el contrato, no al momento en que se reclama la lesión. Pronunciada la rescisión, la ley le da al beneficiado una salida (**art. 1890**): el comprador puede allanarse a ella o pagar lo que falta para el justo precio, descontada una décima parte; el vendedor, allanarse o devolver lo recibido en exceso sobre el justo precio, aumentado también en una décima. Lo llamativo del mecanismo no es solo que permita evitar una nulidad ya declarada, sino que la propia ley acepte que, incluso corrigiendo el desequilibrio, el beneficiado se quede con algo más de lo estrictamente equivalente: de ahí ese margen del diez por ciento.

(ii) **Permuta de bienes raíces.**

La permuta toma prestadas las reglas de la compraventa que no choquen con su naturaleza, entre ellas la lesión enorme (**art. 1900**). Lo que no puede tomar prestado es el mecanismo para evitar la rescisión completando o restituyendo el precio: como lo que se intercambia son dos especies o cuerpos ciertos, no hay una suma de dinero que completar.

(iii) Aceptación de una asignación hereditaria.

El **art. 1234** permite rescindir la aceptación de una herencia por lesión grave (la que disminuye en más de la mitad el valor de la asignación), cuando esa lesión proviene de disposiciones testamentarias que el heredero ignoraba al aceptar. Esta es, precisamente, la excepción que confirma la regla: acá la lesión sí opera como un verdadero vicio del consentimiento, porque recae en un acto unilateral y gratuito, supone un componente subjetivo (ignorar algo, una forma de error) y el propio artículo la enumera junto al dolo y la fuerza como causal de rescisión.

(iv) Partición de bienes.

Las particiones se anulan o rescinden como los contratos, y la rescisión por lesión se concede a quien fue perjudicado en más de la mitad de su cuota (**art. 1348**), aunque la partición puede ser un acto unilateral, bilateral o incluso un acto jurisdiccional (la hecha por un partidor). Los demás copartícipes pueden *atajar* la rescisión ofreciendo y asegurando el suplemento que falta a la cuota del perjudicado (**art. 1350**), incluso antes de que se falle la demanda.

(v) El mutuo.

El interés convencional no tiene más límite que el fijado por ley especial, salvo que exceda en una mitad al interés corriente al tiempo de la convención, caso en que el juez lo reduce a ese interés corriente (**art. 2206**; complementado por el **art. 8 de la Ley N° 18.010**, que tiene por no escrito el pacto que exceda el máximo convencional). Aquí, a diferencia de la compraventa, la sanción no es la nulidad relativa, sino la simple **reducción** del interés.

(vi) La anticresis.

Contrato por el que el deudor, o un tercero que consienta en ello, entrega al acreedor una cosa raíz para que este se pague con sus frutos (**arts. 2435 y 2436**). La ley le aplica la misma lógica que al mutuo: si los intereses pactados resultan lesivos, se reducen de igual forma (**art. 2443**).

(vii) La cláusula penal.

El **art. 1544** distingue tres situaciones. Si la obligación principal y la pena consisten ambas en una cantidad determinada del mismo género, el exceso sobre el duplo de la obligación se rebaja, contando ese duplo como ya incluida la obligación misma: con una obligación de \$100 y una pena de \$300, la cláusula resulta lesiva en \$100, no en \$200. Si la cláusula penal se pactó en un mutuo, el exceso se rebaja hasta el máximo convencional de interés; la regla parece contradecir al **art. 2206**, que ordena rebajar al interés corriente, pero ambas deben leerse en el mismo sentido, sobre todo a

la luz de la Ley N° 18.010. Y si la obligación es de valor inapreciable o indeterminado, queda entregado al juez moderarla cuando le parezca enorme.

(viii) La hipoteca.

Hay un caso de lesión que la doctrina nacional rara vez trata como tal: el **art. 2431** impide que la hipoteca, aunque se haya pactado sin tope, se extienda más allá del duplo del importe conocido o presunto de la obligación principal, y le da al deudor el derecho a exigir que se reduzca a ese duplo. La regla rige incluso cuando la hipoteca garantiza, con una cláusula de garantía general, obligaciones todavía indeterminadas.

EJEMPLO

Reducción de la hipoteca de garantía general al duplo

Doña Marta hipoteca su casa a favor del Banco Estado con una cláusula de garantía general que respalda toda obligación presente o futura. Contrae con el banco un crédito de consumo de \$8.000.000 y luego gira en rojo \$2.000.000 en su cuenta corriente. Aunque la cláusula no fije tope, doña Marta puede exigir que la hipoteca se limite a \$20.000.000, el duplo del importe conocido de la obligación principal (\$10.000.000).

4. SANCIÓN DE LA LESIÓN

La sanción no siempre es la misma. En algunos casos, como la compraventa, es la **nulidad relativa o rescisión**, de la que el ganancioso puede escapar completando o restituyendo la prestación deficiente en los términos que la ley fija; en otros, como el mutuo o la cláusula penal, la ley se conforma con **reducir** la estipulación lesiva a términos razonables. En uno u otro caso, la lesión siempre termina en nulidad relativa o en la corrección de la desproporción.

D. LA SIMULACIÓN

1. CONCEPTO

Hay simulación cuando lo que las partes de un contrato realmente quieren no coincide con lo que declaran: a veces porque no quieren celebrar contrato alguno (**simulación absoluta**), a veces porque quieren uno distinto del que declaran (**simulación relativa**). En ambos casos el acto simulado termina siendo una apariencia que no coincide con la realidad, sea porque esta no existe o porque es otra.

Avelino **LEÓN** define la simulación como *aparentar una declaración de voluntad que no se desea, contando con la aquiescencia de la parte a quien esa declaración va dirigida*.

La **reserva mental** también consiste en declarar algo distinto de lo que se quiere, pero a solas: el declarante guarda su verdadera voluntad en secreto, sin que el destinatario lo sepa ni lo consienta. La simulación, en cambio, exige ese consentimiento: un *acuerdo* entre quien declara y quien recibe la declaración. Por necesitar ese acuerdo, la simulación solo cabe en los actos **bilaterales** y en los unilaterales **recepticios**, dirigidos a un destinatario determinado que debe conocer la declaración; la reserva mental, en cambio, al no requerir ninguna concurrencia ajena, es posible en cualquier acto jurídico.

Por exigir ese acuerdo, la simulación requiere además un **acto unitario**, o unidad de acción de voluntades: la disconformidad entre lo querido y lo declarado debe ser querida y compartida por ambas partes. De ahí una diferencia práctica con la reserva mental: el acto jurídico con reserva mental es, en principio, **válido**, porque la contraparte ignora el desacuerdo; el acto simulado, en cambio, es generalmente **nulo**, porque quien recibe la declaración no solo conoce esa disconformidad, sino que la ha querido junto al declarante.

2. LA SIMULACIÓN EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO CHILENO

Varios códigos civiles del siglo XX sí regulan la simulación de forma expresa: el alemán de 1900 (**art. 117**), el italiano de 1942 (**arts. 1414 a 1417**), el etíope de 1960 (**arts. 1991, 1994 y 2019**), el portugués de 1967 (**arts. 240 a 243**), el boliviano de 1975 (**arts. 543 a 545**), el peruano de 1984 (**arts. 190 a 194**) y el paraguayo de 1985 (**arts. 305 a 310**). El nuestro no: ni la regula ni usa esa palabra en ninguna disposición. Pese a ese silencio, doctrina y jurisprudencia coinciden sin excepción en que la simulación ilícita es un obrar contrario a derecho, y han construido toda la institución apoyándose principalmente en el **art. 1707**: *las escrituras privadas hechas por los contratantes para alterar lo pactado en escritura pública no producirán efectos contra terceros; tampoco las contraescrituras públicas, cuando no se ha tomado razón de su contenido al margen de la escritura matriz*.

La simulación también interesa al derecho penal (**art. 471 N° 2 del Código Penal**, que castiga a quien otorga en perjuicio de otro un contrato simulado, exigiendo un perjuicio patrimonial efectivo y dolo directo; y el **art. 466**, que desde la Ley N° 20.720 de 2014 castiga a la *persona deudora*, definida en el **art. 2° N° 25** de esa misma ley, que se alza con sus bienes o que otorga contratos simulados en perjuicio de sus acreedores) y al derecho tributario, donde el **art. 4 quáter del Código Tributario** la reconoce como una hipótesis de elusión, aplicando los impuestos a los hechos efectivamente realizados, con independencia del acto simulado.

3. SIMULACIÓN LÍCITA

Simular, por sí solo, no es contrario a derecho; lo es únicamente cuando se persigue, con ello, perjudicar a terceros. De ahí nace la distinción entre simulación lícita e ilícita, según cuál sea el fin que la mueve: la lícita suele responder a motivos inocentes, como la modestia o el deseo de hacer el bien anónimamente.

ALCALDE lo explica así: "si bien es cierto que toda simulación, por el hecho de ser tal, persigue engañar a terceros, ello no la transforma necesariamente en ilícita o ilegítima, ya que las partes pueden obligarse como quieran y, en tal sentido, realizar en secreto aquello que también les sería permitido realizar públicamente". En la misma línea, **JOSSERAND** agrega que es el móvil perseguido el que decide la calificación del acto: habrá "mentiras jurídicas" condenables y hasta criminales, otras que serán solo pecados veniales, y algunas, indiferentes a la moral y hasta motivadas por exceso de delicadeza o de escrúpulos de conciencia.

JURISPRUDENCIA

CORTE SUPREMA, 30 DE MARZO DE 2015

La simulación tiene causa y es la que, también en doctrina, se denomina *causa simulandi*, entendiéndose por tal el interés que lleva a las partes a hacer un contrato simulado, el motivo que induce a dar apariencia a un negocio jurídico que no existe o presentarlo en forma distinta a la que corresponde: es el porqué del engaño.

La simulación lícita es, de hecho, muy habitual: basta pensar en la inmensa mayoría de las compraventas de inmuebles del país, donde la escritura pública declara un precio pagado al contado que no es tal. La verdad queda en una *contraescritura privada* (las llamadas *instrucciones notariales*), que deja los documentos representativos del precio en poder del notario: este solo los entrega al vendedor una vez que el comprador logra inscribir el inmueble a su nombre. Esa cautela tiene una razón técnica: como el dominio de un inmueble se transfiere recién con la inscripción del título (**art. 686**), el comprador prefiere no soltar el precio hasta que esa inscripción esté hecha.

Esta práctica no perjudica a terceros: al contrario, los protege y facilita la libre circulación de los bienes, y encuentra respaldo en el propio **art. 1707**, leído junto a los **arts. 1491 y 1876** (que hacen depender la resolución frente a terceros de que la condición conste en el título inscrito). Su utilidad es **doble**: como en el título que se inscribe no figura ningún saldo de precio pendiente, ningún tercero queda expuesto a la resolución por la condición resolutoria tácita que lleva implícita toda compraventa; y el comprador, por su parte, se asegura de que el vendedor no reciba el precio si, por cualquier motivo, el inmueble termina sin inscribirse a su nombre.

JURISPRUDENCIA**CORTE SUPREMA, RDJ, T. XXXVIII, SECC. 2ª, 1936, P. 17**

La simulación, no mediando perjuicio de terceros, es perfectamente lícita en nuestro derecho: así lo demuestra el **art. 1707**, que da valor entre las partes a las escrituras privadas hechas para alterar lo pactado en una escritura pública.

CORTE SUPREMA, RDJ, T. LXXXVIII, SECC. 1ª, 1991, P. 14

Bien pueden las partes comparecientes en un instrumento público, compenetradas del alcance de sus palabras, convenir en cláusulas que no correspondan a la realidad, sin alterar con ello la validez del instrumento.

Fijar los **efectos de la simulación lícita** exige distinguir tres posiciones. Entre las **partes**, que conocen perfectamente la verdad y no buscan engañarse entre sí, gobierna la voluntad real: el acto simulado simplemente no existe para ellas, y cualquiera puede pedir que se declare la vigencia de lo pactado en la contraescritura. Frente a los **terceros de buena fe**, que ignoran que hay simulación, el **art. 1707** hace lo contrario: les vuelve inoponible la contraescritura, de modo que pueden invocar el acto público o simulado a su favor; pero también pueden preferir el acto disimulado, una vez que llegan a conocer la simulación, si eso les conviene más (a los acreedores de un deudor que fingió vender sus bienes a un amigo, por ejemplo, les conviene sostener que esos bienes jamás salieron de su patrimonio). Cuando dos terceros de buena fe tienen intereses opuestos sobre cuál acto prevalece, la doctrina resuelve que lo alegado por uno no puede perjudicar al otro. Y frente al **tercero de mala fe**, que sabía de la simulación, las partes sí pueden oponerle el acto disimulado, y ese tercero debe sufrir sus efectos como cualquiera de ellas.

4. LA SIMULACIÓN ILÍCITA

4.1. Requisitos

Es, según la Corte Suprema, la que "perjudica (o tiene la intención de perjudicar) a terceros o viola (o tiene la intención de violar) la ley". Sus requisitos son:

(i) **Disconformidad**

Entre la voluntad real, efectiva y verdadera, y la voluntad declarada o manifestada.

(ii) **Deliberación y conciencia de la disconformidad**

Voluntad y pleno conocimiento de que, queriéndose algo, se expresa una voluntad diferente. Es lo que distingue la simulación del error, donde también hay disconformidad entre lo querido y lo declarado, pero falta esa conciencia.

(iii) Concierto entre las partes

Comunicación recíproca y acuerdo entre ellas en que lo manifestado es solo apariencia, porque lo realmente convenido es algo distinto, o la nada misma.

(iv) Intención de engañar a terceros

Derivada de los tres requisitos anteriores.

JURISPRUDENCIA

CORTE SUPREMA, 13 DE ENERO DE 2014, ROL N° 9.631-2012

Fija los cuatro elementos de la simulación ilícita recién enumerados. El mismo criterio se reitera en los fallos de 30 de marzo de 2015 y de 30 de marzo de 2017.

4.2. Clases de simulación: absoluta y relativa

Hay **simulación absoluta** cuando, en realidad, ningún acto jurídico se celebra y solo se aparenta uno. Rodrigo, acosado por sus acreedores, simula vender su camioneta a su primo Cristóbal (quien accede a figurar como comprador, sin pagar ni recibir jamás el vehículo) para sustraerla de un eventual embargo: el acto tiene toda la apariencia de una compraventa válida, pero en realidad no existió ninguna. Declarada la simulación, ese acto aparente se desvanece: queda inexistente para parte de la doctrina, y absolutamente nulo para la otra.

Hay **simulación relativa** cuando se aparenta celebrar un acto, pero las partes quieren en verdad otro distinto. Coexisten entonces dos actos: el *ostensible o simulado*, que es el que las partes fingen celebrar, y el *oculto o disimulado*, el que de verdad quieren y mantienen en secreto mediante la contradeciaración. Esa diferencia entre uno y otro puede estar en la **naturaleza** del acto (una donación escondida detrás de una compraventa aparente), en el **objeto** (un precio de un millón declarado cuando en verdad es de dos, o una empleada de casa particular contratada en el acto ostensible cuando el acto secreto pacta un objeto ilícito), o en los **sujetos**, lo que se conoce como *interposición ficticia de persona*.

Por ejemplo: Cristina quiere vender su departamento a su marido Ignacio, pero el **art. 1796** prohíbe la compraventa entre cónyuges no separados judicialmente; para sortear la prohibición, Cristina vende el departamento a su amiga Josefina, quien de inmediato se lo revende a Ignacio. Ignacio, el contratante efectivo y oculto, es el *interponente*; Josefina, que solo figura en el título, es la *interpuesta* (prestanombre, palo blanco, hombre de paja o testaferro). El acto simulado queda sin efecto, por faltarle una causa real o tener una falsa; el disimulado, en cambio, produce sus efectos con normalidad si cumple sus propios requisitos de existencia y validez, y es nulo si no los cumple.

4.3. Sanción civil a la simulación ilícita

A quien perjudica la simulación ilícita, la ley le da legitimación para pedir que el acto simulado quede sin efecto y que se declare cuál era la voluntad real de las partes. El camino que sigue esa nulidad depende del tipo de simulación: la absoluta queda sin **causa real**, y la relativa con una **causa u objeto ilícito**, de modo que en ambos casos el acto simulado es **absolutamente nulo** (**arts. 1467 y 1681**). Un sector doctrinal agrega una vía distinta: una acción autónoma de simulación, pensada solo para fijar la voluntad real de las partes, que en la práctica se ejerce casi siempre junto a la de nulidad absoluta, como alternativa subsidiaria.

Esa regla de la nulidad absoluta tiene una salida: si el propio legislador fijó una sanción especial distinta, es esa la que rige, por aplicación del **art. 10**. El **art. 1768** es un ejemplo: si un cónyuge oculta o distrae dolosamente una cosa de la sociedad conyugal, pierde su porción en ella y debe restituirla doblada. **Distrae** quien se apropia exclusivamente de un bien social, en perjuicio del otro cónyuge, de sus herederos o de los acreedores sociales; **oculta** quien, con el mismo fin, lo esconde, lo hace desaparecer o niega conocerlo o tenerlo, pese a lo contrario. Esta sanción se ha aplicado, en la práctica, a las compraventas que un cónyuge simula para defraudar al otro en la liquidación de la sociedad conyugal (RDJ, t. 55, sec. 1ª, p. 188).

Conviene distinguir, además, los efectos según el tipo de simulación y si se trata de las partes o de terceros:

EFEECTO	SIMULACIÓN ABSOLUTA	SIMULACIÓN RELATIVA
Entre las partes	El acto aparente no produce efecto alguno; cualquiera de las partes puede enervar sus efectos, por vía de acción o de excepción, si la otra pretende hacerlo valer	Prima la voluntad real: rige el acto oculto y carece de valor el aparente. Ninguna parte puede oponer a la otra el acto simulado para eludir el cumplimiento del acto oculto: esa facultad, según el art. 1707 , es solo de los terceros
Frente a terceros de buena fe	El acto simulado o público se considera existente	También se considera existente y válido; las partes no pueden aprovecharse de su propia simulación frente a ellos

En la simulación relativa hay, todavía, una protección extra para los terceros, que pueden elegir el acto que más les convenga: si el acto aparente les basta, pueden ampararse en él oponiendo una excepción de simulación (**art. 1707**); si en cambio el acto aparente los perjudica, pueden preferir el acto real ejerciendo derechamente una acción de simulación.

4.4. Consideraciones probatorias

La simulación casi nunca se puede probar de forma directa, y por eso la **prueba de presunciones** pasa a ser decisiva: como explica Ferrara, "los simuladores no serán tan ingenuos como para dejar accesibles testimonios de sus maniobras, para que luego se las enrosten y emerjan las consecuencias adversas a sus planes". Ya en 1918, en un fallo que sigue citándose, la Corte Suprema resolvió que los terceros pueden valerse de "todos los medios que la ley permite para acreditar el fraude, incluso las presunciones".

Quien alega la simulación debe probarla, porque la ley presume sinceros los actos y contratos. A los terceros se les permite valerse de cualquier medio, incluida la prueba de testigos aunque la obligación supere las dos unidades tributarias (**art. 1709** inc. 1°): lo que prueban no es la obligación, sino la simulación misma. Entre las partes, en cambio, la prueba de testigos está vedada (**art. 1709** inc. 2°) y se aplican las reglas de la responsabilidad contractual. Hay una razón adicional para esa prueba amplia de los terceros: la jurisprudencia trata la simulación ilícita como un verdadero **delito civil**, de modo que deben acreditarla con las reglas probatorias del ámbito delictual, no del contractual.

JURISPRUDENCIA

C. DE CONCEPCIÓN, 29 DE AGOSTO DE 1997 (CONFIRMADA POR LA CORTE SUPREMA, 20 DE OCTUBRE DE 1997)

La simulación, como divergencia psicológica que es de la intención de los declarantes, se sustrae a la prueba directa: se induce, se infiere del ambiente en que ha nacido el contrato, de las relaciones entre las partes, del contenido de aquel y de las circunstancias que lo acompañan, siendo por ende una prueba indirecta, de indicios y de conjeturas, que es lo que verdaderamente hiere a fondo la simulación, porque la combate en su propio terreno.

CORTE SUPREMA, FALLOS DE 30 DE MARZO DE 2015 Y 30 DE MARZO DE 2017

La generalidad de la doctrina y jurisprudencia ha deducido dos consecuencias probatorias: que la valoración de los distintos medios de prueba debe efectuarse algo alejada de la rigurosidad que en algunos ordenamientos impone la tarifa legal, quedando siempre márgenes de apreciación prudencial que el tribunal debe emplear particularmente en esta materia; y que, tratándose de simulación, la prueba de presunciones se eleva a una consideración primordial y de decisiva influencia, como única actitud equitativa para conceder al demandante una opción real de éxito.

4.5. La acción de simulación

Esta acción tiene el perfil de cualquier acción personal: es declarativa, transmisible y prescribe según las reglas generales. Lo particular está en cuándo empieza a correr ese plazo. Entre las partes,

corre desde que una de ellas intenta desconocer el acto real y darle validez al simulado, porque antes de eso no hay ningún interés en demandar. Los terceros, en cambio, solo pueden accionar si tienen un interés actual y patrimonial en que se declare la simulación (sin interés no hay acción), y para ellos el plazo corre desde que supieron del acto disimulado; eso sí, nunca pueden demandar si ya operó la prescripción adquisitiva a favor de quien adquirió la cosa con el contrato simulado.

De la simulación pueden nacer, además, dos acciones distintas e independientes entre sí: una **civil**, para dejar sin efecto el contrato (sea declarando su nulidad o constatando que nunca existió) y cobrar la indemnización de perjuicios; y otra **penal**, dirigida contra quienes celebraron el contrato simulado para defraudar a terceros.

E. LA INOPONIBILIDAD

1. CONCEPTO

La inoponibilidad sanciona, no al acto mismo, sino al intento de hacerlo valer frente a ciertos terceros: un derecho que nace de un acto jurídico válido, o de uno nulo, revocado o resuelto, puede dejar de alcanzarlos si esos efectos los perjudican, y la ley les permite oponerse a ellos. Por eso no es un vicio del acto ni compromete su validez. Para explicarla, **DUCCI** distingue entre los efectos de un acto jurídico (los derechos y obligaciones que de él emanan, que solo obligan a las partes) y su realidad jurídica, que los terceros no pueden desconocer, salvo que en determinadas circunstancias la ley misma los autorice a alegar que el acto no les empece.

No cualquier tercero puede alegarla. La regla general favorece a los **terceros relativos**, esto es, quienes no son representantes de las partes pero sí están o estarán en alguna relación jurídica con ellas (**VODANOVIC** los llama terceros interesados); queda fuera el **tercero absoluto**, por completo ajeno al acto. Pero esa regla tiene excepciones puntuales, como advierte **LÓPEZ SANTA MARÍA**: en la venta, el arrendamiento o la prenda de cosa ajena, es justamente el verdadero dueño, un tercero absoluto, quien se beneficia de la inoponibilidad.

Nuestro Código no le dio a la inoponibilidad un tratamiento orgánico, y en su versión original ni siquiera usaba esa palabra: prefería fórmulas como *no valdrán respecto de* o *no producirán efectos contra terceros* para describir sus numerosas hipótesis. Solo leyes posteriores incorporaron el término de forma expresa, como hoy lo hacen los **arts. 225 inciso final, 246 y 1757 inciso segundo**.

2. INOPONIBILIDADES DE UN DERECHO NACIDO DE UN ACTO JURÍDICO VÁLIDO

La ley reparte sus numerosas hipótesis de inoponibilidad en dos grandes categorías. Son de **forma** cuando lo que falta es una formalidad que la ley no exige para que el acto se constituya, sino para

que sus efectos puedan oponerse a terceros; son de **fondo** cuando, sin que falte ninguna formalidad, los efectos del acto terminan hiriendo injustamente los derechos de esos terceros.

2.1. Inoponibilidades de forma

(i) **Por omisión de formalidades de publicidad.**

Destinadas a que los terceros conozcan un acto o un hecho jurídicamente relevante. Casos:

a) Contraescrituras

El **art. 1707** trata distinto a cada contraescritura según su naturaleza. La privada que altera lo pactado en una escritura pública nunca produce efectos contra terceros, simplemente porque es privada (inciso 1º). La pública, en cambio, sí puede producirlos, pero solo si se tomó razón de su contenido al margen de la escritura matriz y del traslado con que obró el tercero; si no, también les es inoponible (inciso 2º). En ambos casos, entre las partes la contraescritura vale sin problema: la norma solo busca proteger a quienes son ajenos a ella.

Art. 1707. "Las escrituras privadas hechas por los contratantes para alterar lo pactado en escritura pública, **no producirán efecto contra terceros**. Tampoco lo producirán las contraescrituras públicas, cuando no se ha tomado razón de su contenido al margen de la escritura matriz cuyas disposiciones se alteran en la contraescritura, y del traslado en cuya virtud ha obrado el tercero."

Hay quienes ven en el inciso 1º una inoponibilidad distinta, de fondo, llamada *por clandestinidad*: la idea es que el acto se celebró ocultamente y los terceros no tuvieron cómo conocerlo. Esa clasificación es discutible, porque supondría exigir un ánimo de ocultamiento o mala fe en quienes otorgaron la contraescritura, algo que la norma en ningún momento pide. Lo más preciso es leer los dos incisos del **art. 1707** como lo que son: reglas estrictamente formales, del título dedicado a los instrumentos y su valor probatorio. Por eso la contraescritura privada nunca produce efecto contra terceros (es privada), y la pública eventualmente sí lo produce, si cumple esas formas de publicidad (es pública).

b) Cesión de un crédito personal

No produce efecto contra el deudor ni contra terceros mientras no se notifica al deudor o este la acepta (**art. 1902**).

EJEMPLO**La deuda que Nicolás no sabía que había cambiado de dueño**

Bernarda le presta cien mil pesos a Nicolás. Meses después, sin decirle nada a Nicolás, Bernarda cede ese crédito a su hermano Tomás. Como la cesión nunca se le notificó a Nicolás ni este la aceptó, le es inoponible (**art. 1902**): Nicolás sigue pudiendo pagarle válidamente a Bernarda, que incluso podría verse embargado el crédito por sus propios acreedores, como si la cesión nunca hubiera ocurrido (**art. 1905**).

CONEXIONES**Cesión de un crédito personal**

Obligaciones (arts. 1901 a 1908): régimen completo de la cesión de créditos. Revisar apunte de Obligaciones, [FALTA: sección] (p. ____).

c) Sentencia que declara una prescripción

No vale contra terceros sin su competente inscripción (**art. 2513**).

d) Interdicción por disipación

No es oponible a terceros mientras la sentencia que la declara no se inscriba en el Registro de Interdicciones (**art. 447**).

e) Patria potestad

Mientras una subinscripción relativa a su ejercicio no sea cancelada por otra posterior, todo nuevo acuerdo o resolución es inoponible a terceros (**art. 246**).

Art. 246. "Mientras una subinscripción relativa al ejercicio de la patria potestad no sea cancelada por otra posterior, todo nuevo acuerdo o resolución será **inoponible a terceros**."

f) Cuidado personal

La misma regla rige para los acuerdos o resoluciones sobre el cuidado personal de los hijos, mientras la nueva subinscripción no sea cancelada por otra posterior (**art. 225** inciso final).

(ii) Por falta de fecha cierta.

Como la fecha de un instrumento privado la pueden alterar libremente las partes, no hace fe contra terceros hasta que algún hecho se la dé con certeza. El **art. 1703** enumera cuáles: el fallecimiento

de alguno de los firmantes, su copia en un registro público, su presentación en juicio, o que un funcionario competente tome razón de él o lo inventaríe; el **art. 419 del COT** agrega su protocolización. En materia mercantil la exigencia se relaja: basta que la escritura privada guarde uniformidad con los libros de los comerciantes para que haga fe de su fecha frente a terceros, aunque no se dé ninguno de esos hechos (C. de Comercio, art. 127).

2.2. Inoponibilidades de fondo

(i) Por falta de concurrencia.

Quien no concurrió a un acto como parte no tiene por qué soportarlo. El ejemplo de libro es la venta de cosa ajena: perfectamente válida, pero inoponible a su verdadero dueño (**art. 1815**); lo mismo pasa con el arrendamiento (**art. 1916**) y la prenda (**art. 2390**) de cosa ajena. También es este el caso del marido que arrienda, sin autorización de su mujer, bienes raíces sociales o de ella por más de cinco años si son urbanos u ocho si son rústicos: el contrato solo lo obliga por ese plazo legal, y la mujer, sus herederos o cesionarios pueden hacer valer esa inoponibilidad frente al exceso (**arts. 1749, 1756 y 1757**).

(ii) Por falta de poder de representación, o por exceder sus límites.

Quien actúa en nombre de otro sin tener poder para representarlo, o excediendo los límites de ese poder, no puede obligar a su representado: el socio administrador que se excede de sus facultades no obliga a la sociedad (**art. 2079**), y el caso más característico de todos, el del mandatario que obra sin poder o se extralimita (**arts. 2160 y 2154**), se estudia con más detalle al llegar a la representación.

(iii) Por fraude.

Esta causal sanciona los actos ejecutados en fraude de los derechos de terceros, y conviene no confundirla con el dolo: el dolo es un vicio del consentimiento que opera entre las partes, cuando una engaña a la otra para obtener su voluntad; el fraude, en cambio, no busca viciar ningún consentimiento, sino perjudicar deliberadamente a quienes son ajenos al acto. La **acción pauliana** es la manifestación más conocida de esta causal: permite a los acreedores perjudicados pedir la rescisión de los actos de su deudor, cumpliendo los requisitos que fija la ley (**art. 2468**). También se funda en ella la inoponibilidad de la renuncia del usufructo que el usufructuario hace en fraude de sus acreedores (**art. 803**), y las acciones revocatorias especiales de la antigua Ley de Quiebras y de la actual Ley de Reorganización y Liquidación, construidas sobre la misma idea. Queda abierta la pregunta de si, más allá de estos casos puntuales, el ordenamiento sanciona de modo general el acto fraudulento, y en particular el **fraude a la ley**, figura que se analiza a continuación.

(iv) Por lesión de derechos adquiridos.

Esta causal protege a los terceros que ya adquirieron derechos sobre una cosa, frente a los efectos de un acto posterior. Si reaparece el desaparecido y se rescinde el decreto de posesión definitiva de

sus bienes, las enajenaciones, hipotecas y demás derechos reales que terceros constituyeron legalmente sobre ellos no se ven afectados: subsisten igual (**art. 94 N° 4**).

(v) Por lesión de las asignaciones forzosas.

Cuando el testador no asigna nada a quienes la ley lo obliga a favorecer, como sus hijos, el testamento no por eso es nulo: sigue siendo válido, pero les resulta inoponible en la parte que los perjudica, y ellos tienen entonces la acción de reforma de testamento para corregirlo (**art. 1216**).

CONEXIONES

Lesión de las asignaciones forzosas

Sucesorio (**art. 1216**): acción de reforma de testamento. Revisar apunte de Sucesorio, [FALTA: sección] (p. ____).

3. INOPONIBILIDADES DE UN DERECHO NACIDO DE LA NULIDAD O RESOLUCIÓN DE UN ACTO JURÍDICO

Hay excepciones en que ni siquiera la nulidad de un acto alcanza a los terceros, que conservan el derecho a que, respecto de ellos, el acto se trate como plenamente válido. Es lo que ocurre si una sociedad existió de hecho: la nulidad del contrato social no afecta las acciones que los terceros de buena fe tienen contra cada socio (**art. 2058**), igual que, en materia mercantil, la falta de solemnidades no permite alegar la nulidad de una sociedad colectiva contra los terceros interesados en su existencia (**art. 356 inc. 3° C. de Comercio**). Algo parecido pasa con la **resolución**: aunque por regla general opera con efecto retroactivo, la que se declara judicialmente no alcanza a los terceros de buena fe (**arts. 1490 y 1491**); y en la donación, salvo las excepciones que la ley señala expresamente, ni la resolución ni la rescisión ni la revocación afectan a los terceros que poseen los bienes donados (**art. 1432**).

4. MANERAS DE HACER VALER LA INOPONIBILIDAD

Nadie puede invocar la inoponibilidad en lugar del interesado: el juez no puede declararla de oficio, así que debe alegarla quien resulta favorecido por ella. Lo habitual es que se oponga como **excepción**, cuando alguien pretende hacer valer el acto contra el tercero protegido; solo en contados casos, como el de la acción pauliana, se ejerce derechamente como **acción**.

5. DIFERENCIAS ENTRE LA NULIDAD Y LA INOPONIBILIDAD

La nulidad y la inoponibilidad se diferencian en varios puntos:

CRITERIO	NULIDAD	INOPONIBILIDAD
Origen de la causa	Un vicio o infracción presente en el momento del nacimiento del acto jurídico	El acto jurídico es válido; una circunstancia posterior o externa determina su ineficacia frente a terceros
Alcance de la ineficacia y a quién protege	Priva de eficacia al acto tanto respecto de las partes como de los terceros; protege a las partes del acto	Deja el acto eficaz entre las partes; solo priva de efectos a ciertos terceros de buena fe, a quienes protege
Orden público o privado	De orden público: no puede renunciarse anticipadamente	De orden privado, establecida a favor de los terceros: sí puede renunciarse
Declaración de oficio	La absoluta puede y debe declararla el juez de oficio si aparece de manifiesto en el acto o contrato (art. 1683)	Nunca puede declararse de oficio: debe alegarla el interesado

F. EL FRAUDE A LA LEY

1. CONCEPTO

El fraude a la ley hunde sus raíces en el Derecho Romano, aunque se desarrolló sobre todo a partir del siglo XIX. Es una hipótesis especial de ineficacia, porque lo que sanciona no es el acto en sí (que parece lícito) sino su verdadera finalidad: servir de medio para eludir una norma imperativa que, de aplicarse directamente, impediría el resultado buscado.

EJEMPLO

Los casos clásicos del fraude a la ley

En el *Caso Bauffremont*, una condesa belga obtuvo en Francia (país que no admitía el divorcio) la separación personal de su marido; se trasladó a Alemania, que sí lo permitía, se naturalizó alemana y volvió a casarse. La Corte de Casación francesa declaró nulo el segundo matrimonio y fraudulento el cambio de nacionalidad, por entender que su único fin fue sustraerse de la ley francesa. En el *Caso Fritz Mandel*, un austriaco nacionalizado argentino, con domicilio y bienes en Argentina, al ser diagnosticado de una enfermedad grave regresó a Austria, recuperó su nacionalidad de origen y testó de un modo contrario a lo que exigía la ley argentina: los tribunales resolvieron que la sucesión debía regirse igualmente por la ley argentina, porque el cambio de nacionalidad y domicilio se hizo en fraude a sus normas imperativas.

COVIELLO distingue así el acto contrario a la ley del acto en fraude de ella: "el acto es contrario a la ley cuando la voluntad del particular directa y abiertamente se enfrenta con la voluntad de la ley; y es en fraude de la ley cuando la voluntad del particular, respetándola aparentemente, la viola; lo cual ocurre cuando una persona se comporta del modo que el negocio, respetada la letra de ley, llega a violarla en su espíritu". Para **LARENZ**, hay negocio en fraude "cuando las partes pretenden alcanzar la finalidad de un negocio prohibido por la ley con la ayuda de otro que no está expresamente prohibido".

En Chile, **VIAL** recoge la definición de **LIGEROPoulos** que cita **VERGARA BAEZA**: el fraude a la ley consiste en "procedimientos en sí lícitos, o maniobras jurídicas a veces ingeniosas, que tienen la apariencia de legalidad y que, sin embargo, permiten realizar lo que la ley prohíbe o no hacer lo que la ley ordena". Del mismo **VERGARA BAEZA** toma otras dos formulaciones. Según una, "hay fraude a la ley cada vez que un acto es hecho con la intención de sustraerlo a la aplicación de las normas a las que el legislador entendió someterlo". Según la otra, "el fraude a la ley puede concebirse de dos maneras: como una derogación indirecta de una regla imperativa o prohibitiva expresa; o como una violación del espíritu de tal regla al abrigo de una redacción demasiado absoluta".

Para **ALCALDE**, "el acto o conducta fraudulenta tiene la apariencia de la licitud, aunque sus resultados sean, en definitiva, antijurídicos, y constituye una infracción encubierta, pero infracción al fin y al cabo, del ordenamiento".

EJEMPLO

El tío Lucho se adelanta al juez

El tío Lucho lleva dos años dejando la jubilación y los ahorros en el casino de Viña, y sus hermanos ya pidieron que lo declaren en interdicción por disipación (el juego habitual en que se arriesgan porciones considerables del patrimonio la autoriza, **art. 445**). Antes de que el juez la decreta, el tío Lucho vende a la rápida su parcela en Pirque y su camioneta. Como todavía no está en interdicción, es plenamente capaz (el **art. 1447** inc. 3° solo hace incapaz al disipador "que se halle bajo interdicción"; el decreto, además, debe inscribirse y publicarse, **art. 447**), así que cada venta, mirada sola, es válida. Pero la doctrina ve aquí un fraude a la ley: lo que la ley quiere es que el disipador deje de administrar sus bienes, y el tío Lucho alcanza a disponer de ellos justo antes de que eso ocurra.

2. EL FRAUDE A LA LEY EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO NACIONAL

Otros códigos más modernos sí regulan el fraude a la ley de forma expresa, como el argentino de 2014 (**art. 12**); el nuestro, en cambio, guarda silencio. Pero ese silencio no impide llegar, sin controversia, a una conclusión: el Código de **BELLO** se inspira en el principio *fraus omnia corrumpit*.

pit (el fraude todo lo corrompe). DOMÍNGUEZ llega a esa misma conclusión por dos caminos distintos, el moral y el del texto positivo. Desde el iusnaturalismo, razona este autor, el valor de un acto es inseparable de su fin desde el momento en que ese fin se vuelve ilícito: un fin lícito no legitima un acto ilícito (el fin no justifica los medios), pero un fin ilícito sí vicia un acto que, en sí mismo, era perfectamente lícito, y nadie puede aprovecharse de la bondad propia de un acto para desviarlo hacia un fin que no le es propio.

Ya el **Mensaje** del propio Código alude, en su primer párrafo, a *los abusos que introduce la mala fe, fecunda en arbitrios para eludir precauciones legales*. Desde el texto positivo, el principio aparece de forma constante en normas puntuales: el **art. 11**, que manda aplicar la ley aunque se alegue ausencia de fraude en el caso concreto; el **art. 219**, sobre el fraude de falso parto; el **art. 497 N° 12**, que inhabilita para ser guardador a quien por fraude fue condenado a indemnizar a su pupilo; el **art. 539 N° 2**, que establece como causal de remoción del guardador el fraude en el ejercicio de su cargo, reiterada en el **art. 541**.

El **art. 555**, a propósito de las asociaciones, alude al *delito de fraude*; el **art. 706** exige para la posesión de buena fe la convicción de haber adquirido el dominio por medios exentos de fraude; el **art. 803** sanciona la renuncia fraudulenta del usufructo; el **art. 1578 N° 3** anula el pago hecho al deudor insolvente en fraude de sus acreedores; el **art. 1662** excluye la compensación frente a la indemnización por un acto de fraude; el **art. 1792-24** permite perseguir los bienes enajenados en fraude de los derechos del cónyuge acreedor en la participación en los gananciales; y el **art. 2317** hace solidaria la responsabilidad de quienes cometen un fraude en conjunto.

Normas más recientes sí lo reconocen expresamente: el **art. 83 de la Ley de Matrimonio Civil** (2004) desconoce valor a las sentencias de divorcio obtenidas en fraude a la ley chilena (pensada, precisamente, para casos como el *Caso Bauffremont*): se entiende que hay fraude cuando el divorcio se declaró bajo una jurisdicción distinta de la chilena pese a que los cónyuges tuvieron domicilio en Chile durante cualquiera de los tres años anteriores a la sentencia que se pretende ejecutar (si ambos aceptan que su convivencia cesó al menos ese lapso), o durante cualquiera de los cinco años anteriores (si discrepan sobre el plazo de cese). Y el **art. 4 ter del Código Tributario** (2014) sanciona, bajo el nombre de *abuso de formas jurídicas*, los actos que evitan el hecho gravado sin producir efectos jurídicos o económicos relevantes distintos de los tributarios.

EJEMPLO

Interposición de un tercero para burlar la prohibición de compraventa entre cónyuges

VODANOVIC propone un ejemplo clásico: para eludir la prohibición del **art. 1796** de vender entre cónyuges no separados judicialmente, uno de ellos le vende un bien a un tercero, que de inmediato se lo revende al otro cónyuge. Cada compraventa, mirada por separado, es perfectamente válida; juntas, sin embargo, producen exactamente el resultado que la ley quiso impedir, y por eso son anulables. Es un criterio que la Corte Suprema ha reconocido.

3. REQUISITOS PARA QUE UN OBRAR SEA EN FRAUDE A LA LEY

(i) Los actos deben ser, en sí mismos, lícitos.

No basta con un acto aislado: todo el conjunto de actuaciones debe verse, al menos en apariencia, ajustado al ordenamiento. **FERRARA** identifica tres métodos habituales para lograrlo: recurrir a un negocio distinto o a una combinación de actos; modificar las condiciones de hecho; o interponer personas.

(ii) Debe existir una ley defraudada.

Acá lo que se infringe no es la letra de la norma, sino su finalidad, y de manera indirecta: el resultado práctico que se obtiene termina siendo idéntico, o al menos equivalente, al que la norma prohibitiva o imperativa quería evitar. Dos ejemplos que la doctrina civil repite: la separación de bienes y liquidación de la sociedad conyugal, usada para evadir el derecho de prenda general de los acreedores, y la constitución de sociedades para que sus socios, como personas naturales, ejerzan actividades que a ellos les estarían vedadas. **VIAL** llama a este requisito el **elemento material u objetivo**: la similitud o equivalencia práctica entre el resultado que persigue el acto y el que la norma prohíbe.

EJEMPLO

La separación de bienes que llegó justo a tiempo

El Gastón sabe que su empresa está a punto de quebrar. Para que sus acreedores no alcancen los bienes de la sociedad conyugal, se separa de bienes de común acuerdo con su mujer, la Antonia, y le transfiere de inmediato a ella el departamento y el auto. Cada acto, mirado aisladamente, es perfectamente lícito: la separación de bienes y la transferencia son actos permitidos. Pero la combinación persigue exactamente el resultado que la ley prohíbe: sustraer esos bienes del derecho de prenda general de sus acreedores.

(iii) Un elemento intencional.

VIAL lo llama **elemento intencional o subjetivo**: el propósito de burlar la norma y obtener el resultado que ella no quiere, al que se denomina **ánimo fraudatorio**. No hay acuerdo sobre si es indispensable ni sobre qué tan exigente debe ser.

Para una **postura objetiva**, basta que el resultado choque con la norma, aunque no haya mala fe. Así lo plantea **COVIELLO**: el elemento intencional "podrá, a lo más, tener eficacia demostrativa del fraude, cuando éste exista, pero no podrá constituirlo". Para una **postura subjetiva**, en cambio, el ánimo fraudatorio es de la esencia del fraude, y por esa vía el fraude se une con la causa: la intención fraudulenta es una **causa ilícita** (II.D La causa). Entre quienes piden algún componente subjetivo, unos exigen derechamente dolo, y una posición intermedia se conforma con algún grado

de culpabilidad (dolo directo, dolo eventual, o incluso simple culpa), sin llegar a pedir una intención manifiesta y declarada de burlar la ley.

4. FRAUDE A LA LEY Y FIGURAS AFINES

4.1. Fraude a la ley y simulación

Entre la simulación y el fraude a la ley hay semejanzas notorias: las dos buscan crear una apariencia de legitimidad para producir un efecto engañoso, y las dos persiguen eludir una disposición legal. Para la mayoría de la doctrina, sin embargo, son figuras autónomas, porque mientras la simulación es solo una apariencia, un velo sobre la realidad, el fraude a la ley consiste en actos reales, efectivamente queridos y realizados, que combinados de cierta manera, aun siendo lícitos cada uno por separado, terminan burlando la ley.

DOMÍNGUEZ agrega otra diferencia: la simulación no es por sí sola ilícita (existe la simulación lícita), mientras que el negocio fraudulento, que busca sustraer a su autor del alcance de una norma obligatoria, nunca puede ser neutro ante el derecho. **ALCALDE** matiza esta distinción mayoritaria: aunque las diferencias propuestas son correctas desde una perspectiva científica o académica, pierden algo de consistencia frente a la realidad de los hechos, porque el acto en fraude a la ley también persigue un fin distinto del que naturalmente le corresponde, creando una apariencia tras la cual se esconde una infracción legal, del mismo modo en que el acto simulado no manifiesta el verdadero querer interno de las partes.

Frente a una norma que prohíbe un acto, el particular puede acatarla y abstenerse, infringirla abiertamente o infringirla de manera encubierta. Para lo último, explica **CARIOTA FERRARA** (citado por **VIAL**), hay dos caminos. Uno es la simulación relativa, que esconde el negocio prohibido bajo la apariencia de uno lícito: "descubierta la simulación, arrancada la careta, el negocio disimulado es nulo, porque es *contra legem*". El otro, "más tortuoso, más difícil de recorrer, por lo general menos satisfactorio, pero más seguro", no usa el negocio prohibido sino otro distinto, o un complejo de negocios y actos, para conseguir un resultado análogo al prohibido: eso es el fraude a la ley.

VIAL, citando a **FERRARA**, lo resume en una frase: "con el acto en fraude a la ley se pretende eludir un precepto legal; mientras que, con la simulación, se pretende esconder u ocultar la violación de un precepto legal". **VODANOVIC**, por su parte, agrega tres diferencias entre ambas figuras:

- (i) Realidad del acto: el acto simulado produce solo una apariencia de contrato; el acto en fraude a la ley es real y efectivamente querido.
- (ii) Forma de la infracción: el acto simulado, cuando es ilícito, viola la ley directamente; el fraudulento solo la viola de forma indirecta, respetando su letra pero contrariando su espíritu.
- (iii) Licitud: la simulación puede ser lícita o ilícita; el fraude a la ley es siempre ilícito.

4.2. Fraude a la ley y abuso del derecho (en su variante de abuso de formas jurídicas)

El abuso del derecho es una manifestación del principio de la buena fe como límite al ejercicio de los derechos subjetivos: quien lo traspasa obra de modo abusivo e ilícito. Como explica **FERREIRA**, "la buena fe indica un límite, es decir algo que no debe sobrepasarse, sin provocar consecuencias negativas. Ese margen está representado por el respeto a los demás, por el cumplimiento de las normas que impone la buena fe". **DIEZ-PICAZO** agrega que "el ejercicio de un derecho subjetivo es contrario a la buena fe no solo cuando no se utiliza para la finalidad objetiva o función económica o social para la cual ha sido atribuido a su titular, sino también cuando se ejerce de una manera o en unas circunstancias que lo hacen desleal, según las reglas que la conciencia social impone en el tráfico jurídico". Y **BARROS**, en Chile, la resume como "aquel núcleo de sentido que subyace a las normas atributivas de derechos, que se muestra en los límites que la norma no expresa, pero da por supuesto".

La doctrina ha ido catalogando distintas conductas como abuso del derecho: ejercer un derecho con el solo propósito de dañar a otro, una desproporción extrema entre el interés del titular y el perjuicio que causa, actuar contra los propios actos anteriores, ejercer de mala fe un derecho adquirido, o desviar del fin que le es propio un derecho potestativo. En todas ellas, para la doctrina mayoritaria, debe concurrir algún elemento subjetivo, sea dolo o culpa. Una variante especialmente relevante en materia tributaria es el *abuso de formas jurídicas*, hoy reconocido en el **art. 4 ter del Código Tributario**.

No hay acuerdo sobre cómo se relacionan el fraude a la ley y el abuso del derecho: para algunos son figuras similares, para otros están en relación de género a especie, y para otros son institutos del todo distintos. Hay, eso sí, un punto de contacto claro. En sus hipótesis ordinarias, el abuso del derecho consiste en ejercer indebidamente un derecho subjetivo concreto que perjudica a quien debe soportarlo; pero en el abuso de formas jurídicas, igual que en el fraude a la ley, lo que se abusa ya no es un derecho frente a una persona determinada, sino algo más amplio: la autonomía privada misma. **BARROS** lo plantea así: "existe *abuso de la autonomía privada* cuando para evitar la aplicación de una norma de orden público se realizan uno o más actos jurídicos que formalmente son lícitos, pero que conducen al efecto económico que la ley pretende impedir. Es el caso del fraude a la ley, que constituye un tipo de desviación del fin en el ejercicio de una potestad".

5. SANCIÓN AL FRAUDE A LA LEY

No hay una sanción única para el acto fraudulento: según la hipótesis legal, puede ser **inoponible** (**arts. 803 y 1792-24**), **nulo** (**art. 1578 N° 3**), o dar derecho a **indemnización de perjuicios** (**arts. 1662 y 2317**). Para los casos que la ley no normó expresamente, la doctrina no se pone de acuerdo. **DOMÍNGUEZ** defiende la **inoponibilidad**: esa sanción restituye la vigencia de la norma eludida sin ir más allá, dejando el acto válido pero sin efecto frente a quien puede alegarla. Otros prefieren la **nulidad absoluta**, por asimilar el acto a uno prohibido por la ley o de causa ilícita, si-

guiendo la lógica del **art. 1344 del Código italiano**, que declara ilícita la causa del contrato que sirve para eludir una norma imperativa.

Entre quienes sostienen la nulidad absoluta está **VIAL**. Para él, en el acto en fraude a la ley la ilicitud no está en el acto mismo, que no infringe abiertamente la norma, sino en los motivos que lo inspiran, que revelan la intención de burlarla; por eso estos actos se equiparan a los *contra legem*. **VIAL** afirma incluso que en esto hay coincidencia en la doctrina, aunque, como se vio, **DOMÍNGUEZ** defiende la inoponibilidad.

Para zanjar el debate conviene mirar caso por caso. Con un criterio objetivo de causa, el acto que tuvo por causa eludir una ley imperativa queda, sin más, dentro de la **nulidad absoluta** por causa ilícita (**art. 10**). El **fraude a los acreedores** es un caso especial: mientras no se abra un concurso, el espíritu general de la legislación (**arts. 803, 1792-24 y, sobre todo, 2468**, que consagra la acción pauliana) apunta a la **inoponibilidad**. Una vez abierto el concurso, en cambio, el deudor queda desasido de sus bienes (su administración pasa a un tercero) y la ley prohíbe derechamente los actos de enajenación, de modo que ahí la sanción pasa a ser la nulidad (**arts. 1578 N° 3 y 2467**). En cualquiera de los dos escenarios, además, siempre queda abierta la responsabilidad civil del autor del fraude y la indemnización de los perjuicios que haya causado (**arts. 1662 y 2317**).

CONEXIONES

La acción pauliana o revocatoria

Obligaciones (**art. 2468** y ss.): el fraude a los acreedores como fundamento de la acción pauliana. Revisar apunte de Obligaciones, [FALTA: sección] (p. ____).

G. OTRAS CAUSALES DE INEFICACIA

Las causales que siguen reciben un tratamiento más detenido en otros ramos del derecho civil, así que aquí basta una presentación breve de cada una. Todas comparten dos ejes: pueden mirar a las partes o a los terceros, y pueden ser originarias (desde que nace el acto) o sucesivas (por un hecho posterior).

1. LA SUSPENSIÓN

Un acto queda suspendido cuando sus efectos están condicionados a un hecho que todavía no ocurre: puede ser una condición suspensiva que fijaron las partes, o una condición legal (*condictio iuris*), un hecho que la propia ley exige antes de que el acto produzca efectos. El testamento, por ejemplo, queda inmóvil hasta que el testador muere, porque esa muerte es su condición legal; las capitulaciones matrimoniales quedan suspendidas hasta que el matrimonio se celebra y se subinscribe dentro de los treinta días siguientes, requisito sin el cual no valen ni entre las partes ni frente

a terceros (**art. 1716** inciso 1°). Mientras la condición todavía pueda cumplirse, la suspensión es transitoria; pero se vuelve definitiva en cuanto queda claro que ya no se cumplirá, como cuando uno de los esposos muere antes de que se celebre el matrimonio proyectado.

2. LA RESOLUCIÓN

Un acto se vuelve ineficaz por resolución cuando, después de celebrado, ocurre un hecho que hace cesar los efectos ya producidos. Ese hecho puede ser de dos clases: un acontecimiento futuro e incierto al que las partes subordinaron la extinción de un derecho (**condición resolutoria ordinaria**, como un padre que presta en comodato una casa a su hijo hasta que este se traslade a Europa), o el incumplimiento de una de las partes de un contrato bilateral (**condición resolutoria tácita**), que le da a la parte diligente la opción de pedir, a su arbitrio, la resolución o el cumplimiento del contrato, con indemnización de perjuicios en cualquiera de los dos casos (**art. 1489**). Declarada la resolución, no procede la acción reivindicatoria contra terceros poseedores de buena fe si la cosa era mueble (**art. 1490**); tratándose de inmuebles, la resolución solo afecta al tercero si la condición constaba en el título respectivo, inscrito u otorgado por escritura pública (**art. 1491**).

3. LA RESCILIACIÓN

Las partes, cuando son capaces de disponer libremente de lo suyo, pueden extinguir sus obligaciones de mutuo acuerdo, dejando sin efecto el contrato del que nacieron (**art. 1567** inciso 1°): eso es la resciliación. A los terceros ese acuerdo nunca puede afectarlos, por definición: les es inoponible, *res inter alios acta*.

4. LA REVOCACIÓN

Cuando la ley lo permite, quien celebró un acto puede retractarse de él por su sola voluntad: eso es la revocación, posible incluso en actos bilaterales. El testamento es, por naturaleza, siempre revocable; pero no todo acto unilateral lo es, como la ratificación que hace el mandante de lo obrado por un mandatario extralimitado, que una vez conocida por sus destinatarios ya no puede retractarse. Los contratos, en cambio, son irrevocables por regla general: ninguna parte puede dejarlos sin efecto por sí sola, se necesita el consentimiento de ambas (mutuo disenso), a menos que la propia ley autorice su término por voluntad de una sola, como ocurre cuando el mandante revoca el mandato (**art. 2163**).

5. EL DESISTIMIENTO UNILATERAL

El desistimiento unilateral es otra forma de terminar una relación contractual por decisión de una sola parte, comunicada a la otra, pero su ejercicio es excepcional: solo procede cuando la ley lo

permite o las partes lo pactaron, típicamente en contratos de duración indeterminada o de ejecución continuada, como el desahucio en el arrendamiento o en el contrato de trabajo. Suele exigir un aviso previo con cierta anticipación, y es común pactar una multa o arras penitenciales a modo de contraprestación. No debe confundirse con la revocación: esta ataca el acto jurídico mismo, y sus efectos desaparecen solo como consecuencia de esa caída (como cuando se revoca una donación por ingratitud del donatario); el desistimiento, en cambio, deja el acto intacto y se limita a disolver la relación hacia adelante (*ex nunc*), sin retroactividad (*ex tunc*).

6. LA CADUCIDAD

La caducidad no tiene un solo significado. En su sentido más amplio es la pérdida de un derecho por no haberse ejercido dentro del plazo que fijó la ley o las propias partes (lo que los franceses llaman *forclusion* y los italianos, *decadenza*), o la extinción de una relación jurídica por hechos sobrevinientes, con o sin efecto retroactivo según el caso (*déchéance* en Francia, *caducità* en Italia). En un sentido más específico, es la ineficacia que la propia ley le impone a un acto por un hecho sobreviniente, sin que haga falta revocarlo: así caducan los testamentos privilegiados en los casos que la ley señala (**art. 1212** inciso 2°), como el testamento verbal otorgado a bordo de un buque de guerra, que caduca si el testador sobrevive al peligro (**art. 1053**), o las donaciones revocables, que caducan por la sola muerte del donatario antes que la del donante (**art. 1143**).

7. LA TERMINACIÓN

A diferencia de la resolución, la terminación no opera retroactivamente: solo priva de efectos al acto hacia el futuro, dejando intactos los ya producidos. Es la ineficacia propia de los contratos de **tracto sucesivo** (el arrendamiento, la sociedad), donde retrotraer lo ya cumplido, como los meses de arriendo ya gozados o el tiempo ya trabajado en común, sería impracticable o derechamente injusto. Reunidos esos requisitos, la terminación surte plenos efectos también frente a terceros, que no pueden desconocerla.

8. LA RENUNCIA

Es la dejación unilateral de un derecho por su titular, admitida excepcionalmente en ciertos actos, como el mandato o la sociedad (**art. 2163**). Por regla general, solo produce efectos una vez que la otra parte está en condiciones razonables de resguardar sus propios intereses frente al término de la relación: quien renuncia intempestivamente, sin dar tiempo a la contraparte para adoptar los resguardos necesarios, puede quedar obligado a indemnizar los perjuicios que esa renuncia le cause. Esa misma oponibilidad alcanza a los terceros: corre desde el mismo momento en que la renuncia ya es oponible a la contraparte.

9. LA MUERTE

Cuando un acto se celebró en consideración a la persona de una de las partes (*intuito personae*), su muerte puede volverlo ineficaz: es lo que pasa con el mandato, que expira si muere el mandante o el mandatario (**art. 2163**), con la sociedad, que se disuelve si muere cualquiera de los socios salvo pacto en contrario, con el comodato prestado en atención a la persona del comodatario, o con el matrimonio. Esta ineficacia nunca es retroactiva, y siempre sanciona a quien, de mala fe, perjudica a los herederos de la parte fallecida. A los terceros los alcanza desde que se cumplen los requisitos que la ley exige, según la muerte haya sido natural o presunta.

V. LA REPRESENTACIÓN

1. CONCEPTO

Cuando alguien no actúa directamente en un acto jurídico, sino que lo hace otra persona en su lugar, provista de poder para ello, hay **representación**. Una fórmula habitual la define como la relación en la que una persona (el representante) tiene el poder de celebrar actos jurídicos en lugar e interés de otra (el representado), de modo que, mientras obre dentro de ese poder, los efectos del acto recaen de inmediato y únicamente sobre el representado. Quien celebra el acto es el representante, pero quien recibe sus efectos es exclusivamente el representado, como si él mismo lo hubiese celebrado. El **art. 1448** lo recoge así: lo que una persona ejecuta a nombre de otra, estando facultada por ella o por la ley para representarla, produce respecto del representado iguales efectos que si hubiese contratado él mismo.

2. UTILIDAD Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN

La utilidad práctica de la representación es enorme. En los absolutamente incapaces (impúberes, dementes, sordomudos que no pueden darse a entender por escrito) es, de hecho, el único recurso disponible: como carecen de voluntad propia, actúan por ellos sus representantes legales. En los incapaces relativos el recurso es más flexible: sus representantes legales a veces sustituyen directamente su voluntad, y otras veces simplemente la autorizan para que actúen por sí mismos. Y fuera del terreno de la incapacidad, la representación voluntaria también presta un servicio evidente: permite que alguien actúe en un acto del que una persona capaz está impedida de participar, por enfermedad, por distancia, o porque conviene que la represente alguien especializado, como el abogado o el procurador en un juicio.

La regla general es amplia: puede hacerse por representante todo lo que puede hacerse personalmente. Las excepciones son puntuales y deben estar expresamente establecidas en la ley: la facultad de testar es indelegable (**art. 1004**), y tampoco puede delegarse en un mandatario la ratificación, ante el Oficial del Registro Civil, del matrimonio contraído ante un ministro de culto (**art. 15 inc. 2º Ley de Registro Civil**, en relación con el **art. 20 de la Ley de Matrimonio Civil**).

3. PODER DE REPRESENTACIÓN

3.1. Conceptos generales

Tener **poder de representación** significa estar autorizado para concertar negocios por cuenta de otro, de modo que ese otro, y solo él, queda obligado. Al acto que atribuye ese poder se le llama **apoderamiento**.

3.2. Clases de representación

El **art. 1448** deja ver que ese poder puede tener dos orígenes: la ley, o la voluntad del propio interesado.

(i) Representación legal.

Hay representación legal cuando una persona está jurídicamente impedida de ejercer por sí sola su autonomía privada. El **art. 43** menciona a uno o ambos progenitores, al adoptante y al tutor o curador como los representantes legales más comunes, pero la lista no es taxativa: también lo son el juez en las ventas forzadas (**art. 671**) y el partidor en las enajenaciones que se hacen dentro de una partición (**art. 659 C.P.C.**). Que el nombramiento venga de una resolución judicial, como en estos dos casos, no cambia la naturaleza de la representación: sigue siendo la ley la que se la atribuye a quien el juez designa, que solo determina quién ocupa ese lugar. Pensar lo contrario obligaría a sostener que los curadores dativos también ejercen una representación de origen judicial y no legal, cuando el propio **art. 43** los incluye expresamente entre los representantes legales.

(ii) Representación voluntaria.

La representación voluntaria, en cambio, nace solo de la decisión del interesado de otorgarle poder a otra persona para que actúe en su nombre. Esa libertad es amplia: el interesado decide si actúa personalmente o no, y si opta por representarse, también decide a quién elegir, incluso a alguien incapaz.

3.3. Mandato y representación voluntaria

El mandato es el contrato por el que una persona (el mandante) le confía a otra (el mandatario) la gestión de uno o más negocios, que esta asume por cuenta y riesgo de la primera (**art. 2116**). Mandato y apoderamiento, aunque van de la mano, no son lo mismo: el mandato es un vínculo contractual entre dos personas; el apoderamiento, en cambio, es un acto jurídico **unilateral**, por el que una sola persona le confiere a otra la facultad de representarla. De ahí que la representación sea independiente del mandato: hay mandato sin representación cuando el mandatario contrata a su propio nombre, y hay representación sin mandato en la representación legal, o en la agencia oficiosa (el cuasicontrato por el que quien administra sin mandato los negocios de otra persona se obliga para con ella, y a veces también la obliga a ella).

De esa independencia salen dos precisiones. La primera: la representación voluntaria no exige un mandato previo, porque el poder de representar puede nacer antes de que el mandato se perfeccione, aunque otorgarlo ya suponga ofrecer, aunque sea tácitamente, celebrar uno. La segunda: ese orden solo vale para el nacimiento del poder, no para su *ejercicio*, porque ejercer la representación sin aceptar y cumplir el mandato es imposible. De ahí que la facultad de representar, sin necesitar mención especial para entenderse incluida, forme parte de la **naturaleza** del mandato, aunque no de su esencia.

NO CONFUNDIR**Representar no es de la esencia del mandato**

Que la facultad de representar sea de la naturaleza del mandato no significa que sea indispensable: el mandatario puede perfectamente no representar al mandante, contratando a su propio nombre aunque actúe en interés de este (**art. 2151**). Representar exige, en cambio, obrar a nombre del mandante conforme al **art. 1448**; si el mandatario obra a nombre propio, no obliga al mandante frente a terceros, por más que entre ellos sigan rigiendo las reglas del mandato. Así, frente a terceros el mandatario queda como titular de los derechos que nacen del acto que celebró; frente al mandante, sigue siendo su mandatario, nada más.

4. NATURALEZA JURÍDICA DE LA REPRESENTACIÓN

4.1. Teoría de la ficción

Según esta teoría, es el representado quien manifiesta su voluntad, solo que por mediación del representante, un simple vehículo de ella. Hoy está abandonada: no logra explicar la representación legal del demente o el impúber, a quienes la ley les da precisamente curador o tutor porque no tienen una voluntad que pudiera transmitirse.

4.2. Teoría del nuntius o mensajero

Para esta teoría, el representante no hace más que transmitir mecánicamente la voluntad del representado, como un mensajero, de modo que el contrato en realidad se celebra entre el representado y el tercero. Tampoco convence: le niega al representante su condición de tal, y mal podría transmitir una voluntad que no existe, como la del impúber o el demente.

4.3. Teoría de la cooperación de voluntades

Para esta tercera teoría, lo que explica la representación es que las voluntades del representante y del representado cooperan, concurriendo juntas a formar el acto. Se la abandonó por la maraña de distinciones que genera, y porque, igual que las dos anteriores, no logra explicar la representación legal: entre el demente o el impúber, que no tienen voluntad, y su curador o tutor, no hay ninguna voluntad con la que cooperar.

4.4. Teoría de la representación modalidad del acto jurídico

Esta teoría invierte el enfoque: es la voluntad del **representante**, no la del representado, la que participa real y directamente en la formación del acto. La representación sería entonces una **modalidad** del acto jurídico, es decir, una modificación que la ley o las partes introducen en sus conse-

cuencias naturales: lo normal es que esas consecuencias recaigan en quien celebra el acto, pero aquí se desvían hacia el representado. **ALESSANDRI** encuentra apoyo para esta teoría en el propio tenor del **art. 1448**: es el representante quien *ejecuta* el acto, y la ley simplemente le atribuye los mismos efectos que si lo hubiera ejecutado el representado, algo que confirman otras normas donde se exige la voluntad del representante (**arts. 672, 673, 678 y 721**).

JURISPRUDENCIA

CORTE SUPREMA, 9 DE ENERO DE 2017, ROL N° 14.853-2016

La Corte se pregunta cuál es la voluntad que efectivamente contrata, si la del representante o la del representado, y repasa las respuestas que se han dado: la ficción (el representado manifestaría su voluntad a través de una ficción legal que la traslada al representante), el *nuntius* o mensajero (el representante se limitaría a portar esa voluntad ajena) y la cooperación de voluntades (concurrirían ambas). Las tres se descartan por el mismo doble defecto: confunden el acto de apoderamiento con el acto representativo, y fallan sobre todo al intentar explicar la representación legal, donde no existe ninguna capacidad del representado que pudiera ser transportada o que pudiera cooperar.

La Corte se inclina, en cambio, por una lectura objetiva de la obligación: la voluntad que contrata es la del representante, y al acto que este celebra con el tercero se le agrega una modalidad. Lo habitual es que la voluntad sirva al patrimonio de quien la tiene; aquí, por esa modalidad, la voluntad del representante queda puesta al servicio de un patrimonio ajeno, el del representado, de modo que los efectos del acto no recaen en el representante sino en él. Pese a las críticas que recibe, esta es, según la propia Corte, la doctrina de la representación modalidad, hoy la de mayor aceptación, y la misma que ya habían sostenido la Corte de Temuco (29 de marzo de 1939, RDJ, t. 40, p. 304), la Corte de Santiago (29 de agosto de 1945, RDJ, t. 43, secc. 2ª, p. 65) y la propia Corte Suprema (5 de junio de 1951, RDJ, t. 48, p. 171).

Hoy no hay mayor debate: doctrina y jurisprudencia coinciden en que esta es la teoría vigente en el derecho chileno.

5. INFLUENCIA DE LAS CIRCUNSTANCIAS PERSONALES DEL REPRESENTANTE O DEL REPRESENTADO

5.1. En relación a la capacidad

En la **representación legal** la regla es simple: el representante debe ser capaz, y el representado, por lo general, no lo es (precisamente por eso necesita representante). En la **voluntaria** el esquema se invierte en parte: el representado sí debe ser capaz, porque de su capacidad depende la validez del apoderamiento (si fuera incapaz, el poder mismo no valdría); el representante, en cambio, pue-

de ser incapaz relativo, porque el **art. 2128** deja al menor adulto actuar como mandatario incluso sin autorización de su representante legal. Eso sí, las obligaciones que ese mandatario incapaz contraiga con el mandante o con terceros siguen las reglas generales de capacidad: si se contrajeron sin la autorización de su representante legal, son nulas (**art. 2128**).

5.2. En relación con las formalidades habilitantes

Conviene distinguir dos situaciones. Si el bien raíz que se enajena es del hijo de familia, y la enajenación la hace un mandatario del padre, la autorización judicial que la ley exige sigue siendo necesaria, sin excepción. Pero si quien actúa como mandatario es el propio hijo de familia, representando a un tercero capaz y dueño del inmueble, esa autorización no se necesita, porque lo que se enajena no es un bien suyo. La misma lógica rige para cualquier otra formalidad habilitante.

5.3. En relación con los vicios del consentimiento

Según qué teoría se adopte, la respuesta cambia por completo. Con la ficción o el nuncio, el error, la fuerza o el dolo solo importarían si afectan al representado; con la modalidad, en cambio, solo importan si afectan al representante. **VIAL** propone distinguir así:

(i) El error del representante

Vicia el consentimiento solo si ese mismo error también sería relevante para el representado. Rodrigo le da poder a Kevin para que le compre un reloj, siéndole indiferente el material. Si Kevin lo compra creyendo que es de oro y luego resulta ser de bronce, ese error sustancial de Kevin no invalida el contrato: no es relevante para Rodrigo, que es a quien terminan afectando los resultados.

(ii) La fuerza o el dolo sobre el representante

Cuando la fuerza o el dolo determinante recaen sobre el representante, en cambio, sí vician el consentimiento y permiten rescindir el contrato donde se produjo el vicio.

(iii) El vicio sufrido por el representado

Y si el vicio (error relevante, fuerza o dolo) lo sufrió el representado, lo que queda anulable es el poder mismo, y a través de él, también el acto representativo.

5.4. En relación a la buena o mala fe

En muchos casos la ley le da efectos distintos a la buena y a la mala fe (por ejemplo, en materia posesoria), y aquí también importa de quién es esa fe. La mala fe del representante termina afectando al representado. Y si la mala fe la tiene el representado, él carga con sus consecuencias aunque el representante haya actuado de buena fe: no podría valerse de un tercero para quedar a salvo de las sanciones que la ley le impone a la mala fe.

5.5. En relación al principio *nemo auditur propriam turpitudinem allegans*

Quien sabía o debía saber del vicio, o contrató conociendo el objeto o la causa ilícita, no puede después alegar la nulidad ni pedir que le devuelvan lo pagado: eso es claro cuando esas circunstancias se dan en el propio representado. La duda aparece cuando se dan en el representante, y ahí doctrina y jurisprudencia no coinciden: la Corte Suprema ha resuelto que el representado **sí** puede demandar la nulidad aunque el representante conociera el vicio, porque el dolo (lo que la ley castiga negando la acción) es un acto personalísimo de quien lo comete. Lo mismo vale para el objeto o la causa ilícita: el representado puede pedir la nulidad aunque el representante supiera del vicio.

6. REQUISITOS NECESARIOS PARA QUE EXISTA REPRESENTACIÓN Y PRODUZCA PLENAMENTE SUS EFECTOS

6.1. Declaración de voluntad del representante

Quien declara su propia voluntad es el representante, porque es él quien contrata. Eso tiene consecuencias distintas según el tipo de representación. En la **legal**, basta con que el representante sea capaz (si no lo es, sus actos son nulos); el representado no necesita serlo. En la **convencional**, en cambio, el representado sí debe ser capaz, tanto para el mandato del que nace el poder como para el acto que el mandatario celebra en su nombre: si el mandante es incapaz, su mandato es nulo, y declarada esa nulidad, deja de haber mandatario, de modo que lo obrado por quien actuó como tal no compromete al mandante. El mandatario mismo, en cambio, sí puede ser un incapaz relativo, como el menor adulto (**arts. 1581 y 2128**), porque lo que arriesga al actuar no es su propio patrimonio, sino el del representado.

6.2. Existencia al contratar de la *contemplatio domini*

Este requisito, la *contemplatio domini*, exige que el representante deje en claro, de un modo u otro, que actúa en nombre y por cuenta de otro, y que quien contrata con él comparta esa misma intención, aunque sea tácitamente y sin que se mencione el nombre del representado: el negocio se celebra teniendo presente al *dominus*, el representado, no a quien lo ejecuta. El **art. 1448** lo exige con la fórmula *a nombre de otra*, y el **art. 2151** lo confirma al revés: si el mandatario obra a su propio nombre, no obliga frente a terceros al mandante. Sin esa *contemplatio domini*, el acto produce efectos para el representante, no para el representado.

6.3. Existencia de poder, y obrar dentro de sus límites

El representante también necesita poder, legal o voluntario (**art. 1448**), y debe mantenerse dentro de sus límites: si se excede, ese exceso carece de poder, y el acto queda inoponible al representado. Hay, sin embargo, dos situaciones en que los efectos del acto igual recaen en otra persona, pese a la falta o el exceso de poder. Una es la **agencia oficiosa**: si el interesado no ratifica pero el negocio

le resultó útil, de todas formas hay representación legal, porque es la ley la que le impone cumplir las obligaciones que el gerente contrajo en la gestión (**art. 2290**). La otra es la **ratificación** posterior del interesado, que funciona como un poder con efecto retroactivo. El poder de representación, por su parte, se extingue por revocación (acto unilateral del poderdante), por la muerte del representado o del representante, y por la incapacidad legal sobreviniente de este último.

7. EFECTOS DE LA REPRESENTACIÓN

Sean legal o voluntaria, la representación produce los mismos efectos (**art. 1448**): los derechos y obligaciones del acto quedan radicados en el representado, exactamente como si él mismo hubiera contratado.

8. SANCIÓN DE LOS ACTOS EJECUTADOS SIN PODER O CON EXTRALIMITACIÓN

(i) La inoponibilidad como sanción general, y sus excepciones.

Según el **art. 2160**, el mandante debe cumplir las obligaciones que el mandatario contrajo a su nombre dentro de los límites del mandato; lo que quede fuera de esos límites le resulta **inoponible**, a menos que decida ratificarlo, expresa o tácitamente. El **art. 2173** marca una excepción: si el mandato ya había expirado por una causa que el mandatario ignoraba, lo que este haga sigue siendo válido y obliga al mandante frente a los terceros de buena fe; y si el mandatario, sabiendo de esa expiración, igual contrató con terceros de buena fe, el mandante también queda obligado, aunque conserva el derecho a que el mandatario lo indemnice.

(ii) Responsabilidad del representante-mandatario que se extralimitó.

Frente al **mandante**, el mandatario que se extralimitó responde contractualmente, porque incumplió su deber de ceñirse a los términos del mandato (**art. 2131**), siempre que ese exceso le haya causado un perjuicio real: si el mandante no terminó obligado frente a terceros, en principio no hay nada que reclamar. Pero puede haber perjuicio igual, aunque el mandante no quede obligado, como cuando el mandatario, además de extralimitarse, directamente no ejecutó el negocio que le encargaron (le pidieron vender un predio, y en vez de eso lo hipotecó). Si el mandante ratifica los contratos del mandatario, se entiende que renuncia a reclamarle perjuicios, aunque esos contratos le resulten dañosos, porque asumió voluntariamente la obligación de cumplirlos. Y la responsabilidad del mandatario desaparece si se excedió del mandato por una necesidad imperiosa, porque ahí pasa a actuar como agente oficioso (**art. 2122**).

Frente a los **terceros**, en cambio, el mandatario no responde por regla general (**art. 2154**), salvo en dos situaciones: que no les haya informado suficientemente sus poderes, o que se haya obligado personalmente ante ellos. En el primer caso, la negligencia es del mandatario, que responde extracontractualmente ante los terceros que de buena fe creyeron que sus poderes eran más amplios de

lo que realmente eran; si en cambio informó bien sus poderes limitados, no hay nada que reprocharle, porque los terceros tuvieron cómo advertir la insuficiencia y asumieron el riesgo de que el mandante no ratificara. En el segundo caso, es el propio mandatario quien decide asumir la responsabilidad frente a los terceros si el mandante no ratifica lo actuado más allá del mandato, en un escenario parecido al de la promesa de hecho ajeno (**art. 1450**), aunque ahí no hay representación de por medio.

9. LA RATIFICACIÓN

Cuando alguien se dice representante sin serlo, o el representante de verdad se extralimita, el contrato no afecta al representado, a menos que este lo apruebe voluntariamente: esa aprobación es la **ratificación**, que no tiene nada que ver con la ratificación que sanea la nulidad relativa. Es un acto **unilateral**, posible tanto en la representación legal como en la voluntaria: en esta última está prevista expresamente para el mandatario que se extralimitó (**art. 2160**); en la legal procede igual, porque la ley no la prohíbe, y el representado incapaz puede ratificar una vez que su incapacidad termina. Puede ser expresa o tácita, y esta última se desprende de cualquier hecho inequívoco del representado que muestre su voluntad de hacer suyo lo actuado en su nombre, como exigir los derechos que el contrato le da o caucionar las obligaciones que le impone.

Es una ratificación **recepticia**: solo produce efectos una vez que la conocen el representante y el tercero. Debe venir del propio representado, de sus herederos o de sus representantes legales, todos con capacidad suficiente, y puede darse en cualquier momento, incluso después de muerto cualquiera de los involucrados, porque es independiente del contrato al que se refiere: ese contrato ya produjo sus efectos, aunque en suspenso, a la espera de que el representado los haga propios. Una vez hecha, es **irrevocable**, porque los actos jurídicos unilaterales (salvo el testamento) no pueden dejarse sin efecto por la sola voluntad de quien los creó cuando ya generaron consecuencias en un patrimonio ajeno: la Corte Suprema ha dicho que "no cabe la revocación unilateral de la ratificación que ha producido efectos respecto de terceros". Y opera con **efecto retroactivo**, hasta la fecha del contrato que celebró el representante.

Queda abierta una discusión: si el acto que se ratifica es solemne, ¿la ratificación también debe serlo? La doctrina y jurisprudencia mayoritaria contestan que sí, calcando las solemnidades del acto que se ratifica. Es una conclusión discutible: las solemnidades son de derecho estricto, y ninguna norma exige aquí esa misma exigencia, a diferencia de lo que ocurre con la ratificación del acto relativamente nulo, donde el **art. 1694** sí la impone expresamente. Ambas ratificaciones, además, no son comparables: en la del acto relativamente nulo, quien ratifica es quien ejecutó el acto, aunque con la voluntad viciada; en la del acto inoponible por extralimitación, quien ejecutó el acto fue el representante, y la voluntad del representado recién aparece con la ratificación. Por eso, más allá de su utilidad práctica, no hay una verdadera razón jurídica para exigir aquí la misma solemnidad: el acto que se ratifica ya reunió, entre representante y tercero, todas las voluntades y solemnidades que la ley pedía.

10. OTRAS HIPÓTESIS EN QUE LOS EFECTOS DE LOS ACTOS JURÍDICOS ALCANZAN A LOS TERCEROS

Por regla general, los actos jurídicos solo producen efectos para las partes: es el principio de la relatividad de los contratos. La representación es una excepción solo en apariencia, porque ahí el acto afecta a quien sustituyó su voluntad por la del representante, es decir, al representado, y este es jurídicamente parte del acto, no un tercero (se considera parte tanto a quien actúa personalmente como a quien lo hace por representante). Hay, sin embargo, dos hipótesis donde sí resultan afectados verdaderos terceros, relativos o absolutos: la estipulación para otro y la promesa de hecho ajeno.

10.1. Estipulación para otro

En la estipulación para otro, el estipulante le hace prometer al promitente una prestación en favor de un tercero, el beneficiario, que es el único habilitado para exigirla; mientras ese tercero no la acepte, expresa o tácitamente, el contrato sigue siendo revocable por quienes lo celebraron (se entiende por aceptación tácita cualquier acto que solo pudiera haberse ejecutado en virtud del contrato) (**art. 1449**). El seguro de vida es el ejemplo de manual: el asegurador se obliga a pagarle, a la muerte del asegurado, una suma de dinero a su cónyuge o a sus hijos.

Art. 1449. "Cualquiera puede estipular a favor de una tercera persona, aunque no tenga derecho para representarla; pero **sólo esta tercera persona podrá demandar lo estipulado**; y mientras no intervenga su aceptación expresa o tácita, es revocable el contrato por la sola voluntad de las partes que concurrieron a él. Constituyen aceptación tácita los actos que sólo hubieran podido ejecutarse en virtud del contrato."

10.2. Promesa de hecho ajeno

En la promesa de hecho ajeno, uno de los contratantes se compromete a que un tercero (de quien no es representante) dará, hará o no hará algo; ese tercero solo queda obligado si lo ratifica él mismo, y si no ratifica, el otro contratante tiene acción de perjuicios contra quien hizo la promesa (**art. 1450**). Marcela le promete a Ignacio, que quiere comprarle su casa, que su hermano Tomás, dueño del sitio colindante, talará los árboles que tapan la vista; si Tomás no ratifica esa promesa, Ignacio no puede exigirle nada a él, pero sí demandar perjuicios a Marcela. A diferencia de la estipulación para otro, esto no es una excepción a la relatividad de los contratos: el tercero solo se obliga si ratifica, y entonces la obligación nace de su propia voluntad, no del contrato ajeno.

Art. 1450. "Siempre que uno de los contratantes se compromete a que por una tercera persona, de quien no es legítimo representante, ha de darse, hacerse o no hacerse alguna cosa, **esta tercera persona no contraerá obligación alguna, sino en virtud de su ratificación**; y si ella no ratifica, el otro contratante tendrá acción de perjuicios contra el que hizo la promesa."

VI. MODALIDADES DE LOS ACTOS JURÍDICOS

Para **RAMOS**, las modalidades son los elementos que la ley, el testamento o la voluntad de las partes establecen para alterar los efectos normales de un negocio jurídico; **ABELIUK**, por su parte, las define como las cláusulas que las partes incorporan al acto o contrato para modificar esos efectos normales en cuanto a la existencia, exigibilidad o extinción de la obligación. No son las únicas tres: lo que define a una modalidad no es su nombre, sino el solo hecho de alterar el efecto que el acto produciría sin ella. Por eso también se consideran modalidades la **solidaridad** (porque lo normal, entre varios deudores o acreedores, es que cada uno solo deba o pueda exigir su cuota, regla que la solidaridad deja sin efecto), las **obligaciones alternativas o facultativas** (que se apartan igualmente de esa normalidad) y la **representación** (porque los efectos del acto terminan radicados en el patrimonio del representado, y no en el de quien materialmente lo celebra).

Las modalidades tienen tres características.

a) Son elementos accidentales de los actos jurídicos

Se agregan al acto mediante cláusulas especiales (**art. 1444**): el acto puede perfectamente existir y producir sus efectos normales sin ellas. Dos excepciones rompen esa regla: la condición resolutoria tácita, que la ley entiende incorporada a todo contrato bilateral sin necesidad de cláusula, es un elemento de la naturaleza; y en el contrato de promesa, la condición o el plazo dejan de ser accidentales para volverse un elemento de la esencia, sin el cual el contrato no existe (**art. 1554 N° 3**).

b) Son excepcionales

Lo normal es que un acto jurídico sea puro y simple; sujetarlo a una modalidad es la excepción. De ahí se siguen tres consecuencias: quien sostiene que un acto está sujeto a una modalidad debe probarlo, las modalidades se interpretan de manera restrictiva, y no se presumen. La única excepción es la misma que se adelantó en el punto anterior: la condición resolutoria tácita, que el legislador presume incorporada en todo contrato bilateral (**art. 1489**).

c) Requieren una fuente que las cree

Ninguna modalidad surge espontáneamente: debe tener su origen en el testamento, en la convención de las partes o en la ley. La sentencia judicial, en cambio, no es por sí sola fuente de modalidades, a menos que una ley la habilite expresamente para crearlas, como el **art. 904**, que autoriza al juez a fijarle un plazo al poseedor vencido para restituir la cosa reivindicada.

La posibilidad de sujetar un acto a modalidades depende de si se trata de un acto patrimonial o de un acto de familia. En materia patrimonial rige la regla general del derecho privado, que permite hacer todo lo que la ley no prohíbe; por eso los actos patrimoniales admiten modalidades salvo que una norma expresa lo impida, como ocurre con la aceptación o repudiación de una herencia, que no puede sujetarse a condición ni a plazo (**art. 1227**), o con la legítima rigorosa, que no admite condición, plazo, modo ni gravamen alguno (**art. 1192**). Los actos de **familia** siguen la lógica con-

traría: como sus efectos los impone la ley de forma expresa e imperativa, ninguna voluntad particular puede modalizarlos.

El matrimonio ilustra esto con precisión: se define como un contrato que une a los cónyuges *actual e indisolublemente* (**art. 102**), y esas dos palabras son, en el fondo, una prohibición de modalidades. **Actual** excluye cualquier condición o plazo, porque el matrimonio produce sus efectos desde el momento mismo de su celebración; **indisolublemente** excluye cualquier modalidad resolutoria o extintiva, porque el vínculo dura por toda la vida de los cónyuges, sin que pueda subordinarse su término a un suceso futuro.

El tratamiento legal de las modalidades no está concentrado en un solo lugar del Código. Aparece, primero, en el libro III, dentro del título IV sobre las asignaciones testamentarias, en los párrafos dedicados a las condicionales (párrafo 2), a las que se sujetan a un día (párrafo 3) y a las modales (párrafo 4); y reaparece, ya en el libro IV, en el título IV, *De las obligaciones condicionales y modales*, y en el título V, *De las obligaciones a plazo*.

A. LA CONDICIÓN

1. CONCEPTO

Es un hecho futuro e incierto del cual depende el nacimiento o la extinción de un derecho (**arts. 1070 y 1473**). Lo de **futuro** excluye los hechos presentes o pasados: si las partes subordinan el acto a uno de ellos, no hay condición, y el acto es puro y simple si el hecho ya existía, o no vale si no existía (**art. 1071** en relación con el **1493**). Lo de **incierto** es lo que separa la condición del plazo: un hecho que tarde o temprano ha de ocurrir, como la muerte, nunca es por sí solo una condición, aunque sí puede llegar a serlo si se combina con otra circunstancia que sea incierta, como donar una suma de dinero a alguien si no muere antes de cumplir noventa años.

2. CLASIFICACIONES

Las condiciones admiten varias clasificaciones, según el criterio que se use para distinguirlas: por la naturaleza del hecho (positivas y negativas), por su realizabilidad (posibles e imposibles), por quién la hace depender (potestativas, casuales y mixtas) y por su efecto (suspensivas y resolutorias).

2.1. Positivas y negativas

La condición es **positiva** cuando consiste en que algo ocurra, y **negativa** cuando consiste en que algo no ocurra (**art. 1474**). Lo que decide si es una u otra es el hecho mismo, no la forma en que se redacte la cláusula: *te doy un millón si te casas* y *te doy un millón si no permaneces soltero* son,

pese a su redacción distinta, la misma condición positiva; y lo mismo ocurre entre *te doy un millón si no tienes más hijos* y *te doy un millón si te quedas con el único hijo que tienes*, ambas negativas.

2.2. Posibles e imposibles

Es **imposible** la condición que no puede verificarse, sea porque el hecho contradice las leyes de la física (**físicamente imposible**) o porque lo prohíbe la ley, las buenas costumbres o el orden público (**moralmente imposible**); la ley agrega una tercera categoría, la de las condiciones concebidas en términos ininteligibles, que la doctrina llama *intelectualmente imposibles* (**art. 1475**). El ejemplo clásico de imposibilidad física viene del derecho romano: *te doy mi fundo si tomas una estrella con la mano*. Así, también es físicamente imposible la condición *te regalo mi auto si te tomas el lago Llanquihue de un sorbo*, y moralmente imposible la del Maxi que le promete al Pipe su consola si declara como testigo, en el juicio del Maxi, algo que nunca vio: es un hecho prohibido por la ley.

2.3. Suspensiva y resolutoria

El criterio aquí es el efecto que produce el cumplimiento del hecho. Es **suspensiva** la condición que, mientras no se cumple, mantiene en suspenso la adquisición de un derecho; es **resolutoria** la que, al cumplirse, extingue un derecho que ya existía (**art. 1479**). Dicho de otro modo: en la suspensiva, de la condición depende que el derecho nazca; en la resolutoria, depende que se extinga. Por ejemplo, es suspensiva la promesa de la Jose de regalarle su notebook a su ahijado Tomi si queda en Derecho: mientras no salgan los resultados, el Tomi no tiene derecho alguno al notebook. Es resolutoria la del Kike, que le arrienda una pieza al Lucas pactando que el arriendo se termina si el Lucas se va de intercambio a Australia: el Lucas vive en la pieza desde ya, pero si se va, su derecho se extingue. La diferencia práctica entre ambas está en qué existe mientras la condición está pendiente: en la suspensiva, el acto ya existe pero no produce todavía ningún efecto; en la resolutoria, el acto produce desde ya todos sus efectos, y lo único incierto es si esos efectos se van a extinguir.

2.4. Potestativa, casual o mixta

El criterio ahora es de quién depende que el hecho ocurra. Es **potestativa** la condición que depende de la voluntad del acreedor o del deudor; **casual**, la que depende de la voluntad de un tercero o de un acaso; y **mixta**, la que depende en parte de la voluntad del acreedor y en parte de la de un tercero o de un acaso (**art. 1477**). El propio artículo deja bien definidas la potestativa y la casual, pero describe mal la mixta, porque olvida mencionar al deudor junto al acreedor; por eso la doctrina corrige la definición legal y entiende por mixta la que depende en parte de la voluntad del acreedor o del deudor, y en parte de la de un tercero o de un acaso.

Ejemplos: *si me compro una bici eléctrica, te regalo mi bici de paseo* (potestativa); *si el Cristóbal deja la pega en el taller, te la reservo a ti* (casual, de un tercero) y *si llueve en diciembre, te regalo*

un paraguas (casual, de un acaso); *si me caso con la Javiera, te donaré mi auto* (mixta, porque depende de mi voluntad y de la de ella). Dentro de la potestativa se distingue, además, entre la que depende de la mera voluntad de una persona, sin que medie ningún motivo serio para actuar o no actuar (*te daré algo si quiero*), llamada **pura o meramente potestativa**, y la que depende de un hecho voluntario que normalmente no se ejecuta ni se omite sin un motivo (hacer un viaje, por ejemplo), llamada **simplemente potestativa**.

Entre las potestativas, la regla es que todas son válidas, con una sola excepción: la condición **suspensiva** puramente potestativa que depende de la mera voluntad del **deudor**. La jurisprudencia ha explicado el porqué de esa diferencia: "la condición resolutoria puramente potestativa, dependiente de la mera voluntad de la persona que se obliga, es válida porque la obligación ha podido nacer a la vida del derecho y la condición ha afectado únicamente a su extinción. Pero la condición suspensiva meramente potestativa que depende de la mera voluntad de la persona que se obliga, es nula, porque en tal caso el deudor no manifiesta inalterablemente su voluntad de obligarse", es decir, no hay de su parte un propósito serio de obligarse, y falta entonces la voluntad seria que la existencia del acto jurídico exige.

Así, si Bastián le dice a la Fernanda *te pago cinco millones si quiero*, la obligación es nula: es una condición suspensiva puramente potestativa del deudor, porque Bastián nunca manifestó una voluntad seria de obligarse. En cambio, si Bastián le dona su auto a la Fernanda pero se reserva el derecho de quitárselo cuando quiera, la donación es válida, porque ahí la condición es resolutoria: el derecho de la Fernanda ya nació, y solo su extinción queda sujeta a la voluntad de Bastián.

Art. 1477. "Se llama condición potestativa la que depende de la voluntad del acreedor o del deudor; casual la que depende de la voluntad de un tercero o de un acaso; **mixta la que en parte depende de la voluntad del acreedor y en parte de la voluntad de un tercero o de un acaso.**"

3. ESTADOS EN QUE PUEDEN HALLARSE LAS CONDICIONES

Toda condición puede estar **pendiente** (todavía no se sabe si se realizará), **cumplida** (el hecho se verificó) o **fallida** (ya es seguro, fuera de duda, que no se realizará).

3.1. Efectos de la condición suspensiva

(i) Pendiente.

Mientras la condición está pendiente, el derecho todavía no existe: no puede exigirse el cumplimiento de la obligación, y si el deudor paga antes de que eso ocurra, puede repetir lo pagado mientras la condición siga sin cumplirse (**art. 1485**). Eso no significa que el acreedor no tenga nada: cuenta con un **derecho eventual**, que le permite pedir providencias conservativas

(**arts. 761, 1078 y 1492**) y que pasa a sus herederos si fallece mientras la condición todavía está pendiente, salvo en las asignaciones testamentarias y en las donaciones entre vivos (**art. 1492**).

Art. 1485. "No puede exigirse el cumplimiento de la obligación condicional, sino verificada la condición totalmente. **Todo lo que se hubiere pagado antes de efectuarse la condición suspensiva, podrá repetirse mientras no se hubiere cumplido.**"

Art. 1492. "El derecho del acreedor que fallece en el intervalo entre el contrato condicional y el cumplimiento de la condición, **se transmite a sus herederos**; y lo mismo sucede con la obligación del deudor. Esta regla no se aplica a las asignaciones testamentarias, ni a las donaciones entre vivos. El acreedor podrá impetrar durante dicho intervalo las providencias conservativas necesarias."

(ii) Cumplida.

Una vez cumplida, el derecho eventual se consolida y pasa a ser un derecho pleno. La ley, además, finge que esto ocurrió desde siempre: los efectos del acto se retrotraen al momento de su celebración, como si la condición nunca hubiese estado pendiente. Tiene sentido que sea así, porque lo único que había detenido esos efectos era la incertidumbre sobre si el hecho ocurriría; una vez que esa incertidumbre se despeja a favor del acreedor, no hay ninguna razón para seguir postergando lo que el acto habría producido desde el principio.

(iii) Fallida.

Si en cambio la condición falla, esa expectativa se pierde para siempre: no es que el acto deje de producir efectos hacia adelante, es que se tiene por no celebrado también hacia atrás, como si nunca hubiese existido.

3.2. Efectos de la condición resolutoria

(i) Pendiente.

Mientras la condición resolutoria está pendiente, el acto produce desde ya todos sus efectos, exactamente como si fuera puro y simple; lo único en duda es si esos efectos van a durar o se van a extinguir. Por ejemplo, le dono una casa a mi tío Walter, pero si él muere antes que yo, la donación queda sin efecto: mientras tanto, mi tío Walter disfruta la casa con toda normalidad, y solo si muere antes que yo sus herederos tendrán que restituírmela.

(ii) Cumplida.

Cuando el hecho se verifica, el derecho se extingue, y lo hace con la misma fuerza retroactiva de la condición suspensiva, pero en sentido inverso: no solo deja de producir efectos hacia el futuro,

sino que se tiene por extinguido desde siempre. Por eso cada parte debe devolver a la otra lo que recibió en virtud del acto, de manera que ambas queden en la posición en que estaban antes de celebrarlo.

Art. 1487. "Cumplida la condición resolutoria, **deberá restituirse lo que se hubiere recibido bajo tal condición**, a menos que ésta haya sido puesta en favor del acreedor exclusivamente, en cuyo caso podrá éste, si quiere, renunciarla; pero será obligado a declarar su determinación, si el deudor lo exigiere."

(iii) Fallida.

Si en cambio el hecho no se verifica y ya es seguro que no podrá verificarse, ocurre lo contrario: el derecho queda consolidado para siempre, y el acto se mira, desde su celebración, como si nunca hubiese estado sujeto a condición. Por ejemplo, le dono un millón de pesos a mi primo Gonzalo con la condición de que me lo devuelva si se casa con la Antonia: si ella fallece antes, ya no hay ninguna duda de que el hecho no podrá ocurrir, y el derecho de Gonzalo queda consolidado definitivamente.

B. EL PLAZO

1. CONCEPTO

El Código define el plazo como *la época que se fija para el cumplimiento de la obligación* (**art. 1494**). La doctrina lo precisa como un hecho futuro y **cierto** del cual depende el ejercicio o la extinción de un derecho. Comparte con la condición el ser un hecho futuro, que debe ocurrir después de celebrado el acto; se distingue de ella en que es, además, cierto: a diferencia de la condición, no cabe duda de que va a llegar.

2. SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS DEL PLAZO Y LA CONDICIÓN

El plazo y la condición comparten tres rasgos:

- (i) Ambas son modalidades de los actos jurídicos.
- (ii) Ambas son hechos futuros.
- (iii) Ambas permiten impetrar medidas conservativas.

CRITERIO	PLAZO	CONDICIÓN
Naturaleza del hecho	Cierto e inevitable	Incierto: puede o no ocurrir
Qué afecta	El ejercicio o la exigibilidad del derecho	La existencia misma del derecho
Lo pagado antes de su cumplimiento	No está sujeto a restitución (art. 1495)	Puede repetirse mientras no se cumpla (art. 1485)
Origen	Convencional, legal o judicial	Solo la voluntad de las partes o la ley

3. CLASIFICACIONES

3.1. Plazo expreso y tácito

Es **expreso** cuando las partes lo fijan ellas mismas en el acto, y **tácito** cuando, sin que nadie lo estipule, resulta necesariamente de la naturaleza de la obligación (**art. 1494**). Esto último ocurre, por ejemplo, con la obligación de entregar algo en un lugar distinto de donde se contrajo: aunque nadie lo diga expresamente, queda sobreentendido el tiempo que toma trasladarse hasta allá.

3.2. Plazo determinado e indeterminado

Es **determinado** cuando se conoce de antemano el día calendario en que el hecho va a ocurrir, e **indeterminado** cuando, sabiendo con certeza que va a ocurrir, se ignora en qué fecha (la muerte de una persona es el ejemplo clásico). La diferencia entre ambos no está en si el hecho va a pasar, porque en los dos casos eso es seguro; está en si, además, se sabe cuándo.

3.3. Plazo convencional, legal y judicial

Según quién lo fije, el plazo es **convencional**, **legal** o **judicial**. Lo habitual es que lo fijen las partes; la ley rara vez lo hace en materia civil, aunque sí con frecuencia en materia procesal, y dentro del derecho civil su ejemplo más visible son los plazos de prescripción. El juez, por su parte, solo puede fijar un plazo cuando una ley se lo permite expresamente para un caso puntual: así ocurre cuando le señala al poseedor vencido el plazo para restituir la cosa reivindicada (**art. 904**), cuando fija el momento en que el mutuario debe pagar si se pactó que lo haría *cuando le fuera posible* (**art. 2201**), o cuando amplía o restringe el plazo legal para inventariar los bienes del pupilo (**art. 378**). Fuera de esos casos, su intervención se limita a interpretar un plazo que las partes fijaron en términos vagos u oscuros (**art. 1494** inciso 2°).

3.4. Plazo suspensivo y extintivo

El plazo **suspensivo o inicial** marca el momento desde el cual el acto empieza a producir efectos: por ejemplo, si en una compraventa se estipula que el precio se paga seis meses después de celebrado el contrato, ese es el plazo suspensivo. El **extintivo o final**, al contrario, marca el momento hasta el cual esos efectos duran: en un arrendamiento por un año, cumplido ese plazo el contrato cesa.

4. EFFECTOS DEL PLAZO

4.1. Efectos del plazo suspensivo

El derecho existe desde que se celebra el acto: el plazo suspensivo no afecta su nacimiento, solo retrasa el momento en que puede **ejercerse**. Esa es justamente la diferencia con la condición suspensiva, y se nota en sus consecuencias prácticas: lo pagado antes de que venza el plazo no puede repetirse (**art. 1495**), porque el derecho a cobrarlo ya existía, mientras que lo pagado antes del cumplimiento de una condición suspensiva sí puede repetirse, porque ahí el derecho todavía no había nacido. Mientras el plazo corre, el titular puede igualmente pedir providencias conservativas; cuando vence, el derecho se vuelve exigible, pero sin ningún efecto hacia atrás, de modo que no da derecho a los frutos ni a los intereses que se hubiesen devengado antes de su vencimiento.

4.2. Efectos del plazo extintivo

El plazo extintivo pone fin a los efectos del acto y extingue el derecho, pero solo hacia adelante: a diferencia de la condición resolutoria, no borra lo ya ocurrido mientras el plazo corría. Si arriendo una casa hasta el primero de mayo del año siguiente, llegada esa fecha se extingue mi derecho a seguir usándola, pero los cánones que ya se devengaron durante el arriendo no se ven afectados.

C. EL MODO

1. CONCEPTO

El art. 1089 llama **modo** a la carga que se impone a quien recibe algo para que lo tenga por suyo, cuando esa carga consiste en aplicarlo a un fin especial, como hacer ciertas obras o sujetarse a ciertas cargas; el propio artículo aclara que eso no es una condición suspensiva. La doctrina agrega precisión a esa idea: el modo es una carga que se liga a una disposición a título gratuito y que se impone al beneficiario, como ocurriría si se instituye heredero a alguien con la obligación de que construya tres escuelas en zonas fronterizas. Esa carga no funciona como un precio ni como una

contraprestación por lo recibido: es, más bien, una restricción a los efectos de lo recibido, pensada para que se cumplan los fines de quien hizo la disposición.

Art. 1089. "Si se asigna algo a una persona para que lo tenga por suyo con la obligación de aplicarlo a un fin especial, como el de hacer ciertas obras o sujetarse a ciertas cargas, **esta aplicación es un modo y no una condición suspensiva**. El modo, por consiguiente, no suspende la adquisición de la cosa asignada."

Esto es lo que distingue al modo de la condición suspensiva: el modo no suspende la adquisición del derecho. Un aforismo resume bien el contraste: "la condición suspende, pero no obliga"; "el modo no suspende, pero obliga", al menos como regla general. Se ve con un ejemplo: si alguien dona una suma de dinero a condición de que el donatario erija una estatua, el donatario queda libre de construirla o no, pero mientras no la construya, tampoco recibe el dinero; eso es condición suspensiva. Si en cambio dona la suma con la obligación de erigir la estatua, el donatario recibe el dinero de inmediato, pero queda obligado a construirla; eso es modo.

2. EFFECTOS DEL MODO

El modo tampoco afecta la existencia del derecho, que nace y se adquiere desde el comienzo; solo incide en cómo se ejerce ese derecho, por eso el propio **art. 1089**, en su parte final, aclara que el modo no suspende la adquisición de la cosa asignada.

3. CUMPLIMIENTO DEL MODO

Quien se beneficia con el modo no depende de la buena voluntad del obligado: puede exigir su cumplimiento ante los tribunales. Así, si se asigna una suma a don Hernán con la obligación de pagarle una pensión periódica a su sobrina, ella puede recurrir a los tribunales para que don Hernán cumpla con esa carga.

Si el testador no determinó suficientemente el tiempo o la forma en que debe cumplirse el modo, puede fijarlos el juez, consultando en lo posible la voluntad del testador, pero sin dejar al asignatario modal con menos de la quinta parte del valor de la cosa asignada (**art. 1094**). Por ejemplo, si se deja una casa a Camila con la carga de *ayudar a los vecinos del sector*, sin precisar cómo ni por cuánto tiempo, el juez puede fijar esos detalles, resguardando en todo caso que a Camila le quede, como mínimo, la quinta parte del valor de la casa.

Art. 1094. "Si el testador no determinare suficientemente el tiempo o la forma especial en que ha de cumplirse el modo, podrá el juez determinarlos, consultando en lo posible la voluntad de aquél, y **dejando al asignatario modal un beneficio que ascienda por lo menos a la quinta parte del valor de la cosa asignada.**"

El incumplimiento del modo no basta, por sí solo, para que el derecho se resuelva o se extinga: para eso se necesita una **cláusula resolutoria** expresa, que es la que impone la obligación de restituir la cosa y sus frutos si el modo no se cumple. Esa cláusula no se presume nunca: si el testador no la menciona, se entiende que la asignación no la lleva (**art. 1090**). Y si el modo está establecido únicamente en beneficio del propio asignatario, como ocurriría si le dejo a mi sobrina Constanza diez millones de pesos para que se arme una biblioteca jurídica, directamente no genera ninguna obligación, salvo que se haya pactado cláusula resolutoria (**art. 1092**): sin ella, es apenas un consejo, sin fuerza para obligarla.

Art. 1090. "En las asignaciones modales se llama cláusula resolutoria la que impone la obligación de restituir la cosa y los frutos, si no se cumple el modo. **No se entenderá que envuelven cláusula resolutoria cuando el testador no la expresa.**"